

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**



—1996—
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH**

NGUYỄN THANH THƯ

**HÌNH THỨC DI CHỨC THEO PHÁP LUẬT
DÂN SỰ VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN THANH THƯ

**HÌNH THỨC DI CHỨC THEO PHÁP LUẬT
DÂN SỰ VIỆT NAM**

**CHUYÊN NGÀNH: LUẬT DÂN SỰ VÀ TỔ TỤNG DÂN SỰ
MÃ SỐ: 9380103**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

- 1. TS. NGUYỄN HỒ BÍCH HẰNG**
- 2. TS. NGUYỄN XUÂN QUANG**

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

LỜI CAM ĐOAN

Luận án “*Hình thức di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam*” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các thông tin nêu trong luận án là trung thực. Mọi sự tham khảo đều được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ. Các kết quả của luận án chưa từng được ai công bố ở bất cứ công trình nghiên cứu nào khác.

Tác giả luận án

Nguyễn Thanh Thu

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nội dung
BLDS	Bộ luật Dân sự
BLTTDS	Bộ luật Tố tụng Dân sự
BLTTHS	Bộ luật Tố tụng Hình sự
CT	Chỉ thị
NĐ	Nghị định
Nxb	Nhà xuất bản
PLTK	Pháp lệnh Thừa kế
TANDTC	Tòa án nhân dân tối cao
TT	Thông tư
Tr	Trang
UBND	Ủy ban nhân dân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	3
<i>2.1. Mục đích nghiên cứu.....</i>	<i>3</i>
<i>2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu</i>	<i>3</i>
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
<i>3.1. Đối tượng nghiên cứu</i>	<i>4</i>
<i>3.2. Phạm vi nghiên cứu</i>	<i>4</i>
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể	5
<i>4.1. Phương pháp luận.....</i>	<i>5</i>
<i>4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể</i>	<i>5</i>
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án	6
6. Những đóng góp mới về khoa học của luận án	7
7. Kết cấu của luận án	8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU	9
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của luận án	9
<i>1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về những vấn đề lý luận của hình thức di chúc</i>	<i>9</i>
<i>1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về hình thức di chúc bằng văn bản ..</i>	<i>18</i>
<i>1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về hình thức di chúc miệng</i>	<i>28</i>
1.2. Đánh giá kết quả những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án .	30
<i>1.2.1. Những vấn đề lý luận về hình thức di chúc</i>	<i>30</i>
<i>1.2.2. Hình thức di chúc bằng văn bản.....</i>	<i>31</i>
<i>1.2.3. Hình thức di chúc miệng.....</i>	<i>32</i>
1.3. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu	33
<i>1.3.1. Những vấn đề lý luận về hình thức di chúc</i>	<i>33</i>
<i>1.3.2. Hình thức di chúc bằng văn bản.....</i>	<i>34</i>
<i>1.3.3. Hình thức di chúc miệng.....</i>	<i>36</i>
1.4. Cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu luận án	36
<i>1.4.1. Lý thuyết quyền sở hữu tài sản</i>	<i>36</i>
<i>1.4.2. Lý thuyết gia đình</i>	<i>38</i>
<i>1.4.3. Lý thuyết Nhà nước và pháp luật.....</i>	<i>40</i>
<i>1.4.4. Lý thuyết tự do ý chí của cá nhân</i>	<i>41</i>
<i>1.4.5. Lý thuyết luật tự nhiên</i>	<i>42</i>

1.5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu	44
1.5.1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát và giả thuyết nghiên cứu tổng quát.....	44
1.5.2. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể và giả thuyết nghiên cứu cụ thể.....	45
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	47
CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÌNH THỨC DI CHỨC	48
2.1. Khái niệm, đặc điểm di chúc.....	48
2.1.1. Khái niệm di chúc	48
2.1.2. Đặc điểm di chúc	51
2.2. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa hình thức di chúc.....	54
2.2.1. Khái niệm hình thức di chúc	54
2.2.2. Đặc điểm hình thức di chúc	57
2.2.3. Ý nghĩa hình thức di chúc	61
2.3. Lịch sử quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc	63
2.3.1. Quy định pháp luật về hình thức di chúc thời kỳ phong kiến	63
2.3.2. Quy định pháp luật về hình thức di chúc từ thời kỳ Pháp thuộc đến trước năm 1945	65
2.3.3. Quy định pháp luật về hình thức di chúc từ sau năm 1945 đến trước khi có Bộ luật Dân sự 1995.....	66
2.3.4. Quy định pháp luật về hình thức di chúc từ khi có Bộ luật Dân sự 1995 đến nay	70
2.4. Cơ sở để pháp luật quy định về hình thức di chúc	73
2.4.1. Phong tục tập quán, đặc điểm riêng biệt của xã hội từng thời kỳ.....	73
2.4.2. Sự tự do ý chí của người lập di chúc	77
2.4.3. Điều kiện của người lập di chúc	79
2.4.4. Hoàn cảnh lập di chúc.....	83
2.4.5. Tài sản được định đoạt trong di chúc.....	85
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	87
CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC DI CHỨC BẰNG VĂN BẢN	88
3.1. Khái niệm, đặc điểm hình thức di chúc bằng văn bản.....	88
3.1.1. Khái niệm hình thức di chúc bằng văn bản	88
3.1.2. Đặc điểm hình thức di chúc bằng văn bản	92
3.2. Di chúc tự viết.....	94
3.2.1. Quy định pháp luật về di chúc tự viết.....	94
3.2.2. Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về di chúc tự viết.....	96
3.3. Di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy.....	104
3.3.1. Quy định pháp luật về di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy	104

3.3.2	<i>Bắt cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy</i>	109
3.4.	Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực	113
3.4.1.	<i>Quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.....</i>	113
3.4.2.	<i>Bắt cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực</i>	118
3.5.	Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực	123
3.5.1.	<i>Quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực</i>	123
3.5.2.	<i>Bắt cập và kiến nghị hoàn thiện thực tiễn áp dụng pháp luật về di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực.....</i>	126
3.6.	Di chúc điện tử	128
3.6.1.	<i>Kinh nghiệm của một số quốc gia về việc áp dụng di chúc điện tử.....</i>	128
3.6.2.	<i>Bắt cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về di chúc điện tử.....</i>	132
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3		140
CHƯƠNG 4: HÌNH THỨC DI CHỨC MIỆNG.....		142
4.1. Khái niệm, đặc điểm hình thức di chúc miệng.....		142
4.1.1.	<i>Khái niệm hình thức di chúc miệng</i>	142
4.1.2.	<i>Đặc điểm hình thức di chúc miệng</i>	144
4.2. Các trường hợp được lập di chúc miệng		146
4.2.1.	<i>Quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về các trường hợp được lập di chúc miệng</i>	146
4.2.2.	<i>Bắt cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp được lập di chúc miệng</i>	150
4.3. Trình tự, thủ tục lập di chúc miệng		155
4.3.1.	<i>Giai đoạn ghi chép lại di chúc miệng.....</i>	155
4.3.2.	<i>Giai đoạn công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.....</i>	163
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4		171
KẾT LUẬN		173
NHỮNG CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN		
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO		
PHỤ LỤC		

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thừa kế theo di chúc là quan hệ phổ biến trong đời sống xã hội, trong đó di chúc là phương thức chủ sở hữu tài sản lựa chọn để chuyển giao tài sản của mình sau khi chết. Đặc điểm cơ bản của di chúc với tư cách là một giao dịch dân sự đó là hiệu lực pháp lý chỉ phát sinh khi người xác lập giao dịch không còn tồn tại. Sau đó nếu di chúc có hiệu lực pháp luật¹, di sản có thể được phân chia theo di chúc thì sẽ căn cứ vào nội dung di chúc để xác định ý chí của người để lại di sản và tiến hành phân chia di sản. Tuy nhiên vào thời điểm này người để lại di sản đã chết nên việc xác định lại ý chí của họ sẽ khó khăn. Nếu có những tranh chấp, vướng mắc phát sinh xoay quanh di chúc thì người để lại di sản không còn sống để khẳng định, phủ định hay giải thích thêm về nội dung di chúc. Do đó, một di chúc tốt phải được hiểu là di chúc có nội dung tốt và trước hết phải có hình thức di chúc tốt, có ý nghĩa tích cực trong việc chuyển giao tài sản của người chết.

Hiện nay những tranh chấp về thừa kế theo di chúc phần nhiều đều xuất phát từ việc di chúc bị xem là giả mạo, được xác định là bị thay đổi, bị sửa đổi so với ý chí của người để lại di sản. Những tranh chấp này phát sinh do di chúc không đảm bảo được việc ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản. Mặt khác, khi đời sống xã hội, kinh tế có sự thay đổi thì những cách thức, quy trình lập di chúc càng ngày càng có sự khác biệt so với những giai đoạn trước đó. Để giúp cho người lập di chúc được thuận lợi hơn trong quá trình lập di chúc, ý chí của người để lại di sản được ghi nhận chính xác và linh hoạt thì những phương thức để ghi nhận lại ý chí đó phải phù hợp với yêu cầu của xã hội. Tất cả những yêu cầu cấp thiết này muốn được giải quyết phải thông qua việc hoàn thiện một trong những điều kiện rất quan trọng ảnh hưởng đến tính hợp pháp của di chúc đó là hình thức di chúc. Bởi lẽ *“hình thức di chúc được hiểu là phương thức biểu hiện ý chí của người lập di chúc, là căn cứ pháp lý làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc, là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của người được chỉ định trong di chúc”*². Do đó, nghiên cứu về hình thức di chúc có tính cấp thiết từ những vấn đề lý luận, quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng pháp luật.

Thứ nhất, xét về mặt lý luận, cách hiểu về hình thức di chúc; những đặc trưng của hình thức di chúc; những yếu tố chi phối đến việc xây dựng quy phạm pháp luật về hình thức di chúc cần phải được luận giải và nghiên cứu một cách có hệ thống để đảm bảo hình thức di chúc thể hiện được chức năng ghi nhận và bảo vệ ý chí của người để lại di sản.

¹ Điều 630, khoản 1 Điều 643, khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015.

² Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), *Giáo trình Luật dân sự Việt Nam - Tập 1*, Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.319.

Thứ hai, xét đến quy định pháp luật về hình thức di chúc vẫn còn nhiều tồn tại cần hoàn thiện. Các điều kiện đặt ra đối với một số loại hình thức di chúc theo quy định pháp luật vẫn còn cứng nhắc, chưa khả thi, khó có thể áp dụng trên thực tế. Hiện nay để hình thức di chúc hợp pháp cần phải tuân thủ các điều kiện cụ thể về hoàn cảnh lập di chúc, trình tự, thủ tục lập di chúc. Có thể khẳng định hình thức di chúc ảnh hưởng đến nội dung di chúc, chính vì lẽ đó những quy định về các điều kiện này luôn rất chặt chẽ. Yêu cầu về hình thức di chúc được đặt ra nhằm đảm bảo nội dung di chúc không bị sửa đổi, thay thế, bổ sung, giả mạo. Tuy nhiên, khi quy định quá cứng nhắc các điều kiện về hình thức di chúc sẽ làm cho việc lập di chúc không khả thi thực hiện trên thực tế. Ngược lại, có những loại hình thức di chúc được quy định về các điều kiện, trình tự lập di chúc không chặt chẽ sẽ dẫn đến di chúc dễ dàng bị thay đổi nội dung, không ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản. Mặt khác, với sự phát triển của xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì những hình thức ghi nhận của các giao dịch dân sự càng ngày càng thay đổi khi có sự tham gia của công nghệ trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Không nằm ngoài xu hướng chung, di chúc được lập dựa vào sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ hiện đại để tạo thuận lợi cho người lập di chúc muốn ghi nhận và lưu giữ ý chí của mình đã được nhiều nước trên thế giới ghi nhận với tên gọi là di chúc điện tử. Đây là một ghi nhận phù hợp với thời đại và xã hội hiện đại mà pháp luật Việt Nam cần cân nhắc bổ sung để di chúc được thể hiện dưới hình thức này.

Thứ ba, khi nghiên cứu quy định của pháp luật và hướng giải quyết của thực tiễn tác giả nhận thấy hai vấn đề này còn chưa có sự đồng bộ. Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định di chúc được lập không đúng luật định về hình thức thì di chúc không hợp pháp³. Thực tiễn xét xử đã có Tòa án công nhận di chúc dù hình thức di chúc không đáp ứng yêu cầu luật định vì có những bằng chứng chứng minh di chúc này ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc. Hoặc có những trường hợp thực tiễn xét xử đã vận dụng điều kiện của nhiều loại hình thức di chúc cho một trường hợp lập di chúc dẫn đến di chúc không thỏa mãn điều kiện về hình thức và gây khó khăn cho người để lại di sản.

Hình thức di chúc được xem là phương tiện để ghi nhận và lưu giữ lại ý chí định đoạt tài sản của người có tài sản sau khi người này chết. Tuy nhiên, như đã nêu trên, pháp luật về hình thức di chúc vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống dẫn đến pháp luật về thừa kế theo di chúc chưa đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, ổn định trật tự, đạo đức xã hội; ảnh hưởng đến quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu tài sản sau khi họ chết, quyền thừa kế theo di chúc của người thừa kế và chưa hạn chế được những tranh chấp phát sinh. Với các yêu cầu cấp thiết này, tác giả cho rằng việc nghiên cứu về hình thức di chúc theo pháp luật

³ Điểm b khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

dân sự Việt Nam là cần thiết. Nghiên cứu về hình thức di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam giúp hoàn thiện về mặt lý luận để xác định hình thức di chúc là phương thức ghi nhận và xác thực ý chí của người để lại di sản; đánh giá được các quy định pháp luật dân sự Việt Nam hiện nay đã có sự thay đổi và kế thừa các quy định pháp luật trước đó; tham khảo quy định pháp luật nước ngoài nhưng lựa chọn vận dụng cho phù hợp với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Tác giả quyết định chọn đề tài **“Hình thức di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam”** để nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết đã đề cập ở trên.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Thứ nhất, luận án được nghiên cứu nhằm mục đích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về hình thức di chúc để đảm bảo di chúc được lập một cách thuận lợi, thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản để từ đó thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự, đạo đức xã hội.

Thứ hai, luận án được nghiên cứu nhằm mục đích hoàn thiện các quy phạm pháp luật dân sự Việt Nam quy định về hình thức di chúc là một phương tiện để bảo đảm người để lại di sản vẫn thực hiện được quyền định đoạt tài sản sau khi chết. Mặt khác, luận án còn nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về hình thức di chúc nhằm đảm bảo sự tương thích của quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án phải giải quyết được các vấn đề sau:

Thứ nhất, nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận của pháp luật về hình thức di chúc.

Thứ hai, nghiên cứu thực trạng các quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh, lịch sử để xem xét, kiểm tra và hệ thống hóa các quy định pháp luật. Từ đó có đánh giá bước đầu về sự phát triển của các quy định này theo tiến trình lịch sử của pháp luật Việt Nam và sự tương đồng cũng như khác biệt khi so sánh với pháp luật nước ngoài.

Thứ ba, đánh giá thực tiễn thông qua các bản án được xét xử tại Việt Nam, các án lệ ở nước ngoài để có cách nhìn khách quan từ thực tiễn đến mối liên hệ với các quy định pháp luật.

Thứ tư, từ các điểm trên, luận án chỉ ra các bất cập trong quy định của pháp luật trên cơ sở các nghiên cứu đã được đánh giá và đưa ra một số định hướng để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án có đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận về hình thức di chúc, các quy phạm pháp luật quy định về hình thức di chúc và thực tiễn áp dụng pháp luật về hình thức di chúc.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu về hình thức di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam chứa đựng rất nhiều vấn đề lý luận và pháp lý phát sinh khi người để lại di sản lập di chúc. Tuy nhiên hình thức di chúc được nghiên cứu trong luận án được tiếp cận là một phương thức để ghi nhận và xác thực ý chí của người để lại di sản bên cạnh việc nghiên cứu hình thức di chúc là một chế định pháp luật. Do vậy, pháp luật về hình thức di chúc phải đảm bảo cho việc lập di chúc của người để lại di sản được thuận lợi hơn, ý chí của người để lại di sản phải được ghi nhận một cách chính xác để từ đó di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội. Từ đó phạm vi nghiên cứu của luận án được giới hạn bởi các yếu tố sau:

Thứ nhất, về nội dung:

Luận án tập trung nghiên cứu: (i) Những vấn đề lý luận và cơ sở lý luận về hình thức di chúc; (ii) Các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hình thức di chúc như các điều kiện của hình thức di chúc và thể thức lập di chúc của hình thức di chúc bằng văn bản, hình thức di chúc miệng.

Luận án không nghiên cứu tất cả các vấn đề pháp lý, các bất cập về quy định pháp luật hoặc bất cập trong thực tiễn của pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc. Những bất cập trong quy định của pháp luật hoặc trong thực tiễn áp dụng được chỉ ra để nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam được nghiên cứu trong luận án phải đảm bảo pháp luật về hình thức di chúc là phương tiện ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản và giúp cho người để lại di sản lập di chúc một cách thuận lợi hơn để từ đó thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội.

Thứ hai, về không gian:

Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận hình thành nên quy định về hình thức di chúc.

Luận án nghiên cứu về các quy định của BLDS 2015 và các văn bản có liên quan như Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật Công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn có liên quan...về hình thức di chúc. Để làm rõ mục đích nghiên cứu, Luận án có so sánh với quy định pháp luật một số quốc gia trên thế giới ở châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc), Mỹ, Úc, Canada và một số nước châu Âu về hình thức di chúc.

Ngoài những quy phạm pháp luật, luận án còn phân tích thực tiễn thông qua những bản án đã được Tòa án xét xử có hiệu lực pháp luật để đánh giá về quy định pháp luật hiện hành.

Thứ ba, về thời gian:

Luận án nghiên cứu quy định của pháp luật dân sự Việt Nam từ giai đoạn phong kiến đến thời điểm hiện tại về hình thức di chúc nhằm so sánh và làm rõ hơn mục đích nghiên cứu của luận án.

Đối với pháp luật nước ngoài, luận án nghiên cứu một số các quy định pháp luật thời kỳ La Mã để có thể làm rõ sự hình thành, nền tảng cũng như nguyên lý về hình thức di chúc trong pháp luật cổ đại. Đồng thời luận án cũng phân tích và đối chiếu một số các quy định pháp luật hiện hành của các nước ở châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc), Mỹ, Úc, Canada và một số nước châu Âu về hình thức di chúc.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể

4.1. Phương pháp luận

Luận án được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin⁴.

Việc xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc xuất phát từ việc ghi nhận quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu tài sản. Để thể hiện rõ yếu tố này, quy định pháp luật về hình thức di chúc bị ảnh hưởng bởi đặc điểm xã hội, kinh tế, văn hóa, phong tục tập quán – đây là những yếu tố khách quan, yếu tố vật chất tác động đến việc xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc – ý chí của Nhà nước.

Việc nghiên cứu pháp luật về hình thức di chúc phải được xem xét từ những quy định ban đầu sơ khai để theo dõi tiến trình phát triển của các quy định pháp luật này. Khi xã hội có sự thay đổi, quy định pháp luật về hình thức di chúc cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Từ đó có thể xem xét, đánh giá sự phát triển của quy định pháp luật trong hiện tại và tương lai về hình thức di chúc để xây dựng những quy phạm pháp luật phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội.

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

Để thực hiện thành công luận án, đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận án, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:

Phương pháp hệ thống: Phương pháp này được sử dụng trong Chương 1 của luận án để thống kê, sưu tập tài liệu trong nước và nước ngoài nhằm mục đích đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu. Từ đó có cơ sở cho luận án triển khai nghiên cứu tiếp tục hoặc nghiên cứu những vấn đề mới liên quan đến pháp luật về hình thức di chúc. Ngoài ra, phương pháp này cũng được sử dụng trong các Chương còn lại của luận án

⁴ Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), *Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin*, Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia, tr.39, 55, 58.

để thống kê các tài liệu có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu từ đó có sự so sánh, phân tích, bình luận và đánh giá cho từng vấn đề.

Phương pháp lịch sử: Luận án nghiên cứu các vấn đề pháp lý về hình thức di chúc của pháp luật La Mã. Ở Việt Nam, luận án nghiên cứu pháp luật từ giai đoạn phong kiến đến nay. Việc nghiên cứu những quy định pháp luật, những vấn đề lý luận từ trước giúp tác giả có được góc nhìn tổng quát đồng thời theo dõi được tiến trình lịch sử phát triển của các quy định pháp luật về hình thức di chúc. Trên cơ sở này, tác giả có thể nắm rõ sự thay đổi của các quy định pháp luật cũng như tìm hiểu, nghiên cứu lý do của sự thay đổi đó. Phương pháp lịch sử được tác giả sử dụng trong Chương 2 của luận án.

Phương pháp phân tích: Phương pháp này được tác giả sử dụng ở Chương 2 để làm sáng tỏ các vấn đề về lý luận về hình thức di chúc. Trong Chương 3 và Chương 4 tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhằm xem xét chi tiết về các điều kiện, thể thức và trình tự, thủ tục lập di chúc cho các hình thức di chúc cụ thể theo quy định pháp luật Việt Nam. Ngoài việc phân tích những vấn đề lý luận, phân tích các quy định pháp luật, luận án còn phân tích một số bản án được Tòa án xét xử nhằm xác định rõ các vấn đề pháp lý trong các vụ việc thực tiễn.

Phương pháp so sánh: Chương 3 và Chương 4 sử dụng phương pháp so sánh để có thể so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài nhằm chỉ rõ điểm giống nhau, khác nhau và điểm còn hạn chế trong quy định pháp luật Việt Nam. So sánh quy định pháp luật Việt Nam hiện hành với quy định pháp luật Việt Nam ở những giai đoạn trước đó nhằm làm rõ sự phát triển của quy định pháp luật trong các giai đoạn khác nhau của xã hội. So sánh các quan điểm pháp lý khác nhau của các chuyên gia để có cách tiếp cận, cách nhìn đa chiều về một vấn đề.

Phương pháp tổng hợp – đánh giá: Phương pháp này được sử dụng để tập hợp và hệ thống các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn nhằm đưa ra những quan điểm, góc nhìn của tác giả về các vấn đề pháp lý, thực tiễn áp dụng pháp luật của hình thức di chúc. Phương pháp này được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ luận án.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

Về phương diện khoa học, kết quả của luận án có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần xây dựng hệ thống lý luận về hình thức di chúc. Trong đó, luận án xây dựng khái niệm hình thức di chúc, làm rõ bản chất pháp lý của hình thức di chúc và luận giải về các yếu tố chi phối đến pháp luật về hình thức di chúc để từ đó khẳng định vai trò của hình thức di chúc trong việc ghi nhận, xác thực ý chí của người lập di chúc, giúp di chúc được lập một cách thuận lợi hơn và thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội. Từ các nghiên cứu về những vấn đề lý luận của hình thức di chúc, luận án đóng góp thêm những luận điểm khoa học có giá trị tham khảo cho việc hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc.

Về phương diện thực tiễn, luận án chỉ rõ những điểm hạn chế trong quy định pháp luật Việt Nam về các điều kiện, thể thức, trình tự, thủ tục lập di chúc của các hình thức di chúc cụ thể; những điểm chưa đồng bộ trong hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật với quy định pháp luật Việt Nam để từ đó quy định pháp luật Việt Nam được hoàn thiện và có tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn.

Với những kết quả đạt được, luận án có thể đóng góp vào nguồn tài liệu giảng dạy, học tập, nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên ngành luật và những người nghiên cứu, những người hoạt động thực tiễn muốn nghiên cứu lý luận và pháp luật về hình thức di chúc.

6. Những đóng góp mới về khoa học của luận án

Việc nghiên cứu luận án *“Hình thức di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam”* để chứng minh hình thức di chúc là phương thức ghi nhận, xác thực ý chí của người để lại di sản, giúp cho việc lập di chúc được thuận lợi hơn và thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội. Do vậy luận án có thể mang lại những đóng góp sau:

Thứ nhất, luận án đóng góp vào việc làm phong phú, hệ thống hóa và luận giải các vấn đề lý luận của pháp luật dân sự Việt Nam về hình thức di chúc như khái niệm hình thức di chúc, các đặc trưng và vai trò của hình thức di chúc. Luận án chỉ ra và phân tích các yếu tố tác động đến pháp luật về hình thức di chúc như phong tục tập quán, đặc điểm riêng biệt của xã hội trong từng thời kỳ; sự tự do ý chí của người lập di chúc; điều kiện của người lập di chúc; hoàn cảnh lập di chúc và tài sản được định đoạt trong di chúc.

Thứ hai, với xã hội hiện đại hiện nay xu hướng thừa nhận di chúc điện tử là tất yếu và luận án đề xuất pháp luật Việt Nam cần xem xét để ghi nhận hình thức di chúc điện tử trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như Mỹ, Úc và Canada.

Thứ ba, luận án phân tích, đánh giá một cách toàn diện quy định của BLDS 2015 về di chúc bằng văn bản trên cơ sở có sự so sánh với pháp luật nước ngoài và thực tiễn áp dụng để chỉ rõ điểm hạn chế trong quy định pháp luật về các loại hình thức di chúc bằng văn bản để từ đó có các đề xuất về: Thay đổi tên gọi của một số loại hình thức di chúc như di chúc tự viết, di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy; về ngôn ngữ viết di chúc; vấn đề giám định chữ viết khi không có mẫu giám định đối chứng; về điều kiện của người làm chứng di chúc; về di chúc của người không đọc được, không nghe được, không ký hoặc không điểm chỉ được; bổ sung hình thức di chúc niêm phong có công chứng hoặc chứng thực; về việc hoàn thiện thực tiễn áp dụng quy định pháp luật phù hợp cho một hoàn cảnh lập di chúc.

Thứ tư, luận án phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của BLDS 2015 về di chúc miệng; so sánh, tham khảo pháp luật nước ngoài và thực tiễn áp dụng pháp luật để đề xuất bổ sung thêm các trường hợp được lập di chúc ngoài những quy định hiện

nay của pháp luật như: Người không thể nói được và người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc miệng khi ở vào hoàn cảnh cận kề cái chết mà không thể lập di chúc bằng văn bản; căn cứ vào loại tài sản và giá trị tài sản để lập di chúc miệng với thủ tục đơn giản; xác định thời điểm ghi chép lại ý chí của người để lại di sản trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí; bổ sung quyền xác nhận di chúc miệng cho những người không phải là công chứng viên, không phải là người có thẩm quyền chứng thực di chúc.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, những công trình tác giả công bố có liên quan đến luận án và phụ lục những bản án về hình thức di chúc, phần nội dung của luận án được kết cấu thành 4 Chương cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề chung về hình thức di chúc

Chương 3: Hình thức di chúc bằng văn bản

Chương 4: Hình thức di chúc miệng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Chương 1 của luận án giới thiệu về tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước về di chúc, hình thức di chúc. Từ đó tác giả có sự đánh giá các công trình khoa học nhằm xác định được những vấn đề luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu. Ngoài ra, trong Chương 1 tác giả nghiên cứu cơ sở các lý thuyết vận dụng của luận án làm tiền đề định hướng cho việc hoàn thiện quy định pháp luật về các hình thức di chúc. Mặt khác, để xác định được các vấn đề cần nghiên cứu của luận án tác giả đặt ra các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu.

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của luận án

Để xác định những vấn đề cần được tiếp tục triển khai nghiên cứu trong luận án nhằm đạt được mục đích nghiên cứu, tác giả tổng quan những công trình khoa học nghiên cứu về di chúc, hình thức di chúc trên phương diện lý luận và thực trạng pháp luật ở trong nước và ngoài nước. Nghiên cứu về hình thức di chúc phải xuất phát từ việc nghiên cứu về bản chất pháp lý của di chúc để nhận thức rõ những đặc trưng cơ bản của di chúc cũng như vai trò, ý nghĩa pháp lý của di chúc đối với mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, ổn định trật tự, đạo đức xã hội cũng như bảo vệ ý chí của người lập di chúc và bảo vệ quyền thừa kế của người thừa kế theo di chúc. Khi làm rõ được bản chất pháp lý và vai trò, ý nghĩa của di chúc sẽ xác định được vai trò, nhiệm vụ của hình thức di chúc và sẽ có những định hướng nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo được nhiệm vụ đặt ra cho pháp luật về hình thức di chúc.

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về những vấn đề lý luận của hình thức di chúc

Thứ nhất, về khái niệm di chúc và bản chất pháp lý của di chúc

Quan hệ pháp luật về thừa kế theo di chúc đã được ghi nhận từ thời kỳ La Mã và đã có nhiều công trình nghiên cứu về thừa kế theo di chúc trong luật La Mã.

Cuốn sách “*Introduction to Roman Law*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Giới thiệu về Luật La Mã*) của tác giả Barry Nicholas được nhà xuất bản (Nxb) Oxford University Press phát hành năm 2017 đã có đề cập đến vấn đề thừa kế thời kỳ La Mã. Di chúc của người La Mã được phát triển từ rất sớm. Ở những nơi khác, sự phát triển này là muộn, nhưng ở Rome ngay trong Luật Mười hai bảng đã tồn tại nhiều hình thức di chúc. Đặc biệt để xem đây là một di chúc khi nó phải có các yếu tố sau: (i) di chúc chỉ định một chủ thể thừa kế bất kỳ, chủ thể này có thể là bất kỳ ai đó không giới hạn phải là người thừa kế trong gia đình dòng tộc; (ii) di chúc có thể có phần di tặng ngoài phần di sản và có thể chứa đựng những nội dung khác như bổ nhiệm người quản lý hoặc quản lý nô lệ; (iii) di chúc được xem là lời nói từ cái chết (ví dụ: di chúc có thể đặt ra các điều kiện khi được hưởng di sản); (iv) di chúc có thể bị hủy bỏ.

Bài viết của tác giả Rafael Domingo công bố ngày 19 tháng 7 năm 2017 “*The Roman Law of Succession - An overview*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Luật thừa kế La Mã - góc nhìn tổng quan*) đăng trên tạp chí SSRN Electronic Journal. Di chúc là một hành vi pháp lý trong đó một công dân La Mã tuyên bố mong muốn của mình sau khi chết. Ý chí trong di chúc để xác định một người thừa kế xứng đáng, người sẽ mang lại sự phát triển cho gia đình và, theo một nghĩa nào đó, cho nhân cách của người đã chết. Di chúc cũng được sử dụng để chia các phần không đồng đều cho các gia đình khác nhau của những người thừa kế, dùng để trả nợ cho các chủ nợ và thưởng cho những người thân trung thành, bạn bè, người hầu. Nói chung, luật La Mã dành cho người lập di chúc một mức độ tự do cao trong việc định đoạt tài sản. Di chúc có thể bao gồm các định đoạt quan trọng, chẳng hạn như di sản và các nội dung khác như bổ nhiệm các gia sư và quản lý nô lệ. Nhưng nguồn cội của nội dung di chúc trong luật La Mã là việc chỉ định một hoặc một số người thừa kế và đây chính là nội dung bắt buộc phải có trong di chúc. Nếu di chúc không có người thừa kế được chỉ định hoặc những người thừa kế không nhận di sản thì toàn bộ di chúc không thành.

Giáo trình “*Giáo trình Luật La Mã*” của Trường Đại học Luật Hà Nội do Nxb Công an nhân dân xuất bản năm 2003 đề cập đến cách hiểu di chúc trong thời kỳ La Mã. Di chúc là quyết định của người có tài sản sau khi chết sẽ chuyển tài sản của mình cho người thừa kế. Theo luật cổ La Mã thì việc chỉ định người thừa kế phải được ghi vào phần đầu của di chúc và đây là nội dung quan trọng của di chúc. Nếu không ghi rõ ai là người được hưởng thừa kế thì di chúc sẽ vô hiệu. Di chúc là giao dịch một bên vì nó thể hiện ý chí đơn phương của người lập di chúc và người này có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, di chúc chỉ có giá trị pháp lý nếu người được chỉ định trong di chúc thể hiện ý chí là nhận thừa kế theo di chúc đó. Di chúc không được coi là một khế ước, bởi vì người thừa kế thể hiện ý chí của mình sau khi người lập di chúc đã chết. Hành vi của người lập di chúc với hành vi của người thừa kế theo di chúc độc lập với nhau.

Giáo trình “*Giáo trình Luật La Mã*” của tác giả Nguyễn Ngọc Điện, Trường Đại học Cần Thơ do Nxb Chính trị quốc gia xuất bản năm 2009 xác định ở La Mã, việc di chuyển di sản theo pháp luật hiếm khi được áp dụng do người có di sản thường lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Di chúc có tác dụng công khai ý chí của người có di sản liên quan đến việc chuyển giao tài sản của mình sau khi chết.

Hiện nay, cách hiểu về di chúc được các công trình diễn giải như sau:

Cuốn sách “*Law of succession*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Luật thừa kế*) của tác giả Musyoka, William, được Nxb African Books Collective xuất bản năm 2006 đã có phân tích về bản chất pháp lý mối quan hệ của pháp luật thừa kế với Luật Hôn nhân gia đình, với Luật về tài sản. Trong đó, di chúc được xác định là một văn bản không có hiệu lực pháp luật đến khi người lập di chúc chết. Khi người lập di chúc còn sống, di

chức không làm hạn chế quyền sở hữu đối với tài sản của họ và cũng không mang lại lợi ích cho những người đã được đề cập trong di chúc hoặc bất kỳ ai khác. Do đó đặc điểm của di chúc là (i) chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc chết; (ii) các mong muốn được thể hiện nhằm mục đích định đoạt tài sản sau khi chết; (iii) một di chúc có thể thay đổi được hoặc hủy bỏ được khi người lập di chúc còn sống.

Cuốn sách “*Succession Law, Law Essentials*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Luật thừa kế, Luật cần thiết*) được viết năm 2020 do Nxb University of Sherbrooke phát hành của tác giả Mc Carthy Frankie đưa ra cách hiểu về di chúc dựa trên những điều kiện của di chúc. Di chúc là sự dịch chuyển tài sản cho những người thụ hưởng có tên trong di chúc. Di chúc hợp pháp cần cả điều kiện về nội dung di chúc và hình thức di chúc. Trong đó nội dung di chúc cần được ghi nhận một cách chính xác và hình thức di chúc sẽ đảm bảo mục đích này.

Giáo trình “*Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và thừa kế*” của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được Nxb Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2019 đã có khái niệm sau về di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí đơn phương của cá nhân lúc còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết một cách tự nguyện, theo một hình thức, thể thức luật định, có thể bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bất cứ lúc nào bởi người lập di chúc khi người đó còn sống. Di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc chết.

Giáo trình “*Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1*” của Trường Đại học Luật Hà Nội được Nxb Công an nhân dân xuất bản năm 2019 xác định di chúc phải có các yếu tố đó là sự thể hiện ý chí của cá nhân mà không phải là của bất cứ chủ thể nào khác; mục đích của việc lập di chúc là chuyển di sản của mình cho người khác; chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết. Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người lập di chúc, do đó di chúc phải tuân thủ các điều kiện của giao dịch dân sự nói chung và điều kiện có hiệu lực của di chúc nói riêng.

Giáo trình “*Luật Hôn nhân và gia đình - Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế, Tập 2*” của tác giả Nguyễn Ngọc Điện, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2021 đã có phân tích sau về di chúc: Di chúc được hiểu là cách chủ sở hữu thực hiện quyền định đoạt tài sản trong trường hợp đặc thù, định đoạt có điều kiện, cho tương lai. Định đoạt bằng di chúc có điều kiện do di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc chết, người lập di chúc có quyền sửa đổi nội dung di chúc, hủy bỏ di chúc chừng nào còn sống, còn minh mẫn. Di chúc là định đoạt tài sản trong tương lai cũng bởi vì định đoạt không có hiệu lực ngay lập tức. Do việc định đoạt trong di chúc là cho tương lai nên hành vi định đoạt tài sản không chịu sự chi phối của những quy định áp dụng cho định đoạt tài sản trong hiện tại. Mặt khác, tính chất của di chúc là giao dịch một bên bởi đây là hệ quả của sự bày tỏ ý chí của người lập di chúc. Tất nhiên, để sự chuyển giao hoàn thành thì

sự chấp nhận của người thụ hưởng là cần thiết. Tuy nhiên, để di chúc phát sinh hiệu lực, sự bày tỏ ý chí của người lập di chúc là đủ. Ngoài ra, di chúc là giao dịch của cá nhân.

Luận án tiến sĩ *“Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam”* của tác giả Phạm Văn Tuyết thực hiện năm 2003 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Với hai phương thức dịch chuyển di sản thì pháp luật nước ta luôn ưu tiên phương thức dịch chuyển theo di chúc. Nguyên tắc trên chứng tỏ pháp luật luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân của người để lại di sản. Pháp luật luôn dành cho người để lại di sản được quyền tự do ý chí trong việc lựa chọn và chỉ định người thừa kế cũng như khi nào được hưởng, được hưởng như thế nào. Để thể hiện điều đó pháp luật ghi nhận di chúc. Di chúc là phương tiện phản ánh ý chí của cá nhân trước lúc chết để định đoạt tài sản của họ. Di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương nhằm dịch chuyển tài sản và chỉ có hiệu lực khi cá nhân đó chết.

Thứ hai, khái niệm hình thức di chúc và bản chất pháp lý của hình thức di chúc.

Ở thời kỳ La Mã, cách hiểu về hình thức di chúc được ghi nhận trong các công trình:

Cuốn sách *“Introduction to Roman Law”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Giới thiệu về Luật La Mã*) của tác giả Barry Nicholas được Nxb Oxford University Press phát hành năm 2017. Các điều kiện đặt ra đối với hình thức di chúc về vấn đề làm chứng di chúc, về cách thức lập di chúc, về việc viết di chúc tùy vào từng giai đoạn của pháp luật La Mã để có những yêu cầu. Tuy nhiên hình thức di chúc có điều kiện khắt khe nhằm đảm bảo ba mục đích chính: thứ nhất, di chúc chính là sự thể hiện ý chí của người đã chết và có thể xác minh được là của chính người đó; thứ hai, những mong muốn của người đã chết được thực hiện một cách nghiêm túc vì đây là mong muốn cuối cùng của họ; và cuối cùng, di chúc được lưu giữ lại theo thời gian.

Giáo trình *“Giáo trình Luật La Mã”* của tác giả Nguyễn Ngọc Điện, Trường Đại học Cần Thơ do Nxb Chính trị quốc gia xuất bản năm 2009 xác định từ thời cổ đại thì hình thức di chúc đòi hỏi phức tạp nhưng dần dần sau đó được đơn giản hóa vào giai đoạn cuối chế độ cộng hòa. Ở giai đoạn cuối chế độ cộng hòa di chúc chỉ còn hai hình thức là di chúc có người làm chứng việc chuyển giao di sản và di chúc theo án lệ. Trong đó, di chúc theo án lệ hướng tới đề cao sự coi trọng ý chí đích thực của người chết về việc chuyển giao tài sản. Do vậy, dù các thủ tục chứng kiến việc chuyển quyền sở hữu không được tuân thủ, di chúc vẫn có giá trị. Có thể thấy, ở giai đoạn này hình thức di chúc đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu lực của di chúc. Tuy nhiên, quy định về thể thức, trình tự, thủ tục lập di chúc không phải là cứng nhắc. Mặc dù di chúc được lập không đúng hình thức thì di chúc theo án lệ vẫn được công nhận. Đây là một hướng đi rất tiến bộ trên cơ sở đề cao việc tôn trọng ý chí của người lập di chúc.

Và từ đó cũng xác định vai trò của hình thức di chúc là phương thức chủ sở hữu tài sản lựa chọn để chuyển giao tài sản của mình sau khi chết.

Ở Việt Nam, trong thời kỳ Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa đã có công trình nghiên cứu xác định bản chất pháp lý của hình thức di chúc:

Cuốn sách “*Danh từ và tài liệu Dân luật và Hiến luật*” của tác giả Vũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân, từ sách Đại học Sài Gòn xuất bản năm 1968 đã đưa ra khái niệm về hình thức di chúc. Hình thức di chúc được xem là một chứng thư pháp luật đơn phương, trong đó người lập di chúc định đoạt các tài sản của mình để cho ai sau khi chết. Chúc thư là một chứng thư có tính cách khả bãi. Người lập di chúc cho đến khi chết luôn có quyền thay đổi ý định trong chúc thư. Khái niệm về hình thức di chúc thể hiện rõ phương thức ghi nhận lại nội dung di chúc và bản chất pháp lý của di chúc. Di chúc được ghi nhận bằng văn bản và di chúc luôn luôn được thay đổi trên cơ sở ý chí đơn phương của người lập di chúc.

Cuốn sách của tác giả Huỳnh Công Bá “*Định chế Hôn nhân và gia đình thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa - Tài sản*” được Nxb Thuận Hóa xuất bản năm 2020 đã xác định chúc thư là một chứng thư đơn phương và trọng thức, chỉ có hiệu lực kể từ ngày người lập chúc chết. Sự phát biểu về ý chí của người lập chúc phải được thực hiện dưới hình thức luật định. Pháp luật đã ấn định về các hình thức này với mục đích là để cho chung ý của người lập chúc được xác thực chính xác. Do đó, nếu người lập chúc không áp dụng đúng những hình thức luật định thì chúc thư sẽ bị vô hiệu mang tính chất tuyệt đối. Nếu chúc thư đã làm theo hình thức luật định hợp lệ thì Tòa án không có quyền sửa đổi các điều khoản đã ghi trong chúc thư. Án lệ ở Nam Kỳ cũng công nhận về quyền tự do lập chúc theo các quy tắc nói trên của hai Bộ Dân luật Bắc kỳ và Dân luật Trung kỳ.

Hiện nay, cách hiểu về hình thức di chúc và vai trò pháp lý của hình thức di chúc được ghi nhận ở các công trình nghiên cứu sau:

Cuốn sách “*Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *So sánh Luật thừa kế - Tập I, Hình thức di chúc*) của các tác giả Kenneth G C Reid, Marius J De waal, Reinhard Zimmermann viết năm 2011 được Nxb Oxford University Press phát hành. Pháp luật ở phương Tây có một nguyên tắc mà không một luật sư nào nghi ngờ đó là “trừ khi có quy định khác, nếu không thì không cần phải tuân theo hình thức nào trong các giao dịch pháp lý.” Tuy nhiên, có ít nhất một hành vi pháp lý mà các hệ thống pháp luật phương Tây đặt ra các yêu cầu về hình thức đó là hành vi lập di chúc. Lý do không khó để nhận ra do di chúc chỉ có hiệu lực và thường chỉ được biết đến sau khi người lập di chúc đã chết. Khi người đó không còn có thể thay đổi về ý định của họ thì bằng chứng tốt nhất về nội dung và tính xác thực của di chúc do người đã chết để lại là thông qua hình thức di chúc. Do đó, các hệ thống pháp luật của các nước phương Tây sử dụng ba loại phương

thức để ghi nhận sự chắc chắn về ý chí của người để lại di sản là bằng văn bản, dựa vào nhân chứng hoặc sự tham gia của một tổ chức hoặc quan chức trung lập, chẳng hạn như Tòa án hoặc công chứng viên.

Bài viết của tác giả Kelly Purser, Tina Cockburn được viết năm 2019 “*Wills formalities in the twenty first century - Promoting testamentary intention in the face of societal change and advancements in technology: An Australian response to Professor Crawford*”, (tạm dịch ra tiếng Việt là *Hình thức di chúc trong thế kỷ 21 - Thúc đẩy ý định lập di chúc trước sự thay đổi của xã hội và những tiến bộ trong công nghệ: Phản hồi của Úc đối với Giáo sư Crawford*) đăng trên tạp chí Wisconsin Law Review, tập 269. Giáo sư Crawford đã lập luận rằng hình thức di chúc ngày nay không còn phục vụ các chức năng làm bằng chứng, bảo vệ nội dung di chúc hoặc cảnh báo sự giả mạo của di chúc. Bài báo đã tìm cách phản hồi những quan điểm này của Giáo sư Crawford trong bối cảnh ở Queensland. Hiện nay quan điểm về hình thức di chúc đã phá vỡ nhiều nguyên tắc khắt khe trước đó. Trước kia, hình thức di chúc phải tuân thủ đúng hoàn toàn quy định của pháp luật. Hiện nay trong một chừng mực nào đó các điều kiện và trình tự thủ tục về hình thức di chúc đã được thảo luận để có sự linh hoạt hơn. Hình thức di chúc đảm bảo là nơi chứa đựng chứng cứ để bảo vệ sự toàn vẹn nội dung di chúc. Để đạt được điều này hình thức di chúc phải tuân theo ý chí của người lập di chúc và phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Cuốn sách của tác giả Lê Đình Nghị xuất bản năm 2009 do Nxb Giáo dục Việt Nam phát hành với tên gọi “*Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1*” xác định: Hình thức di chúc là nguồn chứng cứ được sử dụng để chứng minh ý chí đích thực của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản. Khi người lập di chúc chết, căn cứ vào di chúc để xác định mong muốn của họ. Do vậy hình thức di chúc phải thể hiện được vai trò quan trọng này.

Luận án tiến sĩ “*Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam*” của tác giả Hoàng Thị Loan thực hiện năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Một di chúc có tồn tại hay không, chúng ta chưa xác định được quá trình di chúc được tạo lập bởi ai, như thế nào, quá trình lập di chúc có tự nguyện hay không mà sẽ dựa vào hình thức biểu hiện ra bên ngoài của di chúc đó. Di chúc là một giao dịch đặc biệt mà người lập di chúc chết di chúc mới phát sinh hiệu lực cho nên sự bày tỏ ý chí ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định rất quan trọng. Vì thông qua sự bày tỏ này, chúng ta nhận biết được mong muốn của người để lại di sản trong việc chuyển dịch tài sản của họ. Hình thức di chúc là một trong những yếu tố quyết định đến tính xác thực ý chí của người để lại di sản, thông qua hình thức di chúc phản ánh yếu tố trung thực hay không trong việc ghi nhận ý chí của người để lại di sản. Hình thức di chúc là một yếu tố thể hiện rõ sự điều tiết việc lập di chúc bằng ý chí của Nhà nước.

Điều này không làm mất đi quyền tự do ý chí của cá nhân mà thay vào đó là sự hỗ trợ, bảo vệ, đảm bảo thực hiện quyền lập di chúc và thực thi di chúc.

Luận văn thạc sĩ *“Hình thức di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành - những bất cập và kiến nghị”* của tác giả Triệu Khắc Thái thực hiện năm 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hình thức di chúc là một yếu tố pháp lý quan trọng của di chúc, có mối quan hệ biện chứng với nội dung, giá trị hiệu lực của di chúc và là phương tiện để diễn đạt ý chí của người lập di chúc cũng như để chứng minh sự tồn tại của di chúc. Người ta sẽ không biết sự tồn tại của di chúc nếu không được thể hiện dưới một hình thức nhất định. Với ý nghĩa đó, hình thức được thừa nhận và được quy định trong pháp luật của hầu hết các quốc gia.

Luận văn thạc sĩ *“Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội”* của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện năm 2022 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Dưới khía cạnh lý luận, hình thức di chúc biểu hiện ý chí và hành vi lập di chúc của người để lại di sản, qua đó làm phát sinh quan hệ thừa kế. Hình thức di chúc còn là chứng cứ để ghi nhận hoặc không ghi nhận quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ thừa kế. Dưới khía cạnh thực tiễn, hình thức di chúc là một trong những điều kiện then chốt để di chúc được ghi nhận tính hợp pháp. Từ đó, đảm bảo tính xác định cho di chúc và là yếu tố cần thiết cho bên thứ ba liên quan hoặc trong trường hợp có tranh chấp phát sinh.

Thứ ba, về các lý thuyết pháp lý vận dụng cho hình thức di chúc

Luận án tiến sĩ *“Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam”* của tác giả Hoàng Thị Loan thực hiện năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận án phân tích về các điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, cơ sở khoa học của các học thuyết pháp lý. Một trong những điều kiện để di chúc hợp pháp là hình thức di chúc. Luận án sử dụng học thuyết về quyền tự nhiên của con người để xác định sự tự do ý chí và hình thức thể hiện của ý chí thuộc quyền tự do của mỗi chủ thể khi xác lập giao dịch. Tuy nhiên luận án cũng sử dụng học thuyết về Nhà nước và pháp luật để chứng minh sự cân bằng trong tự do ý chí về các điều kiện có hiệu lực của di chúc và bản chất của di chúc. Trong các điều kiện đó, hình thức di chúc lại phụ thuộc nhiều vào ý chí của Nhà nước. Hình thức di chúc là một trong những tiêu chí xác định sự khác biệt rõ rệt giữa di chúc và các giao dịch dân sự khác.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Cần Thơ *“Pháp luật về điều kiện hợp pháp của di chúc”* do nhóm tác giả Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền và Trần Khắc Qui thực hiện vào năm 2021. Đề tài nghiên cứu về hình thức di chúc dưới góc độ trao quyền tự do lựa chọn hình thức di chúc cho người lập di chúc trên cơ sở chỉ cần bảo đảm di chúc được ghi nhận đúng ý chí của người để lại di

sản. Do vậy, lý thuyết về sự tự do ý chí trong hình thức của di chúc được áp dụng để xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc.

Thứ tư, các yếu tố tác động đến pháp luật về hình thức di chúc

(i) Về sự tự do ý chí của người lập di chúc

Luận văn thạc sĩ luật *“The Civil Law Influence on the Evolution of Testamentary Succession”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Ảnh hưởng của luật Dân sự đến sự thay đổi của thừa kế theo di chúc*) của tác giả Lindsay Dean Breach, năm 2013 tại khoa Luật, Trường Đại học Canterbury. Ảnh hưởng của pháp luật dân sự tới sự phát triển việc thừa kế theo di chúc được thể hiện rõ qua cái nhìn sâu sắc từ thực tiễn của Tòa án Anh và các luật gia dân sự. Di chúc phải được lập theo trình tự, thủ tục khắt khe nhất định để đảm bảo mục đích xã hội. Tuy nhiên điều đó dẫn đến tính hình thức cứng nhắc của hình thức di chúc và hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc cơ bản đề cao ý chí và tôn trọng sự thỏa thuận của pháp luật dân sự. Do đó, việc áp dụng các nguyên tắc dân luật trong đó ghi nhận sự tự do ý chí là cần thiết để làm nền tảng cho ý chí trong di chúc được bảo vệ. Những phát triển trong tương lai sẽ tiếp tục nói lỏng các thủ tục lập di chúc để đảm bảo tầm quan trọng hàng đầu của việc ghi nhận nội dung di chúc. Đây có vẻ là bước tiếp theo cần thiết nhấn mạnh mục đích ghi nhận ý chí của người để lại di sản hơn là đề cao tính chặt chẽ của hình thức di chúc.

Bài viết *“Testamentary formalities in the time of pandemic”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Hình thức di chúc trong thời kỳ dịch bệnh*) của tác giả Đurđić-Milošević, T. đăng trên tạp chí EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), số 5 năm 2021. Bài viết đánh giá việc ghi nhận quyền tự do ý chí của người lập di chúc trong việc mở rộng thêm các hình thức di chúc cho phù hợp với sự phát triển của xã hội cũng như giảm một số điều kiện về hình thức di chúc nếu di chúc được lập trong hoàn cảnh đặc biệt. Tính trọng thức của di chúc là kết quả của nhu cầu bảo vệ quyền tự do định đoạt và tính xác thực của ý chí cuối cùng của người lập di chúc. Các hình thức di chúc được ghi nhận được cho là nhằm phục vụ nhiều mục đích trong quan hệ thừa kế theo di chúc: làm bằng chứng, cảnh cáo và bảo vệ. Xét đến trình độ phát triển của xã hội hiện đại và công nghệ cũng như những thách thức mới mà con người phải đối mặt ngày nay (như đại dịch, thiên tai, v.v.), câu hỏi đặt ra là: liệu các thủ tục quy định trong việc giải quyết di chúc có hợp lý về mặt pháp lý hay không? mục đích mà họ phải phục vụ? Di chúc được lập trong thời kỳ hiện đại được đặc trưng bởi xu hướng tự do hóa các hình thức di chúc, giảm nhẹ thủ tục, bỏ một số hình thức di chúc lỗi thời nhưng cũng đưa vào các hình thức mới do hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội mới và những yêu cầu mới về thương mại pháp lý và đặc biệt là kinh nghiệm với đại dịch Covid đã khẳng định tầm quan trọng của những vấn đề này.

Cuốn sách *“Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Tập 1”* của tác giả Đỗ Văn Đại được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2020.

Theo quan điểm của tác giả di chúc là một giao dịch dân sự trọng thức thể hiện ý chí của người để lại di sản. Tuy nhiên trong thực tiễn xét xử, khi bản di chúc thể hiện đúng ý chí đích thực thì Tòa án có xu hướng ghi nhận di chúc dù di chúc được lập sai về hình thức luật định. Hướng đề cao ý chí đích thực của người đã khuất là đáng trân trọng vì chúng ta đang xem xét việc dịch chuyển tài sản mà họ để lại. Cuốn sách phân tích nhiều trường hợp thực tiễn người lập di chúc sai về hình thức nhưng Tòa án vẫn công nhận di chúc vì Tòa án theo hướng tôn trọng ý chí định đoạt tài sản của người lập di chúc.

Bài viết “*Ý chí trong giao dịch dân sự*” của tác giả Phạm Công Lạc trên tạp chí Luật học số 5 năm 1998. Bài viết phân tích về sự tự do ý chí trong các giao dịch dân sự được thể hiện như thế nào. Trong đó bài viết có đề cập đến một nội dung về sự tự do ý chí trong di chúc. Sự tự do ý chí trong di chúc phải là sự kết hợp ý chí của người lập di chúc và ý chí của Nhà nước, ý chí của cá nhân phụ thuộc ý chí của Nhà nước. Ý chí phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định. Nếu có một yếu tố phá vỡ ý chí đó sẽ dẫn đến sự không thống nhất giữa ý chí bên trong và biểu hiện ra bên ngoài. Di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương nên sự phá vỡ ý chí là do sự tác động của bên ngoài (như hành vi giả mạo, thay thế, sửa đổi, hủy bỏ di chúc). Như vậy sự tác động đó sẽ ảnh hưởng đến tính hợp pháp của di chúc.

(ii) *Về phong tục tập quán, đặc trưng của xã hội*

Cuốn sách “*Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử*” (Quyển 1 - Tập 1) của tác giả Vũ Văn Mẫu viết năm 1973 xác định di chúc miệng là hình thức di chúc được ghi nhận từ phong tục của người Việt Nam trước khi chết truyền miệng lại những mong muốn về việc phân chia tài sản cho con cháu. Ở thời nhà Nguyễn khi Bộ luật Gia Long không ghi nhận hình thức di chúc thì phải dựa vào tục lệ và quy định trước đó trong thời nhà Lê để áp dụng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “*Pháp luật về thừa kế ở Việt Nam từ thế kỷ XV đến nay*”, chủ nhiệm đề tài Phạm Kim Anh thực hiện tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Nhóm tác giả phân tích các quy định pháp luật về thừa kế từ thế kỷ XV đến BLDS 2005. Xã hội thời nhà Lê là xã hội ảnh hưởng lớn bởi tư tưởng nho giáo và phật giáo nên pháp luật thừa kế thời kỳ nhà Lê có nhiều tiến bộ so với pháp luật của các thời kỳ trước đó nhưng các quy định vẫn chịu ảnh hưởng bởi hai tư tưởng này. Đến những giai đoạn sau pháp luật về thừa kế, thừa kế theo di chúc và hình thức di chúc dần dần có quy định chi tiết và cụ thể hơn về các điều kiện, trình tự lập di chúc cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Xét đến truyền thống tập quán của người Việt Nam tôn trọng hiếu - lễ - nghĩa nên với hình thức di chúc cũng thể hiện yếu tố này đơn cử như hình thức di chúc chung của vợ và chồng.

Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Lê Thị Danh “*Hình thức của di chúc theo quy định của BLDS Việt Nam 2005*”, thực hiện năm 2009 tại Đại học Quốc gia Hà Nội

có nghiên cứu về đặc trưng của xã hội đối với hình thức di chúc. Luận văn xác định sự đa dạng về hình thức di chúc bắt nguồn từ sự phong phú và đa dạng của xã hội, từ truyền thống lịch sử quốc gia và đặc điểm riêng biệt của từng lãnh thổ nhất định. Do vậy ở mỗi quốc gia khác nhau, điều kiện về hình thức di chúc sẽ khác nhau.

Bài viết “*Hình thức của di chúc trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ*” của tác giả Lưu Thị Phần đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20, tháng 10 năm 2021. Bài viết giới thiệu về các hình thức di chúc theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam qua tiến trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến quy định hiện nay là BLDS 2015. Trong quá trình giới thiệu, bài viết đồng thời so sánh và chỉ ra những điểm khác biệt trong quy định pháp luật qua các thời kỳ. Từ đó thấy được sự phát triển trong các quy định pháp luật về hình thức di chúc dựa trên sự kế thừa từ phong tục tập quán, truyền thống và sự điều chỉnh phù hợp với xã hội hiện đại.

1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về hình thức di chúc bằng văn bản

(i) Thứ nhất, hình thức di chúc tự viết

Cuốn sách “*A Casebook on the Law of Succession*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Tình huống về Luật Thừa kế*) của tác giả Musyoka, William do Nxb African Books Collective phát hành vào năm 2010. Trong di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự viết có yếu tố quan trọng là chữ ký của người lập di chúc. Thuật ngữ “chữ ký” không được giải thích trong các đạo luật nhưng Tòa án trong quá trình giải quyết đã giải thích cách hiểu chữ ký theo nghĩa rộng. Đó chính là dấu hiệu dùng để nhận biết được người để lại di sản: điểm chỉ, tên viết tắt, tên đầy đủ, mộc đóng dấu bằng cao su có chữ ký của người lập di chúc trên đó. Chữ ký thậm chí không cần bao gồm một tên nào hoặc chỉ có một phần tên trong một số trường hợp có thể đủ để xác thực chữ ký.

Cuốn sách “*Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *So sánh Luật thừa kế - Tập I, Hình thức di chúc*) của các tác giả Kenneth G C Reid, Marius J De waal, Reinhard Zimmermann viết năm 2011 được Nxb Oxford University Press phát hành. Di chúc tự viết có thể được định nghĩa là di chúc được viết ra và do người lập di chúc ký. Một số nước yêu cầu người lập di chúc thêm ngày, tháng lập di chúc. Di chúc tự viết về bản chất khá đơn giản và rõ ràng, chỉ những người có khả năng viết mới có thể tạo lập di chúc theo hình thức này. So với các hình thức di chúc khác, điều kiện về di chúc tự viết thay đổi tương đối ít qua nhiều năm. Nhưng những thay đổi nhanh chóng trên thế giới về công nghệ đã làm thay đổi vai trò của di chúc tự viết và có thể cuối cùng đặt câu hỏi về tính hữu dụng của di chúc tự viết. Với sự sẵn có rộng rãi đầu tiên của máy đánh chữ và hiện nay là máy tính, việc sử dụng chữ viết tay đang suy giảm nghiêm trọng. Ngay từ năm 1935, một Tòa án ở Scotland đã chấp nhận một tài liệu đánh máy trên cơ sở luật pháp phải theo kịp sự tiến bộ của khoa học và cho rằng bản đánh máy là một hình thức viết tay hiện đại. Cho đến nay chưa có cơ quan tài phán nào khác đã làm theo hướng

dẫn này nhưng cũng cần đặt câu hỏi cho tương lai của di chúc tự viết có thể được thay thế bởi những hình thức di chúc được lập bằng cách đánh máy.

Cuốn sách *“Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Tập 1”* của tác giả Đỗ Văn Đại được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2020. Quan điểm tác giả cho rằng có những người không có thói quen ký mặc dù họ tự tay viết di chúc. Mặt khác, có những ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc cũng không thuận tiện cho việc ký mà phải thay vào đó là điểm chỉ vào bản di chúc. Do đó nên công nhận điểm chỉ. Ngoài ra, với điều kiện chữ viết thì cho phép được lập di chúc đối với ngôn ngữ bằng tiếng nước ngoài. Tác giả còn phân tích thêm trường hợp nếu đây là bản sao của di chúc thì nên công nhận di chúc nếu có đủ cơ sở để xác định ý chí của người lập di chúc.

Luận văn thạc sĩ *“Hình thức của di chúc”* của tác giả Lê Mai Chi thực hiện năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng đối với di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự tay viết cần bổ sung thêm sự lựa chọn điểm chỉ của người lập di chúc bên cạnh chữ ký của họ. Ngoài ra, theo quan điểm của tác giả thực chất quy định về di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự tay viết vẫn có thể điểm chỉ vào bản di chúc do áp dụng thông qua Điều 631 BLDS 2015 do vậy Điều 633 BLDS 2015 cần bổ sung thêm điều kiện về điểm chỉ cho người lập di chúc được lựa chọn.

Luận văn thạc sĩ *“Hình thức di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành – những bất cập và kiến nghị”* của Triệu Khắc Thái thực hiện năm 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội có đưa ra quan điểm của tác giả cũng cho rằng cần bổ sung điều kiện điểm chỉ thay cho lựa chọn chữ ký nếu người để lại di sản muốn điểm chỉ mà không ký vào di chúc.

(ii) *Thứ hai, hình thức di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy*

Cuốn sách *“A Casebook on the Law of Succession”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Tình huống về Luật Thừa kế*) của tác giả Musyoka, William do Nxb African Books Collective phát hành vào năm 2010. Di chúc được lập dưới sự chứng kiến của hai hoặc nhiều người làm chứng. Mỗi người trong số những người làm chứng phải nhìn thấy người lập di chúc ký tên hoặc đóng dấu vào di chúc. Mỗi người làm chứng phải ký vào di chúc trước sự có mặt của người lập di chúc nhưng không nhất thiết phải có nhiều hơn một người làm chứng tại buổi lập di chúc. Tuy nhiên đã có những trường hợp không đúng về vấn đề làm chứng nhưng vẫn công nhận di chúc. Một người lập di chúc đã yêu cầu hai người làm chứng ký tên vào di chúc hoàn toàn bằng chữ viết tay của họ. Tuy nhiên hai người làm chứng không biết đó là di chúc, thậm chí không biết bản chất của văn bản mà họ đã ký. Hai người làm chứng không thỏa điều kiện làm chứng cho việc lập di chúc nhưng di chúc có chữ ký của người lập di chúc và sau đó di chúc được công nhận. Quy định pháp luật xác định hình thức di chúc đóng vai trò quan trọng để

ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc với những điều kiện quan trọng và chi tiết về chữ ký hoặc điểm chỉ, người làm chứng. Tuy nhiên, xu hướng của pháp luật hiện đại đang dần xác định hình thức chỉ là phương thức ghi nhận ý chí. Do đó, nếu di chúc được lập không đúng điều kiện về hình thức thì vẫn công nhận di chúc đó.

Cuốn sách *“Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *So sánh Luật thừa kế - Tập I, Hình thức di chúc*) của các tác giả Kenneth G C Reid, Marius J De waal, Reinhard Zimmermann viết năm 2011 được Nxb Oxford University Press phát hành. Di chúc bằng văn bản với sự hiện diện của người làm chứng được xem là hình thức di chúc trung gian giữa di chúc tự lập với di chúc có công chứng. Đây là hình thức phức tạp hơn di chúc tự lập nhưng lại đơn giản hơn hình thức di chúc có công chứng. Vấn đề đặt ra đối với hình thức di chúc này là sự tham gia của người làm chứng trong quá trình lập di chúc và chữ ký của họ vào di chúc. Ở từng quốc gia, yêu cầu này khác nhau về vị trí của chữ ký, về sự hiện diện của người làm chứng, về sự khẳng định danh tính của người làm chứng, về việc xác định danh tính của người để lại di sản. Do vậy, để di chúc được lập an toàn thì quy định về thể thức lập phải rõ ràng, cụ thể. Đối với hình thức di chúc này người làm chứng đóng vai trò quan trọng. Mỗi nước sẽ có những quy định khác nhau về người không được làm chứng. Thông thường có thể căn cứ vào mối quan hệ giữa người làm chứng và người lập di chúc. Điều kiện đặt ra cho người làm chứng không nhiều, chỉ cần đảm bảo tính khách quan của việc làm chứng.

Cuốn sách *“Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Tập 1”* của tác giả Đỗ Văn Đại được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2020. Đối với di chúc bằng văn bản có người làm chứng tác giả phân tích về việc người làm chứng chỉ ký vào bản di chúc nhưng không có ngôn từ nào nói rõ họ xác nhận chữ ký hay điểm chỉ của người lập di chúc. Bên cạnh đó, đối với hình thức di chúc này cần quan tâm đến người viết hộ và người làm chứng. Tác giả khẳng định người viết hộ có thể là người làm chứng và nên phát triển hướng đi này. Quan điểm tác giả cho rằng danh sách những người không được làm chứng quá rộng so với pháp luật nhiều nước (do quá nghi ngờ người làm chứng). Ngoài ra, tác giả cũng nghiên cứu có những vụ việc thực tế Tòa án giải quyết những người làm chứng không thuộc trường hợp luật cấm nhưng không khách quan trong quá trình làm chứng thì Tòa án cũng không chấp nhận.

Cuốn sách *“Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015”* do tác giả Đỗ Văn Đại làm chủ biên được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam phát hành năm 2021. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng, tác giả theo hướng ủng hộ quy định cho phép người lập di chúc tự mình lựa chọn: đánh máy in ra, ký tên và nhờ người làm chứng xác nhận hoặc nhờ người viết hộ có người làm chứng

xác nhận. Nhóm tác giả cho rằng cần loại trừ nhóm người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người không biết chữ là người làm chứng.

Luận văn thạc sĩ với đề tài *“Người làm chứng cho việc lập di chúc theo quy định của pháp luật Việt Nam”* của tác giả Nguyễn Thị Hoa Huệ thực hiện tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Trong luận văn thạc sĩ luật học, tác giả đã phân tích rất cụ thể hai vấn đề về người làm chứng đó là điều kiện của người làm chứng và thực hiện làm chứng của người làm chứng. Điều kiện của người làm chứng cần loại trừ người bị hạn chế về thể chất, người làm chứng là cả hai vợ chồng thì không được. Đối với quá trình lập di chúc thì người làm chứng phải là người chứng kiến sau đó ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận việc lập di chúc và nội dung di chúc.

Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo với đề tài *“Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”* thực hiện năm 2022 tại Trường Đại học Luật Hà Nội xác định: pháp luật cần đưa ra yêu cầu về người viết hộ di chúc để đảm bảo di chúc được lập được chặt chẽ, tối ưu hơn và bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể liên quan đến di chúc. Người viết hộ cần phải đủ các điều kiện của người làm chứng và phải là người biết đọc, biết viết, biết đánh máy trên văn bản. Ngoài ra, quy định về người làm chứng phải là người không được hạn chế về khả năng tiếp nhận và hiểu toàn bộ thông tin mà người lập di chúc muốn biểu đạt, đồng thời có mặt trong toàn bộ thời gian lập di chúc.

Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân *“Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc”*, đăng trên tạp chí Dân chủ và Pháp luật năm 2020 số 335. Theo quan điểm của tác giả những người không được là người làm chứng như người bị hạn chế về thể chất đến mức ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, truyền đạt và lưu trữ thông tin; người nước ngoài không đọc, viết thành thạo tiếng Việt; người không biết chữ; cả hai vợ chồng không được cùng làm chứng cho di chúc.

(iii) Thứ ba, hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực

Cuốn sách *“Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *So sánh Luật thừa kế - Tập I, Hình thức di chúc*) của các tác giả Kenneth G C Reid, Marius J De waal, Reinhard Zimmermann viết năm 2011 được Nxb Oxford University Press phát hành. Ở nước ngoài chỉ tồn tại hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng và bao gồm ba loại (tùy vào quốc gia): di chúc bí mật, di chúc công khai và di chúc quốc tế (international will và hiện nay có ba quốc gia ghi nhận hình thức di chúc này là Ý, Pháp, Bỉ). Mặc dù di chúc có công chứng khá tốn kém chi phí để lập nhưng di chúc được lập cẩn thận và an toàn vì công chứng viên là người am hiểu pháp luật và thực hiện thể thức lập di chúc theo đúng trình tự luật định. Tuy nhiên thủ tục lập di chúc có công chứng khá phức tạp. Trong ba loại hình thức di chúc này thì di chúc công khai được ưa chuộng sử dụng.

Cuốn sách *“Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Tập 1”* của tác giả Đỗ Văn Đại được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2020. Đối với di chúc có công chứng, chứng thực tác giả phân tích về sự tranh cãi của các điều luật là Điều 635, 636, 639 BLDS 2015 vì thực tế phát sinh trường hợp người lập di chúc tự lập di chúc tại nhà rồi mang di chúc đến tổ chức công chứng hoặc Ủy ban nhân dân (UBND) để xác nhận di chúc. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất, người không biết chữ cần phải có quy định làm rõ nhóm người này.

Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo với đề tài *“Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”* thực hiện năm 2022 tại Trường Đại học Luật Hà Nội xác định rằng đối với di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực tác giả đề xuất quy định hiện nay trong BLDS 2015 nên gộp hai điều luật này thành một điều luật. Bởi vì quy định hiện nay dẫn đến cách hiểu sai về trình tự, thủ tục lập di chúc phải có công chứng, chứng thực dẫn đến di chúc bị lập sai về hình thức.

Luận văn thạc sĩ luật học *“Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực”* của tác giả Trần Thị Thúy thực hiện năm 2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Tác giả phân tích thực trạng tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục công chứng di chúc tại các tổ chức công chứng. Trường hợp người lập di chúc lập sẵn di chúc ở nhà và mang di chúc đến các tổ chức công chứng để yêu cầu công chứng di chúc thì Luật Công chứng lại bỏ ngỏ vấn đề này. Ngoài ra, theo quy định của Luật Công chứng thì chỉ có thể công chứng ngoài tổ chức công chứng trong một số trường hợp nhất định và người công chứng di chúc phải là công chứng viên. Tuy nhiên quy định trong BLDS lại cho phép công chứng di chúc không giới hạn ở các trường hợp và thực tiễn người đến chứng kiến sự kiện lập di chúc không phải là công chứng viên mà có thể chỉ là nhân viên của tổ chức công chứng. Mặt khác, BLDS không quy định việc chứng thực di chúc ngoài UBND cấp xã nhưng theo văn bản hướng dẫn chứng thực thì có thể thực hiện điều này. Và thực tiễn khi những di chúc trong các trường hợp này được lập không đúng trình tự, thủ tục Tòa án vẫn công nhận di chúc. Do đó, tác giả đề xuất không nên yêu cầu công chứng viên, người có thẩm quyền của UBND phải ghi chép lại di chúc mà họ chỉ là người chứng kiến quá trình lập và xác nhận di chúc.

Bài viết của tác giả Đỗ Văn Đại, Nguyễn Hồ Bích Hằng *“Di chúc có công chứng, chứng thực”* đăng trên tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, số 1, năm 2013. Bài viết phân tích về di chúc có công chứng, chứng thực trên cơ sở một bản án đã được giải quyết của Tòa án. Thực tế người lập di chúc tự soạn di chúc tại nhà và mang di chúc đi chứng thực và Tòa án đã công nhận di chúc đó. Hai điều luật được các tác giả phân tích cho thấy có nhiều cách hiểu khác nhau về di chúc có công chứng, chứng thực. Tuy nhiên quan điểm của các tác giả cho rằng nên ghi nhận một cách linh hoạt trình tự lập di chúc có công chứng, chứng thực vì nếu người lập di chúc tự lập, họ

mang di chúc đi công chứng hoặc chứng thực là đã thể hiện di chúc được ghi nhận đúng ý chí của họ và nên công nhận di chúc.

Bài viết của tác giả Hoàng Thị Loan về “*Một số bất cập và hướng hoàn thiện quy định về hình thức của di chúc trong Bộ luật dân sự*” trên tạp chí Luật học số 11 năm 2017. Đối với di chúc có công chứng, chứng thực tác giả kiến nghị bỏ Điều 639 BLDS 2015 và thay đổi tên của Điều 636 BLDS 2015 thành thủ tục do công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã thực hiện.

(iv) *Thứ tư, hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực*

Cuốn sách “*A Casebook on the Law of Succession*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Tình huống về Luật Thừa kế*) của tác giả Musyoka, William do Nxb African Books Collective phát hành vào năm 2010. Ở nước ngoài, hình thức di chúc với thủ tục rút gọn được gọi là di chúc đặc quyền. Di chúc đặc quyền là di chúc được coi là hợp pháp dù không tuân thủ những thủ tục pháp lý nghiêm ngặt cần có của một bản di chúc thông thường về người làm chứng, về công chứng. Di chúc đặc quyền được lập tại những hoàn cảnh mà người lập di chúc không thể nào tuân theo thể thức lập di chúc thông thường như các nữ tu, những người lính trong lực lượng vũ trang trong thời gian phục vụ tại ngũ tham gia hoạt động quân sự, thương gia hàng hải đang ở trên biển hoặc tiến tới biển.

Cuốn sách “*Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *So sánh Luật thừa kế - Tập I, Hình thức di chúc*) của các tác giả Kenneth G C Reid, Marius J De waal, Reinhard Zimmermann viết năm 2011 được Nxb Oxford University Press phát hành. Trong những trường hợp đặc biệt như đang trên máy bay, trên tàu biển hoặc quân nhân đang trong khu vực quân sự muốn lập di chúc có thể lựa chọn hình thức di chúc đặc biệt này. Thể thức lập di chúc đã được giản lược về số lượng và điều kiện của người làm chứng cũng như điều kiện của người xác nhận di chúc có thể không phải là công chứng viên mà là những người đứng đầu, phụ trách đơn vị ở hoàn cảnh đó.

Bài viết “*Are military testamentary instruments unconstitutional? Why compliance with state testamentary formality requirement remains essential*” (tạm dịch ra tiếng Việt là *Di chúc quân sự có vi hiến không? Tại sao việc tuân thủ yêu cầu về hình thức di chúc của nhà nước vẫn cần thiết*) của tác giả Nowell D. Bamberger đăng trên tạp chí Military Law Review, số 196, năm 2008. Bài viết phân tích cụ thể về hình thức di chúc được lập trong quân đội do những người lính đang thực hiện nhiệm vụ lập. Đối với nhóm đối tượng này đòi hỏi các điều kiện đặc biệt và một trong những vấn đề mà bài viết đi sâu vào phân tích đó là làm thế nào để đảm bảo rằng di chúc của quân nhân đã chết được chứng thực mặc dù có sự không phù hợp quy định của liên bang với tiểu bang. Các yêu cầu về hình thức di chúc là một trong những vấn đề mà

pháp luật liên bang không đề cập. Với quyền lập pháp độc lập giữa các tiểu bang, đối với các quy trình chứng thực di chúc, pháp luật của các tiểu bang lại cung cấp các cơ chế để công nhận di chúc trong quân đội bất chấp những khiếm khuyết kỹ thuật. Để tránh sự vô hiệu của di chúc của quân nhân trong bất kỳ trường hợp nào, các luật sư tuân theo các yêu cầu là phải nêu rõ nơi di chúc dự kiến sẽ được trình bày để chứng thực di chúc.

Trong cuốn sách “*Giáo trình Luật La Mã*” của tác giả Nguyễn Ngọc Điện được Nxb Chính trị quốc gia xuất bản năm 2009 phân tích về các hình thức di chúc bằng văn bản của luật La Mã qua các giai đoạn. Ở giai đoạn luật cổ La Mã, theo Luật Mười hai bảng di chúc phải được chấp thuận của Đại hội công dân hoặc ít nhất trước sự chứng kiến của Đại hội đó. Công dân đang lâm chiến có thể lập di chúc quân sự. Các di chúc loại này có tác dụng công khai ý chí của người có di sản liên quan đến việc chuyển giao tài sản nên không thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo với đề tài “*Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội*” thực hiện năm 2022 tại Trường Đại học Luật Hà Nội xác định đối với những di chúc được lập trong trường hợp đặc biệt (những người lập di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực) nên bổ sung thêm ghi âm, ghi hình. Mặc dù hình thức này tiềm ẩn những rủi ro nhưng cũng có những mặt mạnh riêng rất tiện lợi và đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại.

Bài viết của tác giả Hoàng Thị Loan về “*Một số bất cập và hướng hoàn thiện quy định về hình thức của di chúc trong Bộ luật dân sự*” trên tạp chí Luật học số 11 năm 2017. Đối với di chúc có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực không khả thi về mặt thực tế thực hiện nên cũng không cần thiết quy định trừ trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài cần xác nhận.

(v) Thứ năm, hình thức di chúc điện tử

Đề tài nghiên cứu “*Technology and wills - the dawn of a new era*” (tạm dịch ra tiếng Việt là Công nghệ và di chúc – Khởi đầu của kỷ nguyên mới) của tác giả Kimberley Martin và Worrall Moss Martin được công bố tháng 8 năm 2020. Đây là một tài liệu nghiên cứu về di chúc điện tử. Trong tài liệu nghiên cứu này giới thiệu đầy đủ về cách hiểu của di chúc điện tử, chữ ký điện tử, vai trò, chức năng, trình tự lập di chúc điện tử. Theo cách hiểu khái quát, di chúc điện tử được hiểu là di chúc được lập, được ký và lưu trữ bằng các thiết bị điện tử. Tuy nhiên có nhiều loại di chúc điện tử có thể được xem xét đến. (i) Di chúc điện tử ngoại tuyến là những di chúc được đánh giá đơn giản (đánh máy hoặc viết tay qua bút cảm ứng) vào một thiết bị điện tử của chính người lập di chúc, do người lập di chúc ký tên vào di chúc và được lưu trữ trên thiết bị điện tử có ổ cứng cục bộ. Di chúc thường không được in, chứng thực theo cách truyền

thống hoặc tải lên trang mạng. (ii) Di chúc điện tử trực tuyến là di chúc được tạo hoặc lưu trữ bằng dịch vụ của bên thứ ba. (iii) Di chúc điện tử được lập có tổ chức giám sát đủ điều kiện. Tổ chức giám sát này vì lợi nhuận cam kết trở thành người giám sát đủ điều kiện sẽ tạo, thực hiện và lưu trữ di chúc của người lập di chúc, tuân theo các quy tắc và quy định do luật đưa ra.

Bài viết *“Electronic Wills in South Africa”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Di chúc điện tử ở Nam Phi*) của tác giả Sizwe Snail and Nicholas Hall trên tạp chí Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, số 7 năm 2010. Trong bài viết có đề cập đến việc sử dụng công nghệ cho việc lập di chúc. Thông thường, di chúc phải được thực hiện vào bản giấy có chữ ký của người lập di chúc và người làm chứng được ghi vào văn bản. Trong trường hợp di chúc của thủy thủ, binh lính và phi công có thể lập di chúc miệng. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp di chúc được lập với hình thức thể hiện theo mong muốn tự do của người để lại di sản. Như vậy, những người thực hành pháp luật phải nhận thức được những phát triển này và đánh giá việc sử dụng truyền dữ liệu cho mục đích pháp lý để xác định di chúc hợp lệ. Điều kiện di chúc điện tử là phải được viết ra dưới dạng thông điệp dữ liệu, có thể truy cập nhiều lần và phải được ký bằng chữ ký số. Đồng thời cần phải có ít nhất hai người làm chứng có sử dụng chữ ký số để ký vào bản di chúc.

Bài viết *“Electronic Wills: Drawing a line in the sand against their validity”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Di chúc điện tử: ranh giới mập mờ về hiệu lực*) của tác giả Bodderly, Scott S đăng trên tạp chí Real Property, Trust, and Estate Law Journal, Chicago số 47, năm 2012. Bài viết đề cập đến việc các cơ quan lập pháp tiểu bang có nên đi theo hướng của bang Nevada, Mỹ trong việc ban hành luật cho phép các Tòa án công nhận tính hợp lệ của di chúc chỉ tồn tại ở định dạng điện tử gốc. Ngoài ra, bài viết còn phân tích những chi phí của việc sửa đổi các mã chứng thực di chúc hiện có áp dụng cho di chúc hoàn toàn bằng điện tử để tránh những trường hợp giả mạo di chúc trong thời đại kỹ thuật số. Các mã chứng thực di chúc hiện tại đủ linh hoạt để cho phép Tòa án áp dụng mà không cần ban hành Luật Di chúc điện tử. Tòa án công nhận di chúc để bảo vệ ý chí của người lập di chúc, nhưng các nhà lập pháp phải cân nhắc chức năng này với các biện pháp bảo vệ quan trọng và các biện pháp chứng cứ cần thiết để biến việc thực hiện đó thành hiện thực.

Bài viết *“Testamentary succession, new technologies and recodification: on the research that need to be conducted”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Thừa kế theo di chúc, công nghệ mới và sự công nhận: nghiên cứu để ghi nhận*) của tác giả Mariusz Zalucki đăng trên tạp chí Societas et Iurisprudencia số 2, tập 2 năm 2014. Bài viết đề cập đến nhiệm vụ chính của pháp luật thừa kế ở thời kỳ hiện đại trong mối quan hệ với việc dịch chuyển tài sản từ chủ sở hữu tài sản. Băng ghi âm, ghi hình kỹ thuật số trên các máy tính, điện thoại thông minh, máy quay phim là phương tiện để người để lại di sản

có thể ghi nhận lại ý chí của mình. Chúng ta có thể gọi đó là một di chúc ghi hình trong xã hội hiện đại. Nhiệm vụ là phải làm sao để những phương tiện kỹ thuật hiện đại có thể chứa đựng, lưu giữ ý chí của người để lại di sản một cách chính xác nhất.

Bài viết *“About the Need to Adjust the Regulations Regarding the Form of Will to the Modern Requirements”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Về sự cần thiết điều chỉnh các quy định về hình thức di chúc đối với các yêu cầu hiện đại*) của tác giả Mariusz Zahucki trên tạp chí *European Journal of Economics, Law and Politics*, tập 6, số 2 năm 2019. Để đảm bảo việc ghi nhận lại di chúc của người lập di chúc trước khi chết, các nhà lập pháp phải tìm kiếm hình thức có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các hình thức có nguồn gốc từ thời kỳ La Mã. Do đó, bên cạnh các hình thức di chúc truyền thống đã đến lúc bắt đầu nghiên cứu về những hình thức di chúc mới cho phù hợp với thời điểm hiện nay. Những công nghệ mới cũng là những thách thức mới đối với luật thừa kế. Các yêu cầu lập di chúc bằng tay hoặc bất kỳ cách truyền thống nào khác, giờ đây không thể được hiểu theo cùng một cách như khi hình thức di chúc truyền thống được tạo ra. Hình thức di chúc mới đưa ra tuyên bố về ý chí, dựa trên các công cụ kỹ thuật cũng là phương tiện sẵn sàng để được sử dụng trong hình thức di chúc.

Bài viết *“Welcoming e-wills into the mainstream: the digital communication of testamentary intent”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Tiếp nhận di chúc điện tử trở thành xu hướng chủ đạo: giao tiếp kỹ thuật số trong di chúc*) của tác giả Paige Hall đăng trên tạp chí *Nevada Law Journal* số 20.1, năm 2019. Bài viết đề cập đến vấn đề di chúc điện tử được thừa nhận ở Tòa án, cân nhắc xem xét những bất lợi trong cách tiếp cận di chúc điện tử so với di chúc truyền thống. Mục tiêu của nội dung này để xem xét yếu tố cân bằng giữa lợi ích của Nhà nước trong việc thực hiện bốn chức năng của di chúc với lợi ích của di chúc trong việc ghi nhận nguyên tắc cơ bản của luật về di chúc đó là quyền tự do định đoạt. Để chứng minh cho lý thuyết về quyền tự do định đoạt thì bài viết đề cập đến hai án lệ xảy ra ở Ohio và Michigan, Mỹ. Từ đó, tác giả của bài viết rút ra kết luận về việc xem xét các điều kiện của di chúc điện tử không thể nào giống với di chúc được lập truyền thống.

Bài viết của tác giả Banta, Natalie M về *“Electronic Wills and digital assets: Reassessing formality in the digital age”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Di chúc điện tử và tài sản kỹ thuật số: Đánh giá lại hình thức trong thời đại kỹ thuật số*) đăng trên tạp chí *Baylor Law Review*, năm 2019, tập 71, số 3. Luật tài sản kỹ thuật số của Mỹ mở ra cánh cửa cho một sự thay đổi sâu rộng hơn - di chúc hoàn toàn bằng điện tử. Thông qua di chúc điện tử sẽ là một thay đổi đáng kể đối với Đạo luật Di chúc nhưng sẽ không thay đổi đáng kể việc chuyển nhượng tài sản sau khi chết. Bài viết trình bày các lập luận về di chúc điện tử có thể là bằng chứng đáng tin cậy bảo vệ lợi ích của người lập di chúc và thực hiện các mục đích của luật thừa kế. Các cơ quan lập pháp tiểu bang

nên thông qua luật cho phép di chúc điện tử để mang lại một phương thức hiệu quả và tiết kiệm chi phí để chuyển tài sản khi chết và khuyến khích nhiều người hơn thực hiện quyền tự do định đoạt của họ.

Bài viết *“The electronic Wills act: facing the inevitable”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Đạo luật di chúc điện tử: đối diện với sự tất yếu*) của tác giả Gary, Susan N, Orlando J. and Marian H. Hollis đăng trên tạp chí Real Property, Trust, and Estate Law Journal; Chicago tập 55, số 3, năm 2021. Các vấn đề liên quan đến di chúc điện tử phụ thuộc vào ý nghĩa của di chúc điện tử. Mặc dù người lập di chúc có thể viết di chúc bằng tay nhưng ngày nay phần lớn di chúc được tạo ra bằng các phương tiện điện tử như đánh máy vì tính sau đó người lập di chúc hoặc luật sư in ra. Những di chúc này không được gọi là di chúc điện tử. Theo Luật Di chúc điện tử một tài liệu được tạo lập bằng các phương tiện điện tử và lưu trữ ở dạng điện tử mới được gọi là di chúc điện tử.

Bài viết *“Electronic Wills: COVID-19 Relief or Inevitable Trouble for California?”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Di chúc điện tử: Sự giải vây cho dịch Covid-19 hoặc những khó khăn không thể giải quyết ở California?*) của tác giả Francesca Torres đăng trên tạp chí University of the Pacific Law Review, bài 14, số 52, tập 2, năm 2021. Bài viết phân tích cụ thể về giai đoạn khi có đại dịch Covid-19 diễn ra ở Mỹ và người lập di chúc, luật sư không thể gặp mặt nhau để lập di chúc. Tiểu bang Nevada có thừa nhận việc lập di chúc không gặp khó khăn này, nhưng một số tiểu bang khác thì phát sinh khó khăn. Do vậy tiểu bang California đã có văn bản về việc thừa nhận di chúc điện tử để giải quyết trong giai đoạn đại dịch. Lúc này di chúc điện tử có thể sử dụng hai phương thức chứng thực di chúc. Phương thức thứ nhất là áp dụng cách truyền thống bằng việc yêu cầu sự hiện diện của hai nhân chứng trong quá trình xác nhận di chúc. Những nhân chứng đó phải cư trú tại tiểu bang nơi người lập di chúc đang thực hiện di chúc. Phương thức thứ hai cho phép làm chứng từ xa (làm chứng điện tử) nếu cả người lập di chúc và người làm chứng đồng thời ký vào văn bản điện tử của nhau bằng chữ ký số.

Bài viết *“Testamentary formalities in the time of pandemic”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Hình thức di chúc trong thời kỳ dịch bệnh*) của tác giả Đurđić-Milošević, T. đăng trên tạp chí EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), số 5 năm 2021. Khi có đại dịch Covid đã hạn chế quyền tự do lập di chúc theo hướng hạn chế sự tiếp xúc, hiện diện trực tiếp của các công chứng viên hoặc thẩm phán với tư cách là đại diện của các cơ quan công quyền như một yếu tố bắt buộc về hình thức trong các mẫu di chúc công khai; không thể lập hoặc khó bảo đảm lập di chúc có người làm chứng. Vì vậy, những người mù chữ và người khuyết tật bị tước đi cơ hội thực hiện quyền tự do lập di chúc được Hiến pháp bảo đảm do họ không thể lựa chọn những hình thức di chúc khác như là di chúc tự lập. Tình hình đại dịch mới đã khiến

pháp luật phải theo các hướng sau: liệu có cần thiết phải đưa ra các hình thức di chúc mới trong thời kỳ đại dịch hay không (như đã được thực hiện ở Tây Ban Nha, nơi quy định về di chúc trong thời kỳ đại dịch); một số yếu tố nhất định của hình thức di chúc có nên được hiện đại hóa hay không (ví dụ: cho phép khả năng có sự tham gia của người làm chứng trong di chúc trong quá trình lập di chúc trực tuyến qua liên kết âm thanh-video)?; và cuối cùng, liệu có nên mở cửa cho việc số hóa di chúc và khả năng lập di chúc điện tử, đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới của luật di chúc? Đây cũng chính là yêu cầu về thời đại cho di chúc điện tử xuất hiện.

1.1.3. Nhóm các công trình nghiên cứu về hình thức di chúc miệng

Cuốn sách *“A Casebook on the Law of succession”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *Tình huống về Luật thừa kế*) của tác giả Musyoka, William do Nxb African Books Collective phát hành vào năm 2010. Di chúc miệng được lập với sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng thỏa mãn điều kiện và di chúc không thể có hiệu lực trừ khi người lập di chúc chết trong vòng ba tháng sau khi di chúc được tạo ra. Cơ sở lý luận đằng sau điều khoản trong quy định về thời gian với nguyên nhân nói bằng miệng có nguy cơ khiến những người làm chứng có thể quên một số chi tiết hoặc báo cáo sai khi thời gian dài hơn để ghi chép lại di chúc được cho phép. Các lý do khác là những di chúc như vậy thường được lập trong trạng thái hoang mang, sợ hãi hoặc lo lắng. Chẳng hạn khi người lập di chúc bị ốm nặng hoặc đang trong tình trạng nguy cấp. Mọi người trong tình trạng như vậy có xu hướng không hợp lý khi đưa ra các quyết định của họ và thể hiện ý định mà họ có thể không bao giờ có nếu họ có một suy nghĩ kỹ càng hơn. Khoảng thời gian ba tháng nhằm cho phép họ có thời gian xem xét lại các điều khoản của di chúc và nếu họ muốn thay đổi thì họ sẽ lập di chúc khác.

Cuốn sách *“Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities”* (tạm dịch ra tiếng Việt là *So sánh Luật thừa kế - Tập I, Hình thức di chúc*) của các tác giả Kenneth G C Reid, Marius J De waal, Reinhard Zimmermann được Nxb Oxford University Press phát hành năm 2011. Không phải nước châu Âu nào cũng thừa nhận di chúc miệng. Nếu thừa nhận di chúc miệng thì điều kiện cũng cần người làm chứng, ghi chép lại và chỉ được lập di chúc miệng trong tình huống đặc biệt với những chủ thể đặc biệt như những người lính, thủy thủ trên tàu... Về lý thuyết, ranh giới giữa các mô hình về hình thức di chúc có thể bị mờ nhạt vì di chúc miệng có thể được ghi lại bằng văn bản trong khi di chúc bằng văn bản cũng được viết lại.

Cuốn sách *“Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án, Tập I”* của tác giả Đỗ Văn Đại được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2020. Tác giả đã phân tích tất cả các điều kiện đặt ra về di chúc miệng và theo quan điểm của tác giả xác định các điều kiện khá khắt khe nên việc áp dụng vào thực tế rất hiếm gặp Tòa án chấp nhận di chúc miệng và chưa gặp di chúc miệng nào được chấp nhận khi vận dụng đúng các điều kiện mà BLDS 2005, 2015 đặt ra.

Cuốn sách *“Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015”* do tác giả Đỗ Văn Đại làm chủ biên được Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam xuất bản năm 2021. Theo quan điểm của tác giả, hạn chế ở di chúc miệng là thời điểm ghi chép lại. Quy định của pháp luật “ngay sau khi” rất khó giải thích là khi nào và cần án lệ thuyết phục giải quyết. Ngoài ra, vấn đề công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong thời hạn 5 ngày làm việc theo các tác giả nếu không kịp cũng vẫn nên thừa nhận di chúc và hy vọng án lệ sẽ giải quyết theo hướng này.

Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Lê Mai Chi thực hiện năm 2019 với đề tài *“Hình thức của di chúc”* tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối với vấn đề di chúc miệng tác giả cho rằng việc sử dụng thuật ngữ miệng trong BLDS 2015 là không phù hợp với xu thế của thế giới cũng như trình độ lập pháp. Trước đây pháp luật thường sử dụng thuật ngữ hợp đồng miệng. Nhưng hiện nay các thuật ngữ đã được thay đổi như hợp đồng bằng lời nói, giao dịch bằng lời nói. Do vậy theo tác giả cho rằng thuật ngữ di chúc miệng nên được thay thành di chúc bằng lời nói. Ngoài ra, pháp luật nên thừa nhận hình thức ghi âm, ghi hình để di chúc miệng tăng độ thuyết phục về mặt chứng cứ và cũng phù hợp với xã hội hiện nay khi công nghệ đã phát triển.

Luận văn thạc sĩ *“Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực”* của tác giả Trần Thị Thúy thực hiện năm 2017 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực di chúc miệng theo BLDS 2015 không mang tính khả thi do đó nên thay đổi trình tự, thủ tục này hoặc ghi nhận bản ghi âm ghi hình thay thế cho di chúc miệng.

Bài viết của tác giả Hoàng Thị Loan về *“Một số bất cập và hướng hoàn thiện quy định về hình thức của di chúc trong Bộ luật dân sự”* trên tạp chí Luật học số 11 năm 2017. Tác giả không đồng tình với quy định ba tháng di chúc miệng sẽ bị hủy bỏ. Tác giả cho rằng có thể theo một trong hai hướng. Hướng thứ nhất, thay vì xác định là ba tháng thì nên xác định là có đủ thời gian về khả năng lập di chúc bằng văn bản. Hướng thứ hai, không nên đề cập đến vấn đề thời gian mà nên tôn trọng ý chí của người lập di chúc. Ngoài ra, tác giả cho rằng cần bổ sung thêm việc công chứng, chứng thực không chỉ là chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng mà còn xác nhận thông tin cá nhân của người làm chứng.

Bài viết *“Bình luận về vụ án giải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc miệng”* của tác giả Nguyễn Minh Hằng đăng trên tạp chí Nghề Luật, số 2 năm 2019. Bài viết bình luận về một vụ việc thực tế đã được giải quyết thông qua Tòa án. Từ đó tác giả có đánh giá về vấn đề công chứng, chứng thực di chúc miệng: công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực không thể nào công chứng, chứng thực giao dịch của một người mà yêu cầu lại xuất phát từ người khác. Do đó việc bổ sung quy định pháp luật

về công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng cho di chúc miệng là phù hợp.

1.2. Đánh giá kết quả những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án

Nhìn chung, tình hình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về di chúc nói chung và hình thức di chúc nói riêng có được sự quan tâm của những nhà nghiên cứu và thực hành pháp luật. Trên cơ sở những công trình nghiên cứu tiếp cận được, tác giả đánh giá kết quả nghiên cứu của những công trình đó như sau:

1.2.1. Những vấn đề lý luận về hình thức di chúc

(i) Khái niệm và bản chất pháp lý của hình thức di chúc: Xuất phát từ việc xác định bản chất pháp lý của di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương và di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc chết. Việc xác thực lại ý chí của người để lại di sản vào thời điểm di chúc có hiệu lực là không thể vì vậy hình thức di chúc đóng vai trò quan trọng để ghi nhận lại chính xác ý chí của họ. Tác giả nhận thấy đã có nhiều công trình nghiên cứu về khái niệm hình thức di chúc. Khái niệm về hình thức di chúc được tiếp cận dưới góc độ liệt kê các vai trò, chức năng của hình thức di chúc: hình thức di chúc là chứng cứ để ghi nhận nội dung di chúc, là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của người thừa kế theo di chúc, là phương thức ghi nhận lại nội dung di chúc. Tuy nhiên khái niệm được đề cập trong mỗi một công trình nghiên cứu chỉ liệt kê được một vai trò hoặc một chức năng của hình thức di chúc. Cách hiểu về hình thức di chúc chưa được phân tích, luận giải để xây dựng thành một khái niệm tổng quát có thể làm rõ ý nghĩa, bản chất pháp lý và chưa chỉ rõ được các yếu tố cấu thành của hình thức di chúc.

(ii) Các yếu tố tác động đến pháp luật về hình thức di chúc:

- Sự tự do ý chí của người lập di chúc đã có một số công trình đề cập tuy nhiên các công trình nghiên cứu chỉ đề cập đến một cách sơ lược các vấn đề mang tính tổng quan. Công trình nghiên cứu phân tích về sự tự do ý chí trong các điều kiện ảnh hưởng đến hiệu lực của di chúc mà không tập trung phân tích vào hình thức di chúc. Theo nghiên cứu của các công trình, sự tự do ý chí về các điều kiện có hiệu lực của di chúc là không tuyệt đối mà bị giới hạn bởi ý chí của Nhà nước. Đó cũng chính là điểm khác biệt trong quan hệ về thừa kế theo di chúc với quan hệ hợp đồng và hình thức di chúc là một căn cứ để phân biệt di chúc và các giao dịch dân sự khác. Có công trình xác định sự tự do ý chí trong hình thức di chúc còn được thể hiện thông qua hoạt động xét xử của Tòa án đã công nhận yếu tố này. Nhiều bản án được Tòa án công nhận di chúc mặc dù di chúc được lập sai về hình thức nhưng nội dung thể hiện chính xác ý chí của người lập di chúc.

- Yếu tố phong tục tập quán, đặc tính đặc trưng của xã hội đã có công trình khoa học nghiên cứu trên cơ sở phân tích khía cạnh lịch sử của các quy định pháp luật về thừa kế. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu về phong tục tập quán tập trung vào nghiên cứu các quy định của pháp luật thừa kế nói chung như về người thừa kế, nội

dung di chúc, người lập di chúc chịu ảnh hưởng bởi yếu tố phong tục tập quán như thế nào. Những công trình nghiên cứu riêng về hình thức di chúc chưa đánh giá rõ sự phát triển của tiến trình lịch sử pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc và chưa phân tích được nguyên nhân của sự thay đổi các quy định pháp luật về hình thức di chúc qua các giai đoạn lịch sử. Đối với các đặc tính đặc trưng của xã hội công trình nghiên cứu mới dừng lại ở việc giới thiệu về đặc trưng của xã hội chứ chưa phân tích sự ảnh hưởng và tác động đến hình thức di chúc.

- Các yếu tố khác như về chủ thể lập di chúc, hoàn cảnh lập di chúc, tài sản được định đoạt trong di chúc chi phối đến pháp luật về hình thức di chúc: Tác giả nhận thấy chưa thấy có công trình nghiên cứu nào về các yếu tố này.

(iii) Các học thuyết pháp lý ảnh hưởng đến việc xây dựng các quy định pháp luật về hình thức di chúc đã có công trình nghiên cứu đề cập nhưng dưới góc độ nghiên cứu về các điều kiện để một di chúc có hiệu lực pháp luật và hình thức di chúc là một trong những điều kiện này. Trong đó công trình nghiên cứu chỉ rõ các học thuyết có thể áp dụng cho các điều kiện để di chúc có hiệu lực là học thuyết tự do ý chí, học thuyết luật tự nhiên và học thuyết Nhà nước và pháp luật. Sự kết hợp giữa các học thuyết này thể hiện rõ được bản chất của di chúc.

1.2.2. Hình thức di chúc bằng văn bản

(i) Hình thức di chúc tự viết: Các công trình nghiên cứu đã phân tích về điều kiện chữ ký của người lập di chúc. Đối với hình thức di chúc này, chữ ký là điều kiện quan trọng để xác thực ý chí của người để lại di sản. Tuy nhiên cũng có công trình nghiên cứu đề cập đến việc công nhận điểm chỉ thay cho chữ ký trong những trường hợp người để lại di sản không ký hoặc yếu tố đặc thù của chữ viết làm người để lại di sản phải lựa chọn điểm chỉ.

(ii) Hình thức di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy: Các công trình nghiên cứu tập trung vào yếu tố làm chứng của người làm chứng do đây là đặc trưng của hình thức di chúc này. Người làm chứng phải là người chứng kiến việc lập di chúc và điều kiện của người làm chứng là phải hiểu được nội dung di chúc và phải khách quan trong quá trình làm chứng. Do vậy, nhiều công trình đề xuất người làm chứng không thể là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người không biết chữ, vợ, chồng cùng làm chứng cho một di chúc, người nước ngoài không đọc viết thành thạo tiếng Việt. Mặt khác, đã có tài liệu nghiên cứu về điều kiện của người viết hộ di chúc: phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện của người làm chứng; phải biết viết, biết đọc, đánh máy, phải hiểu và truyền tải, ghi nhận được ý chí của người để lại di sản. Ngoài ra, người viết hộ di chúc phải có mặt trong suốt thời gian di chúc được lập.

(iii) Hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực: Các công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập về trình tự, thủ tục thực hiện việc công chứng hoặc chứng thực và ưu điểm, nhược điểm của hình thức di chúc này so với di chúc tự lập

hoặc di chúc đánh máy, nhờ người khác lập. Ở Việt Nam, việc công chứng hoặc chứng thực tại các tổ chức công chứng, UBND hay thực hiện ở nhà đang là điều gây tranh cãi và đã có nhiều cách hiểu khác nhau về việc vận dụng các điều luật này cho việc công chứng hoặc chứng thực di chúc. Mặt khác, đã có công trình nghiên cứu về người bị hạn chế về thể chất và đề xuất pháp luật cần phải làm rõ người bị hạn chế về thể chất phải theo yêu cầu nào mới cần lập di chúc có công chứng, chứng thực.

(iv) Hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực: Ở nước ngoài gọi tên là hình thức di chúc đặc quyền chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt (những người lính đang tham gia cuộc chiến, những thủy thủ thực hiện nhiệm vụ trên tàu...) và sẽ lập di chúc với thủ tục rút gọn. Nhiều nước ghi nhận hình thức di chúc này để đảm bảo tất cả mọi người ở mọi hoàn cảnh đều có thể lập di chúc. Do di chúc được lập ở hoàn cảnh khó khăn nên những thủ tục rườm rà sẽ không thể thực hiện được. Ở Việt Nam, di chúc này cũng dành cho những người trong hoàn cảnh đặc biệt tuy nhiên theo các công trình nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam không mang tính khả thi do khó yêu cầu người có quyền xác nhận di chúc chứng kiến và xác nhận vào bản di chúc.

(v) Hình thức di chúc điện tử: Các tài liệu nước ngoài đã có ghi nhận về hình thức di chúc điện tử và có phân tích, bình luận cũng như đánh giá việc áp dụng di chúc điện tử. Từ đó các công trình phân tích về cách hiểu di chúc điện tử, những điều kiện áp dụng di chúc điện tử để đảm bảo tính xác thực của di chúc này. Những quốc gia ghi nhận di chúc điện tử bắt đầu bằng việc công nhận di chúc điện tử trong các án lệ và hiện nay có Mỹ là quốc gia đã có Luật Di chúc điện tử đã được nhiều tiểu bang áp dụng luật này. Tuy nhiên ở Việt Nam tác giả nhận thấy di chúc điện tử còn là một hình thức di chúc mới chưa được nhiều người quan tâm và nghiên cứu. Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu cụ thể về di chúc điện tử.

Ngoài ra, đã có một số công trình nghiên cứu về những di chúc bằng văn bản được lập sai hình thức luật định nhưng có bằng chứng chứng minh ý chí đích thực của người để lại di sản để từ đó các tác giả đưa ra các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật.

1.2.3. Hình thức di chúc miệng

Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài đã chỉ rõ di chúc miệng được lập khi người để lại di sản rơi vào hoàn cảnh lâm nguy đến tính mạng và không thể lập di chúc bằng văn bản. Các điều kiện cụ thể đặt ra ở các nước là khác nhau tuy nhiên luôn có người làm chứng để chứng kiến quá trình lập di chúc và ghi chép lại ý chí vào văn bản. Di chúc miệng sau một khoảng thời gian có thể bị hủy bỏ nếu người lập di chúc đã ở hoàn cảnh bình thường. Ngoài ra, đã có công trình chỉ rõ mối liên hệ của di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Dù là di chúc bằng văn bản hay di chúc miệng thì cuối cùng sự ghi nhận ý chí của người để lại di sản cũng được thể hiện bằng văn bản.

Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu tập trung vào chỉ rõ yếu tố khắt khe của các điều kiện di chúc miệng. Có công trình nghiên cứu chỉ ra rằng trên thực tiễn để di chúc miệng thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định của BLDS là không có (đó là những điều kiện ghi chép lại ngay sau khi người để lại di sản thể hiện ý chí, thời hạn công chứng, chứng thực). Do đó, khi Tòa án áp dụng đã vận dụng linh hoạt các điều kiện để công nhận di chúc miệng. Ngoài ra, bên cạnh việc ghi chép lại hiện nay có quan điểm đề cập đến việc ghi âm, ghi hình lại lời trăng trối, căn dặn của người đã chết. Tuy nhiên cũng có công trình nghiên cứu đề xuất điều kiện chặt chẽ hơn về vấn đề công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

1.3. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu

Trên cơ sở việc đánh giá kết quả nghiên cứu của những công trình khoa học tác giả đã tiếp cận, luận án tiếp tục nghiên cứu theo hướng sau:

1.3.1. Những vấn đề lý luận về hình thức di chúc

(i) Khái niệm về hình thức di chúc và đặc trưng vai trò của hình thức di chúc: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các công trình đã thực hiện, luận án tiếp tục nghiên cứu khái niệm về hình thức di chúc với cách hiểu hình thức di chúc là một phương tiện để ghi nhận và xác thực ý chí của người để lại di sản, là chứng cứ thể hiện ý chí của người để lại di sản và bảo vệ quyền của người thừa kế theo di chúc. Nghiên cứu về hình thức di chúc không chỉ là nghiên cứu về chất liệu di chúc được thể hiện (trên văn bản hay bằng miệng) mà còn là việc nghiên cứu về các điều kiện thể hiện, xác thực ý chí và thể thức, trình tự, thủ tục lập di chúc. Trên cơ sở này luận án xây dựng khái niệm về hình thức di chúc và phân tích để làm rõ các đặc trưng cũng như ý nghĩa của hình thức di chúc. Đặc trưng của hình thức di chúc là phương thức ghi nhận và lưu giữ ý chí của người để lại di sản nên giữa hình thức di chúc và nội dung di chúc có mối liên hệ nhất định; hình thức di chúc có tính quyết định đến hiệu lực di chúc và hình thức di chúc không trái với quy định của luật. Hình thức di chúc có vai trò đảm bảo việc thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội.

(ii) Các yếu tố chi phối đến pháp luật về hình thức di chúc:

- Sự tự do ý chí trong hình thức di chúc đã có một số công trình đề cập. Luận án từ đó phát triển để đánh giá việc ghi nhận sự tự do ý chí trong hình thức di chúc nhưng phải đảm bảo phù hợp với bản chất của quan hệ thừa kế theo di chúc. Do vậy sự tự do ý chí trong hình thức di chúc chính là sự tự do ý chí của người lập di chúc trong việc lựa chọn hình thức di chúc của người lập di chúc. Tuy nhiên sự tự do trong hình thức di chúc phải phù hợp với ý chí của Nhà nước. Người để lại di sản có quyền tự do lựa chọn hình thức di chúc nhưng ở những trường hợp đặc biệt phải lập di chúc theo hình thức do luật quy định.

- Các yếu tố phong tục tập quán, đặc tính đặc trưng của xã hội từng thời kỳ đã có công trình khoa học nghiên cứu nhưng đó là những công trình nghiên cứu lịch sử pháp luật về thừa kế nói chung. Hoặc đã có công trình nghiên về hình thức di chúc nhưng không nghiên cứu tất cả các giai đoạn lịch sử của pháp luật Việt Nam. Do vậy, dựa trên những nghiên cứu này luận án từ đó phát triển và phân tích cụ thể đi vào chi tiết về sự ảnh hưởng của phong tục tập quán, đặc tính đặc trưng của xã hội từng thời kỳ đến từng hình thức di chúc thông qua các quy định của pháp luật Việt Nam từ thời kỳ phong kiến (giai đoạn nhà Lê, nhà Nguyễn) đến giai đoạn hiện nay. Luận án đánh giá, phân tích lý do cho sự thay đổi trong các quy định pháp luật ở từng giai đoạn phát triển lịch sử của Việt Nam. Luận án đánh giá các yếu tố này ảnh hưởng đến việc ghi nhận hai hình thức di chúc cũng như từng điều kiện trong các hình thức di chúc cụ thể. Mặt khác, dựa vào các yếu tố này để dự đoán việc ghi nhận thêm các hình thức di chúc mới trong tương lai.

- Các yếu tố về chủ thể lập di chúc, về hoàn cảnh lập di chúc, về tài sản của người lập di chúc chi phối đến các việc xây dựng các quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc hiện nay chưa thấy có công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu cụ thể. Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên nghiên cứu chi tiết về các yếu tố này.

(iii) Các lý thuyết pháp lý ảnh hưởng đến việc xây dựng các quy định pháp luật về hình thức di chúc đã có công trình nghiên cứu có đề cập. Tuy nhiên các lý thuyết được nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng đến các điều kiện để di chúc có hiệu lực như là chủ thể lập di chúc, nội dung di chúc, yếu tố tự nguyện khi lập di chúc và hình thức di chúc. Luận án tiếp tục phát triển nghiên cứu lý thuyết về sự tự do ý chí, lý thuyết luật tự nhiên, lý thuyết Nhà nước và pháp luật để nhằm chỉ rõ sự linh hoạt của pháp luật về hình thức khi cho phép sự tự do lựa chọn hình thức di chúc và công nhận di chúc không đúng hình thức nhưng đã ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản. Ngoài ra, luận án còn nghiên cứu lý thuyết quyền sở hữu và lý thuyết gia đình. Xuất phát từ bản chất của quan hệ thừa kế có mối liên hệ chặt chẽ với quan hệ sở hữu và quan hệ hôn nhân gia đình. Thừa kế là sự dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho những người còn sống trong gia đình. Di chúc được đặt ra để tránh những tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, đảm bảo ổn định trật tự và đạo đức xã hội. Do vậy, hai lý thuyết cơ bản cần phải nghiên cứu để pháp luật về hình thức được xây dựng và hoàn thiện là lý thuyết gia đình và lý thuyết quyền sở hữu.

1.3.2. Hình thức di chúc bằng văn bản

(i) Hình thức di chúc do người lập di chúc tự viết: Tiếp nối những công trình nghiên cứu trước đó, luận án tiếp tục nghiên cứu về hai điều kiện đặt ra đối với hình thức di chúc là yếu tố tự viết và chữ ký của người lập di chúc. Trong đó luận án cũng phân tích về điểm chỉ nên là một sự lựa chọn bên cạnh chữ ký. Tuy nhiên quan điểm của tác giả không theo hướng những công trình nghiên cứu trước đó. Chữ ký không

chỉ thể hiện việc xác minh người để lại di sản mà còn thể hiện sự đồng ý của người để lại di sản đối với bản di chúc. Do đó một di chúc được lập không có chữ ký không xem là di chúc mà chỉ là bản nháp của di chúc. Trong khi đó, điểm chỉ có thể là căn cứ để xác định người để lại di sản nhưng chưa chắc rằng đây là sự thể hiện ý chí đồng ý với nội dung của di chúc. Do vậy, luận án nghiên cứu điều kiện điểm chỉ có thể được ghi nhận trong một số trường hợp nhưng phải kèm theo lời chứng của người để lại di sản. Ngoài ra, trong luận án cũng nghiên cứu về điều kiện chữ viết, tên gọi, các thể thức cấu thành của hình thức di chúc này và ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc.

(ii) Hình thức di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy: Do đặc trưng của hình thức di chúc này có sự hiện diện của người làm chứng và người viết hộ di chúc. Do vậy, tiếp nối những công trình nghiên cứu trước đó, luận án nghiên cứu cụ thể về điều kiện của người làm chứng và quá trình người làm chứng tham gia vào giai đoạn tạo lập di chúc. Khác với quan điểm của các công trình nghiên cứu trước đó, quan điểm của tác giả cho rằng không cần đặt thêm nhiều điều kiện dành cho người làm chứng mà chỉ cần người làm chứng có sự khách quan trong quá trình làm chứng là di chúc có thể ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

(iii) Hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực: Từ những kết quả của các công trình trước đó, luận án cũng phân tích về sự khác biệt cũng như sự nhầm lẫn về cách hiểu của hai thủ tục công chứng, chứng thực di chúc tại tổ chức công chứng, UBND hoặc tại nhà. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả đó không phải là bất cập trong quy định của luật mà đây chỉ là cách hiểu chưa chính xác về quy định của luật. Mặt khác, trong luận án còn nghiên cứu về trường hợp của người không đọc được, không nghe được, không ký hoặc không điểm chỉ được khi phải lập di chúc theo hình thức này.

(iv) Hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực: Luận án nghiên cứu về hoạt động thực tiễn xét xử, Tòa án đã áp dụng điều kiện của nhiều loại hình thức di chúc cho một trường hợp xảy ra dẫn đến di chúc khó thỏa mãn điều kiện. Đây cũng là hạn chế của thực tiễn xét xử cần khắc phục.

(v) Hình thức di chúc điện tử: Luận án dựa trên kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài để xem xét đề xuất cho việc ghi nhận tại Việt Nam. Ở thời điểm hiện nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, với sự thông dụng của các thiết bị điện tử và sự am hiểu của người dân thì việc thực hiện các giao dịch dân sự trên thiết bị điện tử cần được xem xét. Do đó, với xu hướng phát triển của tương lai thì di chúc điện tử cần phải được ghi nhận. Tuy nhiên nếu ghi nhận di chúc điện tử ở Việt Nam cần xem xét đến lộ trình phù hợp và các điều kiện cụ thể về thể thức lập, người làm chứng và chữ ký điện tử để pháp luật về hình thức di chúc điện tử hoàn thiện. Mặt khác, nếu so sánh đối chiếu với hình thức của giao dịch dân sự nói chung có thể xem di chúc điện tử là hình thức di chúc bằng văn bản.

1.3.3. Hình thức di chúc miệng

Trên cơ sở kết quả của những công trình đã nghiên cứu trước đó, tác giả tiếp tục nghiên cứu việc ghi âm, ghi hình lời trần trối, căn dặn của người để lại di sản bên cạnh bản ghi chép lại; nghiên cứu về thời điểm ghi chép lại di chúc miệng để đảm bảo tính thực thi những điều kiện này trên thực tế. Ngoài ra, tác giả đã tiếp thu kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài để nghiên cứu về việc mở rộng thêm những đối tượng được lập di chúc miệng cho người không nói được, cho người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi; ghi nhận thể thức lập di chúc miệng đơn giản cho những di chúc miệng định đoạt tài sản thuộc hình thức sở hữu tư nhân của người để lại di sản và giá trị tài sản nhỏ; mở rộng thêm thẩm quyền xác nhận di chúc miệng ngoài công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND.

1.4. Cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu luận án

*“Trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử, các nhà lập pháp đều chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của các học thuyết khác nhau. Vai trò của học thuyết tạo ra tư duy pháp luật, các phương pháp để hiểu và giải thích pháp luật.”*⁵ Do vậy, để có tiền đề lý luận là cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu luận án, tác giả sử dụng các lý thuyết nghiên cứu sau đây:

1.4.1. Lý thuyết quyền sở hữu tài sản

Trên thế giới hình thành nên hệ tư tưởng thừa nhận rằng quyền sở hữu tài sản là quyền tự nhiên và tuyệt đối, hệ tư tưởng này vốn nổi tiếng ở các nước phương Tây. Quyền sở hữu tài sản là quyền tự nhiên, bắt đầu có từ khi con người được sinh ra. Ngoài ra, quyền sở hữu tài sản là quyền tuyệt đối nên chủ sở hữu có toàn quyền thực hiện quyền năng của chủ sở hữu tài sản theo ý chí của mình. Pháp luật được đặt ra để bảo vệ các quyền này.⁶ Trên cơ sở quyền sở hữu tài sản, việc ghi nhận sự tự do sở hữu tài sản sẽ kéo theo tự do định đoạt tài sản sau khi họ chết. Luật thừa kế cho phép những người có tài sản tự do để quyết định cách phân phối tài sản của họ sau khi chết bằng di chúc. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội theo hai cách tổng quát. Đầu tiên, quyền tự do định đoạt của người để lại di sản tạo ra quyết định có mục đích di sản có lợi cho xã hội. Thứ hai, khi luật ghi nhận quyền tự do định đoạt tài sản của người để lại di sản sẽ khuyến khích hành vi có lợi cho xã hội, chẳng hạn như người để lại di sản cố gắng tăng năng suất trong hoạt động tạo ra tài sản để để lại cho người thừa kế. Khi đó luật thừa kế xác định quyền tự do định đoạt có thể tối đa hóa phúc lợi xã hội theo những cách này.⁷ Những lợi ích mà phúc lợi xã hội được đưa ra để giải thích

⁵ Thái Vĩnh Hằng (2010), *Nhà nước và pháp luật tư sản đương đại – Lý luận và thực tiễn*, Nxb. Tư pháp, tr.482-483.

⁶ Marett Leiboff and Mark Thomas (2009), *Legal Theories – Contexts and Practices*, Nxb. Thomson Reuters, tr.32.

⁷ Mark Glover (2018), “A Social Welfare Theory of Inheritance Regulation”, *Utah Law Review*, No. 2, lesson 4, <https://dc.law.utah.edu/ulr/vol2018/iss2/4> [truy cập 08/09/2021].

cách các lực lượng chính trị và kinh tế định hình các thể chế cấu trúc của phúc lợi xã hội và cũng nhấn mạnh vai trò của các nhóm lợi ích.⁸

Thừa kế theo di chúc là việc định đoạt tài sản của cá nhân sau khi họ chết, do đó di chúc là cơ sở để ghi nhận sự chuyển dịch về tài sản của chủ sở hữu tài sản cho những người thừa kế. Lý thuyết về quyền sở hữu tài sản ảnh hưởng mạnh mẽ đến pháp luật về thừa kế theo di chúc. Quyền sở hữu là vô hạn theo thời gian trong khi cuộc đời con người thì có giới hạn, từ đó mới có tiếp nối vấn đề thừa kế. Khi một người được xác định là chủ sở hữu đối với tài sản, họ không chỉ thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ khi còn sống mà còn thực hiện việc dịch chuyển tài sản theo ý chí của họ sau khi chết. Đến thời điểm họ chết, căn cứ vào nội dung trong di chúc, tài sản sẽ được thừa kế bởi những người được chỉ định và như vậy sẽ đáp ứng được sự chuyển giao lợi ích vật chất và phúc lợi xã hội đáp ứng yêu cầu của xã hội, của nền kinh tế. Do vậy luận án sử dụng lý thuyết quyền sở hữu tài sản nhằm giải thích tính nguồn gốc của di chúc và xác định mục đích quy định pháp luật về hình thức di chúc cần phải hoàn thiện mới có thể bảo vệ nội dung di chúc.

Quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc dựa trên yếu tố tài sản. Một người muốn lập di chúc bằng văn bản có công chứng của công chứng viên. Tuy nhiên trong nội dung di chúc nếu định đoạt tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì lúc này theo thủ tục của luật định người lập di chúc cần đưa ra được những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu để công chứng viên có thể xác nhận nội dung di chúc.⁹ Ở Mỹ, quy định pháp luật cũng dựa vào tài sản để có thể xác định hình thức di chúc cho phù hợp. Tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng và giá trị không quá lớn thì người để lại di sản có thể lập di chúc miệng với thủ tục đơn giản¹⁰. Đây là một quy định mang lại sự lựa chọn rất linh hoạt cho người để lại di sản khi họ có thể đơn giản hóa thủ tục lập di chúc nếu tài sản giá trị không quá lớn, không quá quan trọng. Những vấn đề này dựa trên nội dung của lý thuyết quyền sở hữu tài sản khi định đoạt tài sản loại tài sản đặc biệt tác động đến hình thức di chúc.

Việc xây dựng quy định pháp luật về hình thức di chúc nếu dựa vào lý thuyết về quyền sở hữu tài sản để lý giải bản chất pháp lý và vai trò của hình thức di chúc đối với di chúc để từ đó pháp luật về hình thức di chúc cần phải hoàn thiện. Việc vận dụng lý thuyết này được thể hiện rõ trong Chương 2 của luận án.

⁸ David Stoesz (1989), *A Theory of Social Welfare*, Nxb. Oxford University Press, Vol. 34, No. 2, tháng 3/1989, tr. 101.

⁹ Điều 40 Luật Công chứng 2014.

¹⁰ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann (2011), *Comparative Succession Law*, Nxb. Oxford University Press, tr.373–374: theo quy định của luật của các tiểu bang Indiana, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, Ohio, Tennessee, Virginia, Washington.

1.4.2. Lý thuyết gia đình

Luật gia đình và luật thừa kế có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Ở nhiều khía cạnh, luật thừa kế được coi là một phần của luật gia đình. Sau khi cha hoặc mẹ chết thì tài sản của họ thường được chia cho các thành viên trong gia đình của người đã chết. Nếu đây là thừa kế theo pháp luật, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và bốn phận gia đình là cơ sở để xác định người thừa kế và việc phân chia di sản. Nếu đây là thừa kế theo di chúc thì nền tảng cơ bản là tự do cá nhân. Sự tự do ý chí của người để lại di sản trong việc định đoạt tài sản của họ sau khi chết không bị giới hạn bởi các mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên về cơ bản ý chí này vẫn hướng tới phân chia di sản cho những người trong gia đình mà ít khi định đoạt di sản cho người ngoài. Bởi lẽ, thừa kế theo di chúc dù là thừa kế trên cơ sở tôn trọng ý chí của người để lại di sản nhưng ẩn sâu trong đó luôn tồn tại một nghĩa vụ đạo đức và trách nhiệm của người lập di chúc với mong muốn để lại tài sản để chu cấp cho gia đình mình.¹¹ Và di chúc có vai trò để tránh tranh chấp, phát sinh những mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Vì những lý do này, luật gia đình được coi là có ảnh hưởng mạnh mẽ đến luật thừa kế và việc xây dựng các quy phạm pháp luật về thừa kế dựa trên lý thuyết gia đình để đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội.

Pháp luật thừa kế Việt Nam nói chung và thừa kế theo di chúc nói riêng được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết về gia đình. Một gia đình truyền thống có tôn ti, trật tự, nề nếp dựa trên những chuẩn mực đạo đức, tình cảm giữa các thành viên với nhau. Ở Việt Nam, *“cấu trúc làng xã từ xa xưa đã hình thành những cộng đồng dân cư gắn bó với nhau từ đời này qua đời khác, đây là những người hiểu rõ nhau về cội nguồn, gia cảnh, tính tình. Với kết cấu bền vững, lâu đời đó con người Việt Nam lấy chữ “tín” làm đầu trong lối ứng xử với nhau. Người ta trọng cái tâm, cái nghĩa, cái tình hơn là sự chắc chắn của các chứng cứ. Trong quan hệ giữa các thành viên của một gia đình, lối ứng xử trọng cái tâm, cái nghĩa càng được đậm nét hơn bởi tư tưởng hiếu, lễ, hòa, mục giữa những người ruột thịt với nhau. Vì thế, một người trước khi chết thường sẽ chỉ để lại những lời trăng trối mà ít quan tâm đến hình thức thể hiện lời trăng trối đó phải như thế nào, phải tuân thủ những gì pháp luật quy định.”*¹² Thời xưa, di chúc thường được ghi nhận là sự bày tỏ ý chí của cha và mẹ để chuyển giao tài sản của gia đình cho con, cháu nhằm mục đích tránh những tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình¹³. Trong bối cảnh đó, di chúc được xem là tuyên bố long trọng của cha,

¹¹ Musyoka, William (2006), *Law of succession*, Nxb. African Books Collective, tr.3-4.

¹² Phạm Văn Tuyết (2003), *Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự*, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.28-29.

¹³ Vũ Văn Mẫu, *“Les successions testamentaires en droit vietnamien”* (Thừa kế theo di chúc trong luật Việt Nam), Luận án tiến sĩ, Paris, 1948, lưu tại thư viện Cujas, Paris trong Nguyễn Ngọc Điện (2021), *Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình-Quan hệ tài sản vợ chồng, Thừa kế, Tập 2*, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. tr.214.

mẹ về việc phân chia di sản cho con cháu nhằm ngăn ngừa tranh chấp nội bộ, dẫn đến mất đoàn kết gia đình.

Ngày nay, “với sự phát triển của kinh tế, các giao lưu dân sự không chỉ trong phạm vi một làng, xã do đó lối ứng xử ngày càng phức tạp hơn. Những di chúc để lại mong manh về tính xác thực sẽ là nguyên nhân góp phần làm phát sinh các tranh chấp về thừa kế, gây xáo trộn và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, ảnh hưởng đến đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam xưa”¹⁴. Mặt khác, “hành vi lập di chúc định đoạt tài sản không thể được hiểu là những quyết định thuần túy của cá nhân mà đúng hơn, chúng được điều chỉnh bởi các chuẩn mực khiến hành động của người lập di chúc phải tuân theo những kỳ vọng của xã hội và theo cách này ảnh hưởng đến quyết định của họ. Thừa kế là một lĩnh vực pháp luật mà Nhà nước có lợi ích rõ ràng. Do đó Nhà nước thông qua luật để đảm bảo rằng nghĩa vụ của người chết đối với những người trong gia đình và người phụ thuộc nhất định được thực hiện.”¹⁵ Do vậy nếu chỉ hiểu đơn giản di chúc là hành vi định đoạt tài sản của người chết cho những người khác còn sống thì đó chỉ là bề nổi của vấn đề pháp lý. Đằng sau đó phải là những ràng buộc về mặt đạo đức, trách nhiệm của người đã chết với gia đình, xã hội. Các nhà sử học pháp lý thường dẫn ra trích dẫn từ các cuộc trò chuyện của Goethe để nói về ảnh hưởng của nguyên tắc pháp lý nói chung đối với các lĩnh vực pháp lý như một con vịt ở trong hồ nước bởi vì “đôi khi nó có thể nhìn thấy được, bơi lội nổi bật trên mặt nước; lúc khác nó ẩn mình, lặn giữa độ sâu. Nhưng nó luôn ở đó”¹⁶. Dùng con vịt để miêu tả về vấn đề này rất phù hợp. Di chúc là sự tự do về mặt ý chí của người để lại di sản trong việc định đoạt tài sản tuy nhiên những ý chí được thể hiện trong di chúc thông thường sẽ là sự phân chia tài sản cho những người trong gia đình, người thân mà ít khi cho người ngoài.

Theo lời của Chánh án Gray của tiểu bang Massachusetts, Mỹ “Việc chuyển giao di sản thực tế chắc chắn sẽ phụ thuộc vào luật pháp. Quyền định đoạt tài sản theo di chúc không phải là quyền tự nhiên hay hiến định mà là phụ thuộc hoàn toàn vào quy định của luật”¹⁷. Do đó, pháp luật cần phải điều chỉnh việc lập di chúc mà cụ thể là một trong những điều kiện để di chúc hợp pháp là hình thức di chúc. Hình thức di chúc được quy định đủ chặt chẽ sẽ đảm bảo tính xác thực của di chúc và từ đó tránh được những tranh chấp phát sinh.

Lý thuyết gia đình được tác giả vận dụng để làm rõ nguồn gốc, đặc trưng của di chúc và vai trò của thừa kế theo di chúc đối với xã hội Việt Nam. Từ đó lý thuyết gia đình là nền tảng cơ bản để xác định vai trò pháp lý của hình thức di chúc, xác định tính

¹⁴ Phạm Văn Tuyết, *tlđd* (số chú thích 12), tr.28-29.

¹⁵ Jens Beckert (2008), *Inherited Wealth*, Nxb. Princeton University Express, tr.83.

¹⁶ Lindsay Dean Breach (2013), *The Civil Law Influence on the Evolution of Testamentary Succession*, Luận văn thạc sĩ luật, Khoa Luật-Trường Đại học Canterbury, tr.343.

¹⁷ James M. Morton, Jr. (1894), “The theory of Inheritance”, *Tạp chí Harvard Law Review*, tập 8, số 3, tr.161.

nguồn gốc của hình thức di chúc để trả lời câu hỏi vì sao hình thức di chúc cần được quy định chi tiết, nghiêm ngặt hơn so với các giao dịch dân sự khác. Một trong những yếu tố thể hiện rõ nét nhất sự ảnh hưởng của lý thuyết này đến hình thức di chúc chính là yếu tố của phong tục tập quán, đặc trưng của xã hội Việt Nam trong từng thời kỳ. Những nội dung này sẽ được thể hiện rõ trong Chương 2 của luận án.

1.4.3. Lý thuyết Nhà nước và pháp luật

C. Mác và Ph. Ăng-ghe-n là những người đã sử dụng những tư tưởng mang tính nguyên tắc về Nhà nước và pháp luật của các nhà tư tưởng trước đó để phát triển quan điểm về Nhà nước và pháp luật của riêng mình¹⁸. Trong đó, Nhà nước là một hình thức mà các cá nhân thuộc giai cấp thống trị thực hiện các lợi ích chung của mình và vì vậy giai cấp thống trị cần phải tổ chức sức mạnh của mình dưới dạng Nhà nước và cần phải tạo cho ý chí của mình, vốn do các quan hệ xã hội quyết định, dưới hình thức pháp luật. Sự thể hiện, nội dung của pháp luật do chính các quan hệ của giai cấp đó quyết định. Từ đó có thể khẳng định khi có Nhà nước, giai cấp thống trị dùng pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo ý chí của mình.

Quan hệ về thừa kế là một quan hệ thuộc phạm trù về mặt kinh tế chỉ sự dịch chuyển tài sản của người chết sang cho những người khác còn sống. Nhưng dưới sự điều chỉnh của pháp luật, quan hệ pháp luật về quyền thừa kế là một quan hệ thuộc phạm trù pháp lý được các quy phạm pháp luật điều chỉnh theo ý chí của giai cấp thống trị nhằm bảo vệ quyền dịch chuyển tài sản và quyền được hưởng tài sản đó. Khi Nhà nước ghi nhận quyền lập di chúc cho người có tài sản trước khi chết được thể hiện mong muốn của mình thì sự can thiệp của Nhà nước sẽ đảm bảo quyền định đoạt được thể hiện một cách tuyệt đối, tránh những hành vi làm sai lệch nội dung của di chúc. Do đó pháp luật về hình thức di chúc (với cách hiểu hình thức di chúc là “nơi” ghi nhận, chứa đựng, lưu giữ ý chí của người để lại di sản) phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định do luật quy định. Người lập di chúc không thể tự sáng tạo ra hình thức di chúc hay tự lập di chúc theo những thể thức mà họ mong muốn. Tất cả các điều kiện về loại hình thức di chúc, về trình tự, thủ tục lập di chúc và sự tự do lựa chọn các loại hình thức di chúc đều dựa trên cơ sở luật định để đảm bảo di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

Lý thuyết Nhà nước và pháp luật được tác giả sử dụng xuyên suốt trong Chương 3 và Chương 4 của luận án để khẳng định các điều kiện, trình tự, thủ tục lập di chúc ở các hình thức di chúc dù có khác nhau nhưng vẫn luôn dựa trên các quy định của pháp luật mới đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

¹⁸ Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái (1997), *Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý*, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, tr.123-130.

1.4.4. Lý thuyết tự do ý chí của cá nhân

“Ngay từ khi sinh ra, con người vốn dĩ đã có những quyền con người một cách tự nhiên, những quyền con người ấy có cả trước khi có Hiến pháp hay luật¹⁹. Trong đó, “tự do của một người được hiểu là sự vắng bóng những cản trở, ràng buộc, đe dọa từ người khác”²⁰. Tự do ý chí có thể hiểu là sự tự do dựa trên nền tảng của tự do cá nhân, tự do ý chí được xem là quyền con người - quyền tự nhiên của mỗi cá nhân từ khi họ được sinh ra mà không ai có thể bị ép buộc làm hay không làm một việc gì đó ngoài ý muốn của họ. Do vậy quyền tự do của con người là quyền tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có. Mục đích của pháp luật là để bảo vệ và mở rộng quyền tự do của con người chứ không phải để hạn chế và xóa bỏ tự do của cá nhân. BLDS Pháp 1804 và BLDS Đức 1900 là hình mẫu cho tư tưởng của lý thuyết này đối với hệ thống pháp luật thành văn.²¹ BLDS các nước xác định sự tự do ý chí còn được thể hiện dưới hình thức luật quy định cho phép các bên lựa chọn²². Trong hoạt động thực tiễn, nếu xem xét hệ thống luật Anh - Mỹ sẽ thấy Tòa án và cơ quan hành chính phải lấy “tinh thần pháp luật” để giải quyết các vụ việc vốn không hiện diện trong từng câu chữ của văn bản quy phạm pháp luật mà theo lý lẽ của sự công bằng²³.

Trên cơ sở lý thuyết tự do ý chí, BLDS Việt Nam đề cao sự tự do ý chí thông qua các nguyên tắc chung điều chỉnh cho mọi giao dịch dân sự bên cạnh các quy định của pháp luật chuyên ngành. Một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự đã khẳng định “*cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận*”²⁴. Từ nguyên tắc cơ bản này, trong quan hệ thừa kế sự tự do ý chí thể hiện ở việc thông qua di chúc, người để lại di sản có thể định đoạt chủ thể hưởng di sản, nội dung di sản, thời hạn hưởng di sản và các điều kiện kèm theo (nếu có). Quyền để lại di sản là quyền tự nhiên của con người được phát sinh hiệu lực khi người có tài sản chết. Quyền lập di chúc lại là quyền thể hiện việc ghi nhận sự tự do ý chí của con người. Do vậy, quyền lập di chúc được ghi nhận dựa trên lý thuyết về sự tự do ý chí của cá nhân. Để có thể ghi nhận ý chí

¹⁹ Nguyễn Minh Tuấn (2014), *Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới*, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, tr.432.

²⁰ FA. Hayek (2011), *The constitution of Liberty: The definitive edition*, Nxb. University of Chicago, tr.232.

²¹ Nguyễn Trọng Điệp, Cao Thị Hồng Giang (2016), “Những giới hạn của tự do ý chí và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay”, *Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học*, tập 32 số 2/2016, tr.12 “Trong quan hệ dân sự, sự tự do ý chí được thể hiện rất rõ nét. Đối với hệ thống thông luật (Anh – Mỹ), chẳng hạn như trong quan hệ hợp đồng, tự do hợp đồng được thừa nhận là học thuyết của trung tâm luật hợp đồng cổ điển”.

²² Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hồng Trinh (2018), “Ý chí và tự do ý chí trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng”, *Tạp chí Pháp luật và thực tiễn*, số 35/2018, tr.7 “Thực chất từ khi các bên thỏa thuận đã tồn tại sự tự do ý chí, do vậy sự tự do về ý chí luôn quyết định. Từ đó mới có cách vận dụng linh hoạt quy định tại Điều 129 BLDS 2015 khi vi phạm về hình thức”.

²³ Phan Trung Hiền (2020), *Lý luận về Nhà nước và pháp luật*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr.31.

²⁴ Khoản 2 Điều 3 BLDS 2015.

định đoạt tài sản của người để lại di sản, lý thuyết tự do ý chí chi phối đến các điều kiện để xác định một di chúc là hợp pháp.

Di chúc là một giao dịch dân sự trọng thức nên đối với hình thức di chúc phải tuân thủ quy định của luật và nếu các yêu cầu về hình thức di chúc không được tuân thủ, di chúc sẽ không có hiệu lực. Tuy nhiên, sự trọng thức trong di chúc không ảnh hưởng đến sự tự do ý chí của người lập di chúc về hình thức của di chúc. Khi nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam trong nhiều văn bản pháp luật qua các giai đoạn khác nhau và thực tiễn xét xử về hình thức di chúc có thể thấy pháp luật về hình thức di chúc chịu ảnh hưởng nhiều bởi lý thuyết về sự tự do ý chí của cá nhân. Pháp luật ghi nhận nhiều loại hình thức di chúc cho người để lại di sản được quyền lựa chọn để phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của họ, chỉ trừ trường hợp đối với những người lập di chúc đặc biệt cần phải tuân thủ hình thức di chúc do luật định. Di chúc bằng văn bản có nhiều loại như di chúc tự lập, di chúc nhờ người khác lập, di chúc có công chứng, chứng thực, di chúc có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực. Bên cạnh hình thức di chúc bằng văn bản còn có hình thức di chúc miệng.

Nếu vận dụng lý thuyết về sự tự do ý chí của cá nhân khi xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc sẽ đảm bảo hình thức của di chúc được ghi nhận linh hoạt và tự do trong một giới hạn nhất định theo quy định của pháp luật mà vẫn đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc. Việc vận dụng lý thuyết tự do ý chí của cá nhân thể hiện xuyên suốt luận án. Khi nghiên cứu khái quát về hình thức di chúc ở Chương 2, việc vận dụng lý thuyết về sự tự do ý chí cá nhân thể hiện ở một yếu tố ảnh hưởng đến định hướng khi quy định các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc là cho phép sự tự do ý chí của người lập di chúc. Ở Chương 3 và Chương 4, lý thuyết về sự tự do ý chí của cá nhân thể hiện xuyên suốt ở những bất cập và kiến nghị tác giả phân tích khi nghiên cứu về các quy định pháp luật Việt Nam để đảm bảo quy định pháp luật về hình thức di chúc được linh hoạt và khả thi áp dụng trên thực tế chứ không mang tính cứng nhắc, khắt khe khó thực hiện.

1.4.5. Lý thuyết luật tự nhiên

Lý thuyết luật tự nhiên là lý thuyết về các nguyên tắc và quyền con người được thể hiện ở những quy tắc, tiêu chuẩn về công bằng, lẽ phải, tôn trọng các quyền con người²⁵. Lý thuyết về luật tự nhiên hiểu một cách cơ bản nhất chính là điểm gặp gỡ giữa luật và đạo đức²⁶. Trong luật tự nhiên có sẵn những quy chuẩn, mực thước của đạo lý và công lý nên con người cần phải soạn thảo pháp luật tuân theo những quy chuẩn của tự nhiên²⁷. Xét một cách tổng quan, lý thuyết luật tự nhiên là một lý thuyết

²⁵ Đỗ Đức Minh (2014), “Tìm hiểu học thuyết pháp luật tự nhiên”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 6 (262), tháng 3/2014, tr.23.

²⁶ Raymond Wacks (2018), *Triết học luật pháp*, Phạm Kiều Tùng (dịch), Nxb. Tri thức, tr.16.

²⁷ Hoàng Thị Kim Quế, Nguyễn Đăng Dung (2016), *Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.358.

pháp lý nền tảng khi chúng ta xem xét ảnh hưởng của nó đối với lý thuyết pháp lý nói chung²⁸.

Các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ pháp luật thừa kế dựa nhiều vào phong tục tập quán, truyền thống của người Việt Nam, dựa vào yếu tố tình cảm, đạo đức và sự bình đẳng giữa người với người. Đối với quan hệ thừa kế theo di chúc, quyền lập di chúc của cá nhân là quyền của chủ sở hữu được tự do ý chí trong việc định đoạt tài sản của họ. Bên cạnh ghi nhận quyền tự do định đoạt, pháp luật còn ghi nhận quyền bình đẳng cho các chủ sở hữu tài sản được lựa chọn hình thức di chúc mà họ có thể lập. Do vậy, người lập di chúc ở vào những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau vẫn có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn hình thức di chúc. Đối với người lập di chúc là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, người không nói được, người bị hạn chế về thể chất thì việc lập di chúc bằng hình thức nào đều được pháp luật cân nhắc và xem xét đến. Giữa những người được liệt kê ở trên với những người từ đủ mười tám tuổi trở lên, trong điều kiện thể chất bình thường, không ở những hoàn cảnh khách quan đặc biệt thì quyền được lựa chọn loại hình thức di chúc là bình đẳng.²⁹ Yếu tố tôn trọng phong tục tập quán, nét văn hóa của người Việt Nam còn được thể hiện thông qua việc ghi nhận di chúc miệng. Mặt khác, nếu xã hội đạt đến sự phát triển với sự thông dụng của các phương tiện công nghệ hiện đại, di chúc điện tử cũng là hình thức cần phải nghiên cứu để áp dụng. Tất cả những yếu tố này đều chịu sự ảnh hưởng của học thuyết luật tự nhiên, một học thuyết được chi phối bởi đạo đức và đặc tính của từng xã hội riêng biệt.

Những vận dụng của lý thuyết luật tự nhiên thể hiện xuyên suốt luận án. Trong Chương 2 khi phân tích về phong tục, tập quán và đặc điểm đặc trưng của xã hội từng thời kỳ ảnh hưởng đến pháp luật về hình thức di chúc chính là sự ảnh hưởng của lý thuyết luật tự nhiên. Việc vận dụng lý thuyết luật tự nhiên sẽ giúp luận án xác định được các yếu tố chi phối đến quy định pháp luật về hình thức di chúc như phong tục tập quán, đặc tính của xã hội đồng thời làm rõ sự khác biệt về bản chất của quan hệ thừa kế theo di chúc với quan hệ hợp đồng hoặc các giao dịch dân sự khác. Lý thuyết luật tự nhiên hướng đến khẳng định quyền tự do định đoạt tài sản và quyền tự do lựa chọn hình thức di chúc phù hợp. Chính từ yếu tố khách quan này ảnh hưởng đến sự chủ quan trong tư duy của những nhà lập pháp để xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc. Khi đề cập đến thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật tại Chương 3, Chương 4 tác giả vận dụng lý thuyết luật tự nhiên để phân tích sự bình đẳng giữa những chủ thể ở những hoàn cảnh, điều kiện, năng lực thể chất khác nhau có quyền lựa chọn hình thức di chúc cho phù hợp. Mặt khác, nếu dựa vào các yếu

²⁸ Neil MacCormick (1997), *Legal Reasoning and Legal Theory*, Nxb. Larendon Press. Oxford, tr.229.

²⁹ Khoản 2, 3 Điều 630; Điều 633-635; Điều 638 BLDS 2015.

tổ đặc trưng của xã hội Việt Nam có thể bổ sung thêm các hình thức di chúc mới cho người lập di chúc có thêm quyền lựa chọn hình thức di chúc.

Kết luận: Pháp luật thừa kế Việt Nam được xây dựng dựa trên nền tảng bốn phạm gia đình và tự do cá nhân. Do vậy để pháp luật về hình thức di chúc đảm bảo được mục tiêu bảo vệ đoàn kết trong gia đình, trật tự và đạo đức xã hội thì luận án sử dụng các lý thuyết pháp lý cơ bản là lý thuyết về quyền sở hữu tài sản, lý thuyết gia đình, lý thuyết tự do ý chí của cá nhân, lý thuyết Nhà nước và pháp luật và lý thuyết luật tự nhiên. Bằng việc ghi nhận sự tự do ý chí của cá nhân trong quy định về hình thức di chúc, mở rộng thêm cách lựa chọn hình thức di chúc thông qua tài sản, khi di chúc ghi nhận đúng ý chí của người để lại di sản sẽ mang lại lợi ích về kinh tế cho xã hội. Tuy nhiên sự tự do ý chí để tôn trọng quyền tự do định đoạt tài sản phải trên cơ sở phù hợp với ý chí của Nhà nước để bảo vệ quyền thừa kế theo di chúc. Do vậy, các lý thuyết này được xác định là cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, các quy định pháp luật và đưa ra những đề xuất để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc.

1.5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.5.1. Câu hỏi nghiên cứu tổng quát và giả thuyết nghiên cứu tổng quát

Câu hỏi nghiên cứu tổng quát: Pháp luật về hình thức di chúc cần phải hoàn thiện như thế nào để người lập di chúc thể hiện được ý chí đích thực của mình và việc lập di chúc được thuận lợi hơn từ đó bảo đảm thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội?

Giả thuyết nghiên cứu tổng quát: Cơ sở lý luận xây dựng pháp luật về hình thức di chúc dựa trên lý thuyết quyền sở hữu tài sản, lý thuyết gia đình, lý thuyết Nhà nước và pháp luật, lý thuyết luật tự nhiên và lý thuyết tự do ý chí của cá nhân. Từ đó những vấn đề lý luận về hình thức di chúc phải gắn với ba vấn đề (i) hình thức di chúc là cơ sở để ghi nhận và lưu giữ chính xác ý chí của người để lại di sản; (ii) hình thức di chúc là cơ sở giúp di chúc được lập một cách thuận lợi hơn. (iii) hình thức di chúc là cơ sở để thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội. Đây là triết lý phù hợp để làm rõ vai trò, bản chất pháp lý của hình thức di chúc giúp pháp luật dân sự Việt Nam về hình thức di chúc được hoàn thiện bằng cách (i) cần phải giảm các điều kiện của hình thức di chúc khi pháp luật về hình thức di chúc quá cứng nhắc, không khả thi khi áp dụng vào thực tiễn; (ii) cần phải tăng các điều kiện về hình thức di chúc khi pháp luật về hình thức di chúc chưa chặt chẽ, di chúc có thể bị giả mạo, bị sửa đổi, bổ sung bởi người khác; (iii) bổ sung thêm các hình thức di chúc mới hoặc các bổ sung các trường hợp đặc biệt được lập hình thức di chúc phù hợp bên cạnh các quy định pháp luật hiện hành để việc lập di chúc được thuận lợi hơn.

1.5.2. Câu hỏi nghiên cứu cụ thể và giả thuyết nghiên cứu cụ thể

Để trả lời được câu hỏi nghiên cứu tổng quát trên, tác giả đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như sau:

Câu hỏi nghiên cứu 1: Tại sao quy định của pháp luật về hình thức di chúc phải đặt ra sự nghiêm ngặt, khắt khe hơn so với hình thức của các giao dịch dân sự khác? Những đặc trưng của hình thức di chúc là gì? Hình thức di chúc có ý nghĩa pháp lý gì?

Giả thuyết nghiên cứu 1: Di chúc là giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi người để lại di sản chết. Thời điểm này những chất vấn xoay quanh di chúc và nội dung di chúc khó có thể làm rõ. Mặt khác, bản chất pháp lý của hình thức di chúc là (i) phương thức ghi nhận và lưu giữ ý chí định đoạt tài sản của người để lại di sản; (ii) hình thức di chúc có tính quyết định đến hiệu lực của di chúc và (iii) hình thức di chúc không trái với quy định của luật xuất phát từ bản chất di chúc là một giao dịch dân sự trọng thức. Do đó hình thức di chúc có vai trò ghi nhận và là chứng cứ bảo vệ quyền định đoạt tài sản của người để lại di sản theo ý chí của họ, bảo vệ quyền thừa kế của người thừa kế theo di chúc; phòng ngừa rủi ro khi ghi nhận và lưu giữ ý chí của người lập di chúc và là cơ sở để hạn chế các tranh chấp khi phân chia di sản. Từ những vai trò của hình thức di chúc để đảm bảo thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội. Trên cơ sở những đặc trưng và vai trò của hình thức di chúc để xác định về mặt lý luận hình thức di chúc là phương tiện xác thực ý chí của người để lại di sản.

Câu hỏi nghiên cứu 2: Để pháp luật về hình thức di chúc đạt được mục tiêu, đâu là các yếu tố chi phối, tác động đến pháp luật về hình thức di chúc?

Giả thuyết nghiên cứu 2: Khi nghiên cứu về hình thức di chúc có thể thấy hình thức di chúc bị chi phối và tác động bởi phong tục tập quán, đặc tính đặc trưng của xã hội từng thời kỳ; sự tự do ý chí của người lập di chúc; điều kiện của người lập di chúc; hoàn cảnh lập di chúc và tài sản được định đoạt trong di chúc. Các yếu tố này giúp cho việc lập di chúc được thuận lợi hơn cũng như đảm bảo di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc và từ đó thừa kế theo di chúc bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội.

Câu hỏi nghiên cứu 3: Quy định về điều kiện lập di chúc, trình tự thủ tục lập di chúc của hình thức di chúc bằng văn bản và hình thức di chúc miệng phải được ghi nhận như thế nào để đảm bảo di chúc được lập thuận lợi và thể hiện ý chí đích thực của người lập di chúc?

Giả thuyết nghiên cứu 3: Điều kiện lập di chúc, trình tự, thủ tục lập di chúc của hình thức di chúc bằng văn bản và hình thức di chúc miệng cần được ghi nhận một cách linh hoạt. Những quy định nào còn khắt khe và làm di chúc không khả thi để lập thì cần được giảm các điều kiện. Những quy định nào còn lỏng lẻo dẫn đến di chúc có

thể bị giả mạo thì cần tăng thêm các điều kiện. Ngoài ra, để di chúc được lập một cách thuận lợi thì cần bổ sung thêm các hình thức di chúc mới và các trường hợp đặc biệt được lập di chúc với hình thức di chúc phù hợp.

Câu hỏi nghiên cứu 4: Làm sao để quy định pháp luật về hình thức di chúc bao quát và tương thích với thực tiễn áp dụng pháp luật về hình thức di chúc?

Giả thuyết nghiên cứu 4: Khi xã hội có sự thay đổi về những điều kiện kinh tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì những điều kiện và những loại hình thức di chúc cũng cần thay đổi cho phù hợp. Mặt khác, thực tiễn áp dụng pháp luật cũng cần phải áp dụng chính xác phù hợp quy định pháp luật vào từng trường hợp, hoàn cảnh lập di chúc.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Pháp luật về hình thức di chúc nhận được nhiều sự quan tâm của những nhà nghiên cứu và thực hành pháp luật ở Việt Nam và trên thế giới. Ngoài hai hình thức di chúc truyền thống là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng, ở một số nước trên thế giới còn có thêm hình thức di chúc điện tử. Những công trình nghiên cứu ở Việt Nam và nước ngoài đã phân tích về hình thức di chúc dưới góc độ liệt kê các vai trò, chức năng của hình thức di chúc. Hình thức di chúc là chứng cứ để ghi nhận nội dung di chúc, là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của người thừa kế theo di chúc. Để hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức di chúc, các công trình khoa học đã nghiên cứu về các yếu tố tác động đến pháp luật về hình thức di chúc như phong tục tập quán, sự tự do ý chí của người lập di chúc cũng như phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam khi áp dụng vào thực tiễn.

Tiếp nối những kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu trước đó, luận án phát triển và nghiên cứu pháp luật về hình thức di chúc để làm sáng tỏ các vấn đề về lý luận, thực trạng pháp luật và đưa ra các định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc. Luận án xác định hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận, lưu giữ chính xác ý chí của người lập di chúc và đảm bảo di chúc được lập một cách thuận lợi hơn. Pháp luật về hình thức di chúc chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như: phong tục tập quán, đặc tính riêng biệt của xã hội; sự tự do ý chí của người lập di chúc; điều kiện của người lập di chúc; hoàn cảnh lập di chúc và tài sản được định đoạt trong di chúc. Xét về thực trạng áp dụng pháp luật của hai hình thức di chúc bằng văn bản và di chúc miệng còn nhiều vấn đề chưa phù hợp do đó cần có những định hướng hoàn thiện. Những quy định pháp luật còn khắt khe không mang tính khả thi để ghi nhận lại ý chí của người lập di chúc thì cần giảm bớt điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc cho hình thức di chúc đó. Những quy định pháp luật còn khá lỏng lẻo dẫn đến không bảo vệ được ý chí của người để lại di sản thì cần tăng điều kiện hoặc quy định chặt chẽ hơn về trình tự thủ tục lập di chúc. Luận án nghiên cứu kiến nghị bổ sung loại hình thức di chúc mới cho người lập di chúc có thêm nhiều lựa chọn.

Để đạt được các mục đích nghiên cứu này, luận án phải trả lời được câu hỏi “Pháp luật về hình thức di chúc cần phải hoàn thiện như thế nào để người lập di chúc thể hiện được ý chí đích thực của mình và việc lập di chúc được thuận lợi hơn từ đó bảo đảm thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội?”. Ngoài ra, luận án sử dụng các lý thuyết cơ bản: lý thuyết quyền sở hữu, lý thuyết gia đình, lý thuyết Nhà nước và pháp luật, lý thuyết luật tự nhiên và lý thuyết tự do ý chí của cá nhân cho việc nghiên cứu lý luận và các quy định pháp luật để từ đó có những đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc.

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÌNH THỨC DI CHÚC

Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu tổng quan, cơ sở lý thuyết và xác định mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, Chương 2 của luận án nghiên cứu khái quát những vấn đề cơ bản về hình thức di chúc. Do vậy, nhiệm vụ của Chương 2 là làm sáng tỏ và bổ sung một số vấn đề khái quát chung về hình thức di chúc để từ đó có cơ sở tiền đề cho việc nghiên cứu các Chương tiếp theo về từng hình thức di chúc cụ thể. Luận án nghiên cứu và xây dựng khái niệm về hình thức di chúc; trình bày và phân tích các đặc điểm, ý nghĩa pháp lý của hình thức di chúc; trình bày và phân tích những yếu tố tác động đến pháp luật về hình thức di chúc. Ngoài ra, Chương 2 nghiên cứu lịch sử quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc để đánh giá, xem xét sự phát triển của các quy định pháp luật khi xã hội thay đổi.

2.1. Khái niệm, đặc điểm di chúc

2.1.1. Khái niệm di chúc

Di chúc là thuật ngữ được xuất hiện từ rất lâu, rất gần gũi với cuộc sống của con người Việt Nam. Xét về mặt ngữ nghĩa, “*di chúc*” là một từ Hán - Việt, được ghép bởi hai từ “*di*” và “*chúc*”. Theo từ điển tiếng Việt thì “*di*” là để lại; “*chúc*” là trời, dẫn lại; nên “*di chúc là dẫn lại những điều cần thiết trước khi chết*”³⁰ hay “*di chúc là dẫn lại trước khi chết những điều cần làm và nên làm*”³¹.

Nếu hiểu theo nghĩa thông thường, di chúc là lời dặn dò, nhắn nhủ của ông bà, cha mẹ - những người sắp chết đối với con cháu, họ hàng. Những lời dặn dò đó có thể về tình cảm đạo hiếu, cách cư xử của con cháu trong mối quan hệ gia đình, có thể về ý nguyện mà người chết chưa thực hiện được hoặc có thể về những mong muốn mà người chết muốn người còn sống thực hiện trong tương lai. Di chúc còn có thể là mong muốn, lời nhắn nhủ của người sắp chết về ý nguyện đối với những người khác để họ thực hiện. Chẳng hạn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn dân, toàn Đảng, toàn thể bộ đội, các cháu thanh niên và nhi đồng với những mong muốn to lớn và lời căn dặn để đất nước hoàn toàn thống nhất, dân tộc Việt Nam được độc lập và đời sống nhân dân Việt Nam được nâng cao³². Truyền thống của người Việt Nam luôn tôn trọng giá trị đạo đức, đề cao giá trị hiếu - lễ - nghĩa trong cách ứng xử giữa người

³⁰ Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), *Đại từ điển tiếng Việt*, Nxb. Văn hóa-Thông tin, tr.397, 532 và 533.

³¹ Hoàng Phê (chủ biên) (1993), *Từ điển tiếng Việt*, Nxb. Khoa học xã hội, tr.262.

³² Trần Thị Thu Hoài (2019), “Những nội dung cốt yếu trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, <https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh/-/2018/814305/nhung-noi-dung-cot-yeu-trong-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh.aspx>, [truy cập 29/9/2023]; “Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (2014), <https://baochinhphu.vn/toan-van-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-102169104.htm>, [truy cập 29/9/2023].

với người. Do vậy, những lời dặn dò của người đã chết được thể hiện trong di chúc luôn được tôn trọng, lắng nghe và thực hiện.

Xét dưới góc độ khoa học pháp lý, di chúc là một phương thức mà chủ sở hữu tài sản lựa chọn để chuyển giao tài sản của mình sau khi chết. Theo cách giải nghĩa trong từ điển luật Black-law có thể hiểu *“di chúc là việc định đoạt tài sản cá nhân diễn ra trước khi chủ sở hữu qua đời, theo nguyện vọng và mong muốn của người đó”*³³. Cách giải thích nghĩa di chúc theo từ điển luật này xác định đầy đủ các điều kiện cần của một bản di chúc. Khác với cách hiểu theo nghĩa thông thường, không phải tất cả những mong muốn, lời dặn dò, trăn trối của người đã chết đều được xác định là di chúc. Về mặt pháp lý, chỉ những mong muốn định đoạt tài sản của người đã chết cho người khác mới được xác định là di chúc.

Khái niệm di chúc được hình thành từ rất sớm. Ở giai đoạn La Mã cổ đại, chế định thừa kế đã được ghi nhận trong những công trình lập pháp của Nhà nước La Mã. Pháp luật thời kỳ La Mã quy định hai hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và theo pháp luật³⁴. Tuy nhiên ở La Mã, việc dịch chuyển tài sản theo pháp luật hiếm khi được áp dụng do người có di sản thường lập di chúc để định đoạt tài sản của mình³⁵. Chính vì vậy khái niệm di chúc đã được các luật gia thời kỳ La Mã cổ đại nghiên cứu và đề cập đến. Theo đó *“di chúc là sự thể hiện ý chí của chúng ta và ý chí đó được thực hiện sau khi chúng ta chết”*³⁶. Ở thời La Mã, di chúc được hiểu là cách thức để ghi nhận lại ý chí của người lập di chúc và có hiệu lực khi người lập ra di chúc chết. Ngay từ thời kỳ này khái niệm về di chúc đã thể hiện được chức năng và bản chất pháp lý của mình. Di chúc là sự ghi nhận ý chí khi người lập di chúc còn sống. Di chúc là mong muốn của người lập di chúc và là bằng chứng để phân chia di sản sau khi người lập di chúc chết.

Tiếp nối những quy định trong pháp luật thời kỳ La Mã, giai đoạn pháp luật thời kỳ hiện đại vẫn xác định di chúc là cách thức chủ sở hữu tài sản định đoạt tài sản của họ để sau khi họ chết tài sản sẽ được chuyển giao cho những người họ mong muốn cho hưởng. Tuy nhiên đối với những quốc gia theo trường phái tôn trọng quyền tự do cá nhân như ở Anh - Mỹ thì di chúc đề cao sự tự tôn trọng ý chí của người để lại di sản và thường người để lại di sản quyết định phân chia tài sản theo mong muốn, ý chí của mình. Dưới cách tiếp cận của các nước theo hệ thống pháp luật Anh - Mỹ, di chúc được hiểu *“là một phương tiện mà một người sử dụng để định đoạt tài sản của mình và chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết, với bản chất có thể thay đổi hoặc hủy bỏ*

³³ Henry Campbell Black (1968), *Black Law Dictionary - fourth edition*, Nxb. West Publishing Co., tr.1643.

³⁴ Trường Đại học Luật Hà Nội (2003), *Giáo trình Luật La Mã*, Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr.169.

³⁵ Nguyễn Ngọc Điện (2009), *Giáo trình Luật La Mã*, Nxb. Chính trị quốc gia, tr.101.

³⁶ Xem thêm Nguyễn Đình Huy (2001), “Quyền thừa kế trong luật La Mã cổ đại”, *Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam*, số 4/2001, tr.37; khái niệm di chúc được xây dựng bởi luật gia Ulpian (một luật gia La Mã nổi tiếng).

trong suốt thời gian mà người lập di chúc còn sống”³⁷. Cách hiểu này cũng xác định bản chất pháp lý và chức năng của di chúc. Di chúc là phương tiện chứa đựng ý chí của người lập di chúc. Do vậy, trong khoảng thời gian người lập di chúc còn sống họ có quyền tự do thay đổi ý chí của mình và di chúc có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế cho đến khi người lập di chúc chết. Chỉ khi người lập di chúc chết, ý chí đã được xác định, không thể thay đổi thì di chúc mới có hiệu lực pháp luật. Sự tự do ý chí được thể hiện rõ ở nội dung di chúc khi người để lại di sản định đoạt tài sản cho người thân, người trong gia đình hoặc người ngoài.

Tuy nhiên sẽ có những quốc gia mà cách thức xử sự, tư tưởng và hành vi của con người khi lập di chúc dựa trên nền tảng gia đình. Mặc dù quy định của pháp luật xác định di chúc là sự tự do ý chí nhưng người để lại di sản thường đặt nặng vai trò, trách nhiệm của họ đối với gia đình nên di chúc là sự phân chia tài sản theo ý chí của họ dành cho những người trong gia đình. Việt Nam là một quốc gia nằm trong nhóm này.

Ở Việt Nam, xuất phát từ tục lệ cổ di chúc được hiểu là việc cha, mẹ tổ chức phân chia tài sản cho con, cháu trong gia đình. Di chúc được lập xuất phát từ nỗi lo của cha, mẹ khi cha, mẹ chết mà không phân phối tài sản thì dẫn đến việc tranh giành, anh em mất đoàn kết gây mất thể diện gia đình. Di chúc được xem là tuyên bố long trọng của cha, mẹ để phân chia tài sản cho con, cháu, những người trong gia đình. Nếu di chúc định đoạt tài sản cho người ngoài mà không để lại cho người trong gia đình sẽ khiến gia đình đương đầu với sự chê cười của dư luận. Sau này khi xã hội phát triển, dưới sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và hội nhập thì người Việt Nam theo xu hướng cá nhân chủ nghĩa và lúc này di chúc được lập có thể là sự chuyển giao tài sản cho người ngoài. Tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận tư tưởng gia đình thống trị là phong tục tập quán của Việt Nam vẫn được duy trì nên di chúc có nội dung để lại di sản cho người ngoài sẽ không nhiều. Bởi lẽ một trong những mục đích quan trọng của thừa kế theo di chúc là hướng đến mục tiêu bảo vệ đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội. Mặt khác, việc định đoạt tài sản trong di chúc cho những người thân trong gia đình còn xuất phát từ nghĩa vụ tình cảm, trách nhiệm và đạo đức của người để lại di sản. Do đó hiện nay ở Việt Nam, di chúc là sự ghi nhận ý chí định đoạt tài sản của người có tài sản và nội dung di chúc sẽ là định đoạt tài sản cho những người thân trong gia đình và/hoặc cho người ngoài.

Ở Việt Nam khi nghiên cứu về di chúc trong một số công trình nghiên cứu pháp luật, các học giả đưa ra cách hiểu về di chúc với bản chất là ghi nhận quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu tài sản sau khi họ chết. Theo đó di chúc là “*sự thể hiện ý*

³⁷ Cavendish Law – Cards (2019), *Succession 1st Editon*, Nxb. Cavendish, London, 1997, tr.1 trong Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2019), *Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế*, Lê Minh Hùng (chủ biên), Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, tr.434.

*chí của cá nhân mà không phải là của bất kỳ chủ thể nào khác. Mục đích của việc lập di chúc là chuyển tài sản là di sản của mình cho người khác. Di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người đó chết*³⁸. Hay “*di chúc là sự thể hiện ý chí đơn phương của cá nhân lúc còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết một cách nguyện, theo một hình thức, thể thức luật định, có thể bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bất cứ lúc nào bởi người lập di chúc khi người đó còn sống, và di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc chết*”³⁹. Cũng có tài liệu đã xác định “*ở góc độ pháp luật tài sản, di chúc được hiểu là cách chủ sở hữu thực hiện quyền định đoạt tài sản trong trường hợp đặc thù là định đoạt có điều kiện và định đoạt cho tương lai do di chúc chỉ có hiệu lực khi người đó chết*”⁴⁰. Cách hiểu về di chúc của các công trình nghiên cứu thể hiện rất rõ những đặc điểm, nội dung và bản chất pháp lý của di chúc. Nội dung di chúc đặt ra là để định đoạt tài sản của người có tài sản trước khi họ chết. Bản chất của di chúc là sự thể hiện ý chí đơn phương của chủ sở hữu tài sản mà ai cũng phải tôn trọng và chỉ người lập di chúc mới có quyền thay đổi ý chí này với điều kiện sự thay đổi phải được thể hiện trước khi họ chết.

Như vậy có thể hiểu *di chúc là sự ghi nhận ý chí của cá nhân lúc còn sống nhằm định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi chết*.

Xét về bản chất pháp lý, di chúc phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện về chủ thể lập di chúc, nội dung di chúc, yếu tố tự nguyện của người lập di chúc và hình thức để xác định một di chúc hợp pháp. Trong đó hình thức di chúc đóng vai trò quan trọng để ghi nhận chính xác ý chí định đoạt tài sản của người lập di chúc. Bởi vì di chúc chỉ được thực hiện khi người lập di chúc đã chết do đó việc xác thực lại những nội dung trong di chúc là điều khó khăn. Chính vì không còn đối chứng nên di chúc có thể bị người khác giả mạo, bị thay đổi nội dung. Để loại trừ những khả năng bất thường đó, pháp luật rất chú trọng đến hình thức của di chúc với những quy định chặt chẽ về điều kiện và thủ tục lập di chúc.⁴¹

2.1.2. Đặc điểm di chúc

Thứ nhất, di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương của người để lại di sản.

Di chúc được xác lập dựa trên hành vi đơn phương của người để lại di sản, họ thực hiện hành vi lập di chúc và hành vi này nhằm làm phát sinh hậu quả pháp lý. Một quan hệ pháp luật về thừa kế theo di chúc được phát sinh khi hành vi pháp lý đơn phương này thỏa mãn tất cả các điều kiện có hiệu lực của nó. Do đó đây là đặc điểm thể hiện rõ bản chất pháp lý của di chúc được hình thành dựa trên ý chí đơn phương của cá nhân là chủ sở hữu tài sản. Đối với quan hệ thừa kế theo di chúc, chủ thể tham

³⁸ Trường Đại học Luật Hà Nội, *tlđđ* (số chú thích 2), tr.311.

³⁹ Lê Minh Hùng (1995), *Vấn đề di chúc trong pháp luật thừa kế của nước ta hiện nay*, Luận văn thạc sĩ luật học, Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tr.23.

⁴⁰ Nguyễn Ngọc Điện, *tlđđ* (số chú thích 13), tr.213.

⁴¹ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.437.

gia vào quan hệ này với tư cách là người thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Tuy nhiên đối với người để lại di sản thì pháp luật không ghi nhận quyền lập di chúc của bất cứ chủ thể nào khác ngoài cá nhân⁴². Bởi lẽ cá nhân là một “con người” sinh học, có sinh có tử, sẽ có yêu cầu về việc tiếp tục chuyển tiếp tài sản cho những người khác còn sống. Đối với pháp nhân đây là một “con người” pháp lý, pháp nhân có thể không còn hoạt động nhưng những vấn đề về tài sản sẽ được giải quyết chuyển giao theo pháp luật sau khi pháp nhân chấm dứt hoạt động.

Mặt khác, di chúc là hành vi pháp lý đơn phương bởi hành vi lập di chúc được hình thành thông qua sự bày tỏ ý chí của người để lại di sản, không phải bởi sự gặp gỡ của hai hay nhiều ý chí tại một thời điểm như trong quan hệ hợp đồng⁴³. Trên thực tế việc quyết định việc chuyển giao tài sản cho ai, chuyển giao như thế nào, chuyển giao bao nhiêu đều hoàn toàn do người để lại di sản quyết định. Có thể vẫn có những cân nhắc, xem xét, thảo luận và lấy ý kiến của người khác. Nhưng người quyết định sẽ vẫn là người để lại di sản trên cơ sở sự tự do ý chí. Trước đây, pháp luật tồn tại di chúc chung của vợ, chồng cùng lập để định đoạt tài sản. Mặc dù đây là ý chí của hai người cùng thảo luận để định đoạt đối với một khối tài sản chung nhưng đó là sự thảo luận của những người cùng một phía trong quan hệ thừa kế - là người để lại di sản để định đoạt tài sản cho phía chủ thể bên kia – là người thừa kế theo di chúc. Do đó, trong trường hợp này vẫn xác định đây là một hành vi pháp lý đơn phương về mong muốn chuyển dịch tài sản của họ cho những người khác.

Thứ hai, nội dung của di chúc phải nhằm chuyển dịch tài sản của người chết cho các chủ thể được ghi nhận trong di chúc.

Đây là đặc điểm cơ bản của di chúc thể hiện mối liên hệ của quan hệ thừa kế theo di chúc và quan hệ quyền sở hữu khi công nhận quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu tài sản. Một người còn sống là chủ sở hữu tài sản, họ có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản theo ý chí của mình. Khi họ chết, tài sản vẫn có thể được dịch chuyển theo ý chí của họ thông qua di chúc cho những người khác còn sống. Đây cũng là đặc điểm thể hiện rõ ý nghĩa của di chúc đối với xã hội, nền kinh tế, đối với người thừa kế và người để lại di sản. “*Thông qua thừa kế theo di chúc, quyền sở hữu của một người đối với thành quả lao động của họ được dịch chuyển từ đời này sang đời khác theo ý chí của người có tài sản*”⁴⁴. Những lời căn dặn, dặn dò về những vấn đề không liên quan đến việc định đoạt tài sản cho con, cháu, người thân thực hiện sẽ chịu sự tác động, điều chỉnh của các quy phạm đạo đức, phong tục tập quán nhưng

⁴² Phan Trung Hiền, *ltdđ* (số chú thích 23), tr.126.

⁴³ Nguyễn Ngọc Điện (1999), *Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật Dân sự Việt Nam*, Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, tr.157.

⁴⁴ Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2017), *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*, Nxb. Tư pháp, tr.153.

không được xác định là di chúc để áp dụng các quy phạm pháp luật về di chúc điều chỉnh cho nội dung đó.

Nếu như hợp đồng là sự thỏa thuận của các chủ thể nhằm chuyển dịch tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác, thì di chúc lại nhằm chuyển dịch tài sản của người đã chết sang cho người khác còn sống⁴⁵. Do vậy để đảm bảo quyền định đoạt tài sản và quyền thừa kế tài sản, pháp luật đặt ra các điều kiện chặt chẽ về chủ thể lập di chúc, nội dung di chúc, yếu tố tự nguyện khi lập di chúc và về hình thức di chúc.

Thứ ba, di chúc có hiệu lực pháp luật vào thời điểm người để lại di sản chết.

Di chúc đã được lập nhưng chỉ phát sinh hiệu lực khi người lập di chúc chết. Do đó, pháp luật quy định người lập di chúc khi còn sống và còn minh mẫn, sáng suốt, bất kỳ lúc nào cũng có quyền thay đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc nếu thấy quyết định đó không còn phù hợp.⁴⁶ Chính vì vậy khoản 5 Điều 643 BLDS 2015 quy định nếu một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc nào thể hiện ý chí tự nguyện sau cùng mới được coi là có hiệu lực pháp luật.

Đây chính là một đặc điểm rất riêng mà các giao dịch dân sự khác không tồn tại bởi lẽ việc dịch chuyển tài sản phải theo ý chí của chủ sở hữu tài sản là người đã chết sang cho những người khác còn sống. Đối với những giao dịch dân sự khác như các hành vi pháp lý đơn phương (hứa thưởng, thi có giải, đề nghị giao kết hợp đồng) hay hợp đồng đều có hiệu lực pháp luật khi người xác lập giao dịch còn sống nhưng chỉ có di chúc hiệu lực pháp luật lại phụ thuộc vào thời điểm người để lại di sản chết. Chính từ đặc điểm này dẫn đến sự ảnh hưởng rõ rệt của hình thức di chúc đối với hiệu lực của di chúc. Đây cũng là đặc điểm có thể so sánh sự khác biệt của di chúc so với các giao dịch dân sự khác, chẳng hạn là hợp đồng. Nếu hình thức di chúc quyết định đến hiệu lực của di chúc thì hình thức của hợp đồng chỉ quyết định đến hiệu lực của hợp đồng khi luật có quy định. Thậm chí khi luật có quy định về điều kiện hình thức của hợp đồng nhưng hợp đồng được giao kết không đúng hình thức luật định thì hợp đồng vẫn có thể có hiệu lực pháp luật nếu thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 129 BLDS 2015. Bởi lẽ *“trong quan hệ hợp đồng phải có sự gặp gỡ về ý chí của hai bên để xác lập quan hệ pháp lý, các bên giao kết phải thống nhất ý chí về việc ràng buộc lẫn nhau trong một quan hệ đặc trưng bằng thái độ cư xử của một bên nhằm đáp ứng yêu cầu của bên kia (hoặc ngược lại)”*⁴⁷. Khi các bên vẫn còn sống, hợp đồng có hiệu lực nên bất kỳ sự khác biệt nào về nội dung của hợp đồng, về quá trình thực hiện hợp đồng các bên đều có thể gặp gỡ trao đổi để bày tỏ ý chí. Nhưng đối với di chúc vấn đề này không thể xảy ra, do đó hình thức di chúc chặt chẽ để đảm bảo bảo vệ ý chí đích thực của người để lại di sản.

⁴⁵ Điều 624 BLDS 2015.

⁴⁶ Điều 640 BLDS 2015.

⁴⁷ Nguyễn Ngọc Điện (2016), *Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2*, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr.26.

2.2. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa hình thức di chúc

2.2.1. Khái niệm hình thức di chúc

Không phải quốc gia nào cũng ghi nhận cả hai hình thức di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Một số quốc gia châu Âu không ghi nhận sự tồn tại của di chúc miệng⁴⁸, đơn cử như là ở Pháp⁴⁹. Ở Việt Nam, di chúc được thể hiện dưới hai hình thức truyền thống là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. *“Tùy từng hình thức khác nhau của di chúc mà có những thuật ngữ riêng để gọi tên như: chúc thư, chúc ngôn, di lệnh, di văn, di ngôn... Các thuật ngữ này đã từng được sử dụng trong văn bản pháp luật của các Nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây.”*⁵⁰ Di chúc là thuật ngữ được sử dụng chung đề cập đến việc định đoạt tài sản của cá nhân sau khi họ chết. Thuật ngữ chúc thư, di lệnh, di văn là tên gọi dùng cho di chúc được viết (di chúc bằng văn bản); mệnh lệnh, chúc ngôn, di ngôn là thuật ngữ sử dụng cho di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản hay di chúc miệng được xem là hình thức ghi nhận ý chí của người để lại di sản để sau khi họ chết những mong muốn này sẽ được thực hiện.

Nghiên cứu về hình thức di chúc tức là luận giải về cách thức ghi nhận lại nội dung của bản di chúc. Bởi lẽ, xét theo nghĩa thông thường, hình thức được hiểu cơ bản là *“cái bên ngoài, cái chứa đựng nội dung”*⁵¹. Hay hình thức là *“toàn thể nói chung những gì làm thành mặt bề ngoài của sự vật, cái chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung”*⁵². Còn nội dung là *“mặt bên trong của sự vật, được hình thức chứa đựng, biểu hiện”*⁵³. Nội dung chứa đựng tính chất, đặc điểm riêng biệt của sự vật và thông qua hình thức thể hiện ra bên ngoài. Hình thức và nội dung là hai yếu tố cấu thành để nhận biết một sự vật. Theo quan điểm của triết học Mác-Lê Nin, *“phương thức tồn tại và phát triển của sự vật là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của nó”*⁵⁴. Do vậy, giữa hình thức và nội dung luôn tồn tại song hành, giữa hai yếu tố này là mối liên hệ tương đối bền vững. Nếu không có hai yếu tố này sự vật không tồn tại và không phát triển. Dưới góc nhìn pháp luật, hình thức là dáng vẻ bề ngoài, tồn tại của pháp luật để chứa đựng nội dung pháp luật là cách thức xử sự của con người theo một định hướng nhất định được luật ghi nhận. Do vậy có thể nhận định hình thức di chúc là *“cái bên ngoài”* còn nội dung di chúc là sự ghi nhận ý chí để định đoạt tài sản của người để lại di sản.

Từ cách hiểu thông thường của hình thức di chúc, đã có nhiều tác giả đưa ra cách hiểu về hình thức di chúc xét về mặt pháp lý. Có quan điểm xác định *“hình thức*

⁴⁸ Daniel H. Redfearn (1957), *Practical Treatise on the Law of Wills and administrations of estate in Florida*, Nxb. Harrison Co; chỉnh sửa lần thứ 3, Chương 1.

⁴⁹ Từ Điều 967 đến Điều 1001 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (2018), *Bản dịch Bộ luật Dân sự Pháp*, tr.240-245: không quy định về di chúc miệng).

⁵⁰ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.432.

⁵¹ Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr.87.

⁵² Viện Ngôn ngữ học (2016), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb. Hồng Đức, tr.558.

⁵³ Viện ngôn ngữ học, *tlđđ* (số chú thích 52), tr.935.

⁵⁴ Bộ Giáo dục và Đào tạo, *tlđđ* (số chú thích 4), tr.85.

di chúc là phương thức biểu hiện ý chí của người lập di chúc; là căn cứ pháp lý làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc, là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi người được chỉ định trong di chúc”⁵⁵. Hay theo một cách diễn dịch khác thì hình thức di chúc được hiểu là “phương thức biểu hiện ý chí của người lập di chúc (nội dung di chúc), là căn cứ pháp lý cụ thể làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc đồng thời là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho người được chỉ định trong di chúc”⁵⁶. Cũng có tác giả đưa ra cách hiểu về hình thức di chúc như sau “ý chí tự nguyện của người lập di chúc được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định. Hình thức của di chúc là nguồn chứng cứ được sử dụng để chứng minh ý chí đích thực của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản”.⁵⁷

Dù các cách dùng từ của các tác giả có khác nhau nhưng các cách hiểu đều thể hiện được cơ bản đặc tính và ý nghĩa pháp lý của hình thức di chúc. Hình thức di chúc là phương tiện, là cách thức để người để lại di sản ghi nhận lại ý chí của họ trước khi họ chết. Trong mong muốn định đoạt tài sản cho ai, để lại là bao nhiêu, để lại như thế nào, để lại những loại tài sản nào thì hình thức di chúc (bằng văn bản hay bằng miệng) là “nơi” chứa đựng những nội dung đó. Ý chí định đoạt của người để lại di sản phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định, hình thức đó có thể là sự ghi nhận trên văn bản hoặc hình thức đó có thể là thông qua lời nói. Từ đó hình thức di chúc là nguồn chứng cứ để chứng minh sự tồn tại ý chí của người để lại di sản. Đây chính là đặc điểm pháp lý quan trọng của hình thức di chúc, đảm bảo cho sự tồn tại di chúc và từ đó có thể phân chia di sản theo di chúc để bảo vệ quyền lợi của người để lại di sản cũng như của người thừa kế theo di chúc.

Ý chí xuất phát từ nội tâm bên trong của người để lại di sản. Để ý chí được thể hiện ra bên ngoài và được ghi nhận lại một cách đúng đắn thì hình thức di chúc là một phương tiện để chứa đựng. Do đó luôn phải hiểu một cách khái quát nhất, “*hình thức của di chúc là sự biểu hiện ý chí của người để lại di sản ra bên ngoài thế giới khách quan, là sự chứa đựng nội dung di chúc theo một trình tự, kết cấu nhất định*”⁵⁸. Quy định về hình thức di chúc phải thỏa mãn những điều kiện luật định để di chúc ghi nhận ý chí đích thực của người để lại di sản. Sau khi người để lại di sản chết thì di chúc có hiệu lực pháp luật⁵⁹.

Hình thức di chúc là sự thể hiện của nội dung di chúc và để ghi nhận, lưu giữ, chứa đựng nội dung di chúc thì hình thức di chúc phải được thể hiện thông qua những chất liệu cụ thể với các kết cấu và trình tự, thủ tục lập di chúc nhất định. Nghiên cứu quy định pháp luật từ xưa đến nay ở nhiều quốc gia có thể thấy di chúc được thể hiện

⁵⁵ Trường Đại học Luật Hà Nội, *tlđd* (số chú thích 2), tr.319.

⁵⁶ Nguyễn Ngọc Điệp (2001), *Những điều cần biết về quyền thừa kế*, Nxb. Phụ nữ, tr.24.

⁵⁷ Lê Đình Nghị (2009), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, tr.246.

⁵⁸ Lê Tuấn Tú (2013), “Hình thức di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005”, *Tạp chí Pháp luật và thực tiễn*, số 6 năm 2013, tr.25.

⁵⁹ Khoản 1 Điều 643 BLDS 2015.

thông qua hai hình thức truyền thống là bằng văn bản và bằng miệng. Sự ghi nhận lại ý chí vào văn bản (với chất liệu cơ bản là trên giấy hoặc những chất liệu không cơ bản khác có thể được ghi nhận như trên vải, trên gỗ, trên phiến đá...) hoặc thông qua lời nói là phương tiện để chứa đựng ý chí đó. Tuy nhiên để tạo thành chỉnh thể hoàn chỉnh và ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản thì hai hình thức di chúc phải căn cứ vào trình tự, kết cấu nhất định trong quá trình lập di chúc. Những yếu tố như: chữ viết, lời nói, chữ ký, điểm chỉ, ngày, tháng, năm lập di chúc, người làm chứng, người công chứng, người chứng thực di chúc, người viết hộ di chúc là những yêu cầu của thể thức lập di chúc. Dựa trên những thể thức này, di chúc được lập phải tuân theo những điều kiện, trình tự, thủ tục nhất định tùy vào từng loại hình thức di chúc. Tất cả những yếu tố này tạo thành sự hoàn thiện trong hình thức di chúc khi được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng miệng. Do đó khi nghiên cứu về hình thức di chúc không chỉ đơn giản là đề cập đến hai phương thức văn bản hoặc lời nói mà cần phải xem xét đến thể thức, trình tự, thủ tục để ghi nhận ý chí của người để lại di sản.

Như vậy nếu tiếp cận hình thức di chúc nhằm làm rõ đặc trưng pháp lý có thể xác định *hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận và xác thực ý chí định đoạt tài sản của người để lại di sản theo một trình tự, kết cấu nhất định và từ đó là căn cứ để chứng minh quyền thừa kế theo di chúc của người thừa kế.*

Ở góc độ quy định pháp luật, hình thức di chúc có thể được hiểu là một chế định pháp luật được quy định cụ thể và có hệ thống trong các văn bản pháp luật nhằm ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản và là một trong những điều kiện để di chúc hợp pháp.⁶⁰ Di chúc được tạo lập nhưng không đương nhiên khi người lập di chúc chết di chúc sẽ có hiệu lực pháp luật. Di chúc được xem là hợp pháp phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 630 BLDS 2015, bao gồm điều kiện về chủ thể lập di chúc, điều kiện về nội dung di chúc, điều kiện về yếu tố tự nguyện khi lập di chúc và điều kiện về hình thức của di chúc. Có thể khẳng định các quy định về hình thức di chúc đóng vai trò quan trọng để xác định tính hợp pháp của di chúc. Đây chính là cách hiểu về hình thức di chúc theo nghĩa rộng được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc. Từ đó có thể xác định hình thức di chúc là *một phạm trù pháp lý bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc tùy vào từng loại hình thức di chúc.* Quy định pháp luật về hình thức di chúc luôn có sự thay đổi khi xã hội thay đổi. Những quy định về điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc nhằm đảm bảo di chúc luôn là sự ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc.

⁶⁰ Hình thức di chúc được quy định từ Điều 627 đến Điều 639 BLDS 2015 và các Điều luật trong Luật Công chứng 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2.2. Đặc điểm hình thức di chúc

Thứ nhất, hình thức di chúc là phương thức ghi nhận và lưu giữ ý chí định đoạt tài sản của người để lại di sản. Do đó giữa hình thức di chúc và nội dung di chúc có mối liên hệ nhất định.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại di sản khi họ định đoạt tài sản của mình. Nhưng thông qua hình thức di chúc ý chí đó mới được ghi nhận lại và lưu giữ qua thời gian để đến khi người để lại di sản chết, di chúc có hiệu lực pháp luật⁶¹ thì di sản mới có thể phân chia thừa kế theo di chúc.

Ý chí của người để lại di sản được ghi nhận trong nội dung di chúc. Do đó nội dung di chúc là những mong muốn, quyết định của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Nội dung của di chúc có thể được chia thành nội dung chủ yếu bắt buộc phải có và các nội dung khác. Những nội dung chủ yếu bắt buộc phải có là nội dung cơ bản mà phải căn cứ vào mới có thể phân chia di sản thừa kế. Những nội dung đó có thể xác định việc người lập di chúc là ai, người thừa kế theo di chúc là người cụ thể nào và những thông tin chi tiết về tài sản được định đoạt trong di chúc. Như vậy hai yếu tố cơ bản phải được thể hiện trong nội dung di chúc cần phải có chính là người thừa kế và tài sản được định đoạt. Người thừa kế theo di chúc phải luôn được xác định để biết chính xác tài sản sẽ được dịch chuyển cho ai. Thậm chí theo pháp luật La Mã, di chúc không chỉ định người hưởng di sản thì di chúc đó không được công nhận⁶². Tài sản luôn được thể hiện rõ trong nội dung di chúc bởi bản chất của di chúc là sự dịch chuyển tài sản từ người đã chết sang cho người khác còn sống. Ngoài những yêu cầu này, di chúc có thể có những nội dung không bắt buộc như đặt ra các điều kiện cho người thừa kế, di tặng di sản hoặc để lại di sản dùng vào việc thờ cúng. Dù là các nội dung nào thì phải bảo đảm nội dung của di chúc không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ý chí của người lập di chúc đã biểu đạt ra nhưng để ghi nhận và lưu giữ lại ý chí để từ đó là căn cứ cho sự tồn tại của một bản di chúc và có thể phân chia di sản thừa kế theo di chúc thì cần phải có hình thức di chúc. Đây chính là điều kiện đủ để tạo lập nên một bản di chúc. Hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận ý chí của người lập di chúc, là chứng cứ chứng minh cho sự tồn tại của ý chí này và là phương thức có thể xác thực ý chí đó. Vì vậy, hình thức di chúc là một điều kiện quan trọng hình thành nên bản di chúc.

Do đó, nội dung di chúc và hình thức di chúc là hai yếu tố tạo nên một bản di chúc, không thể tách rời. Nội dung di chúc là sự biểu đạt ý chí của người lập di chúc còn hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận lại ý chí đó. Nếu thiếu một trong hai

⁶¹ Khoản 1 Điều 611, khoản 1 Điều 643 BLDS 2015.

⁶² Rafael Domingo (2017), “The Roman Law of succession - An overview”, *Tạp chí SSRN Electronic Journal*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2989061, [truy cập 28/4/2023].

yếu tố này không thể tạo ra được một bản di chúc. Không có nội dung di chúc thì không thể hiện được bản chất của di chúc là sự thể hiện ý chí định đoạt tài sản của người lập di chúc. Nội dung di chúc là điều kiện cần, tiền đề để tạo nên bản di chúc. Hình thức di chúc là điều kiện đủ để nội dung được ghi nhận, lưu trữ và xác thực được ý chí của người lập di chúc.

Ngoài ra không phải gia đình nào khi người lập di chúc chết cũng ngay lập tức phân chia di sản của người để lại di sản. Sau một khoảng thời gian dài hay ngắn tùy vào từng gia đình di sản mới được phân chia. Do vậy để bảo vệ ý chí của người để lại di sản thì hình thức di chúc là phương tiện để lưu giữ ý chí đó.

Thứ hai, hình thức di chúc được cấu thành bởi phương thức thể hiện, ghi nhận, lưu giữ ý chí của người để lại di sản và những điều kiện về thể thức lập di chúc thông qua trình tự, thủ tục nhất định do luật quy định.

Hình thức di chúc bằng văn bản và hình thức di chúc miệng là tên gọi của hai phương thức người để lại di sản thể hiện ý chí và ý chí đó được ghi nhận và lưu giữ lại trong một khoảng thời gian. Hai hình thức di chúc truyền thống có phương thức thể hiện và lưu giữ lại ý chí của người để lại di sản thông qua những chất liệu vật chất cụ thể bằng giấy, trên vải, trên gỗ, trên phiến đá hay bằng lời nói thông qua sự ghi nhớ của người làm chứng và được ghi chép. Tuy nhiên những phương thức để ghi nhận và lưu giữ ý chí của người để lại di sản chỉ là một yếu tố cấu thành nên hình thức di chúc.

Bên cạnh đó những điều kiện cụ thể về chữ ký, điểm chỉ, người làm chứng, người viết hộ di chúc, công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực di chúc sẽ được đặt ra cho từng loại hình thức di chúc. Những điều kiện cụ thể này tương ứng với từng loại hình thức di chúc sẽ có những yêu cầu khác nhau về trình tự, thủ tục lập di chúc. Tất cả những yếu tố đó tạo thành thể thức lập di chúc được thể hiện trên phương thức cụ thể là bằng văn bản hay bằng lời nói.

Do vậy, khi nghiên cứu về hình thức di chúc không chỉ là đề cập đến phương thức thể hiện, ghi nhận và lưu giữ ý chí của người lập di chúc mà còn nghiên cứu về các điều kiện và thể thức của từng loại hình thức di chúc.

Thứ ba, hình thức di chúc có tính quyết định đến hiệu lực của di chúc.

Di chúc là một giao dịch dân sự, giống những giao dịch dân sự khác, di chúc cần phải thỏa mãn các điều kiện để di chúc hợp pháp. Bốn điều kiện để di chúc hợp pháp đó là điều kiện về chủ thể lập di chúc, điều kiện về nội dung di chúc, điều kiện về yếu tố tự nguyện khi lập di chúc và điều kiện về hình thức của di chúc.⁶³ Di chúc vi phạm một trong bốn điều kiện này sẽ bị vô hiệu⁶⁴. Việc di chúc vô hiệu toàn bộ hay vô hiệu một phần thì tùy thuộc vào việc vi phạm điều kiện có hiệu lực ảnh hưởng đến toàn bộ di chúc hay chỉ ảnh hưởng đến một phần di chúc. Tuy nhiên, hình thức là một

⁶³ Khoản 1 Điều 117, khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

⁶⁴ Điều 122 BLDS 2015.

điều kiện quan trọng để di chúc hợp pháp. Hình thức di chúc là nơi chứa đựng và ghi nhận lại nội dung di chúc. Hình thức di chúc là một trong những căn cứ cơ bản để xác định di chúc được lập ghi nhận đúng với ý chí của người để lại di sản khi người để lại di sản đã chết. Do vậy nếu di chúc vi phạm quy định về hình thức, di chúc sẽ bị vô hiệu toàn bộ.

Đây là một đặc trưng của hình thức di chúc mà các giao dịch dân sự khác không tồn tại. Chẳng hạn trong quan hệ hợp đồng được hình thành dựa trên cơ sở sự tự do thỏa thuận⁶⁵ và hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác⁶⁶. Hợp đồng được thực hiện khi các phía chủ thể trong quan hệ hợp đồng về cơ bản đều đang tồn tại. Do đó trong mối quan hệ hợp đồng, hình thức đơn thuần chỉ là một phương tiện để ghi nhận ý chí của các chủ thể giao kết hợp đồng. Khi các chủ thể muốn thay đổi ý chí, họ có thể thỏa thuận để chỉnh sửa, bổ sung nội dung hợp đồng. Khi có tranh chấp phát sinh, họ có thể tự thể hiện ý chí của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Hình thức trong quan hệ hợp đồng không phải là một điều kiện để hợp đồng có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp luật có quy định khác. Thậm chí, đối với những hợp đồng luật có quy định hình thức là một điều kiện để hợp đồng có hiệu lực thì hiệu lực của hợp đồng cũng có thể không bị ảnh hưởng.⁶⁷

Như vậy, khi so sánh hình thức di chúc với hình thức của hợp đồng có thể kết luận hình thức không phải là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng như hình thức của di chúc. Từ đó cũng có thể khẳng định di chúc là một giao dịch dân sự trọng thức. Hình thức di chúc đóng vai trò quan trọng và có tính quyết định đến hiệu lực của di chúc.

Thứ tư, hình thức di chúc không trái với quy định của luật⁶⁸.

Quy định về hình thức di chúc với những trình tự, thủ tục khắt khe cũng nhằm đảm bảo ý chí của người để lại di sản được truyền tải một cách chính xác và trung thực nhất, cũng như không xảy ra trường hợp giả mạo, thay đổi di chúc. Đặc điểm này cũng xuất phát từ tính đặc thù trong quan hệ thừa kế theo di chúc. Thừa kế theo di chúc là một quan hệ xuất phát từ ý chí đơn phương của người lập di chúc và chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc chết. Những tranh chấp, vướng mắc xoay quanh nội dung di chúc không thể nào được người để lại di sản lý giải lại. Sự xác nhận lại nội dung di chúc là điều khó có thể thực hiện khi người lập di chúc đã chết. Do đó, di chúc được lập phải có hình thức di chúc không trái với quy định của luật. Đặc điểm này đã được ghi nhận trong pháp luật về hình thức di chúc từ giai đoạn phong kiến đến hiện nay.

⁶⁵ Điều 385 BLDS 2015.

⁶⁶ Khoản 1 Điều 401 BLDS 2015.

⁶⁷ Theo quy định tại Điều 129 BLDS 2015 thì nếu hợp đồng đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng.

⁶⁸ Điểm b khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

Quy định trong Bộ luật Hồng Đức ghi nhận hai hình thức di chúc bằng văn bản và bằng miệng. Đối với di chúc miệng không đặt ra các điều kiện nhưng hình thức di chúc bằng văn bản cần điều kiện tự viết nếu biết chữ hoặc nhờ Xã trưởng viết thay và xác nhận, nếu không biết chữ. Di chúc không được thực hiện đúng thì không được công nhận.⁶⁹ Ở giai đoạn pháp luật thời kỳ Pháp thuộc, chúc thư là một chứng thư đơn phương và trọng thức chỉ có hiệu lực kể từ ngày người lập di chúc chết. Sự phát biểu về ý chí của người lập chúc phải được thực hiện dưới hình thức luật định. Pháp luật đã ấn định về các hình thức này với mục đích là để cho mong muốn của người lập di chúc được xác thực. Do đó, nếu người lập di chúc không áp dụng đúng những hình thức luật định thì chúc thư sẽ bị vô hiệu mang tính chất tuyệt đối. Nếu chúc thư đã làm theo hình thức luật định hợp lệ thì Tòa án không có quyền sửa đổi các điều khoản đã ghi trong chúc thư. Án lệ ở Nam Kỳ cũng công nhận về quyền tự do lập chúc theo các quy tắc nói trên của hai Bộ Dân luật Bắc kỳ và Bộ Dân luật Trung kỳ.⁷⁰

Hiện nay, người để lại di sản tùy vào từng hoàn cảnh, điều kiện thể chất, khả năng ngôn ngữ là khác nhau có thể lựa chọn những loại hình thức di chúc cho phù hợp với điều kiện, khả năng của họ và đảm bảo sự thuận lợi khi lập di chúc nhưng không thể phủ nhận rằng các điều kiện về hình thức di chúc rất chặt chẽ. Theo quy định tại Điều 633 BLDS 2015 đối với di chúc được tự lập bởi người để lại di sản phải thỏa mãn điều kiện là bắt buộc người lập di chúc tự tay mình viết vào bản di chúc. Sau khi viết xong người này phải ký vào bản di chúc. Di chúc được đánh số từng trang và có chữ ký vào từng trang. Do vậy, người để lại di sản không thể in ra và ký tên vào được. Nếu người để lại di sản không tự tay viết mà in ra và ký tên vào di chúc thì di chúc này sẽ là di chúc bằng văn bản được in ra và cần có người làm chứng. Đối với di chúc có người làm chứng cần thiết phải có ít nhất hai người làm chứng chứng kiến người viết hộ viết thay người để lại di sản hoặc đánh máy thay người để lại di sản theo quy định tại Điều 634 BLDS 2015. Trên đây chỉ là sự liệt kê hai hình thức di chúc bằng văn bản cho người lập di chúc có thể lựa chọn bên cạnh những loại hình thức di chúc bằng văn bản khác và di chúc miệng.

Theo nguyên tắc chung, giao dịch dân sự có thể được ghi nhận dưới bất kỳ hình thức nào nhưng có những ngoại lệ mà các giao dịch dân sự cần phải tuân thủ quy định về hình thức do luật định để phục vụ cho mục tiêu đặc thù. Di chúc là một loại giao dịch ngoại lệ như thế. Hình thức di chúc cần được lập theo đúng quy định của luật để đảm bảo ý chí của người đã chết đã được ghi nhận một cách chính xác.

⁶⁹ Điều 366 Bộ luật Hồng Đức (được dịch từ Nguyễn Quốc Thắng (phiên âm, dịch nghĩa), Nguyễn Văn Tài (hiệu đính), *Lê Triều Hình Luật (Bộ luật Hồng Đức)*, Nxb. Văn hóa thông tin, tr.200).

⁷⁰ Huỳnh Công Bá (2020), *Định chế Hôn nhân và gia đình thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa – Tài sản*, Nxb. Thuận Hóa, tr.551-552, 582.

2.2.3. Ý nghĩa hình thức di chúc

Thứ nhất, hình thức di chúc có ý nghĩa bảo vệ sự đoàn kết gia đình và đạo đức xã hội.

Pháp luật thừa kế nói chung và thừa kế theo di chúc nói riêng được xây dựng dựa trên nền tảng bốn phạm gia đình. Chủ sở hữu tài sản trước khi chết định đoạt tài sản theo ý chí của họ cho những người được chỉ định trong di chúc hưởng di sản. Sự định đoạt tài sản của chủ sở hữu là tự do ý chí. Tuy nhiên theo lẽ thường và theo phong tục tập quán truyền thống của người Việt Nam đề cao tình yêu thương, đoàn kết, mối quan hệ bền chặt giữa các thành viên trong gia đình và đề cao giá trị tình cảm, trách nhiệm chăm lo vật chất tinh thần của ông, bà, cha, mẹ, đối với con, cháu thì di chúc được lập thường để lại cho con, cháu – những người thân trong gia đình. Di chúc là lời căn dặn của ông, bà, cha, mẹ trong việc phân chia tài sản để tránh con, cháu trong gia đình sẽ tranh chấp sau khi họ chết. Ngoài ra, cũng không hẳn không tồn tại những di chúc định đoạt tài sản cho người ngoài. Với sự bình đẳng và tự do trong việc thực hiện quyền định đoạt tài sản thì di chúc để lại cho người ngoài cũng là phổ biến.

Một di chúc tốt là một di chúc có nội dung tốt, thể hiện rõ ràng việc phân chia tài sản (cho ai, cho bao nhiêu). Tuy nhiên, để di chúc có ý nghĩa tích cực trong việc chuyển giao tài sản của người để lại di sản một cách có trật tự, tránh các tranh chấp phát sinh thì di chúc đó phải có hình thức tốt. Hình thức di chúc tốt sẽ đảm bảo được sự ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản. Và từ đó, các thành viên trong gia đình cũng như những người khác được hưởng di sản trong di chúc có thể dựa vào di chúc để phân chia tài sản. Anh, chị, em, con, cháu không có cảnh tranh giành, gây mất đoàn kết nội bộ gia đình và ảnh hưởng đến tình cảm, đạo đức giữa các thành viên trong gia đình. Những người khác được chỉ định hưởng di sản theo di chúc cũng có thể căn cứ vào nội dung di chúc để hưởng, tránh những mâu thuẫn gây mất tình cảm giữa những người thừa kế với nhau.

Thứ hai, hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận và là chứng cứ bảo vệ quyền định đoạt tài sản của người để lại di sản theo ý chí của họ, bảo vệ quyền thừa kế của người thừa kế theo di chúc.

Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân một cách tuyệt đối. Không ai có quyền xâm phạm quyền sở hữu của cá nhân, chỉ trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai Nhà nước mới có quyền trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường⁷¹. Cá nhân không chỉ mong muốn thực hiện quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của họ đối với những giao dịch dân sự khi họ còn sống mà còn thể hiện quyền định đoạt tài sản trước khi họ chết. Ý chí định đoạt tài sản với mong muốn dịch chuyển tài sản sau khi chết sẽ được thực hiện thông qua di chúc. Di chúc sẽ là phương tiện ghi nhận lại

⁷¹ Điều 163 BLDS 2015.

mong muốn này và hình thức di chúc là nơi chứa đựng ý chí đó. Hình thức di chúc sẽ được pháp luật quy định một cách cụ thể bằng những điều kiện kèm theo để đảm bảo rằng đây là sự ghi nhận ý chí đích thực của người để lại di sản, tránh trường hợp di chúc bị giả mạo, bị sửa đổi.

Ngoài ra, di chúc được lập đúng điều kiện, trình tự, thủ tục luật định còn nhằm bảo vệ quyền lợi của người thừa kế theo di chúc. Trên thực tế, tranh chấp về thừa kế theo di chúc xảy ra rất phổ biến và việc phân chia di sản bao giờ cũng là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa những người thừa kế theo di chúc, người thừa kế theo pháp luật. Ngoài ra, tranh chấp về phân chia di sản theo di chúc khá phức tạp do việc chuyển quyền sở hữu của di sản được thực hiện giữa một người đã chết cho một hoặc nhiều người thừa kế còn sống. Người đã chết không thể thể hiện ý chí nên tất cả những gì được ghi nhận trong di chúc là chứng cứ để tiến hành các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được định đoạt trong di chúc. Nhưng nếu di chúc được lập không bảo đảm ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản thì quyền thừa kế của người thừa kế theo di chúc sẽ không được pháp luật bảo vệ. Do đó, hình thức di chúc là yếu tố quan trọng ghi nhận chính xác ý chí đó để bảo vệ quyền lợi của người thừa kế theo di chúc.

Thứ ba, hình thức di chúc có vai trò phòng ngừa rủi ro khi ghi nhận và lưu giữ ý chí của người lập di chúc và là cơ sở để hạn chế các tranh chấp khi phân chia di sản.

Phân chia thừa kế theo di chúc là phân chia tài sản theo ý chí của người để lại di sản. Để phòng ngừa các rủi ro dẫn đến sự sai lệch ý chí của người để lại di sản thì hình thức di chúc là một trong những yếu tố quan trọng. Những yếu tố cấu thành nên hình thức di chúc và các yếu tố tác động đến pháp luật về hình thức di chúc giúp hình thức di chúc ghi nhận và bảo vệ tốt nội dung di chúc trong khoảng thời gian dài. Một di chúc tự lập là di chúc cần phải thỏa mãn đầy đủ hai điều kiện về yếu tố chữ viết và chữ ký. Một người bị hạn chế về thể chất không thể lựa chọn hình thức di chúc tự viết. Một người không thể lập di chúc bằng văn bản trong tình trạng cận kề cái chết muốn lập di chúc miệng thì di chúc cần phải thỏa các điều kiện về trình tự, thủ tục lập di chúc rất khắt khe. Khi hình thức di chúc được quy định chặt chẽ, sự giả mạo di chúc sẽ được giảm thiểu và di chúc sẽ bảo vệ được ý chí của người để lại di sản cũng như ý chí này sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian dài đến khi gia đình của người để lại di sản muốn phân chia di sản. Mặt khác, quy định về hình thức di chúc được hoàn thiện cũng là cơ sở để chứng minh rằng ý chí của người để lại di sản đã được ghi nhận chính xác từ đó có thể hạn chế các tranh chấp về di sản.

Hình thức di chúc có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu lực di chúc, quyền lợi của người để lại di sản và người thừa kế theo di chúc. Do đó, *“quy định một cách chặt chẽ về hình thức di chúc không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ thể mà*

còn hướng tới việc tạo ra tính xác thực cho những di chúc đã lập, qua đó nhằm tạo ra cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích cho các chủ thể trong quan hệ thừa kế theo di chúc”.⁷²

2.3. Lịch sử quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc

2.3.1. Quy định pháp luật về hình thức di chúc thời kỳ phong kiến

Di chúc bằng văn bản và di chúc miệng đã được ghi nhận ở nước ta từ rất lâu. “Theo một tài liệu luật cổ, ở Việt Nam công nhận cả việc lập di chúc bằng miệng và bằng giấy tờ nên đã từng nói đến di lệnh và di ngôn bên cạnh chúc thư và di văn (ĐTHL 366, 388; Thiện Chính Thư 272, 273; LGL 82; X. Vũ Văn Mẫu o.c. tr.54 tiếp)”⁷³. Mặt khác, di chúc miệng được tồn tại từ tục lệ của người Việt Nam, “theo tục lệ xưa kia, cá nhân có thể đối miệng lại những ý muốn sau cùng, chẳng hạn để phân chia của cải trước khi chết”⁷⁴.

Ở thời kỳ phong kiến, Bộ luật Hồng Đức có một ảnh hưởng sâu xa trong xã hội Việt Nam⁷⁵ đã có quy định rất cụ thể về hình thức di chúc. Trong Bộ luật Hồng Đức, vấn đề thừa kế được quy định từ Điều 374 đến Điều 400 (Chương điền sản) và rải rác ở một số điều luật trước đó và hình thức di chúc được quy định như sau: “Nếu đã có mệnh lệnh của cha mẹ hoặc chúc thư, thì phải theo đúng, trái thì mất phần mình”⁷⁶, “Cha mẹ làm chúc thư phân chia di sản, thiết lập hương hỏa trong chúc thư”⁷⁷. Như vậy, Bộ luật Hồng Đức đã quy định quyền lập di chúc để lại di sản, quy định này nhằm tránh sự tranh chấp tài sản về sau và thừa nhận hai hình thức di chúc: di chúc miệng (mệnh lệnh của cha mẹ), và di chúc viết (tức chúc thư).

Tại Điều 366 Bộ Luật Hồng Đức có ghi nhận điều kiện lập chúc thư như sau: “Những ai làm chúc thư, văn khế mà không do Xã trưởng viết thay và chứng kiến thì đánh 80 trượng, phạt tiền theo việc nặng nhẹ. Chúc thư, văn khế ấy bị xem như không có giá trị. Biết chữ thì cho phép tự viết lấy”⁷⁸. Theo quy định này điều kiện đặt ra chúc thư sẽ có hai thể thức lập: hình thức tự viết di chúc nếu biết chữ, trong trường hợp không biết chữ thì chúc thư phải do Xã trưởng viết thay và chứng kiến. Nếu không tuân thủ hình thức do pháp luật quy định thì di chúc sẽ không có giá trị pháp lý. Nhìn chung, nhà làm luật chỉ tin vào chúc thư do chính tay người để lại di sản viết hay do

⁷² Phạm Văn Tuyết, *tlđd* (số chú thích 12), tr.34.

⁷³ Nguyễn Văn Thành: *Dân luật, Luật khoa đại học Sài Gòn, Quyển 2*, tr.107 trong Đỗ Văn Đại (2019), *Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án (Tập 1)*, Nxb. Hồng Đức-Hội luật gia Việt Nam, tr.502.

⁷⁴ Trần Đại Khâm (1968), *Án lệ vưng tập*, Nhà sách Khai Trí, tr.86.

⁷⁵ Vũ Văn Mẫu (1973), *Cổ Luật Việt Nam và Tư pháp sử - Quyển 1, Tập 1*, tr.193: “Bộ Quốc Triều Hình luật được ban bố lần đầu tiên khoảng niên hiệu Hồng Đức (1470-1497) và phần chắc là vào những năm cuối cùng niên hiệu hồng Đức, dưới đời Lê Thánh Tông. Các đời vua sau chỉ cho in lại Bộ luật ấy.”

⁷⁶ Điều 388 Bộ luật Hồng Đức (được dịch từ Nguyễn Quốc Thắng (phiên âm, dịch nghĩa), Nguyễn Văn Tài (hiệu đính), *tlđd* (số chú thích 69), tr.209).

⁷⁷ Điều 390, (được dịch từ Nguyễn Quốc Thắng (phiên âm, dịch nghĩa), Nguyễn Văn Tài (hiệu đính), *tlđd* (số chú thích 69), tr.211).

⁷⁸ Điều 366 (được dịch từ Nguyễn Quốc Thắng (phiên âm, dịch nghĩa), Nguyễn Văn Tài (hiệu đính), *tlđd* (số chú thích 69), Nxb. Văn hóa thông tin, tr.200).

Xã trưởng viết và làm chứng (nếu nhờ người khác viết hộ thì chúc thư không có giá trị)⁷⁹. Đây là một quy định thể hiện rõ cách thức tạo lập di chúc bằng văn bản. Người không biết chữ trong thời kỳ nhà Lê hay trong thời kỳ phong kiến là khá phổ biến. Trong thực tế thì người không biết chữ sẽ nhờ người khác viết thay di chúc và nhờ người điếm chỉ vào nội dung văn bản, vấn đề này rất phổ biến trong thời kỳ bấy giờ. Quy định nhằm bảo vệ cho chủ thể lập di chúc là người không biết chữ, đây cũng là một quy định thể hiện tính khoa học và tiến bộ của trình độ lập pháp của nhà Lê.⁸⁰ Bởi lẽ, *“theo quan niệm cổ điển, các điều thuộc về dân luật không được nhà làm luật Đông Phương quy định. Vì vậy, trong luật Trung Hoa, không nói rõ ràng về cách soạn thảo văn tự, chúc thư... Trái lại, trong Bộ luật Hồng Đức lại quy định cách rõ ràng cách làm chúc thư.”*⁸¹. Từ những quy định cụ thể này, *“trong thời kỳ cận kim, các Tòa án Việt Nam thường hay căn cứ vào điều này để phân xử các vụ kiện”*⁸².

Nếu di chúc viết được ghi nhận những điều kiện cụ thể về hình thức lập thì di chúc miệng lại được quy định đơn giản. Ở thời kỳ này *“nhà làm luật không quy định các điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực pháp lý như thời điểm lập di chúc, người làm chứng, thủ tục...”*⁸³ và chỉ đơn giản cho phép cha, mẹ được để lại di sản cho đời sau thông qua lời nói bằng việc xác định là “lệnh” của cha, mẹ.

So với thời Lê, Bộ luật Gia Long (Hoàng Việt luật lệ) dưới thời nhà Nguyễn có rất ít chế định liên quan đến thừa kế. Nhìn chung, Hoàng Việt luật lệ (Bộ luật Gia Long) và luật thừa kế dưới thời nhà Nguyễn trên tinh thần kế thừa luật triều Lê. Những nguyên tắc về quan hệ tài sản và thừa kế cơ bản vẫn không khác nhiều so với thời Lê trước đó⁸⁴. Nguyên nhân *“vì quá vọng ngoại, nhà làm luật Triều Nguyễn đã chép lại gần đúng nguyên văn của Bộ luật nhà Mãn Thanh. Mặc dầu, Bộ Hoàng Việt luật lệ được ban hành nhưng dân chúng vẫn tiếp tục sống theo cổ tục; các tục lệ về giá thú, các chứng thư như chúc thư, phân sản, mua bán đều làm theo các mẫu có từ triều Lê để lại”*⁸⁵. Do vậy Trong Bộ Hoàng Việt luật lệ không còn những điều khoản liên quan đến chúc thư⁸⁶.

Có thể xác định, di chúc được ghi nhận ở pháp luật thời kỳ phong kiến nhà Lê, nhà Nguyễn dưới hai hình thức là: di chúc viết và di chúc miệng. Trong đó, di chúc viết được quy định cụ thể với những điều kiện về chữ viết, về người lập di chúc, về

⁷⁹ Trần Quang Trung (2010), *Nhận diện quyền dân sự trong Bộ luật Hồng Đức*, Nxb. Lao động, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.108.

⁸⁰ Phạm Thị Minh Trang (2014), *Hình thức giao dịch dân sự theo pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, tr.23.

⁸¹ Vũ Văn Mẫu, *tlđđ* (số chú thích 75), tr.204.

⁸² Vũ Văn Mẫu, *tlđđ* (số chú thích 75), tr.204.

⁸³ Trần Quang Trung, *tlđđ* (số chú thích 79), tr.108.

⁸⁴ Hồ Thị Vân Anh (2017), *Pháp luật thừa kế thời kỳ nhà Lê, nhà Nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr.46.

⁸⁵ Vũ Văn Mẫu, *tlđđ* (số chú thích 75), tr.121.

⁸⁶ Vũ Văn Mẫu, *tlđđ* (số chú thích 75), tr.214.

người viết thay và xác nhận. Mặc dù di chúc viết lúc này mới chỉ tồn tại hai thể thức là tự viết và nhờ người viết thay, có xác nhận nhưng đây là một điểm tiến bộ trong kỹ thuật lập pháp của luật pháp thời kỳ phong kiến. Di chúc miệng đã được ghi nhận nhưng không đề cập đến các điều kiện cụ thể. Nhìn chung, hình thức di chúc được quy định phù hợp với xã hội lúc bấy giờ.

2.3.2. Quy định pháp luật về hình thức di chúc từ thời kỳ Pháp thuộc đến trước năm 1945

Pháp luật về thừa kế thời Pháp thuộc theo khuôn mẫu của BLDS Napoleon của Pháp đã quy định một cách chi tiết hơn trong Bộ Dân luật Bắc Kỳ và Hoàng Việt Trung Kỳ hộ luật (Bộ Dân luật Trung kỳ), mặc dù vậy thì Bộ Dân luật Bắc Kỳ vẫn thể hiện được những đặc thù của xã hội Việt Nam thời bấy giờ⁸⁷. Tuy nhiên, nếu nói về chúc thư, *“Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều của pháp luật Pháp. Về hình thức, chúng ta đã ghi nhận những hình thức di chúc mới như chúc thư do Chương khế lập mà tục lệ trước kia không hề biết đến; nhà làm luật Bắc Trung và các Tòa án ở Nam dựa vào nhân sự thiếu sót của luật cũ mà ấn định điều kiện về hình thức cho các chúc thư cổ truyền với ý định rõ rệt là giảm bớt tranh chấp về di sản. Kỹ thuật lập pháp tiến bộ nên nhiều chỗ thiếu sót của luật cũ đã được bổ túc”*⁸⁸. Đơn cử như theo quy định trong Bộ Dân luật Bắc kỳ di chúc bằng văn bản lúc này vẫn được sử dụng với thuật ngữ chúc thư. Chúc thư phải làm thành văn bản hoặc do viên quản lý văn khế làm ra hoặc có công chứng thị thực. Chúc thư không có viên chức thị thực phải do người lập chúc thư viết lấy và ký tên. Nếu người lập chúc thư đọc để người khác viết thay thì phải có ít nhất hai người thành niên làm chứng. Người làm chứng thường là Lý trưởng tại nơi trú quán của người lập chúc thư, nếu ở xa không về nơi trú quán được thì chúc thư ấy phải có sự chứng kiến của Lý trưởng nơi hiện ở của người lập chúc thư⁸⁹. Chúc thư phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập chúc thư; tên, họ, tuổi, nơi trú quán của người làm chứng. Chúc thư khi đã làm xong thì Lý trưởng đọc to cho mọi người cùng nghe rồi Lý trưởng, người lập chúc thư, người viết hộ (nếu có) và những người làm chứng cùng ký tên vào văn bản. Nếu người lập chúc thư và các người làm chứng không biết chữ thì Lý trưởng phải biên chú vào trong chúc thư⁹⁰. Có bao nhiêu người được thừa kế thì chúc thư được làm thành bấy nhiêu bản gốc để gửi cho mỗi người thừa kế một bản⁹¹. *“Khi soạn Bộ Dân luật Bắc kỳ, nhà làm luật hồi ấy đã có ý định rõ rệt là noi theo Bộ Dân luật Pháp quốc nhằm giảm bớt sự dễ dãi trong việc lập chúc thư nhưng cũng*

⁸⁷ Nguyễn Thị Khánh Huyền (2016), *Đặc trưng cơ bản của Bộ Dân luật Bắc Kỳ 1931*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.83.

⁸⁸ Vũ Văn Hiền (1960), *Chế độ tài sản trong gia đình Việt Nam, tập 2 – Di sản (quyển 3)*, Bộ Quốc gia giáo dục xuất bản, tr.325.

⁸⁹ Điều 326 Bộ Dân luật Bắc kỳ.

⁹⁰ Điều 325 Bộ Dân luật Bắc kỳ.

⁹¹ Điều 328 Bộ Dân luật Bắc kỳ

không quay về sự khắt khe của các án lệ trước năm 1899.”⁹² Trong Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật, chúc thư được quy định từ Điều 315 đến Điều 319 về thể thức lập cũng như sự tham gia người viết hộ và Lý trưởng tương tự như quy định trong Bộ Dân luật Bắc kỳ.

Các quy định trong Bộ Dân luật Bắc kỳ cũng như Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật mang tính chặt chẽ về trình tự và các điều kiện (người làm chứng, vấn đề sao chép, thay đổi di chúc) khi lập di chúc viết.⁹³ Những thể lệ của hai Bộ Dân luật Bắc kỳ và Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật thì luật và lệ áp dụng ở miền Nam về cơ bản cũng không khác biệt⁹⁴.

Mặt khác, Bộ Dân luật Bắc kỳ cũng như Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật không quy định về di chúc miệng chỉ quy định về di chúc viết (chúc thư). Ở miền Nam, Bộ Dân luật Nam kỳ và các án lệ cũng không ghi nhận di chúc miệng. Dưới ảnh hưởng của dân luật Pháp, pháp luật thời kỳ Pháp thuộc ở Việt Nam đã bỏ hẳn cách lập chúc thư bằng miệng hay chúc thư khẩu truyền⁹⁵. Do đó, *“không những phải có chúc thư viết vào giấy làm bằng, mà chúc thư còn lại phải làm theo những nghi thức nhất định đã nói từ Điều 323 đến Điều 328 của Bộ Dân luật Bắc kỳ. Trên thực tế khi xét xử, Tòa án không ghi nhận di chúc miệng nếu không có chúc thư.”*⁹⁶

Như vậy ở giai đoạn Pháp thuộc đến trước năm 1945, chúc thư được quy định trong Bộ Dân luật Bắc kỳ và Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật mang tính chất trọng thức, phải đúng hình thức luật định thì chúc thư mới có hiệu lực.⁹⁷ Ở miền Nam mặc dù các án lệ được ghi nhận rộng rãi hơn so với Bắc kỳ và Trung kỳ nhưng cũng chỉ tồn tại chúc thư mà không có di chúc miệng. Đây cũng là đặc trưng của pháp luật về hình thức di chúc trong thời kỳ Pháp thuộc do luật dân sự nói chung và thừa kế nói riêng chịu nhiều ảnh hưởng từ luật dân sự và luật thừa kế của Pháp.

2.3.3. Quy định pháp luật về hình thức di chúc từ sau năm 1945 đến trước khi có Bộ luật Dân sự 1995

Vào những năm 1945, giai đoạn đầu khi đất nước giành được độc lập, dấu mốc quan trọng là ngày tuyên bố độc lập (02/9/1945) thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, vào ngày

⁹² Huỳnh Công Bá, *tlđđ* (số chú thích 70), tr.581.

⁹³ Trần Đại Khâm, *tlđđ* (số chú thích 74), tr.90. Trong một vụ việc Tòa án xử một chứng thư ở đầu đề rằng “tờ phân gia tài..” rồi sau lại viết “tôi là...lập tờ di chúc...” thì không thể xem như một tờ phân sản lúc sinh thời tổ phụ vì không có Chương khế hay Lý trưởng thị thực và không có chữ ký của con trai, con gái (theo Điều 395 Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật). ...Như vậy chứng thư ấy chỉ có tính cách và hiệu lực của một chúc thư viết tay (theo Điều 319 đoạn 2 của Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật) (Tòa án Huế 6/7/1955 trong Pháp lý tập san năm 1955 số III, tr.38).

⁹⁴ Phan Văn Thiết (1961), *Dân luật tu tri*, Nhà sách Khai Trí, tr.161.

⁹⁵ Huỳnh Công Bá, *tlđđ* (số chú thích 70), tr.583.

⁹⁶ Trần Đại Khâm, *tlđđ* (số chú thích 74), tr.86, 87. Trong vụ án Tòa án xác định không có chúc thư làm bằng chứng thì một người em không thể nại chứng để bày tỏ con mình đã được người chết dối lại cho một phần di sản chẳng hạn một số ruộng (theo án sơ thẩm Hà Nội ngày 15/6/1951 trong Pháp lý tập san năm 1951 số IV, tr.73).

⁹⁷ Vũ Văn Hiền, *tlđđ* (số chú thích 88), tr.335.

10/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh 47/SL cho phép tạm thời sử dụng một số luật lệ hiện hành ở Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ để điều chỉnh các vấn đề về dân sự. Với Sắc lệnh trên, các BLDS ban hành trong thời kỳ Pháp thuộc được tiếp tục thi hành nếu *"những luật lệ ấy không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt Nam và chính thể dân chủ cộng hòa"*⁹⁸. Vào giai đoạn này, bản Hiến Pháp đầu tiên của Việt Nam được ban hành, Hiến Pháp 1946 được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua ngày 9/11/1946. Hiến pháp năm 1946 đã ghi nhận nhiều điều luật quan trọng trong lĩnh vực dân sự tại Chương 2 về “Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân”. Để phù hợp với hoàn cảnh mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều Sắc lệnh và trong lĩnh vực dân sự Sắc lệnh 97/SL ngày 22/5/1950 về “Sửa đổi một số quy định và chế định trong Luật Dân sự” được ký và ban hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ dân sự phát sinh trong đời sống xã hội. Khi ban hành Sắc lệnh này thì những Bộ luật được ban hành trước đó ở ba miền Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ vẫn được giữ lại nhưng những quy định nào trái với nguyên tắc trong Sắc lệnh thì bị bãi bỏ. Về vấn đề thừa kế vẫn được giữ lại quy định như trong Bộ luật của ba miền trước đó. Như vậy, trong giai đoạn này hình thức di chúc vẫn chỉ được ghi nhận di chúc viết.

Bắt đầu từ năm 1959, việc áp dụng ba Bộ Dân luật được chấm dứt hoàn toàn bởi Chỉ thị 772/CT-TATC ngày 10/7/1959 về vấn đề đình chỉ áp dụng luật pháp cũ của đế quốc và phong kiến. Việc giải quyết quan hệ thừa kế chủ yếu dựa vào các văn bản pháp luật như Sắc lệnh số 97/SL ngày 22/05/1950 sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959, Quyết định số 115/QĐ ngày 08/03/1965 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các văn bản pháp luật trên có một số quy phạm điều chỉnh quan hệ thừa kế nhưng chủ yếu là thừa kế theo pháp luật, còn thừa kế theo di chúc, hình thức di chúc chưa được quy định rõ ràng.

Ở miền Nam, Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972 cũng chỉ ghi nhận di chúc viết và được lập dưới ba thể thức là chúc thư tự tả, chúc thư công chính và chúc thư bí mật.⁹⁹ Trong đó chúc thư tự tả là chúc thư do chính người để lại di sản viết, còn chúc thư công chính là chúc thư được lập trước mặt Chứng khế hay chúc thư được nhà chức trách có thẩm quyền thị thực. Chúc thư bí mật là sự kết hợp pha trộn của hai loại chúc thư trên, đây là chúc thư do người để lại di sản tự tay viết nhưng có xác nhận của Chứng khế trước mặt hai nhân chứng.¹⁰⁰ Trong Bộ luật còn đề cập đến điều kiện của người làm chứng để đảm bảo tính khách quan trong quá trình làm chứng¹⁰¹. Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972 chịu nhiều ảnh hưởng bởi BLDS của Pháp do đó hình

⁹⁸ Chương 2 Sắc lệnh 47/SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

⁹⁹ Điều thứ 573 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972.

¹⁰⁰ Điều thứ 574-578 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972.

¹⁰¹ Điều thứ 579 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972.

thức di chúc cũng tương tự như pháp luật của Pháp với việc ghi nhận chúc thư bí mật và không quy định về di chúc miệng.

Đến khi đất nước thống nhất kể từ Thông tư số 81/TT-TANDTC ngày 24/7/1981 Thông tư của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử các tranh chấp thừa kế (TT 81/TT-TANDTC), Pháp lệnh thừa kế 1990 (PLTK) đã kế thừa và quy định rất cụ thể về các loại di chúc bằng văn bản và bằng miệng với những điều kiện, trình tự, thủ tục rất chi tiết. Các quy định mang tính chất ngày càng hoàn thiện, tiến bộ so với các văn bản trước đó.

Quy định trong TT 81/TT-TANDTC về di chúc bằng văn bản được sử dụng với thuật ngữ “di chúc viết” thay cho thuật ngữ “chúc thư” đã được sử dụng trong các văn bản ở những giai đoạn trước đó, có thể thấy đây là sự nhấn mạnh về thể thức lập di chúc phải được viết tay. Tuy nhiên quy định trong TT chưa gọi tên từng loại hình di chúc viết và nếu dựa vào các điều kiện đặt ra thì có thể thấy trong TT 81/TT-TANDTC có các loại di chúc viết sau đây: *“(i) Di chúc viết phải...được chính quyền địa phương xác nhận. (ii) Trong trường hợp đặc biệt, di chúc có thể do cơ quan, đơn vị nơi đương sự làm việc xác nhận. (iii) Nếu người có tài sản đang đi trên phương tiện giao thông hay đang ở trong một cơ sở chữa bệnh mà gặp tình huống phải cấp bách lập di chúc thì sự chứng nhận của người phụ trách của phương tiện giao thông hay cơ sở chữa bệnh cũng được coi là hợp lệ.”* Đây là những di chúc được lập phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người phụ trách phương tiện, cơ sở chữa bệnh. Đối với những di chúc không cần sự chứng nhận thì cần có người làm chứng bảo đảm, hoặc xác định được di chúc đó đúng là do người có di sản tự nguyện lập ra (như đúng là chữ viết và chữ ký của người có di sản, thời gian và địa điểm ghi trong di chúc cũng phù hợp...) thì cũng có giá trị. Quy định trong TT 81/TT-TANDTC mang tính liệt kê và tùy từng loại hình di chúc viết mà điều kiện là khác nhau. Nhưng về cơ bản hầu như đều cần có một người thứ ba đứng ra làm chứng xác nhận cho di chúc, trừ khi di chúc do người lập di chúc tự viết.

Đối với di chúc miệng, TT 81/TT-TANDTC đã đề cập đến điều kiện về người làm chứng¹⁰². Mặc dù không nói rõ là mấy người làm chứng, tuy nhiên đây cũng là một điểm tiến bộ khi đã đặt ra điều kiện của di chúc miệng. Việc bổ sung điều kiện người làm chứng để đảm bảo tính khách quan trong quá trình lập di chúc và là căn cứ chứng minh tính xác thực của di chúc miệng.

Đến khi có PLTK thì quy định trong PLTK vẫn sử dụng thuật ngữ di chúc viết, tuy nhiên đã có sự phân loại rõ về các loại di chúc viết và thủ tục để lập các loại di chúc này. Cụ thể bao gồm di chúc viết được cơ quan công chứng hoặc UBND chứng thực; di chúc viết được cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực; di chúc viết có giá trị như di chúc được chứng thực và di chúc viết

¹⁰² TT 81/TT-TANDTC: phần IV - A “Nếu là di chúc miệng thì phải có người làm chứng bảo đảm”.

không có chứng thực, xác nhận. Đối với mỗi loại hình di chúc viết sẽ cần có những điều kiện riêng về trình tự lập di chúc. Ngoài ra, PLTK cũng quy định về nhóm đối tượng đặc biệt như người lập di chúc không đọc, không ký hoặc điểm chỉ được bản di chúc; người Việt Nam ở nước ngoài hoặc những người đang trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt (quân nhân, người bị tạm giam, người đang điều trị bệnh...) sẽ có thể lập di chúc trong những hoàn cảnh đó với sự trợ giúp. Trong PLTK đã có quy định đến điều kiện của người không được chứng thực, xác nhận di chúc, chứng kiến việc chứng thực di chúc tại Điều 19. Quy định trong PLTK về hình thức di chúc bằng văn bản đang dần hoàn thiện hơn các văn bản giai đoạn trước đó. PLTK đã có sự phân loại rõ về các hình thức di chúc bằng văn bản và điều kiện của người hỗ trợ cho việc lập di chúc là người làm chứng di chúc.

Đối với di chúc miệng, PLTK quy định cụ thể, rõ ràng và chặt chẽ hơn về hoàn cảnh lập di chúc miệng. Bởi lẽ theo tục lệ từ xa xưa, di chúc miệng trên thực tế chỉ sử dụng trong hoàn cảnh cần thiết, khi con người cận kề cái chết và cần phải ngay lập tức trình bày mong muốn, suy nghĩ của họ về vấn đề tài sản. Tuy nhiên các văn bản trước đó lại không thể hiện được điều kiện này và chỉ đến PLTK mới đề cập đến hoàn cảnh được lập di chúc miệng. Xét theo điều kiện được nêu trong PLTK có thể thấy di chúc miệng được xem là loại hình di chúc mang tính chất trừ bị cho di chúc bằng văn bản. Để có thể lập di chúc miệng, người để lại di sản phải trong tình trạng tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng và không thể lập di chúc bằng văn bản. Người để lại di sản có thể bị bệnh tật hiểm nghèo trong lúc hấp hối hoặc trong hoàn cảnh bị tai nạn, bệnh tật mà ở những nơi xa xôi hẻo lánh không có điều kiện để có thể lập di chúc bằng văn bản. Mặc dù vậy, so với TT 81/TT-TANDTC thì yêu cầu có người làm chứng bị hủy bỏ tại PLTK. Quy định trong PLTK không nói rõ về điều kiện cần phải có người làm chứng mà chỉ nhấn mạnh ở chứng cứ để chứng minh di chúc đó đúng do người để lại di sản để lại và người này lập khi còn sống, minh mẫn, sáng suốt là được. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 18 PLTK *“Sau ba tháng kể từ ngày lập di chúc miệng, nếu người lập di chúc còn sống và minh mẫn, thì coi như di chúc miệng đó bị hủy bỏ”*. Quy định này để xác định đúng tính chất của di chúc miệng là loại hình di chúc mang tính chất dự phòng, khi không thể lập di chúc bằng văn bản. Do vậy, nếu sau này tình trạng kia đã mất đi, người để lại di sản đã có thể lập di chúc bằng văn bản thì di chúc miệng bị hủy bỏ.

Có thể nhận định pháp luật về hình thức di chúc ở giai đoạn này thể hiện rõ đặc trưng của xã hội Việt Nam. Pháp luật về hình thức di chúc ở giai đoạn từ sau năm 1945 kế thừa quy định trong pháp luật ở giai đoạn phong kiến khi quay trở lại ghi nhận hình thức di chúc miệng. Thừa nhận hình thức di chúc miệng là sự ghi nhận lại phong tục tập quán của người Việt Nam mà giai đoạn pháp luật thời kỳ Pháp thuộc đã loại bỏ. Mặt khác, những thể thức lập di chúc viết mang tính đa dạng với nhiều loại hình cho

những chủ thể ở vào những hoàn cảnh khác nhau có thể lựa chọn để lập di chúc. Mặt khác, pháp luật ở giai đoạn này đã ghi nhận cụ thể điều kiện của người làm chứng để đảm bảo tính khách quan trong quá trình làm chứng di chúc.

2.3.4. Quy định pháp luật về hình thức di chúc từ khi có Bộ luật Dân sự 1995 đến nay

BLDS đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1995 có hiệu lực ngày 1/7/1996 sử dụng thuật ngữ “di chúc bằng văn bản” thay cho thuật ngữ “di chúc viết” trong PLTK. Điều này không chỉ là sự thay thế từ ngữ mà còn mở rộng hơn loại hình của di chúc không chỉ được viết ra mà còn có thể được đánh máy và in ra. Lúc này các loại di chúc bằng văn bản theo Điều 628 BLDS 1995 được liệt kê như sau: *“Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn; Di chúc bằng văn bản có chứng nhận của công chứng nhà nước.”*. Quy định về từng loại di chúc bằng văn bản đã có sự cụ thể với những điều kiện chi tiết hơn so với quy định trong PLTK. Đặc biệt đối với những nhóm đối tượng đặc thù như người bị hạn chế về thể chất, người không biết chữ, người không thể tự mình viết di chúc, người không đọc được, không nghe được sẽ luôn luôn phải lập di chúc theo một hình thức định sẵn mà không có sự lựa chọn nào khác. Quy định này không phải không cho những người trong nhóm đối tượng đặc biệt có quyền tự quyết định loại hình di chúc họ sẽ lập mà hướng đến bảo vệ chính ý chí của họ, tránh việc bị giả mạo, bị lừa dối khi lập di chúc. Điểm khác biệt khá rõ khi so sánh quy định trong BLDS 1995 so với PLTK đó chính là nhóm đối tượng người chưa thành niên được lập di chúc. Trong quy định của PLTK cho phép người từ đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nếu thỏa mãn các điều kiện kèm theo, tuy nhiên lại không quy định về hình thức di chúc được lập. Vậy nếu họ rơi vào các trường hợp được lập di chúc miệng thì nhóm đối tượng này sẽ vẫn được lập di chúc miệng. Tuy nhiên quy định trong BLDS 1995 lại có xác định rõ người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nếu lập di chúc thì phải lập di chúc bằng văn bản bên cạnh các điều kiện khác. Ngoài ra, cũng trên cơ sở phát triển những quy định từ PLTK quy định về người làm chứng đã mở rộng hơn phạm vi áp dụng đối với những đối tượng không được là người làm chứng so với trước đây.

Về cơ bản những quy định của PLTK phù hợp với thực tế đời sống, do đó chế định thừa kế trong BLDS 1995 đã kế thừa hầu hết các quy định của PLTK và tương tự đối với quy định về di chúc miệng. Quy định trong BLDS 1995 về điều kiện để lập di chúc và trường hợp di chúc miệng bị hủy bỏ về cơ bản là giống với PLTK. Nhưng BLDS 1995 còn quy định rõ hơn về *“việc gây đe dọa tính mạng một cá nhân mà họ không thể làm di chúc bằng văn bản đó là do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác”*¹⁰³. BLDS 1995 quy định mang tính chất giải thích và liệt kê rõ hơn hoàn cảnh vì sao

¹⁰³ Khoản 1 Điều 654 BLDS 1995.

người để lại di sản không thể lập di chúc bằng văn bản. Ngoài ra, quy định trong BLDS 1995 còn là sự kết hợp của quy định trong PLTK và TT 81/TT-TANDTC về các điều kiện lập di chúc miệng. Quy định của BLDS 1995 bổ sung yêu cầu số lượng người làm chứng là ít nhất hai người và những người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Ta thấy rằng, BLDS 1995 đã có những quy định hoàn thiện hơn so với các văn bản trước đó về điều kiện lập di chúc miệng. Cũng theo BLDS 1995, di chúc miệng sẽ bị hủy bỏ sau ba tháng kể từ ngày lập mà người lập di chúc vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn sáng suốt¹⁰⁴. Việc bổ sung này nhằm làm rõ điều kiện để một di chúc miệng được hủy bỏ và không có giá trị pháp lý¹⁰⁵. Tuy nhiên BLDS 1995 không quy định thủ tục để hủy bỏ và ai có quyền tuyên bố hủy bỏ di chúc miệng đó.

Khi tiến hành sửa đổi, bổ sung BLDS 1995 và đến ngày 1/1/2006, BLDS được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực. BLDS 2005 về cơ bản quy định về hình thức di chúc bằng văn bản không khác so với quy định trong BLDS 1995 mà chỉ có một sự thay đổi nhỏ ở di chúc bằng văn bản có công chứng. Quy định trong BLDS 1995 xác định cơ quan công chứng Nhà nước nhưng đến BLDS 2005 đã có Luật công chứng 2006¹⁰⁶ quy định văn phòng công chứng và phòng công chứng, do đó BLDS 2005 đã sửa đổi cho phù hợp với Luật Công chứng, không còn sử dụng thuật ngữ công chứng Nhà nước mà thay vào đó là thuật ngữ cơ quan công chứng.

BLDS 2005 quy định về di chúc miệng cũng trên cơ sở sự kế thừa quy định trong BLDS 1995 về hoàn cảnh lập di chúc miệng, về người làm chứng và về vấn đề ghi chép lại di chúc miệng. Tuy nhiên, quy định trong BLDS 2005 có bổ sung về thời điểm ghi chép lại di chúc miệng, yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc và thời gian cho phép công chứng, chứng thực di chúc để tăng cường tính xác thực cho bản di chúc. Về vấn đề ghi chép lại di chúc miệng phải là ngay sau khi người để lại di sản thừa kế thể hiện ý chí của họ, người làm chứng phải ghi chép lại ngay. Quy định này nhằm đảm bảo việc chuyển tải ý chí của người để lại di sản vào bản di chúc được chính xác nhất. Về thời hạn để là yêu cầu công chứng, chứng thực là trong thời gian năm ngày kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. BLDS 2005 xác định chính xác khoảng thời gian mà người làm chứng phải công chứng, chứng thực di chúc miệng là “*năm ngày, sau khi người di chúc miệng thể ý chí cuối cùng*”. Với thủ tục chặt chẽ này, việc lập di chúc miệng sẽ bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao hơn, ngăn ngừa sự thể hiện ý chí chủ quan của người làm chứng và đồng thời tăng cường trách nhiệm của người làm chứng di chúc. Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 651 BLDS 2005 đã bổ sung cụm từ “mặc nhiên” so

¹⁰⁴ Khoản 1 Điều 654 BLDS 1995.

¹⁰⁵ Lê Thị Danh (2009), *Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, tr.48.

¹⁰⁶ Điều 23 Luật Công chứng 2006.

với BLDS 1995 làm cho điều luật trở nên rõ nghĩa hơn. Theo BLDS 1995, di chúc miệng sẽ bị hủy bỏ sau ba tháng kể từ ngày lập mà người lập di chúc vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn sáng suốt. Tuy nhiên BLDS 1995 không quy định thủ tục để hủy bỏ và ai có quyền tuyên bố hủy bỏ di chúc miệng đó. Việc bổ sung này nhằm làm rõ điều kiện để một di chúc miệng được hủy bỏ và không có giá trị pháp lý¹⁰⁷.

BLDS 2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017 có sự thay đổi nhiều hơn về quy định hình thức di chúc bằng văn bản. Các thay đổi có thể liệt kê đến như sau. *Thứ nhất*, đối với di chúc có người làm chứng đã mở rộng hơn về nhóm đối tượng so với BLDS 2005 và 1995. Trước kia chỉ những người không thể tự mình viết bản di chúc mới có thể lựa chọn hình thức di chúc này. Nhưng hiện nay người lập di chúc có người làm chứng có thể là bất kỳ ai, người không thể tự mình lập bản di chúc hay người có thể tự mình lập bản di chúc nhưng vì lý do nào đó họ có thể không muốn tự mình lập mà thông qua người viết hộ di chúc và có người làm chứng cho việc lập di chúc. *Thứ hai*, đối với quy định về người làm chứng đã có sự thay đổi về nhóm đối tượng để mang tính bao quát hơn và không bị trùng lặp giữa các các nhóm đối tượng không được là người làm chứng.

Quy định trong BLDS 2015 về di chúc miệng vừa có sự bổ sung, vừa có sự tinh gọn lại mang tính giản lược cho điều luật phù hợp hơn về thực tiễn áp dụng di chúc miệng. Đối với hoàn cảnh lập di chúc miệng, quy định trong BLDS 2015 dường như quay trở lại quy định trong PLTK, quy định một cách rất khái quát “*Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng*”¹⁰⁸. Về vấn đề công chứng, chứng thực thì có sự thay đổi cho phù hợp hơn với thực tiễn “*Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng*”¹⁰⁹. Thời hạn đi công chứng, chứng thực vẫn còn là 5 ngày nhưng là 5 ngày làm việc thì sẽ là phù hợp và được kéo dài hơn so với quy định trước đây. Thời hạn dài hơn tạo sự chủ động và linh hoạt cho những người làm chứng khi họ sẽ sắp xếp thời gian, công việc để đi công chứng, chứng thực di chúc miệng. Mặt khác, quy định đã chỉ rõ hơn mục đích của việc đi công chứng, chứng thực là công chứng, chứng thực để xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người làm chứng. Thật vậy, nội dung di chúc đã được người để lại di sản thể hiện ra bằng lời nói và được người làm chứng ghi chép lại vào văn bản. Trong quá trình ghi chép lại không có công chứng viên hay người có thẩm quyền chứng thực chứng kiến. Do vậy, khi yêu cầu công chứng, chứng thực thì không thể yêu cầu xác nhận nội dung trong bản di chúc đó được. Trường hợp có yêu cầu thì công chứng viên

¹⁰⁷ Lê Thị Danh, *tlđd* (số chú thích 105), tr.48.

¹⁰⁸ Khoản 1 Điều 629 BLDS 2015.

¹⁰⁹ Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

hoặc người có thẩm quyền chứng thực chỉ xác nhận có đúng là chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng hay không. Đối với sự hủy bỏ của di chúc miệng, quy định trong BLDS 2015 không có sự thay đổi so với BLDS trước đó.

Có thể nhận định trong giai đoạn áp dụng BLDS 1995, 2005 và 2015 đã cho thấy sự phát triển của pháp luật về hình thức khi ghi nhận đầy đủ và phù hợp với xã hội về các loại hình thức di chúc bằng văn bản cũng như điều kiện của từng hình thức di chúc bằng văn bản và bằng miệng. Quy định trong BLDS là sự kế thừa và có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung so với các quy định trước đó cho pháp luật về hình thức di chúc được hoàn thiện hơn và phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống.

Kết luận: Theo tiến trình lịch sử lập pháp của pháp luật Việt Nam, các quy định pháp luật về hình thức di chúc luôn có sự kế thừa và thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của xã hội và văn hóa của người Việt Nam. Sự phát triển này nhằm hướng đến bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người để lại di sản, người thừa kế và ổn định các quan hệ thừa kế. Do vậy khi đánh giá những hình thức di chúc trong tương lai, tác giả cho rằng khi xã hội phát triển mạnh về công nghệ thì di chúc được lập và lưu giữ trên các phương tiện điện tử dần dần sẽ thông dụng và được ghi nhận bên cạnh những hình thức di chúc truyền thống với những điều kiện về chữ ký điện tử, người làm chứng, cách lưu giữ trên thiết bị điện tử được đặt ra để đảm bảo di chúc vẫn là phương tiện để ghi nhận và lưu giữ chính xác ý chí của người để lại di sản. Bên cạnh đó, đối với những hình thức di chúc truyền thống thì điều kiện đặt ra có thể sẽ thay đổi cho phù hợp. Pháp luật hiện đại nên đảm bảo vai trò của hình thức di chúc là phương thức ghi nhận, lưu giữ và xác thực ý chí của người lập di chúc nên không thể để hình thức di chúc ảnh hưởng đến di chúc. Nếu xem xét hình thức di chúc chính là phương thức lưu giữ ý chí của người lập di chúc thì khi có bằng chứng chứng minh ý chí của người để lại di sản đã được ghi nhận chính xác thì hình thức di chúc được luật quy định nên được quy định linh hoạt hơn cũng như mở rộng ghi nhận thêm hình thức di chúc mới, bổ sung người có thẩm quyền xác nhận di chúc.

2.4. Cơ sở để pháp luật quy định về hình thức di chúc

2.4.1. Phong tục tập quán, đặc điểm riêng biệt của xã hội từng thời kỳ

*“Luật pháp nảy sinh từ lịch sử và phát triển theo tiến trình riêng. Trong các xã hội tiền quốc gia, tập quán pháp giữ vai trò thống trị. Tục lệ mang sức mạnh xuyên suốt lịch sử. Sau này tập quán pháp còn ảnh hưởng tới cả những Bộ luật được soạn thảo trong các thời kỳ Nhà nước đã ra đời.”*¹¹⁰ Do đó có thể nói *“pháp luật phản ánh các quy phạm xã hội, tức là pháp luật chịu sự tác động nhất định từ các quy phạm đạo đức, phong tục tập quán, quy phạm tôn giáo...”*¹¹¹. *“Luật pháp thường là các quy tắc xử sự được khái quát hóa từ tập tục, thói quen của cộng đồng người, được hình thành,*

¹¹⁰ Viện Đông Nam Á (1995), *Một số luật tục và luật cổ ở Đông Nam Á*, Nxb. Văn hóa thông tin, tr.5.

¹¹¹ Phan Trung Hiền, *tlđd* (số chú thích 23), tr.53.

*tuân thủ qua nhiều thế hệ và được Nhà nước pháp điển hóa thành pháp luật. Do đó, sự phát triển của pháp luật không thể tách rời khỏi phong cách sống và truyền thống của dân tộc.*¹¹² Pháp luật Việt Nam là sự ghi nhận một cách rõ nét những đặc trưng, phong tục tập quán, bản sắc của người Việt Nam đặc biệt đối với quan hệ thừa kế. Một trong những yếu tố này chính là nền tảng gia đình truyền thống có tôn ti, trật tự để xây dựng quy phạm pháp luật về thừa kế. Trong quan hệ thừa kế việc xác định hàng thừa kế, diện thừa kế theo pháp luật, di sản thờ cúng, di chúc chung của vợ, chồng hay cả các quy định về hình thức di chúc đều thể hiện ảnh hưởng của phong tục tập quán.

Phải khẳng định rằng pháp luật luôn có tính kế thừa và tính truyền thống của dân tộc. Do vậy yếu tố phong tục tập quán ảnh hưởng đến quy định pháp luật về hình thức di chúc rất rõ nét. *“Ở giai đoạn luật cổ, Việt Nam công nhận cả việc lập di chúc bằng miệng và bằng giấy tờ”*¹¹³. Điều đó có nghĩa, di chúc được lập bằng văn bản và bằng miệng đã được ghi nhận từ rất lâu. Yếu tố phong tục tập quán thể hiện rõ nét ở việc ghi nhận hình thức di chúc miệng. Đã có quan điểm khẳng định rằng *“BLDS Việt Nam quy định hình thức di chúc miệng là sự thể hiện pháp luật nước ta đã ghi nhận một tập tục vốn là truyền thống từ lâu đời của dân tộc”*¹¹⁴. Và *“theo tục lệ xưa kia, cá nhân có thể đối miệng lại những ý muốn sau cùng, chẳng hạn để phân chia của cải, trước khi chết”*¹¹⁵. Một người trước khi chết sẽ bằng lời nói của mình để căn dặn lại việc chuyển giao tài sản cho những người mà họ mong muốn để lại. Di chúc miệng lúc này đúng nghĩa là di ngôn tức là chỉ thông qua lời nói để truyền đạt mong muốn định đoạt tài sản đến những người được hưởng tài sản và những người khác trong gia đình. Đến thời kỳ phong kiến nhà Lê, quy định trong Bộ luật Hồng Đức về di chúc miệng vẫn là sự ghi nhận phong tục tập quán truyền đạt lại ý nguyện định đoạt tài sản của cha, mẹ thông qua mệnh lệnh của họ mà không đề cập đến điều kiện ghi chép lại¹¹⁶. Như vậy có thể thấy quy định về hình thức di chúc trong thời kỳ nhà Lê đã phản ánh được sự kế thừa về hình thức di chúc từ luật cổ khi vẫn tiếp tục ghi nhận hai hình thức di chúc là bằng văn bản và bằng miệng. Mặt khác, hình thức di chúc miệng là hình thức di chúc được ghi nhận dựa trên phong tục truyền miệng thể hiện mong muốn của một người trước khi chết để chuyển giao tài sản cho con cháu đời sau.

¹¹² Phạm Duy Nghĩa (2004), *Chuyên khảo Luật kinh tế*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.7, 8.

¹¹³ Nguyễn Văn Thành, *Dân luật, Luật khoa Đại học Sài Gòn, Quyển 2*, tr.107 trong Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.588.

¹¹⁴ Phạm Văn Tuyết (2007), *Thừa kế quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng*, Nxb. Chính trị quốc gia, tr.165.

¹¹⁵ Trần Đại Khâm, *tlđđ* (số chú thích 74), tr.86.

¹¹⁶ Điều 388 Bộ luật Hồng Đức (được dịch từ Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Tá Nhí (dịch nghĩa), *Quốc Triều Hình Luật (Bộ luật Hồng Đức)*, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, tr.152 “Cha mẹ mất cả, có ruộng đất, chưa kịp để lại chúc thư, mà anh chị em tự chia nhau thì lấy một phần 20 số ruộng đất làm phần hương hỏa...Nếu đã có lệnh của cha mẹ và chúc thư, thì phải theo đúng, trái thì mất phần mình”). Quy định không đặt ra điều kiện cho di chúc miệng mà chỉ xác định di chúc miệng ở giai đoạn này được gọi là “lệnh” do cha mẹ đặt ra để phân chia tài sản trước khi chết.

Bên cạnh yếu tố phong tục tập quán, mỗi một xã hội ở mỗi quốc gia có một đặc điểm riêng biệt về con người, về những yếu tố khách quan như điều kiện tự nhiên, văn hóa. Tất cả những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng các quy phạm pháp luật. Bởi vì pháp luật là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, pháp luật được vai trò to lớn của nó, pháp luật phải hiện thực hóa vào đời sống. Bởi lẽ *“xây dựng pháp luật được vận hành nhờ các chất liệu đa dạng từ cuộc sống, chịu sự tác động nhiều chiều từ các khía cạnh, yếu tố khác nhau trong xã hội. Từ các yếu tố chung như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bối cảnh quốc tế, ý thức pháp luật, truyền thống lịch sử cho đến các yếu tố trực tiếp như: tổ chức, năng lực, kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo, phạm vi, tính chất, đối tượng điều chỉnh...hoạt động xây dựng pháp luật, đến lượt mình, cũng tác động trở lại mạnh mẽ đến các khía cạnh xã hội.”*¹¹⁷ Hoạt động xây dựng pháp luật và xã hội có mối quan hệ biện chứng qua lại với sự tác động và hỗ trợ nhau để đảm bảo điều chỉnh được các quan hệ trong xã hội nhằm đạt được mục đích mà các nhà làm luật đã đề ra. Do đó xã hội càng phát triển thì những đặc điểm riêng biệt của xã hội sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quy phạm pháp luật.

Đặc điểm riêng biệt của xã hội là tổng hợp tất cả những đặc trưng về mặt khách quan như các điều kiện tự nhiên, chính trị và những đặc trưng về mặt chủ quan như yếu tố con người, văn hóa ở những vùng miền, lãnh thổ khác nhau và trong từng giai đoạn xã hội khác nhau. Tác động của các đặc điểm riêng biệt của xã hội ảnh hưởng rõ ràng đến việc xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc.

Ở các quốc gia khác nhau, pháp luật về hình thức di chúc cũng sẽ có những điều kiện về hoàn cảnh lập di chúc, thể thức lập di chúc và trình tự, thủ tục lập di chúc là khác nhau. Việt Nam có hình thức di chúc bằng văn bản có chứng thực bởi người có thẩm quyền chứng thực của UBND. Đây là hình thức di chúc các quốc gia khác không có do sự khác biệt về cơ cấu tổ chức, vai trò, chức năng của cơ quan quản lý hành chính ở Việt Nam so với các nước. Việt Nam chưa ghi nhận di chúc được lập trên các phương tiện điện tử nhưng một số quốc gia như Mỹ, Úc, Canada đều đã ghi nhận hình thức di chúc này. Sự ghi nhận hay không ghi nhận di chúc điện tử, nên ghi nhận vào thời điểm nào cho phù hợp đều chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt về đặc điểm riêng biệt của xã hội. Ở Mỹ, Úc, Canada việc sử dụng phương tiện điện tử trong giao dịch đã là thông dụng. Việc các tổ chức công chứng công chứng các giao dịch tư cũng đã được thực hiện trên các phương tiện điện tử. Do vậy, cách khởi tạo, duy trì và xác minh tính nguyên gốc của những tài liệu được tạo lập trên các phương tiện điện tử thì họ có thể dễ dàng thực hiện được. Mặt khác, trong giai đoạn đại dịch Covid-19 diễn ra việc lập di chúc có sự chứng kiến của luật sư, người lập di chúc, người chứng thực di chúc là khó khăn và di chúc điện tử là một cách để nhiều người lập di chúc ở Mỹ có thể tạo lập

¹¹⁷ Phạm Thị Duyên Thảo (2021), “Xã hội học xây dựng pháp luật”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 10 (434), tháng 5/2021, tr.4.

di chúc của mình. Ở Việt Nam, vào thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực di chúc được lập thông qua các phương tiện điện tử vẫn chưa được xem xét đến. Điều này cũng xuất phát từ việc đối chiếu đến tình hình xã hội vào thời điểm đó. Sự thông dụng của các thiết bị điện tử được người dân sử dụng khi soạn thảo văn bản, sự hiểu biết của người dân để vận dụng thiết bị điện tử vào việc lập di chúc, vào việc sử dụng chữ ký điện tử khi lập di chúc, việc quản lý và xác thực di chúc của các tổ chức công chứng nếu di chúc được lập và lưu trữ trên các thiết bị sẽ là các yếu tố ảnh hưởng đến việc xem xét di chúc điện tử. Nhưng sau đó 10 năm, 15 năm sau với sự thông dụng của các thiết bị điện tử, điều kiện đời sống phát triển, khả năng nhận thức được nâng cao, khả năng xác thực các văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thực hiện thì di chúc được thể hiện thông qua các phương tiện điện tử là một lựa chọn phù hợp mà pháp luật nên từng bước ghi nhận.

Mặt khác, những đặc điểm riêng biệt của xã hội không chỉ là khác biệt ở lãnh thổ khác nhau mà cùng một lãnh thổ nhưng ở những giai đoạn khác nhau của xã hội cũng tạo ra sự ảnh hưởng đến pháp luật về hình thức di chúc. Những quy định về hình thức di chúc bằng văn bản và bằng miệng ở Việt Nam luôn có sự điều chỉnh cho phù hợp qua từng văn bản pháp luật trong tiến trình phát triển của xã hội. Pháp luật thời kỳ phong kiến ghi nhận di chúc bằng văn bản chỉ với hình thức tự lập (nếu biết chữ) hoặc nhờ Xã trưởng viết thay¹¹⁸. Đối với di chúc bằng văn bản trong thời kỳ phong kiến không phải ai cũng có thể lập vì giai đoạn này không phải ai cũng biết chữ¹¹⁹. Xã hội phát triển, di chúc bằng văn bản đã có thêm nhiều loại hình thức, di chúc không chỉ là những bản ghi tay được người lập di chúc hoặc người viết hộ viết mà di chúc còn có thể là những bản in được đánh máy in ra. Di chúc miệng trong thời kỳ phong kiến không đặt ra các điều kiện cụ thể chi tiết như những văn bản pháp luật sau này: về người làm chứng; về công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng; về hủy bỏ di chúc miệng nhưng pháp luật trong thời kỳ hiện đại đều có các điều kiện này.

Ở Việt Nam, việc xây dựng pháp luật dựa vào phong tục tập quán, điều kiện xã hội và tự chung lại sẽ chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh. *“Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật chứa đựng những triết lý sâu sắc về bản chất, vai trò và mối quan hệ tương đồng giữa pháp luật với các quy tắc xử sự xã hội khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, pháp luật phải gắn liền với đạo đức, việc tuân thủ pháp luật cũng có nghĩa thuận theo đạo đức, thuần phong mỹ tục của xã hội.”*¹²⁰ Do vậy, yếu tố phong tục tập quán, đặc điểm riêng biệt của xã hội ảnh hưởng rất lớn và sẽ là căn cứ để pháp

¹¹⁸ Điều 366 Bộ luật Hồng Đức (được dịch từ Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Tá Nhí (dịch nghĩa), *tlđđ* (số chú thích 116), tr.143).

¹¹⁹ Bộ Tư pháp – Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, *Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc*, Nxb. Chính trị quốc gia, tr.130, 135-137.

¹²⁰ Viên Thế Giang, Bùi Hữu Toàn (đồng chủ biên) (2020), *Giáo trình Nhập môn Luật học*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, tr.40.

luật luôn luôn phải có sự thay đổi, điều chỉnh cùng với sự phát triển của xã hội. Pháp luật không phát triển kịp sẽ kéo theo những bất cập mà không thể điều chỉnh được những quan hệ xã hội và không đảm bảo quyền tự do, dân chủ khi xã hội càng phát triển.

Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã khẳng định phải xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ quyền con người; hệ thống pháp luật phải dân chủ, đầy đủ, thống nhất... Với những tiêu chí này, việc xây dựng pháp luật phải trên cơ sở kế thừa phong tục tập quán, đánh giá đặc tính của xã hội. Đối với hình thức di chúc việc kế thừa từ những quy định trước đó là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng nhưng quy định phù hợp hơn về các điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc; bổ sung thêm hình thức di chúc mới là một bước tiến mới trong hoạt động xây dựng pháp luật. Những hướng đi này đảm bảo rằng quy định pháp luật về hình thức di chúc đang phát triển phù hợp với sự phát triển của xã hội, tôn trọng sự dân chủ trong quan hệ pháp luật về thừa kế.

2.4.2. Sự tự do ý chí của người lập di chúc

Khi xã hội có Nhà nước, có pháp luật thì pháp luật được đặt ra để điều chỉnh các ứng xử của con người theo một trật tự nhất định, đảm bảo cân bằng các quyền lợi tùy theo mong muốn của Nhà nước và của pháp luật. Trong các quyền đó có một quyền rất quan trọng của con người phải được ghi nhận và bảo vệ đó chính là quyền tự do và theo nhiều quan điểm tiến bộ, quyền tự do này được xác định là quyền tự do tự nhiên¹²¹. Quyền tự do tự nhiên con người có không bị ràng buộc bởi Nhà nước, bởi pháp luật. Do vậy, khi xây dựng pháp luật phải đảm bảo được quyền tự do của con người và quyền tự do chỉ được phép giới hạn nhằm mục đích tự bảo vệ và bảo vệ những người khác. Chính vì thế, nguyên tắc của tự do không phải ở chỗ xác định hành vi nào phải được xã hội kiểm soát mà là ở chỗ xác định rõ lĩnh vực quyền tự do cá nhân mà xã hội tuyệt nhiên không được giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào.¹²²

Trong pháp luật Việt Nam, quan hệ dân sự thể hiện rõ nét quyền tự do của các bên chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó. Chủ thể trong quan hệ dân sự được tự do tham gia vào quan hệ, được tự do xác định quyền và nghĩa vụ dân sự, tự do lựa chọn các trách nhiệm dân sự phát sinh để bảo vệ cho quyền dân sự của mình. Quyền tự do thể hiện trong quan hệ dân sự thể hiện ở nhiều khía cạnh và ở tất cả các quan hệ dân

¹²¹ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật (2011), *Văn hóa pháp luật – Những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành*, Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương (đồng chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.511.

¹²² Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật, *tlđd* (số chú thích 121), tr.182: theo quan điểm của John Stuart Mill (1806-1873), một triết gia, nhà kinh tế chính trị học người Anh, một nhà tư tưởng có ảnh hưởng đến sự phát triển lịch sử các nước Phương Tây.

sự. Pháp luật ghi nhận quyền tự do của chủ thể trong giới hạn không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác.¹²³

Khi nghiên cứu về hình thức của giao dịch dân sự, quyền tự do được thể hiện ở việc cho phép các bên được lựa chọn hình thức giao dịch dân sự phù hợp theo ý chí của họ, trừ những trường hợp luật bắt buộc phải tuân thủ quy định về hình thức. Xét về mặt lý luận, hình thức của giao dịch dân sự là sự biểu hiện, nơi chứa đựng nội dung của giao dịch dân sự - chính là sự thể hiện ý chí của chủ thể trong giao dịch dân sự. Do đó, hình thức chỉ là công cụ để lưu giữ, chứa đựng ý chí của chủ thể. Hình thức của giao dịch dân sự không là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của giao dịch dân sự và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp luật có quy định khác. Những giao dịch dân sự mà luật bắt buộc phải tuân thủ quy định về hình thức nhằm đảm bảo hệ thống quản lý hành chính Nhà nước và bảo vệ quyền lợi của chủ thể trong giao dịch dân sự.

Đối với quan hệ hợp đồng, *“trên thực tế, không có hệ thống pháp luật dân sự nào ghi nhận sự tự do tuyệt đối về hình thức của hợp đồng. Trong cổ luật Việt Nam, một số hợp đồng cũng phải tuân thủ hình thức bắt buộc và đã có Tòa án tuyên xử theo hướng hợp đồng không có giá trị pháp lý khi không theo hình thức bắt buộc. Pháp luật hiện hành của Việt Nam ghi nhận sự tự do về hình thức của hợp đồng nhưng cũng đưa ra giới hạn đối với hình thức bắt buộc.”*¹²⁴ Điều đó không có nghĩa quy định pháp luật về hình thức hợp đồng bị giới hạn về sự tự do lựa chọn, chỉ là sự tự do sẽ được hướng theo mục đích nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể trong quan hệ hợp đồng và những chủ thể khác. Đây là sự tự do để đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các bên trong quan hệ hợp đồng.

Khác với quan hệ hợp đồng, di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương và chỉ có hiệu lực pháp luật khi người để lại di sản chết. Người để lại di sản thông qua di chúc để thể hiện ý chí của họ và hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận lại nội dung của di chúc. Di chúc là một giao dịch dân sự mà hình thức di chúc không được trái với quy định của luật hay xét về mặt lý luận, có thể xác định di chúc là một giao dịch dân sự trọng thức. Trên thực tế, những bản án của Tòa án đều giải quyết theo hướng nếu di chúc được lập không đúng hình thức thì di chúc sẽ không được công nhận. Lý do cho việc xác định hình thức di chúc ảnh hưởng quan trọng đến hiệu lực của di chúc vì hình thức di chúc là chứng cứ pháp lý để chứng minh di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên cũng không thể khẳng định pháp luật về hình thức di chúc không tồn tại sự tự do về ý chí của người lập di chúc mặc dù điều kiện về hình thức di chúc là

¹²³ Điều 3 BLDS 2015.

¹²⁴ Đỗ Văn Đại (2013), “Hình thức bắt buộc của hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam: Những bất cập và hướng hoàn thiện”, *Tạp chí Luật học*, số 2/2013, tr.3.

chặt chẽ. Sự tự do ý chí của người lập di chúc trong hình thức của di chúc thể hiện ở việc người để lại di sản được quyền lựa chọn hình thức di chúc lập cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và khả năng của họ, trừ trường hợp luật bắt buộc một số nhóm người để lại di sản phải tuân theo đúng hình thức luật định. Nhưng nếu chỉ xét về sự tự do trong hình thức của di chúc tồn tại ở sự lựa chọn hình thức di chúc để lập thì sẽ là không ghi nhận đầy đủ quyền tự do ý chí của người lập di chúc thể hiện ở hình thức di chúc.

Ngoài ra, sự tự do về ý chí trong quy định về hình thức di chúc còn được thể hiện ở những điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc. Pháp luật không được đặt ra những điều kiện về hình thức di chúc khó có thể thực hiện hoặc không khả thi thực hiện. Quy định mang tính linh hoạt trong các điều kiện hình thức của di chúc sẽ đảm bảo di chúc được lập vừa đúng quy định hình thức vừa có thể ghi nhận ý chí của người để lại di sản để bảo vệ quyền định đoạt tài sản của họ. Mặt khác, việc mở rộng ghi nhận thêm nhiều loại hình thức di chúc, thêm nhiều trường hợp đặc biệt được lập ở các hình thức di chúc phù hợp cũng là một sự mở rộng của sự tự do ý chí về hình thức di chúc. Cụ thể như: di chúc điện tử, di chúc miệng cho người không thể nói được, di chúc miệng cho người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi mà luận án có đề xuất luật nên ghi nhận thêm.

Có thể thấy, để đảm bảo ghi nhận quyền tự do định đoạt tài sản của người để lại di sản thừa kế một cách tuyệt đối, đảm bảo ghi nhận ý chí đích thực của người để lại di sản và mang lại sự thuận lợi nhất trong quá trình lập di chúc thì sự tự do ý chí của người để lại di sản là một yếu tố chi phối quan trọng cần xem xét đến khi xây dựng quy phạm pháp luật về hình thức di chúc. Ghi nhận sự tự do ý chí của người để lại di sản trong hình thức di chúc không phải là tự do quá đà. Sự tự do vẫn trên cơ sở quy định của pháp luật để đảm bảo di chúc tránh bị giả mạo, bị lừa dối nhưng sẽ không còn là quá máy móc và khắt khe với từng điều kiện về hình thức di chúc.

2.4.3. Điều kiện của người lập di chúc

Di chúc là một giao dịch dân sự và để di chúc hợp pháp thì di chúc phải thỏa mãn các điều kiện do luật quy định về chủ thể lập di chúc, nội dung di chúc, yếu tố tự nguyện khi lập di chúc và hình thức di chúc. Trong đó, hình thức di chúc không trái với quy định của luật¹²⁵. Việc xây dựng các quy phạm pháp luật về hình thức di chúc chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố chi phối trực tiếp đến các hình thức di chúc chính là chủ thể lập di chúc. Chủ thể lập di chúc là người quyết định nội dung di chúc do vậy để tạo điều kiện tốt nhất cho họ dễ dàng tạo lập được di chúc và di chúc chứa đựng chính xác nguyện vọng của họ thì quy định về hình thức di chúc phải căn cứ vào yếu tố này.

¹²⁵ Điểm b khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

Khi một người muốn lập di chúc để định đoạt tài sản của mình thì họ phải thỏa mãn điều kiện về chủ thể để di chúc hợp pháp. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 BLDS 2015 điều kiện bắt buộc là người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc và di chúc được lập khi họ không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 625 BLDS 2015 người lập di chúc phải là người từ đủ 15 tuổi trở lên. Đây là những điều kiện chung, cơ bản đảm bảo di chúc là sự thể hiện mong muốn đích thực của người lập di chúc khi dịch chuyển tài sản cho những người thừa kế theo di chúc. Tuy nhiên những chủ thể ở những điều kiện khác nhau sẽ lựa chọn những loại hình thức di chúc khác nhau để đảm bảo việc ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản là chính xác nhất. Bởi lẽ dù họ đã minh mẫn sáng suốt khi lập di chúc nhưng với những hạn chế về thể chất, về khả năng ngôn ngữ, về điều kiện khách quan thì việc lựa chọn hình thức di chúc phải phù hợp mới đảm bảo được khả năng lập di chúc và đảm bảo di chúc ghi nhận đúng ý chí của người lập di chúc.

BLDS 2015 đã căn cứ vào điều kiện của người lập di chúc để ghi nhận các loại hình thức di chúc phù hợp. Theo quy định từ Điều 633 đến Điều 636, Điều 638 và khoản 5 Điều 630 BLDS 2015, những người trong điều kiện bình thường về sức khỏe, không bị hạn chế về thể chất, độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, không phải là người không biết chữ có thể lựa chọn để lập bất kỳ loại hình thức di chúc bằng văn bản nào. BLDS 2015 ghi nhận quyền tự do lựa chọn cho người để lại di sản bởi khả năng tự thể hiện ý chí và tự ghi nhận lại ý chí là họ có thể tự mình thực hiện được. Nếu người lập di chúc muốn tự mình viết thì họ sẽ lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản tự tay viết và sẽ ký tên vào bản di chúc. Đối với hình thức di chúc tự lập thủ tục đơn giản, không tốn kém, không cần người hỗ trợ và có thể giữ bí mật nội dung di chúc. Nhưng nếu người lập di chúc không muốn tự mình viết tay, họ có thể đánh máy bản di chúc rồi in ra, ký tên vào. Lúc này di chúc được lập cần phải có người làm chứng để xác nhận nội dung di chúc và xác nhận sự kiện lập di chúc. Người lập di chúc cũng có thể nhờ người khác viết hộ hoặc đánh máy hộ bản di chúc dưới sự chứng kiến của ít nhất hai người làm chứng. Nếu người lập di chúc muốn thông qua tổ chức công chứng hoặc UBND cấp xã để chứng thực di chúc thì họ sẽ lựa chọn hình thức di chúc có công chứng hoặc chứng thực.

Tuy nhiên nếu đây là người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ thì khả năng tự lập di chúc của họ là không thể và cần phải có sự hỗ trợ của những người khác để ghi nhận lại ý chí của mình. Lúc này người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải nhờ người khác lập di chúc và để đảm bảo tính xác thực của di chúc, di chúc cần phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại khoản 3 Điều 630 BLDS 2015. Đây là hình thức di chúc được lập có sự chứng kiến của cả người làm chứng và công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc. Tồn tại cả hai nhóm người hỗ trợ việc lập di chúc sẽ đảm bảo tính xác thực trong nội dung di

chức, di chúc sẽ khó bị giả mạo. Giả sử có một bản di chúc được lập bởi người không biết chữ, do người không biết chữ tự viết thì có quyền nghi ngờ tính xác thực của bản di chúc đó. Do vậy hình thức di chúc được lập phù hợp với khả năng của người lập di chúc nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho họ.

Di chúc chung của vợ chồng là loại hình di chúc mà chủ thể lập di chúc không chỉ là một người. Đây là di chúc có sự thống nhất và bàn bạc ý chí của cả hai vợ chồng để tạo lập. *“Thời xưa, di chúc thường được ghi nhận là sự bày tỏ ý chí của cha và mẹ để chuyển giao tài sản của gia đình cho con. Việc cha, mẹ lập chung di chúc là tục lệ đặc trưng của xã hội Việt Nam thời xưa”*¹²⁶. Từ đó quy định trong BLDS 1995, 2005 ghi nhận di chúc chung của vợ, chồng như là sự kế thừa truyền thống dân tộc¹²⁷. Đến BLDS 2015 không còn ghi nhận di chúc chung của vợ, chồng. Có quan điểm cho rằng *“theo quy định tại các Điều 663, 664, 668 BLDS 2005 thì vợ chồng có thể lập di chúc chung. BLDS 2015 bãi bỏ các quy định về di chúc chung. Khái niệm di chúc tại Điều 624 BLDS 2015 cũng ghi rõ di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Các quy định liên quan đến hiệu lực của di chúc chung; quy định về quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc chung trong BLDS 2005 đều không còn tồn tại trong BLDS 2015. Do đó, việc vợ chồng tự lập di chúc chung sẽ là một rủi ro pháp lý rất khó giải quyết.”*¹²⁸ Tuy nhiên vì pháp luật không cấm nên trên thực tế vẫn có thể xảy ra trường hợp có di chúc chung của vợ chồng và sẽ vẫn phải thừa nhận di chúc này. Tuy nhiên có quan điểm cho rằng di chúc theo quy định BLDS 2015 là sự bày tỏ ý chí của cá nhân về việc định đoạt tài sản cá nhân nên khi hai vợ, chồng lập di chúc chung thì phải thừa nhận có hai di chúc trong cùng một văn bản¹²⁹.

Xét về hình thức di chúc nếu trong trường hợp vợ chồng có lập di chúc chung thì có quan điểm cho rằng hình thức di chúc nên bắt buộc phải bằng văn bản chứ không thể lập di chúc miệng. Việc cho phép vợ chồng lập di chúc chung bằng miệng sẽ trở nên phức tạp và không bảo đảm sự an toàn pháp lý cho quyền lợi chính đáng của chính người lập di chúc lẫn người thừa kế hợp pháp của họ. Nguyên nhân xuất phát từ vấn đề di chúc miệng được lập trong tình trạng cận kề cái chết và lúc này bản di chúc của vợ chồng sẽ khó có sự thống nhất về nội dung di chúc. Hoặc khi di chúc được lập xong thì vẫn còn một người minh mẫn, sáng suốt nhưng người kia thì chết hoặc không còn minh mẫn, sáng suốt sẽ khó giải quyết hậu quả pháp lý của bản di chúc miệng của

¹²⁶ Vũ Văn Mẫu (1948), *Les successions testamentaries en droit vietnamien (Thừa kế theo di chúc trong luật Việt Nam)*, luận án tiến sĩ, Paris, lưu tại thư viện Cujas, Paris trong Nguyễn Ngọc Điện, *tlđđ* (số chú thích 13), tr.214.

¹²⁷ Nguyễn Ngọc Điện, *tlđđ* (số chú thích 13), tr.215.

¹²⁸ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.487.

¹²⁹ Nguyễn Ngọc Điện, *tlđđ* (số chú thích 13), tr.215.

hai vợ chồng đã được lập.¹³⁰ Tuy nhiên quy định của pháp luật khi còn ghi nhận di chúc chung của vợ chồng không giới hạn về hình thức di chúc mà vợ chồng được phép tạo lập và hiện nay BLDS 2015 không còn ghi nhận di chúc chung của vợ chồng. Do vậy vợ, chồng có thể tạo lập di chúc chung với các hình thức nào sẽ tùy thuộc vào mong muốn, lựa chọn và sự phù hợp về điều kiện của hình thức di chúc đó theo quy định của luật.

Với những phân tích trên có thể thấy pháp luật Việt Nam đã dựa vào khả năng và điều kiện của từng nhóm người để lại di sản để có những quy định phù hợp đảm bảo họ có thể lập di chúc thuận lợi và di chúc là sự ghi nhận đúng ý chí của người để lại di sản.

Không chỉ pháp luật Việt Nam dựa vào khả năng của chủ thể lập di chúc để quy định về hình thức di chúc mà pháp luật của Pháp cũng căn cứ vào yếu tố này. Theo BLDS Pháp có một số nhóm người để lại di sản đặc biệt mà trình tự thủ tục lập di chúc sẽ khác nhau hoặc sẽ bị giới hạn hình thức lập di chúc. Có thể dẫn chứng trường hợp sau: *“(i) Nếu người lập di chúc không thể diễn đạt được bằng tiếng Pháp, việc đọc nội dung di chúc cho công chứng viên và việc đọc lại cho người lập di chúc nghe có thể thông qua một phiên dịch mà người lập di chúc tự chọn trên danh sách quốc gia các chuyên gia tư pháp do Tòa phá án lập hoặc trên danh sách các chuyên gia tư pháp do từng Tòa phúc thẩm lập. Phiên dịch phải đảm bảo độ chính xác của bản dịch các câu chữ đã được sử dụng. Công chứng viên không cần mời phiên dịch nếu bản thân công chứng viên cũng như, tùy từng trường hợp, công chứng viên kia hoặc những người làm chứng hiểu được ngôn ngữ mà người lập di chúc sử dụng để đọc. (ii) Nếu người lập di chúc có thể viết bằng tiếng Pháp nhưng không thể nói, công chứng viên tự viết di chúc hoặc giao cho người khác viết hoặc đánh máy di chúc theo những ghi chép mà người lập di chúc đã thảo ra trước mặt công chứng viên, sau đó đọc lại cho người lập di chúc nghe. (iii) Khi người lập di chúc không thể nghe, người lập di chúc sẽ xem di chúc và tự đọc lại sau khi công chứng viên đã đọc.”*¹³¹ Ngoài ra, BLDS Pháp cũng quy định rõ *“những người không biết hoặc không thể đọc thì không thể lập di chúc dưới hình thức di chúc bí mật”*¹³². Di chúc bí mật là loại di chúc có nội dung di chúc được giữ bí mật mặc dù được công chứng viên và người làm chứng xác nhận di chúc. Nếu người không biết hoặc không thể đọc được mà lập di chúc bí mật thì người khác có quyền nghi ngờ tính xác thực của nội dung di chúc.

¹³⁰ Phạm Kim Anh (2011), *Pháp luật thừa kế ở Việt Nam từ thế kỷ XV đến nay*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên đề 4 - Di chúc chung của vợ chồng theo quy định của BLDS 2005 – Thực trạng và kiến nghị, tr.70.

¹³¹ Điều 972 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđd* (số chú thích 49), tr.240).

¹³² Điều 978 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđd* (số chú thích 49), tr.242).

Quy định khác biệt về trình tự, thủ tục lập di chúc hay giới hạn nhóm chủ thể không được lựa chọn một hình thức di chúc nào đó nhằm mục đích hướng đến bảo vệ cho họ. Nếu họ không có khả năng cũng như không thể tự xác thực nội dung di chúc khi nhờ người khác viết hoặc làm chứng thì họ sẽ không bảo đảm rằng di chúc được lập thể hiện đúng với ý chí của mình. Do vậy, dựa vào khả năng của chủ thể lập di chúc để quy định các hình thức di chúc là phù hợp. Mỗi người ở sự khác nhau về thể chất, về khả năng ngôn ngữ thì sự biểu đạt ý chí, khả năng ghi nhận ý chí sẽ là khác nhau.

2.4.4. Hoàn cảnh lập di chúc

Hoàn cảnh lập di chúc cũng là một trong những yếu tố chi phối đến pháp luật về hình thức di chúc. Trong những hoàn cảnh lập di chúc khác nhau, phương thức để ghi nhận lại nội dung của di chúc là khác nhau. Bởi vì hoàn cảnh lập di chúc sẽ quyết định đến khả năng và cách thức để ghi nhận lại nội dung di chúc.

Xét theo nghĩa thông thường, hoàn cảnh là *“toàn thể nói chung những nhân tố khách quan bên ngoài có tác động sự sinh sống, sự hoạt động của con người, đến sự xảy ra hoặc diễn biến của sự việc nào đó”*¹³³. Do đó có thể hiểu hoàn cảnh chính là tổng thể tất cả các yếu tố khách quan tác động đến con người hay sự vật, hiện tượng. Về mặt pháp lý, đối với các quan hệ pháp luật nói chung hoàn cảnh chỉ là các yếu tố khách quan nhưng tác động rất lớn đến cách thức xử sự của con người. Ở những hoàn cảnh khác nhau, sự lựa chọn các xử sự pháp lý của chủ thể phải phù hợp với điều kiện, khả năng mà chủ thể có thể thực hiện được để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ cũng như đảm bảo sự cân bằng lợi ích quyền lợi với các chủ thể khác. Đối với quan hệ thừa kế theo di chúc, hoàn cảnh lập di chúc ảnh hưởng đến khả năng ghi nhận lại ý chí của người lập di chúc. Một người trong hoàn cảnh bình thường thì việc lập di chúc sẽ dễ dàng cho nên việc lựa chọn loại hình thức di chúc để lập là tùy vào ý chí của người lập di chúc. Nhưng với những hoàn cảnh đặc biệt quy định về trình tự, thủ tục lập di chúc phải phù hợp để có thể ghi nhận lại chính xác ý chí của người lập di chúc.

Ở xã hội La Mã lúc đầu tồn tại hai hình thức di chúc trong đó có một hình thức di chúc được lập bởi những người lính trước khi ra chiến trường khi có chiến tranh xảy ra. Đối với họ nguy cơ tử trận cao nên ở hoàn cảnh đó luật La Mã cho phép họ lập di chúc với thủ tục rút gọn.¹³⁴ Sau này việc ghi nhận di chúc được lập bởi những người lính đang trong cuộc chiến được ghi nhận một cách rõ ràng hơn. Bởi vì đây là di chúc được lập bởi những người lính nên các điều khoản cụ thể liên quan đến di chúc quân sự đã được giới thiệu bắt đầu từ thời Julius Caesar để miễn cho binh lính khỏi các thủ tục di chúc có liên quan. Như vậy, di chúc quân sự được coi là hợp lệ ngay cả khi di chúc không được niêm phong bởi bảy nhân chứng. Di chúc cũng không cần phải được

¹³³ Viện Ngôn ngữ học, *tlđđ* (số chú thích 52), tr.567.

¹³⁴ Barry Nicholas, *An Introduction to Roman Law*, Nxb. Oxford University Press, tr.253, 254.

viết bằng tiếng Latinh và quy tắc loại trừ không áp dụng trong quan hệ thừa kế.¹³⁵ Những mong muốn cuối cùng của một người lính trung thành đã ngã xuống phải được tôn trọng. Thậm chí ngay cả khi những người lính này, theo quy định của luật thời Hoàng Đế Constantine ghi nhận *“người lính đã viết ý định của họ trên bao kiếm hoặc trên khiên của họ với những chữ cái màu đỏ thẫm bằng máu của chính họ, hoặc đã vạch ra chúng trong bụi với mũi kiếm của họ vào thời điểm họ sắp chết trong trận chiến”* cũng sẽ được công nhận.¹³⁶ Hoàn cảnh lập di chúc đặc biệt nên những yêu cầu về thủ tục lập di chúc cơ bản không được áp dụng trong trường hợp này.

Ở Pháp cũng có những hình thức di chúc dành cho những người ở những hoàn cảnh đặc biệt có thể lập được. *“Nếu các hoạt động quân sự được tiến hành ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia hoặc đóng quân ở nước ngoài trên cơ sở chiếm đóng hoặc theo Hiệp định liên Chính phủ thì di chúc của quân nhân, lính thủy và công nhân viên quốc phòng đang trong cuộc chiến, có thể được xác nhận bởi một sỹ quan cấp tá hoặc bác sỹ quân y có quân hàm cùng cấp và trước hai người làm chứng; hoặc bởi hai cán bộ hậu cần hoặc sỹ quan quản lý hành chính; hoặc bởi một trong các viên chức hay sỹ quan đó và trước hai người làm chứng; hoặc bởi sỹ quan chỉ huy một phân đội độc lập trước sự có mặt của hai người làm chứng nếu trong phân đội đó không có sỹ quan cấp tá hoặc sỹ quan quản lý hành chính. Thậm chí các tù binh đang bị đối phương giam giữ cũng có quyền lập di chúc theo hình thức này.”*¹³⁷ Hoặc *“ở hoàn cảnh mà giao thông với bên ngoài bị gián đoạn do có bệnh truyền nhiễm thì di chúc có thể do người nhiễm bệnh lập”*¹³⁸. Đây là những hoàn cảnh rất nguy cấp mà di chúc của người lập di chúc có thể có thủ tục rút gọn hoặc được xác nhận bởi chủ thể đặc biệt.

Ở Việt Nam, trường hợp một người trong hoàn cảnh tính mạng nguy hiểm, cận kề cái chết với trạng thái tinh thần hoang mang, lo lắng, với sự sống chỉ tính từng phút, từng giây, không thể lập di chúc bằng văn bản sẽ lựa chọn hình thức di chúc miệng¹³⁹. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi lập di chúc muốn nhờ một bên thứ ba xác thực nội dung di chúc thì không có tổ chức công chứng hoặc UBND để chứng thực di chúc. Lúc này có thể thông qua một tổ chức khác hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cho họ để chứng nhận di chúc như là cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao ở nước đó.¹⁴⁰ Hay quân nhân tại ngũ có thể lựa chọn lập di chúc với xác nhận của thủ trưởng

¹³⁵ Rafael Domingo, *tlđđ* (số chú thích 62), tr.13.

¹³⁶ Rafael Domingo, *tlđđ* (số chú thích 62), tr.13-14.

¹³⁷ Điều 93, Điều 981 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.42, 242).

¹³⁸ Điều 985 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.243).

¹³⁹ Khoản 1 Điều 629 BLDS 2015.

¹⁴⁰ Khoản 5 Điều 638 BLDS 2015.

đơn vị từ cấp đại đội trở lên nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực¹⁴¹.

Có thể thấy hoàn cảnh lập di chúc ảnh hưởng rất lớn đến pháp luật về hình thức di chúc. Những điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc phải căn cứ vào những hoàn cảnh thực tế của người lập di chúc để xác định khả năng người để lại di sản có thể tạo lập và ghi nhận được nội dung di chúc. Có những quy định đặc biệt hướng đến những hoàn cảnh lập di chúc đặc thù sẽ bảo vệ được quyền lập di chúc cũng như đảm bảo việc ghi nhận nội dung di chúc được chính xác.

2.4.5. Tài sản được định đoạt trong di chúc

Thừa kế và sở hữu là hai phạm trù kinh tế tồn tại song song trong mọi hình thái kinh tế xã hội. Trong phạm vi một chế độ xã hội, hai phạm trù này gắn bó chặt chẽ với nhau, mỗi phạm trù là tiền đề và cũng chính là hệ quả đối với nhau.¹⁴² Sở hữu là cơ sở, là yếu tố tiền đề để xuất hiện thừa kế. Ngược lại trên cơ sở có thừa kế mới có sự tiếp tục chuyển giao sở hữu. Thừa kế và sở hữu là hai khái niệm thuộc phạm trù về mặt kinh tế chỉ sự tác động đến tài sản và sự dịch chuyển tài sản. Trên cơ sở mối liên hệ giữa sở hữu và thừa kế, xét về mặt pháp lý quyền thừa kế và quyền sở hữu có mối liên hệ tương hỗ với nhau. Khi một người là chủ sở hữu tài sản, họ thực hiện quyền sở hữu của mình khi họ còn sống. Khi họ chết quyền sở hữu tài sản của họ sẽ được dịch chuyển sang cho những người khác trên cơ sở quyền thừa kế được pháp luật ghi nhận. Chủ sở hữu tài sản để thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản của mình kể cả sau khi họ chết bằng cách lập di chúc để dịch chuyển tài sản của mình sang cho người mà mình mong muốn được hưởng. Do vậy trong nội dung di chúc sẽ thể hiện rõ quyền định đoạt tài sản của người lập di chúc. Hình thức di chúc và nội dung di chúc có mối liên hệ chặt chẽ là điều kiện cần thiết để tạo lập nên một bản di chúc. Từ đó yếu tố tài sản được định đoạt trong di chúc có ảnh hưởng nhất định đến hình thức di chúc.

Đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (nhà ở, quyền sử dụng đất, xe ô tô, xe máy...) khi người lập di chúc muốn lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng thì sẽ phải thêm trình tự chứng minh họ là chủ sở hữu đối với tài sản đó theo yêu cầu của công chứng viên. Theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014 ngoài những giấy tờ tùy thân thì người lập di chúc cần phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định để chứng minh họ là chủ sở hữu hoặc là người có quyền sử dụng hợp pháp tài sản được định đoạt trong di chúc. Nếu có đầy đủ giấy tờ này thì công chứng viên mới công chứng nội dung di chúc. Hoặc cũng với những loại tài sản này nếu người lập di chúc muốn lập di chúc bằng văn bản có chứng thực cũng cần các giấy

¹⁴¹ Khoản 1 Điều 638 BLDS 2015.

¹⁴² Phạm Kim Anh, *tlđd* (số chú thích 130), Chuyên đề 1 – Một số lý luận về thừa kế, tr.49.

tò chứng minh quyền sở hữu theo thủ tục yêu cầu của việc lập di chúc¹⁴³. Như vậy thủ tục lập di chúc cho hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực cần thêm các giấy tờ có liên quan chứng minh họ là chủ sở hữu tài sản tùy thuộc vào loại tài sản được định đoạt trong di chúc.

Yếu tố tài sản cũng ảnh hưởng đến quy định về hình thức di chúc theo pháp luật Mỹ. Ở một số tiểu bang của Mỹ tài sản được định đoạt trong di chúc sẽ ảnh hưởng đến trình tự, thủ tục khi lập di chúc miệng. *“Hầu hết các Đạo luật chỉ cho phép định đoạt động sản hoặc tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng của cá nhân, và thậm chí sau đó, một số Đạo luật buộc phải giới hạn tiền tệ đối với số tài sản có thể được chuyển giao bằng di chúc miệng”*¹⁴⁴. Cụ thể ở tiểu bang Montana có đề cập đến trường hợp *“di chúc miệng không cần phải được viết cũng không được tuyên bố cũng không được chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng cho tài sản cá nhân. Số tiền được để lại không được vượt quá giá trị \$1000.”*¹⁴⁵ Ở Mỹ căn cứ vào loại tài sản và giá trị tài sản nếu muốn lập di chúc miệng theo thủ tục rút gọn bên cạnh hoàn cảnh của người lập di chúc miệng.

Tóm lại tài sản của người lập di chúc có những ảnh hưởng nhất định đến hình thức di chúc. Do đó đối với một số loại tài sản đặc biệt thì hình thức di chúc phải được ghi nhận một cách phù hợp.

¹⁴³ Điểm c khoản 1 Điều 36 NBĐ 23/2015/NBĐ-CP ngày 16/2/2015 Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

¹⁴⁴Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (sổ chú thích 10), tr.373, 374.

¹⁴⁵ J. Howard Toelle (1951), “Succession Under Montana Law”, *Montana Law Review*, số 20, tr.20.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Hình thức di chúc có thể được tiếp cận ở hai góc độ. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận lại ý chí định đoạt tài sản của người để lại di sản theo một trình tự, kết cấu nhất định và từ đó là căn cứ để chứng minh ý chí đích thực của người để lại di sản. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì hình thức di chúc là một phạm trù pháp lý bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc tùy vào từng loại hình thức di chúc.

Pháp luật về hình thức di chúc chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. (i) Sự tự do ý chí của người lập di chúc chính là sự tự do trong việc lựa chọn hình thức di chúc của người lập di chúc. (ii) Yếu tố phong tục tập quán, đặc tính đặc trưng của xã hội trong từng thời kỳ ảnh hưởng rõ rệt đến quy định về các điều kiện, trình tự, thủ tục lập di chúc. Minh chứng rõ rệt của sự ảnh hưởng bởi phong tục tập quán chính là quy định về di chúc miệng đã tồn tại từ thời kỳ cổ luật đến giai đoạn hiện nay. Đặc tính đặc trưng của xã hội căn cứ vào điều kiện xã hội của từng quốc gia hoặc trong một quốc gia nhưng ở những giai đoạn lịch sử khác nhau cũng sẽ có sự khác biệt và cũng sẽ ảnh hưởng đến quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục lập di chúc ở từng hình thức di chúc. (iii) Điều kiện của người lập di chúc ảnh hưởng đến từng hình thức di chúc mà luật cho phép những nhóm người khác nhau được lập. (iv) Ngoài ra, chủ thể ở những hoàn cảnh lập di chúc khác nhau sẽ có thể lựa chọn hình thức di chúc phù hợp để di chúc có thể khả thi và thuận lợi được lập. (v) Yếu tố về tài sản của người lập di chúc ảnh hưởng đến việc xây dựng điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc. Những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu nếu người lập di chúc muốn lựa chọn hình thức di chúc có công chứng hoặc chứng thực thì phải có các giấy tờ chứng minh họ là chủ sở hữu của tài sản được định đoạt trong di chúc.

Khi nghiên cứu lịch sử pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc từ giai đoạn phong kiến đến nay có thể thấy pháp luật về hình thức di chúc được quy định phù hợp với từng giai đoạn xã hội Việt Nam trên cơ sở sự ghi nhận phong tục tập quán. Pháp luật ở giai đoạn sau có sự kế thừa quy định của pháp luật trước đó nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với đặc tính xã hội từng thời kỳ. Do vậy, khi xã hội ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ thì di chúc được ghi nhận, lưu giữ trên các thông điệp dữ liệu thông qua các phương tiện điện tử được dự đoán sẽ là một loại hình thức di chúc mới được bổ sung.

CHƯƠNG 3: HÌNH THỨC DI CHỨC BẰNG VĂN BẢN

Chương 3 của luận án nghiên cứu về hình thức di chúc bằng văn bản trên cơ sở phân tích về lý luận, quy định của pháp luật, thực trạng pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở những phân tích này và với sự tham khảo kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài, luận án đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình thức di chúc bằng văn bản. Những kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản để đảm bảo rằng di chúc bằng văn bản phải là cơ sở để ghi nhận, lưu giữ ý chí đích thực của người lập di chúc và giúp di chúc được tạo lập dễ dàng hơn.

3.1. Khái niệm, đặc điểm hình thức di chúc bằng văn bản

3.1.1. Khái niệm hình thức di chúc bằng văn bản

Theo cách hiểu thông thường, di chúc bằng văn bản là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc được ghi nhận lại dưới dạng văn bản thay cho việc lưu giữ ý chí đó bằng lời nói hoặc sự ghi nhớ của người làm chứng.

Nếu hiểu theo nghĩa hẹp, văn bản là *“hình thức ngôn ngữ viết, được trình bày trên một chất liệu hữu hình nhằm thể hiện một nội dung xác định mà người ta có thể đọc, lưu giữ và bảo đảm sự vẹn toàn của nội dung đó”*¹⁴⁶. Do đó, văn bản là một phương tiện để ghi nhận, lưu giữ và truyền đạt thông tin bằng ký hiệu gọi là chữ viết. Văn bản có thể thể hiện dưới dạng bản giấy (viết tay, đánh máy in ra...) hoặc trên các chất liệu khác như vải, phiến đá, miếng gỗ... thông qua chữ viết để ghi nhận lại nội dung muốn truyền tải. Văn bản có thể được viết tay hoặc có thể thông qua các phương tiện điện tử để ghi chép lại nội dung bằng chữ viết và được thể hiện bằng bản in.

Hiểu theo nghĩa rộng, văn bản không chỉ là những bản giấy mà còn có thể thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu được lưu giữ trên các phương tiện điện tử (bản file lưu trữ trong máy tính hoặc các thiết bị điện tử). Cách hiểu văn bản theo nghĩa rộng này hiện nay đang được xem xét cho quy định về hình thức của giao dịch dân sự theo BLDS 2015. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử được xem là giao dịch bằng văn bản¹⁴⁷.

Về mặt pháp lý, khi nghiên cứu về hình thức di chúc bằng văn bản đã có nhiều cách giải nghĩa. Có quan điểm diễn giải, di chúc bằng văn bản *“là một chứng thư pháp luật đơn phương, trong đó người lập di chúc (người làm ra chúc thư) định đoạt các tài sản của mình để cho ai, sau khi chết. Chúc thư là một chứng thư có tính cách khả bãi*.

¹⁴⁶ Lê Minh Hùng (2010), *Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tr.57.

¹⁴⁷ Khoản 1 Điều 119 BLDS 2015.

Người lập chúc, cho đến khi chết, có quyền thay đổi ý định trong chúc thư”¹⁴⁸. Hoặc có cách diễn đạt khác, có thể xem di chúc bằng văn bản là “*loại di chúc được thể hiện dưới dạng chữ viết (viết tay, đánh máy, in) có chứng nhận hoặc không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền*”¹⁴⁹. Hai cách mô tả về di chúc bằng văn bản là khác nhau nhưng đều nhấn mạnh đến tính chất của di chúc bằng văn bản, đây là bản di chúc được thể hiện ý chí ra bên ngoài dưới dạng bản ghi lại hoặc đánh máy trên giấy hoặc được đánh máy trên máy tính và in ra trên giấy. Đối với cách hiểu thứ nhất nghiêng về nội dung thể hiện trong bản di chúc và đặc điểm pháp lý cơ bản của di chúc bằng văn bản. Di chúc bằng văn bản là sự ghi nhận ý chí đơn phương của một bên và di chúc luôn được thay đổi cho đến khi người để lại di sản chết. Di chúc bằng văn bản là một chứng thư, một chứng cứ pháp lý được ghi nhận và thể hiện dưới bản giấy. Cách hiểu thứ hai mang tính liệt kê các cách thức thể hiện của di chúc bằng văn bản có thể được ghi nhận bằng bản viết tay, bản giấy được đánh máy và in ra. Dù là cách hiểu nào thì di chúc bằng văn bản đóng vai trò quan trọng để ghi nhận ý chí của người để lại di sản.

Một cách tiếp cận khác khi phân tích về di chúc bằng văn bản là không mô tả về hình thức di chúc nhưng đưa ra cách hiểu theo hình thức thể hiện ra bên ngoài của ý chí và xác định di chúc bằng văn bản được gọi tên là di chúc viết. “*Đây là hình thức văn bản truyền thống mà trước kia được thể hiện với hai thể thức: di chúc tư chứng thư và di chúc công chính chứng thư. Đối với tư chứng thư, người lập di chúc có thể tự viết di chúc hoặc nhờ người khác viết hộ di chúc và phải có hai người làm chứng. Di chúc công chính chứng thư được lập trước công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực, người có quyền xác nhận di chúc theo quy định của pháp luật.*”¹⁵⁰ Theo cách hiểu này, di chúc bằng văn bản chính là di chúc viết. Di chúc được người lập di chúc thể hiện ý chí và ghi nhận lại ý chí bằng việc tự mình viết hoặc nhờ người khác viết.

Theo tiến trình lịch sử của pháp luật Việt Nam thì di chúc bằng văn bản ban đầu được ghi nhận với bản chất chính là hình thức di chúc viết. Di chúc bằng văn bản theo luật cổ và pháp luật thời phong kiến Việt Nam được sử dụng với tên gọi là “chúc thư”¹⁵¹, là một văn bản được viết ra trên giấy thể hiện ý chí của người để lại di sản. Sau này đến quy định trong TT 81/TT-TANDTC di chúc bằng văn bản được sử dụng với thuật ngữ “di chúc viết”. Thuật ngữ di chúc viết được sử dụng nhằm nhấn mạnh phương thức thể hiện của di chúc phải được viết tay. BLDS 1995 quy định về di chúc loại này với thuật ngữ “di chúc bằng văn bản” thay cho thuật ngữ “di chúc viết” được

¹⁴⁸ Vũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân (1968), *Danh từ và tài liệu Dân luật và Hiến Luật*, Tủ sách Đại học Sài Gòn, tr.61.

¹⁴⁹ Lê Đình Nghi, *tlđđ* (số chú thích 57), tr.265.

¹⁵⁰ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.467.

¹⁵¹ Nguyễn Quyết Thắng (2002), *Lược khảo Hoàng Việt Luật lệ*, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, tr.432.

sử dụng trước đó. Điều này không chỉ là sự thay thế từ ngữ mà còn mở rộng hơn loại hình của di chúc không chỉ được viết tay mà còn có thể được đánh máy và in ra. Như vậy, từ BLDS 1995 trở đi thuật ngữ “di chúc viết” được thay thế bằng thuật ngữ “di chúc bằng văn bản” với việc ghi nhận thêm cách thức thể hiện của văn bản có thể bằng bản in. Thuật ngữ di chúc bằng văn bản được sử dụng từ BLDS 1995 đến nay.

Từ tiến trình lịch sử của pháp luật Việt Nam về di chúc bằng văn bản tác giả nhận thấy di chúc bằng văn bản ở giai đoạn đầu chỉ được thể hiện dưới dạng các bản viết tay bằng chữ viết của người lập di chúc hoặc của người viết hộ. Đến khi xã hội phát triển, di chúc bằng văn bản còn được thể hiện dưới dạng bản in được in ra từ những nội dung được ghi nhận trên các phương tiện điện tử. Do đó, với định hướng phát triển của tương lai di chúc bằng văn bản có thể được tạo lập, ghi nhận và lưu giữ trên các phương tiện điện tử thông qua các thông điệp dữ liệu.

Hiện nay theo pháp luật Việt Nam di chúc bằng văn bản gồm các loại hình thức: di chúc tự viết; di chúc được đánh máy hoặc nhờ người viết, đánh máy; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực và một loại hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Tất cả những loại hình thức di chúc bằng văn bản này được thể hiện dưới phương tiện truyền thống là các bản giấy (phổ biến) hoặc thể hiện trên những chất liệu vật chất khác như vải, gỗ... (không phổ biến). Tùy vào từng loại hình thức di chúc mà những điều kiện về chữ ký, điểm chỉ, người làm chứng, công chứng hoặc chứng thực sẽ được yêu cầu với những trình tự, thủ tục lập khác nhau. Với sự đa dạng về các loại hình thức di chúc bằng văn bản sẽ giúp *“người lập di chúc bằng văn bản có quyền, tùy ý muốn của mình và tùy theo hoàn cảnh cụ thể chọn một trong những hình thức di chúc bằng văn bản nói trên”*¹⁵². Tất cả các loại hình thức di chúc bằng văn bản hiện nay theo pháp luật Việt Nam đang được hiểu theo nghĩa hẹp. Những bản di chúc dưới định dạng dữ liệu điện tử chưa được in ra đang được lưu giữ trên các phương tiện điện tử không được thừa nhận.

Trên thế giới, đối với di chúc được thể hiện bằng các bản file được lưu trên máy tính, điện thoại chưa in ra đã được nhiều quốc gia thừa nhận và xem đây là hình thức di chúc bằng văn bản với tên gọi là di chúc điện tử¹⁵³. Chẳng hạn ở Mỹ, theo quy định của Luật Di chúc điện tử có thể hiểu di chúc điện tử là một bản ghi có thể đọc được dưới dạng văn bản tại thời điểm ký. Di chúc điện tử là di chúc được tạo lập, lưu trữ và có thể đọc được dưới dạng văn bản trên các phương tiện điện tử.¹⁵⁴ Như vậy di chúc

¹⁵² Hoàng Thế Liên (chủ biên) (2010), *Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 – Tập 3*, Nxb. Chính trị quốc gia, tr.51.

¹⁵³ Kimberley Martin TEP (2020), *Technology and Wills – The dawn of a New Era*, https://www.step.org/sites/default/files/media/files/2020-08/Technology-and-Wills_The-Dawn-of-a-New-Era.pdf?fbclid=IwAR2AOBem_3Qrp8qXiuDy6TBMSvVkrqYnOyVBHxD1EpFExAUDhGUh8MQB7Ck, [truy cập 21/12/2021], tr.10.

¹⁵⁴ Điều 5 Luật Di chúc điện tử Mỹ 2019 (tác giả tạm dịch).

điện tử cũng là một loại hình thức di chúc bằng văn bản nhưng chất liệu thể hiện, ghi nhận và lưu trữ di chúc không phải là những chất liệu truyền thống. Thông qua các phương tiện kỹ thuật hiện đại, ý chí của người để lại di sản sẽ được ghi nhận và lưu giữ bằng các thông điệp dữ liệu trên các thiết bị điện tử. Đối với loại hình thức di chúc này những điều kiện về chữ ký số, về người làm chứng, về cách thức bảo mật và cách thức xác định tính nguyên gốc của di chúc sẽ được quy định cụ thể và di chúc được lập theo một trình tự gắn liền với các thiết bị điện tử.

Với cách hiểu này về di chúc điện tử, thực chất di chúc điện tử có những yêu cầu về điều kiện, thể thức lập di chúc giống như di chúc bằng văn bản truyền thống. Các loại hình di chúc bằng văn bản này đều có những điều kiện tương tự về chữ viết, chữ ký, người làm chứng, người viết hộ, người công chứng di chúc. Điểm khác biệt là các loại hình thức di chúc bằng văn bản truyền thống được ghi nhận và lưu giữ bằng các chất liệu truyền thống (như trên giấy, trên vải...), được ký tên bằng chữ ký tay hoặc được điểm chỉ, việc làm chứng là chứng kiến trực tiếp quá trình lập di chúc để xác nhận di chúc. Đối với di chúc điện tử, tất cả các giai đoạn từ ghi nhận ý chí, lưu giữ ý chí đều được thực hiện trên các phương tiện điện tử với chữ ký số. Di chúc điện tử có chữ viết được thể hiện bằng các thông điệp dữ liệu trên các phương tiện điện tử; người lập di chúc, người làm chứng sử dụng chữ ký số để ký vào di chúc; quá trình làm chứng di chúc có thể có việc làm chứng thông qua sự hiện diện điện tử.

Mặt khác, quy trình lập di chúc điện tử phải đảm bảo được yêu cầu xác định tính nguyên gốc và tính bảo mật nội dung di chúc trên thiết bị điện tử. Tuy nhiên các yếu tố về tính nguyên gốc và tính bảo mật của di chúc điện tử khi so sánh với di chúc bằng văn bản truyền thống cũng không phải là khó thực hiện. Đối với các bản ghi tay hoặc được đánh máy in ra khó có thể thay đổi do yếu tố đặc biệt về chữ viết, chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc, người làm chứng, người công chứng hoặc chứng thực di chúc (tùy vào từng loại hình di chúc bằng văn bản mà có sự tham gia của những chủ thể nào) được thể hiện trên từng trang trong di chúc. Đối với những bản lưu trên các phương tiện điện tử cũng khó có thể bị thay đổi khi mỗi trang của di chúc cũng có sự hiện diện của chữ ký số của người lập di chúc, người làm chứng di chúc và có chế độ bảo mật có mật mã cho các file khi muốn truy cập.

Đối với những quốc gia ghi nhận di chúc điện tử đã có những bản khoản về việc xác định di chúc điện tử có phải là di chúc bằng văn bản; chữ ký số có tương tự như chữ ký được ký tay. Tuy nhiên khi hợp đồng điện tử được giao kết và thực hiện đã thông dụng, phổ biến thì di chúc điện tử cũng tương tự như vậy và đây cũng chính là một loại hình thức di chúc bằng văn bản.¹⁵⁵ Do đó, dù được lưu giữ trên các chất liệu truyền thống hay trên các phương tiện điện tử thì tính xác thực của các bản di chúc này

¹⁵⁵ Gary, Susan N, Orlando J. and Marian H. Hollis (2021), “The electronic Wills act: facing the inevitable”, *Real Property, Trust, and Estate Law Journal*, Chicago, tập 55, số 3, tr.312-313.

là như nhau. Do đó trên thế giới đã có nhiều quốc gia ghi nhận hình thức di chúc này như là một loại hình thức của di chúc bằng văn bản.

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra khái niệm di chúc bằng văn bản như sau: *di chúc bằng văn bản là di chúc được ghi chép lại bằng cách viết, bản in thể hiện trên giấy hoặc bản file được lưu giữ trên các phương tiện điện tử ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản để định đoạt tài sản. Tùy vào từng trường hợp mà bản ghi chép lại hoặc bản file chứa đựng nội dung di chúc cần phải thỏa mãn các điều kiện về chữ ký, điểm chỉ, người làm chứng, có công chứng, chứng thực hoặc không có công chứng, chứng thực.*

3.1.2. Đặc điểm hình thức di chúc bằng văn bản

Thứ nhất, di chúc bằng văn bản là hình thức di chúc cơ bản khi người để lại di sản muốn lập di chúc.

Hiện nay ở Việt Nam và các nước có hai hình thức di chúc cơ bản là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Một số nước không ghi nhận hình thức di chúc miệng mà chỉ tồn tại di chúc bằng văn bản¹⁵⁶. Mặt khác, đối với những quốc gia có quy định về hai hình thức di chúc thì thực chất, hình thức di chúc miệng là hình thức di chúc trừ bị cho di chúc bằng văn bản. Chỉ trong trường hợp người lập di chúc cận kề cái chết, không thể lập di chúc bằng văn bản mà vẫn muốn thể hiện ý chí của mình mới có thể lựa chọn hình thức di chúc miệng. Ở thời kỳ La Mã, mặc dù ghi nhận cả di chúc bằng văn bản và di chúc miệng nhưng di chúc miệng không được sử dụng nhiều so với di chúc bằng văn bản¹⁵⁷. Do vậy, khi một người muốn định đoạt tài sản của họ sau khi họ chết thì họ sẽ lập di chúc bằng văn bản. Di chúc miệng chỉ được lựa chọn khi người để lại di sản cận kề cái chết. Bên cạnh đó, di chúc bằng văn bản còn có nhiều loại hình thức cho người lập di chúc có thể lựa chọn tùy thuộc vào khả năng của người lập di chúc, hoàn cảnh của người lập di chúc để có di chúc phù hợp với điều kiện do luật quy định.

Thứ hai, hình thức di chúc bằng văn bản là di chúc được thể hiện và lưu giữ trên một chất liệu vật chất cụ thể.

Đây là một đặc điểm cơ bản thể hiện phương thức ghi nhận, lưu giữ ý chí của người để lại di sản. Đúng với tên gọi của hình thức di chúc này, ý chí của người để lại di sản được thể hiện ra, được ghi nhận và lưu giữ lại bằng văn bản. Văn bản là một chất liệu vật chất cụ thể mà thông qua chữ viết để ghi nhận lại nội dung di chúc. Chất liệu vật chất này có thể được thể hiện trên giấy, trên vải, trên phiến đá, trên miếng gỗ...hoặc có thể thông qua các thông điệp dữ liệu trên các phương tiện điện tử. Tùy vào từng loại hình thức di chúc bằng văn bản sẽ cần thêm các điều kiện để chứa đựng

¹⁵⁶ Phạm Văn Tuyết (2007), *Thừa kế quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng*, Nxb. Chính trị quốc gia, tr.165.

¹⁵⁷ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (sổ chú thích 10), tr.543.

các yếu tố cấu thành di chúc và điều kiện về thể thức lập di chúc để đảm bảo di chúc được lập theo trình tự, thủ tục chặt chẽ.

Thứ ba, các loại hình thức di chúc bằng văn bản có điều kiện và thể thức lập di chúc rất đa dạng.

Hiện nay, BLDS 2015 ghi nhận năm loại hình thức di chúc bằng văn bản¹⁵⁸. Trong đó di chúc bằng văn bản tự tay viết là văn bản thường, còn những hình thức di chúc bằng văn bản đánh máy in ra hoặc nhờ người khác viết; di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực; hoặc di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực là các trường hợp ngoại lệ. Di chúc bằng văn bản tự tay viết là di chúc do tự bản thân người để lại di sản lập do đó đây chính là di chúc bằng văn bản mang tính nguyên tắc trong luật. Người để lại di sản sẽ tự mình thể hiện ý chí và ghi nhận lại để lưu giữ ý chí sau khi họ chết. Còn các loại hình thức di chúc bằng văn bản khác được ghi nhận trong BLDS là các trường hợp đặc biệt vì việc lập di chúc không phải và không thể do tự bản thân người để lại di sản mà cần có hỗ trợ của một số hoặc tất cả những người làm chứng, người viết hộ, người công chứng hoặc chứng thực di chúc.

Đối với từng loại hình thức di chúc bằng văn bản khác nhau thì những điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc sẽ khác biệt mà không có quy định chung về điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc chung. Bởi lẽ những loại hình thức di chúc bằng văn bản được quy định cho người lập di chúc ở vào những điều kiện, hoàn cảnh, khả năng, mong muốn là khác nhau. Những điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc đa dạng được thể hiện rất rõ tại các quy định từ Điều 633 đến Điều 636, Điều 638 BLDS 2015. Khi người để lại di sản có thể tự lập được di chúc thì người này sẽ tự mình viết bản di chúc rồi ký tên vào bản di chúc là đã thỏa mãn điều kiện hình thức của di chúc bằng văn bản tự lập. Tuy nhiên nếu người để lại di sản không muốn tự mình viết hoặc vì lý do nào đó người này không thể tự viết di chúc thì có thể thông qua người khác viết hộ di chúc và phải kèm theo điều kiện về người làm chứng di chúc. Ngoài ra, nếu người để lại di sản muốn di chúc của mình lập được công chứng hoặc chứng thực thì có thể lựa chọn hình thức di chúc có công chứng hoặc chứng thực. Đối với những người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc người bị hạn chế về thể chất thì phải tuân theo những hình thức di chúc bằng văn bản đã được luật quy định mà không có lựa chọn khác. Những người không có điều kiện công chứng hoặc chứng thực di chúc vẫn có thể xin xác nhận di chúc của những chủ thể do luật quy định và di chúc này có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Nếu liệt kê ở đây sẽ thấy có khá nhiều lựa chọn cho loại hình di chúc bằng văn bản. Tùy vào những điều kiện, hoàn cảnh, khả năng khác nhau để người lập di chúc có thể lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản phù hợp cho họ, đảm bảo di chúc không vi phạm điều kiện về hình thức.

¹⁵⁸ Điều 628, 638 BLDS 2015.

Như vậy khi xét về hình thức di chúc bằng văn bản thì những điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc đặt ra khá phong phú tùy vào từng loại hình thức di chúc bằng văn bản.

3.2. Di chúc tự viết

3.2.1. Quy định pháp luật về di chúc tự viết

BLDS 2015 quy định về hình thức di chúc bằng văn bản do tự người lập di chúc viết với tên gọi là di chúc bằng văn bản không có người làm chứng tại Điều 633 với điều kiện “*người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc*”. Đây là hình thức di chúc mà người để lại di sản để lập và có thể giữ bí mật nội dung di chúc. Di chúc tự viết cũng có đặc điểm gắn liền với đặc điểm của di chúc nói chung là ý chí của cá nhân được giữ bảo mật nên nó là loại di chúc truyền thống và có xu hướng tồn tại lâu dài.¹⁵⁹ Đối với hình thức di chúc tự viết chỉ cần người để lại di sản thể hiện ý chí của mình, không cần có thêm sự hỗ trợ của người làm chứng hay những người như công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc. Để có thể lập di chúc theo hình thức này ngoài việc người lập di chúc phải thỏa mãn các điều kiện về chủ thể lập di chúc, nội dung của di chúc¹⁶⁰ thì di chúc phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau đây.

Điều kiện thứ nhất, người lập di chúc tự viết bản di chúc. Đây là điều kiện để chứng minh bản di chúc này là của người để lại di sản khi không có ai là người làm chứng cho di chúc tự lập. Do vậy, người lập di chúc phải là người biết chữ, có thể viết được, tự mình lập được di chúc. “*BLDS cũng không nêu phải viết tay bằng chất liệu gì nên có thể chấp nhận di chúc viết bằng mực, bút bi, bút chì, bút lông, thậm chí là bằng máu nếu có cơ sở xác định chữ viết đó là của người để lại di sản*”¹⁶¹. Việc tự viết có thể viết bằng tay hoặc bằng chân nhưng thể hiện được ý chí của người để lại di sản dưới dạng ký hiệu chữ viết. Đối với điều kiện này việc quan trọng là xác định được đó có phải là chữ viết của người để lại di sản, người để lại di sản có tự viết không chứ không quan tâm đến chất liệu thể hiện của bản di chúc.

Điều kiện thứ hai, sau khi người lập di chúc tự mình viết bản di chúc thì họ phải ký vào bản di chúc. Nếu người để lại di sản đã tự tay mình viết di chúc mà không ký vào bản di chúc thì xem như không thỏa mãn điều kiện về hình thức. Có quan điểm còn cho rằng “*viết đủ nội dung mà chưa ký thì cũng vẫn chỉ là dự thảo*”¹⁶². Bởi lẽ ký tên vào di chúc được xem như việc khẳng định ý chí của người để lại di sản. Tác giả cũng cho rằng điều kiện chữ ký rất quan trọng. Chữ ký là yếu tố để khẳng định rằng người lập di chúc biết đọc, biết viết và đã hiểu rõ mình đang làm gì và đồng ý với toàn bộ nội dung di chúc đã được mình viết ra. Nếu một văn bản đã được người lập di chúc

¹⁵⁹ Chu Xuân Minh, “Di chúc hợp pháp không có công chứng, chứng thực”, <https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/di-chuc-hop-phap-khong-co-cong-chung-chung-thuc>, [truy cập 23/3/2021].

¹⁶⁰ Khoản 1 Điều 630 BLDS 2015.

¹⁶¹ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.455.

¹⁶² Chu Xuân Minh, *tlđđ* (số chú thích 159).

viết mà họ chưa ký thì có thể suy luận rằng đó chỉ là bản thảo và người lập di chúc có thể còn đang suy nghĩ về nội dung của bản di chúc. Ngoài ra, quy định về chữ ký là rất cần thiết nhằm đảm bảo cho việc giám định chữ viết và chữ ký trong tờ di chúc có phải đích thực là chữ viết của người để lại di sản hay không¹⁶³.

Thật ra, nếu quy định không chặt chẽ đối với việc lập di chúc bằng văn bản tự viết thì rất dễ xảy ra tranh chấp¹⁶⁴. Chữ ký là một trong những nội dung thường xảy ra tranh chấp đối với hình thức di chúc tự viết¹⁶⁵. Do vậy, bắt buộc trong di chúc tự lập cần phải có chữ ký. Nhưng nếu phải ký vào di chúc tự lập thì BLDS không quy định vị trí cần phải ký trong di chúc. Thông thường người viết sẽ ký vào phần cuối của bản di chúc¹⁶⁶. Và dù có không ký vào đoạn cuối của di chúc thì cũng không ảnh hưởng gì đến di chúc nếu di chúc đã có chữ ký.

Quy định về điều kiện “chữ ký” đã tạo ra khá nhiều quan điểm và tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu pháp luật. Nhiều quan điểm đặt vấn đề tại sao pháp luật lại chỉ quy định về chữ ký mà không cho phép người để lại di sản có thể điểm chỉ vào di chúc. Chữ ký hay điểm chỉ đã tạo ra hai luồng quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng *“nếu người lập di chúc đã tự tay viết vào bản di chúc nhưng không ký vào bản di chúc, mà thay vào đó là điểm chỉ vào bản di chúc, thì di chúc cũng không có giá trị”*¹⁶⁷. Bởi lẽ khi người để lại di sản đã có thể tự mình viết bản di chúc thì cũng sẽ không có gì khó cho họ khi họ cũng sẽ ký vào bản di chúc mà họ lập. Nếu cần giám định chữ viết sẽ căn cứ vào chữ viết trong di chúc do chính tay người để lại di sản lập ra cộng thêm chữ ký của họ trong di chúc thì di chúc đã quá đủ độ tin cậy. Ngoài ra, việc điểm chỉ chỉ cần thiết đối với những người không biết chữ, không viết, không ký được. Vì vậy, các nhà làm luật không quy định việc điểm chỉ trong loại di chúc này.¹⁶⁸ Quy định thủ tục như vậy sẽ rất đơn giản cho người để lại di sản.

Tuy nhiên, nhiều người mong muốn có thêm lựa chọn ngoài chữ ký và họ ủng hộ cho việc cho phép điểm chỉ vào bản di chúc. Những người ủng hộ cho quan điểm này xuất phát từ yếu tố khoa học. Họ cho rằng trên thực tế, tính xác thực của điểm chỉ cao hơn nhiều so với chữ ký nên nếu cần giám định thì điểm chỉ sẽ mang lại tính chính xác cao hơn. Do vậy những người theo quan điểm này ủng hộ việc pháp luật nên thừa nhận bên cạnh chữ ký vào di chúc thì có thể cho phép người để lại di sản được điểm chỉ vào bản di chúc.¹⁶⁹

¹⁶³ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.468.

¹⁶⁴ Nguyễn Hồng Nam (2005), *Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.69.

¹⁶⁵ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.456.

¹⁶⁶ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.455.

¹⁶⁷ Hoàng Thế Liên, *tlđđ* (số chú thích 152), tr.61.

¹⁶⁸ Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, *tlđđ* (số chú thích 45), tr.184.

¹⁶⁹ Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (2021), “Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 14 (438), tr.45-46.

Cũng giống pháp luật Việt Nam, pháp luật Nhật Bản cũng có di chúc tự lập. Luật Nhật Bản quy định về di chúc tự lập khá đơn giản: người để lại di sản phải tự mình viết bản di chúc, ghi ngày, tháng, năm lập di chúc, tên người lập di chúc và xác nhận vào bản di chúc¹⁷⁰. Đối với pháp luật Trung Quốc di chúc tự lập chỉ cần điều kiện người để lại di sản tự tay mình viết bản di chúc và ký tên vào bản di chúc¹⁷¹. Ở Pháp, di chúc tự lập phải đảm bảo được viết đầy đủ, ghi ngày, tháng, năm và có chữ ký của người lập di chúc nhưng hình thức của nó không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào¹⁷².

Với quy định của pháp luật các nước và của Việt Nam có thể thấy di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự lập luôn phải có đủ hai điều kiện, đó là: người lập di chúc tự tay mình viết bản di chúc và họ phải ký tên vào bản di chúc. Di chúc do người để lại di sản tự lập là loại hình thức di chúc bằng văn bản được lập một cách đơn giản, không tốn kém chi phí và người để lại di sản có thể giữ bí mật. Theo tác giả đây là loại hình di chúc có nhiều ưu điểm và nên là lựa chọn đầu tiên của người để lại di sản.

3.2.2. *Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về di chúc tự viết*

Thứ nhất, về tên gọi của di chúc tự viết

Hiện nay quy định tại Điều 634 BLDS 2015 gọi tên hình thức di chúc này là di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Cách gọi tên loại hình di chúc bằng văn bản không có người làm chứng bắt đầu từ quy định trong BLDS 1995. Tuy nhiên tên gọi “di chúc bằng văn bản không có người làm chứng” không thể hiện được bản chất của hình thức di chúc là phương tiện thể hiện ý chí của người để lại di sản mà đang đề cập đến điều kiện của hình thức di chúc này. Trước đây theo quy định của Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972 đặt tên hình thức di chúc này là “chức thư tự tả”¹⁷³, tức là di chúc bằng văn bản do chính người lập di chúc tự lập ra, đề ngày, tháng, năm và ký tên vào di chúc¹⁷⁴. Cách gọi tên như trong Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972 theo quan điểm của tác giả thể hiện đúng hình thức thể hiện của di chúc. Đây là di chúc được lập bằng văn bản do người để lại di sản tự lập.

Trong BLDS Trung Quốc 2020 có quy định di chúc do người lập di chúc tự viết và ký tên, ghi rõ ngày, tháng, năm được gọi tên là di chúc tự viết¹⁷⁵. Quy định trong BLDS Pháp 1804 về di chúc do người lập di chúc tự mình viết tay toàn bộ di chúc, ghi

¹⁷⁰ Điều 968 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

¹⁷¹ Điều 1134, 1135, 1136, 1139 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên (2021), *BLDS Trung Quốc 2020 - Bản dịch và lược giải*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.335).

¹⁷² Điều 970 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.240).

¹⁷³ Điều 573 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972.

¹⁷⁴ Điều 574 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972.

¹⁷⁵ Điều 1134 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

ngày, tháng, năm và ký tên với tên gọi là di chúc viết tay.¹⁷⁶ Tác giả cho rằng cách gọi tên về hình thức di chúc do chính bản thân người lập di chúc tự viết và ký tên vào bản di chúc là di chúc tự viết hay di chúc viết tay như trong BLDS Trung Quốc 2020 và BLDS 1804 Pháp là phù hợp. Tên gọi phải thể hiện rõ hình thức và điều kiện của hình thức di chúc thể hiện, bằng văn bản và tự tay người lập di chúc viết ra.

Với những lý do trên tác giả đề xuất tên gọi về hình thức di chúc này nên là **“di chúc tự viết”** thay cho tên gọi hiện nay tại Điều 634 BLDS 2015 là **“di chúc bằng văn bản không có người làm chứng”**.

Thứ hai, về vấn đề điểm chỉ trong di chúc tự viết

Điều 633 BLDS 2015 quy định *“Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc”*. Đối với loại di chúc này người lập di chúc phải tự viết vào bản di chúc mà không có người làm chứng. Việc thừa nhận hình thức di chúc tự tay người lập di chúc viết không cần người làm chứng có ưu điểm là có thể đảm bảo tính bí mật của bản di chúc; lúc này chỉ có người để lại di sản biết về nội dung của bản di chúc.

Tuy nhiên quy định tại Điều 633 BLDS 2015 bắt buộc người lập di chúc phải ký tên vào bản di chúc. Vậy trường hợp người để lại di sản không ký mà điểm chỉ vào bản di chúc có được không? Có quan điểm cho rằng *“nếu người lập di chúc đã tự tay viết văn bản di chúc nhưng không ký vào bản di chúc, mà thay vào đó là điểm chỉ vào bản di chúc, thì di chúc cũng không có giá trị pháp lý”*¹⁷⁷. Quan điểm này đang ủng hộ cho việc không thừa nhận điểm chỉ là một điều kiện thay thế cho việc ký tên vào di chúc. Nếu người lập di chúc không ký tên thì dù di chúc có được chính bản thân người đó viết, có điểm chỉ thì di chúc cũng không thỏa mãn điều kiện về hình thức. Dấu điểm chỉ là căn cứ để xác thực người lập di chúc nhưng chưa chắc chắn đó là căn cứ xác thực sự đồng ý của họ đối với bản di chúc. Nhưng cũng có quan điểm trái ngược cho rằng *“nên căn cứ vào ý chí đích thực của người lập di chúc, các quy định về hình thức chỉ để thể hiện nội dung không nên quá máy móc vào ngôn từ của điều luật”*¹⁷⁸. Hay BLDS cần ghi nhận điểm chỉ cũng là một điều kiện bên cạnh thay thế cho chữ ký để người lập di chúc có thể lựa chọn chữ ký hoặc điểm chỉ¹⁷⁹. Quan điểm này dường như lại theo hướng mở rộng hơn nữa điều kiện của di chúc tự viết. Theo quan điểm này thì bản di chúc không cần ký tên mà chỉ cần điểm chỉ cũng có thể được chấp nhận nếu di chúc đã thể hiện ý chí đích thực của người lập di chúc. Thậm chí có quan điểm xác định không cần chữ ký của người lập di chúc cũng được¹⁸⁰.

¹⁷⁶ Điều 970 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđd* (số chú thích 49), tr.240).

¹⁷⁷ Hoàng Thế Liên, *tlđd* (số chú thích 152), tr.61.

¹⁷⁸ Đỗ Văn Đại, *tlđd* (số chú thích 73), tr.458.

¹⁷⁹ Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Trần Khắc Qui (2021), *Pháp luật về điều kiện hợp pháp của di chúc*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Cần Thơ, tr.49-51.

¹⁸⁰ Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, *tlđd* (số chú thích 169), tr.46.

BLDS 2015 quy định bắt buộc cá nhân phải ký vào bản di chúc do mình tự lập để đảm bảo rằng họ đã xác nhận đây là bản di chúc của họ, xác nhận và đồng ý với những nội dung thể hiện trong bản di chúc. Mặc dù vậy chữ ký của một người có thể làm giả được hay không. Hiện nay “*không phải chữ ký của bất kỳ người nào trong xã hội cũng được đăng ký (số người đăng ký chữ ký chỉ chiếm số ít trong xã hội vì họ giữ những vị trí nhất định)*”¹⁸¹. Mặt khác “*chữ ký của con người có thể khác nhau theo thời gian, sức khỏe...*”¹⁸² và chữ ký của cá nhân có thể bị giả mạo. Ngược lại điểm chỉ có tính xác thực cao hơn so với chữ ký¹⁸³ vì “*điểm chỉ để lại dấu vân tay, mà dấu vân tay thì khoa học hình sự đã chứng minh tính cá biệt của nó*”¹⁸⁴. Tuy nhiên tác giả cho rằng, không thể khẳng định dấu vân tay có tính xác thực cao hơn chữ ký được vì chữ ký và dấu vân tay có chức năng khác nhau. Chữ ký thể hiện ý chí của người lập di chúc, còn dấu vân tay dùng để xác nhận chính bản thân người đó.

Trong thực tiễn xét xử, ở một bản án của Tòa án đã có nhận định “*hình thức 02 bản di chúc không có người làm chứng thì mỗi trang của di chúc phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc nhưng cả 2 bản di chúc đều không có chữ ký hoặc điểm chỉ của cụ Nguyễn H...*”¹⁸⁵. Trường hợp này với nhận định của Tòa án có thể thấy Tòa án vẫn xác định điểm chỉ có thể là một yếu tố tồn tại thay cho chữ ký của người để lại di sản trong bản di chúc. Nhưng di chúc trong vụ việc này không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc do đó Tòa án xác định di chúc vi phạm hình thức. Tòa án đã đưa ra nhận định điểm chỉ có thể là cách thay chữ ký nếu người để lại di sản không ký tên vào bản di chúc.

Ở một bản án khác, di chúc được người lập di chúc tự viết tay nhưng không ký mà điểm chỉ vào bản di chúc và Tòa án vẫn công nhận di chúc. Vụ việc cụ thể như sau: cụ Di tự lập bản di chúc bằng tiếng Hán và có điểm chỉ vào di chúc. Dấu vân tay trên bản di chúc của cụ đã được mang đi giám định và theo kết luận giám định số 21/GĐ-2009 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu thì đây là dấu vân tay của cụ. Do đó, Tòa phúc thẩm xác định di chúc do cụ Di lập thỏa mãn điều kiện về hình thức theo quy định của BLDS.¹⁸⁶ Trong trường hợp này Tòa án đã công nhận điểm chỉ là một điều kiện thay cho chữ ký của người lập di chúc. Bởi vì ở đây di chúc do cụ Di lập bằng tiếng Hán nên chữ ký và chữ viết dường như khó phân biệt đối với người Việt

¹⁸¹ Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ (2017), *Luật Dân sự 1*, Nxb. Đại học Cần Thơ, tr.146.

¹⁸² Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ, *tlđđ* (số chú thích 181), tr.146.

¹⁸³ Hồ Thị Vân Anh (2015), “Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế theo di chúc”, *Tạp chí Nghề luật*, số 2, 3/2015, tr.43 – 47.

¹⁸⁴ Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ, *tlđđ* (số chú thích 181), tr.146

¹⁸⁵ Bản án số 132/2017/DSST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-1322017dsst-ngay-28092017-ve-tranh-chap-chia-di-san-thua-ke-va-chia-tai-san-chung-12902>, [truy cập 21/2/2019].

¹⁸⁶ Bản án số 53/2010/DS-PT ngày 1/4/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.440-460.

Nam. Xét về thực tiễn xét xử có thể thấy Tòa án đang áp dụng điều kiện của di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự lập một cách linh hoạt, không quá máy móc đến yêu cầu về chữ ký của người lập di chúc.

Trên thực tế, có những người có thói quen viết nhưng không ký mà lại sử dụng điểm chỉ để thể hiện ý chí hoặc có những trường hợp do đặc tính của chữ viết (ví dụ như chữ Hán, chữ Nhật Bản) thì việc điểm chỉ sẽ phù hợp hơn so với chữ ký. Do vậy theo tác giả hướng giải quyết của Tòa án đối với di chúc của cụ Di là khá linh hoạt khi đã công nhận di chúc do cụ tự viết và cụ điểm chỉ vào bản di chúc. Tuy nhiên nếu luật ghi nhận điểm chỉ thay cho chữ ký sẽ có thể dẫn đến các trường hợp sau. Một người tự tay viết di chúc nhưng chưa ký, họ còn đang băn khoăn suy nghĩ về nội dung di chúc. Có thể khẳng định bản viết tay này chưa được xem là di chúc mà mới chỉ là bản thảo của di chúc. Sau đó trong di chúc có thể xuất hiện dấu điểm chỉ của người lập di chúc (do người khác dùng tay của người lập di chúc để điểm chỉ vào). Nếu di chúc này được công nhận thì không đảm bảo sự ghi nhận chính xác mong muốn của người lập di chúc.

Do đó theo quan điểm của tác giả, việc ghi nhận điểm chỉ là một điều kiện thay cho chữ ký là sự ghi nhận linh hoạt của luật khi có những người lập di chúc không muốn ký hoặc chữ viết trong ngôn ngữ của họ không tiện để ký. Nhưng trong những trường hợp này, cần có yêu cầu về lời chứng của người lập di chúc trong bản di chúc để thể hiện ý chí xác định họ đã thể hiện sự đồng ý và công nhận di chúc. Quy định theo hướng này bổ sung thêm sự lựa chọn cho người lập di chúc bên cạnh chữ ký là điểm chỉ, giúp cho việc lập di chúc được thuận lợi hơn và cũng tránh rủi ro khi di chúc có thể mới chỉ là bản thảo (do người lập di chúc bị động trong việc điểm chỉ vào bản di chúc). Lời chứng khẳng định trong di chúc để đảm bảo di chúc là sự ghi nhận chính xác ý chí và mong muốn của người lập di chúc.

Thứ ba, về việc lựa chọn ngôn ngữ của người lập di chúc

BLDS 2015 không giới hạn ngôn ngữ của di chúc do vậy có thể suy luận người lập di chúc có thể lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ nào để tự mình viết di chúc. Trong trường hợp nếu di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng, chứng thực khi công bố di chúc¹⁸⁷. Quy định này là sự tiến bộ khi so sánh với BLDS 1995 và 2005. Quy định trước đó có khẳng định “người dân tộc thiểu số có quyền lập di chúc bằng chữ viết hoặc tiếng nói của dân tộc mình”¹⁸⁸ được đánh giá là có sự phân biệt với nhóm người dân tộc thiểu số và làm nhiều người hiểu sai di chúc bị giới hạn ở chữ viết phải là tiếng Việt.

Pháp luật của các nước cũng không hạn chế ngôn ngữ được thể hiện trong bản di chúc. BLDS Tây Ban Nha 2012 cho phép người nước ngoài được lập di chúc bằng

¹⁸⁷ Khoản 5 Điều 647 BLDS 2015.

¹⁸⁸ Điều 652 BLDS 1995, Điều 649 BLDS 2005.

tiếng nước ngoài và cũng không ngụ ý bắt người bản địa phải lập di chúc bằng tiếng Tây Ban Nha¹⁸⁹. Ở những nước khác thậm chí còn cho phép lập di chúc bằng những ngôn ngữ ít hoặc không còn sử dụng như tiếng Latinh hoặc Hy Lạp cổ đại nhưng không cho phép lập di chúc bằng ngôn ngữ do chính người lập di chúc phát minh¹⁹⁰. Quy định cho phép được lựa chọn ngôn ngữ mà người lập di chúc muốn thể hiện trong di chúc là một quy định trao quyền tự do lựa chọn ngôn ngữ lập di chúc cho người lập di chúc. Tuy nhiên nếu như một người lập di chúc bằng ngôn ngữ mà họ không biết, không thành thạo hoặc một di chúc có nhiều ngôn ngữ đan xen, trộn lẫn thì có thể ảnh hưởng đến tính xác thực của di chúc.

Xét về mặt bản chất, di chúc do người lập di chúc tự viết nên nếu đây là ngôn ngữ họ không biết hoặc không thành thạo thì có quyền nghi ngờ về tính xác thực của nội dung di chúc. Bởi lẽ nếu người lập di chúc không biết hoặc không thành thạo về ngôn ngữ đó mà họ lại sử dụng ngôn ngữ này để thể hiện ý chí của mình là không hợp lẽ tự nhiên và di chúc không thể nào phản ánh đúng ý chí của họ. Do vậy theo quan điểm của tác giả đối với di chúc tự lập, một điều kiện quan trọng bên cạnh chữ viết, ký tên chính là việc người lập di chúc phải biết ngôn ngữ mà họ thể hiện trong di chúc mới đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc. Bên cạnh đó, trường hợp một di chúc được lập bởi nhiều ngôn ngữ đan xen mà người lập di chúc đều biết về ngôn ngữ đó thì theo quan điểm của tác giả nếu nội dung di chúc có thể hiểu được, không gây nhầm lẫn và có thể xác định được ý chí của người lập di chúc về tài sản định đoạt trong di chúc, về người được hưởng di sản, về các điều kiện đặt ra cho người được hưởng thì nên công nhận di chúc.

Vì vậy, đối với di chúc tự lập ngoài điều kiện về chữ viết, chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc thì ngôn ngữ lập di chúc cũng là một điều kiện cần thiết để đảm bảo di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc.

Kết luận: trên cơ sở các bất cập về tên gọi, về vấn đề điểm chỉ và về ngôn ngữ cho di chúc tự lập đã được phân tích ở trên, tác giả đề xuất quy định tại Điều 633 BLDS 2015 cần được ghi nhận như sau ***“Điều 633. Di chúc tự viết. Người lập di chúc phải tự viết và ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Trong trường hợp di chúc được điểm chỉ cần có lời chứng khẳng định sự đồng ý và công nhận di chúc của người lập di chúc. Người lập di chúc phải biết ngôn ngữ được chính họ thể hiện trong di chúc.”***

Điều 633 BLDS 2015 khi được sửa đổi, bổ sung sẽ giải quyết được các vấn đề sau đây:

Tên gọi của hình thức di chúc sẽ sát với ngôn từ của điều luật và loại hình thức di chúc.

¹⁸⁹ Điều 684 BLDS Tây Ban Nha 2012 (tác giả tạm dịch).

¹⁹⁰ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.480.

Luật đã linh hoạt hơn khi ghi nhận điểm chỉ có thể là một điều kiện thay thế cho chữ ký để tạo điều kiện thuận lợi cho người lập di chúc trong quá trình lập di chúc. Tuy nhiên để đảm bảo di chúc được lập ghi nhận đúng mong muốn của người lập di chúc thì trường hợp này cần có thêm lời chứng khẳng định của người lập di chúc.

Để đảm bảo di chúc tự lập thể hiện ý chí của người lập di chúc thì họ cần biết ngôn ngữ mà họ sẽ tự tay viết trong di chúc.

Thứ tư, vấn đề giám định chữ viết khi không có mẫu giám định đối chứng hoặc tổ chức giám định không kết luận được

Chữ viết của người lập di chúc là điều kiện quan trọng đối với di chúc do người lập di chúc tự lập. Trong những trường hợp nghi ngờ về tính xác thực của di chúc, di chúc sẽ được giám định chữ viết khi so sánh với những mẫu văn bản khác mà người lập di chúc đã từng viết. Trong một bản án được Tòa án xét xử, Tòa án cũng căn cứ vào kết quả giám định chữ viết và chữ ký để xác định đây có phải là di chúc do ông X để lại hay không do nguyên đơn cho rằng di chúc là giả mạo, không phải do X viết. Trong bản án xác định “Mặt khác, tại kết luận giám định số 1700/KLGĐ ngày 28/8/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: chữ ký dạng chữ viết “X” và các chữ Hoàng Minh X trên “bản di chúc” (tài liệu cần giám định ký hiệu A) so với chữ ký dạng chữ viết “X” và các chữ Hoàng Minh X dưới mục “Người xin; Đại diện gia đình; Người viết đơn ký tên; Người khai; Người làm đơn” trên “Đơn xin trợ cấp; Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn; Đơn đề nghị giải quyết chất độc da cam; Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần; Đơn xin vào Hội Cựu chiến Binh kết hợp sơ yếu lý lịch” (tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1.M2.M3.M4.M5) là do cùng một người ký và viết ra.”¹⁹¹ Tòa án xác định có căn cứ đây chính là di chúc do X để lại và hướng giải quyết này theo tác giả là phù hợp.

Ở vụ việc thứ hai, Tòa án dựa vào bản kết luận giám định số 2671/GĐ-C54 ngày 27/11/2015 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (BL157) và bản kết luận giám định số 2067/C54B ngày 06/10/2016 của Học viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh (BL 261) đều kết luận “*Không đủ cơ sở/không kết luận được chữ ký và chữ viết mang tên Nguyễn Đình M trên tờ di chúc lập ngày 06/8/2014 so với chữ viết và chữ ký trên các mẫu so sánh có phải do cùng một người ký, viết ra hay không*”. Như vậy, bản di chúc lập ngày 06/8/2014 không đảm bảo đầy đủ về mặt hình thức, nội dung theo quy định và cũng không đủ căn cứ để xem xét đối với chữ ký và chữ viết trên di chúc, nên xét yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Đình T3 là có cơ sở chấp nhận, không công nhận bản di chúc lập ngày 06/8/2014 của ông Nguyễn Đình M là hợp pháp.¹⁹² Khi có nghi ngờ về chữ viết hoặc chữ ký trong di chúc, thông thường

¹⁹¹ Bản án số 14/2017/DSST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện C tỉnh Phú Thọ, <https://congboanan.toaan.gov.vn/2ta40641t1cvn/chi-tiet-ban-an> [truy cập 19/8/2020].

¹⁹² Bản án số 113/2019/DS-PT ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Phụ lục I).

sẽ tiến hành giám định so sánh với những văn bản khác để xác định chữ viết trong di chúc. Do đây là di chúc tự tay viết nên yêu cầu phải tự viết bản di chúc là cần thiết để đánh giá tính chính xác của bản di chúc. Bản án này Tòa án đã căn cứ vào giám định chữ viết, chữ ký trong bản di chúc và chữ viết, chữ ký trong những văn bản khác mà người để lại di sản đã ký để so sánh và đưa ra kết luận.

Tuy nhiên nếu không còn mẫu giám định để đối sánh hoặc có mẫu đối sánh nhưng tổ chức giám định không giám định được thì sẽ phải giải quyết như thế nào, công nhận hay không công nhận di chúc. Yếu tố chữ viết là điều kiện quan trọng để xác định tính xác thực của nội dung di chúc. Tuy nhiên, trên thực tế khi không thể và không có cơ sở để xác định yếu tố chữ viết thì Tòa án có thể căn cứ vào những bằng chứng khác để xác định đây có phải là di chúc do người lập di chúc viết hay không. Thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật khi giải quyết các tranh chấp về di chúc Tòa án đã thể hiện sự linh động của mình trong quá trình xét xử, đã có những bản án Tòa án căn cứ vào nhiều yếu tố để xác định ý chí của người để lại di sản và căn cứ vào đó để công nhận di chúc. Tòa án có thể căn cứ vào những hành vi của người lập di chúc vào thời điểm họ còn sống, căn cứ vào lời khai của những thân, người quen trong gia đình để xác định ý chí của người lập di chúc khi họ còn sống. Trong một vụ việc cụ thể Tòa án đã căn cứ vào hành vi khi còn sống của người lập di chúc để xác định ý chí của người lập di chúc. Lúc còn sống người lập di chúc đã từng đi làm thủ tục sang tên nhà, quyền sử dụng đất cho người con nhưng còn thiếu giấy tờ nên chưa thể hoàn tất các thủ tục. Ngoài ra, người lập di chúc có nói mong muốn để lại nhà và đất của mình cho người con cho nhiều người khác nghe. Sau này khi người lập di chúc chết và trong nội dung có di chúc cho chính người con này được thừa kế mà di chúc lại không thỏa mãn điều kiện về hình thức thì Tòa án vẫn công nhận di chúc.¹⁹³

Nếu Tòa án giải quyết theo hướng khác là không công nhận di chúc do chữ viết không có cơ sở để đối sánh thì sẽ là một hướng giải quyết không hợp lý khi đã có những bằng chứng chứng minh ý chí của người lập di chúc. Hướng giải quyết này không đảm bảo được vai trò của hình thức di chúc là một phương thức ghi nhận ý chí của người lập di chúc. Theo quan điểm của tác giả nếu không thể giám định chữ viết thì Tòa án có thể căn cứ vào các bằng chứng thực tế khác như đã liệt kê ở trên để xác thực ý chí của người lập di chúc. Từ đó nếu có cơ sở đảm bảo rằng đây chính xác là ý

¹⁹³ Các bản án được sử dụng ở đây có di chúc được lập không phải là hình thức di chúc tự viết nhưng các bản án này được tác giả sử dụng để chỉ rõ sự linh hoạt trong quá trình áp dụng pháp luật của Tòa án và có thể dựa vào hướng xét xử này để Tòa án khi giải quyết những vụ việc tương tự trong tương lai có di chúc được người để lại di sản tự lập nhưng không có hoặc không xác định được mẫu giám định đối chứng về chữ viết vẫn có thể mạnh dạn công nhận di chúc nếu có bằng chứng chứng minh ý chí đích thực của người để lại di sản. Bản án số 296/2017/DSPT ngày 12/10/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-yeu-cau-tuyen-bo-di-chuc-khong-hop-phap-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-va-chia-thu-46672> [truy cập 21/7/2019]. Bản án số 21/2019/DSST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (Phụ lục II). Quyết định sơ thẩm số 01/2022/QĐST-VDS ngày 17/1/2022 của Tòa án nhân dân huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc (Phụ lục III).

chí của người lập di chúc thì di chúc cần phải được ghi nhận. Hướng giải quyết của thực tiễn sẽ đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình áp dụng pháp luật cũng như đảm bảo bảo vệ ý chí của người lập di chúc.

Như vậy, trong trường hợp nếu không giám định được chữ viết khi không có mẫu giám định đối chứng hoặc tổ chức giám định không kết luận được thì tác giả đề xuất Tòa án trong quá trình áp dụng pháp luật cần linh hoạt xem xét đến các bằng chứng khác để chứng minh ý chí đích thực của người để lại di sản. Trường hợp nếu có thể chứng minh được ý chí của người để lại di sản trước khi họ chết trùng lặp với nội dung di chúc thì cần công nhận di chúc đã lập.

Thứ năm, về việc xác định các yếu tố cấu thành hình thức di chúc

Xét về mặt lý luận, hình thức di chúc và nội dung di chúc có mối quan hệ với nhau để tạo nên một bản di chúc. Nội dung di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc còn hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận và lưu giữ ý chí đó. Tuy nhiên hiện nay quy định trong BLDS 2015 đang gây nhầm lẫn khi có một số yếu tố bắt buộc phải có trong một bản di chúc được xác định là nội dung di chúc. Quy định tại Điều 631 BLDS 2015 xác định nội dung của di chúc phải có ngày, tháng, năm lập di chúc. Đây là yếu tố bắt buộc cần phải có trong một bản di chúc để xác định được di chúc lập vào thời điểm nào. Dựa vào ngày, tháng, năm lập di chúc có thể xác định bản di chúc nào có hiệu lực pháp luật (nếu người lập di chúc để lại nhiều bản di chúc), xác định được thời điểm lập di chúc để xác thực lại di chúc. Nhưng yếu tố này có phải là nội dung trong bản di chúc hay đây chính là hình thức của di chúc.

Ngoài ra, các yếu tố khác như không được viết tắt, viết bằng ký hiệu, đánh số trang và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ ở từng trang, việc tẩy xóa trong di chúc chính là yêu cầu về hình thức của di chúc. Đây chính là yêu cầu của một thể thức thể hiện của văn bản nói chung, là các yếu tố cấu thành hình thức của văn bản chứ không phải nội dung của văn bản. Hiện nay quy định của Điều 631 BLDS 2015 đang xác định các yếu tố này là nội dung của di chúc.

Trong BLDS Trung Quốc 2020 tại Điều 1134 có quy định di chúc do người lập di chúc tự tay viết và ký tên phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập di chúc¹⁹⁴. Quy định trong BLDS Pháp về di chúc do người lập di chúc tự mình viết tay toàn bộ di chúc và cũng phải ghi ngày, tháng, năm¹⁹⁵. Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972 cũng quy định người lập di chúc tự tay viết ra, đề ngày, tháng, năm vào di chúc¹⁹⁶. BLDS Nhật Bản 1896 xác định di chúc phải có ngày, tháng, năm lập di chúc trong di chúc tự

¹⁹⁴ Điều 1134 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

¹⁹⁵ Điều 970 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch BLDS Pháp, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.240).

¹⁹⁶ Điều 574 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972.

lập¹⁹⁷. Với các quy định này có thể thấy pháp luật các nước đều xác định yếu tố ngày, tháng, năm là hình thức của di chúc không phải là nội dung di chúc.

Do vậy, theo quan điểm của tác giả những quy định về ngày, tháng, năm lập di chúc; yêu cầu về viết tắt viết bằng ký hiệu hoặc đánh số trang; yêu cầu về điều kiện của việc tẩy xóa là những quy định về hình thức di chúc chứ không phải nội dung di chúc theo như quy định tại Điều 631 BLDS 2015. Từ những phân tích trên, tác giả đề xuất quy định tại Điều 631 BLDS 2015 cần lược bỏ nội dung được quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3. Những nội dung trong các điểm, khoản của điều này được ghi nhận tại Điều 627 BLDS 2015. Do vậy Điều 627 BLDS 2015 quy định cụ thể như sau **“Điều 627. Hình thức của di chúc. 1. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. 2. Di chúc phải ghi ngày, tháng, năm lập di chúc. 3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.”**

3.3. Di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy

3.3.1. Quy định pháp luật về di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy

Di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy được quy định tại Điều 634 BLDS 2015 với tên gọi là di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Đây là di chúc cần có sự tham dự thêm của người làm chứng, người viết hộ bên cạnh người để lại di sản. Khác với hình thức di chúc bằng văn bản do người lập di chúc tự lập có thể được giữ bí mật; nội dung của di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy sẽ bị tiết lộ cho người viết hộ, người làm chứng do đó đây là di chúc khó giữ được bí mật nội dung của di chúc. Người để lại di sản có thể tự mình đánh máy bản di chúc và in ra hoặc người để lại di sản nhờ người khác lập hộ di chúc. Khi đó người để lại di sản có thể lập di chúc thông qua hai cách sau đây:

Cách thứ nhất, người để lại di sản tự mình đánh máy bản di chúc. Đối với trường hợp này không cần người viết hộ di chúc mà chỉ cần hai người làm chứng chứng kiến việc lập di chúc. Người để lại di sản in bản di chúc và ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Sau đó đến lượt người làm chứng xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di sản và ký tên vào bản di chúc.

Cách thứ hai, người để lại di sản nhờ người viết hộ viết hoặc đánh máy bản di chúc. Sau đó, người viết hộ in bản di chúc và yêu cầu người để lại di sản ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt người làm chứng. Những người làm chứng cũng ký vào bản di chúc sau khi xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

¹⁹⁷ Điều 968 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

Hiện nay quy định về hình thức di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy tạo thuận lợi cho người để lại di sản không tự mình viết di chúc nhưng cũng không cần phải công chứng, chứng thực di chúc. Họ có thể nhờ người khác viết hoặc thông qua bản đánh máy in ra để thể hiện ý chí của mình. Để đảm bảo thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản, tránh trường hợp gian dối, giả mạo di chúc; người làm chứng phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người để lại di sản. Do vậy, đối với loại hình thức di chúc này người làm chứng đóng vai trò quan trọng để chứng minh tính xác thực của di chúc, đảm bảo di chúc có thể phát sinh hiệu lực. Nếu người làm chứng không đáp ứng điều kiện thì sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý là di chúc vô hiệu.¹⁹⁸

Hiểu theo nghĩa thông thường, người làm chứng là người chứng kiến sự việc một cách độc lập, không bị bất cứ yếu tố khách quan cũng như chủ quan nào tác động để xác nhận chính xác sự kiện xảy ra. Đối với việc lập di chúc, người làm chứng là người chứng kiến và xác nhận sự kiện truyền tải ý chí của người để lại di sản vào di chúc. Họ có thể đồng thời là người ghi nhận nội dung di chúc hoặc chỉ là người chứng kiến để xác nhận sự kiện đó. Người làm chứng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho người để lại di sản có thể thể hiện ý chí của mình, đảm bảo cho di chúc ghi nhận chính xác sự định đoạt tài sản của người để lại di sản. *Ở nhiều quốc gia, những người làm chứng tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong luật về các hình thức của di chúc*¹⁹⁹.

Người làm chứng đã được xuất hiện trong pháp luật Việt Nam từ rất lâu. Quy định về người làm chứng là một trong những điều kiện nhỏ nhưng quan trọng để hoàn thiện về mặt hình thức của di chúc²⁰⁰. Quy định này nhỏ vì không phải loại hình thức di chúc nào cũng cần có sự xuất hiện của người làm chứng. Chẳng hạn như di chúc do người lập di chúc tự mình viết bản di chúc sẽ không cần có sự xuất hiện của người làm chứng. Đối với di chúc tự lập, người để lại di sản có thể tự họ thể hiện ý chí bằng chữ viết và chữ ký nên không cần sự chứng kiến của người làm chứng. Tuy nhiên, quy định về người làm chứng lại khá quan trọng vì đối với những di chúc được lập cần có sự chứng kiến của người làm chứng thì vai trò của người này không thể thiếu được. Họ là những người giám sát quá trình lập di chúc, giám sát sự thể hiện nội dung di chúc và xác nhận di chúc đó đảm bảo đúng ý chí của người để lại di sản. Do vậy để có thể đảm bảo nhiệm vụ quan trọng này, pháp luật một số nước còn giới hạn người làm chứng không thể là những người sau đây: “người có đầu óc không minh mẫn hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự”, “người bị điếc, bị câm hoặc bị mù”²⁰¹, “những

¹⁹⁸ Nguyễn Thị Hồng Vân (2020), “Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc”, *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 335, tr.15.

¹⁹⁹ Kenneth G C Reid, Marius J de Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.457.

²⁰⁰ Hoàng Thị Loan (2016), “Một số bất cập và hướng hoàn thiện quy định về hình thức của di chúc trong Bộ luật Dân sự”, *Tạp chí Luật học*, số 11/2016, tr.42.

²⁰¹ Khoản 2, khoản 3 Điều 1670 BLDS Thương mại Thái Lan (được dịch từ *Bản dịch - Bộ luật Dân sự, Thương mại Thái Lan* (1995), Nxb. Chính trị quốc gia, tr.479).

người không biết ngôn ngữ của người lập di chúc”²⁰² hay *“cả hai vợ chồng không thể cùng làm chứng trong một di chúc”*²⁰³, Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972 cũng có quy định tương tự²⁰⁴. Ở Pháp, *“người làm chứng phải biết tiếng Pháp”*²⁰⁵.

Ở Việt Nam, quy định trong BLDS 2015 theo hướng liệt kê những người không được là người làm chứng di chúc. Quy định tại Điều 632 BLDS 2015 về người làm chứng cho việc lập di chúc mang tính loại trừ những người không được làm người làm chứng di chúc. Tuy nhiên dù vẫn tiếp nối nguyên tắc loại trừ trong việc ghi nhận người làm chứng trong các văn bản pháp luật trước đó, BLDS 2015 đã có sự thay đổi. Quy định tại hai khoản đầu tiên của điều luật được giữ nguyên so với quy định trong BLDS 2005. Sự thay đổi đó được thể hiện ở khoản 3 từ nhóm đối tượng *“người chưa đủ 18, người không có năng lực hành vi dân sự”* được chuyển thành *“người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”*. Việc thay đổi nhóm đối tượng trong khoản 3 Điều 632 BLDS 2015 theo hướng mở rộng hơn những người không được là người làm chứng và tránh lặp lại cùng một nhóm đối tượng. Sự thay đổi thứ nhất là từ người chưa đủ 18 tuổi sang người chưa thành niên là sự thay đổi thuật ngữ nhưng đây vẫn là cùng một nhóm đối tượng. Cách thay đổi thuật ngữ này đảm bảo sự thống nhất trong cách quy định của luật²⁰⁶. Sự thay đổi thứ hai là người không có năng lực hành vi dân sự không được quy định mà bổ sung thêm hai nhóm người khác là người mất năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Cách sửa đổi nhóm đối tượng này cũng là phù hợp vì người không có năng lực hành vi dân sự là người chưa đủ 6 tuổi. Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi, sẽ bao gồm cả người chưa đủ 6 tuổi. Nếu giữ lại nhóm người không có năng lực hành vi dân sự thì sẽ bị trùng với nhóm người chưa thành niên. Mặt khác, để những người có năng lực hành vi dân sự đặc biệt như người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi không thuộc nhóm loại trừ không được là người làm chứng. *Do vậy việc sửa đổi quy định tại khoản 3 về người làm chứng được đánh giá là hợp lý hơn so với quy định trước đó trong BLDS 2005*²⁰⁷.

Số lượng người làm chứng phải có ít nhất hai người đối với di chúc đánh máy in ra hoặc nhờ người viết hộ hoặc đánh máy hộ di chúc²⁰⁸. Quy định về số lượng người làm chứng đảm bảo sự khách quan trong việc làm chứng nếu thấy cần thiết. Một người làm chứng sẽ dẫn đến sự không khách quan, có thể bị ghi nhận sai lệch ý chí của người

²⁰² Khoản 3 Điều 681 BLDS Tây Ban Nha 2012 (tác giả tạm dịch).

²⁰³ Điều 980 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.242).

²⁰⁴ Điều 579 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972.

²⁰⁵ Điều 980 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.242).

²⁰⁶ Điều 21 BLDS 2015.

²⁰⁷ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.575.

²⁰⁸ Điều 634 BLDS 2015.

để lại di sản trừ trường hợp di chúc chỉ cần một người làm chứng là di chúc có công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực di chúc chứng kiến²⁰⁹.

Trong quá trình lập di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy di chúc, những người làm chứng phải có mặt để chứng kiến quá trình lập di chúc, chứng kiến người để lại di sản ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Nếu không có mặt đồng thời thì không thể xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ trong bản di chúc vì việc ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc chỉ diễn ra ở một thời điểm²¹⁰. Sau đó “*người làm chứng phải xác nhận cả chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc và nên xác nhận thêm là di chúc được viết phù hợp với những tuyên bố của người lập di chúc nếu có người viết giúp hay đánh máy hộ. Nếu người làm chứng không làm chứng một công đoạn của việc lập di chúc thì di chúc không hợp pháp*”.²¹¹

Bên cạnh người làm chứng thì hình thức di chúc nhờ người khác lập cũng cần thêm một người nữa chính là người viết hộ di chúc. Pháp luật Việt Nam hiện nay không quy định rõ là một trong số hai người làm chứng hay phải là một người khác ngoài hai người làm chứng ra là người viết hộ. Với quy định trong BLDS 2015 tại Điều 634 “*trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể...nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng.*” có thể hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất, nếu hiểu theo nghĩa khẳng định thì người viết hộ được nhờ viết bản di chúc không thể là người làm chứng nên để lập di chúc nhờ người khác viết hoặc đánh máy hộ thì ngoài người viết hộ phải có sự chứng kiến của ít nhất hai người làm chứng. Cách thứ hai, nếu hiểu để có thể vận dụng điều luật một cách linh hoạt hơn có thể giải thích theo hướng người viết hộ có thể là một trong hai người làm chứng. Điều 634 BLDS 2015 chỉ đòi hỏi ở điều kiện phải có ít nhất hai người làm chứng và những người làm chứng phải thỏa mãn điều kiện theo Điều 655 BLDS 2015. Ngoài ra, trong BLDS 2015 đã không nêu về điều kiện của người viết hộ di chúc có nghĩa rằng người viết hộ di chúc có thể là bất kỳ ai chỉ cần đảm bảo được rằng họ có khả năng ghi nhận lại (viết hoặc đánh máy) ý chí của người để lại di sản. Tuy nhiên có thể xác định nhiệm vụ của người viết hộ là ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản vào bản giấy hoặc đánh máy di chúc. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng “*cần phải có sự quy định hoặc hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện của người viết hộ di chúc*”²¹². Hoặc có quan điểm khẳng định hơn thì xác định người viết hộ di chúc không thể là người làm chứng di chúc để đảm bảo người viết hộ di chúc viết đúng ý kiến của người lập di chúc dưới sự chứng kiến của người làm chứng²¹³.

²⁰⁹ Điều 636 BLDS 2015.

²¹⁰ Nguyễn Văn Tiến (2017), “Hình thức di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 – Một số vấn đề cần hoàn thiện”, *Tạp chí Khoa học kiểm sát*, số 3, tr.44.

²¹¹ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.487.

²¹² Nguyễn Hồng Nam, *tlđđ* (số chú thích 164), tr.23.

²¹³ Hoàng Thế Liên, *tlđđ* (số chú thích 152), tr.63.

Tác giả cho rằng với quy định tại Điều 634 BLDS 2015 nên giải thích theo hướng linh hoạt như sau: người viết hộ có thể là bất kỳ ai bên cạnh người làm chứng chứng kiến sự kiện lập di chúc. Người viết hộ có thể là người thừa kế, có thể là người chưa thành niên chỉ cần đảm bảo họ có thể chuyển tải đúng ý chí của người để lại di sản vào văn bản. Ngoài ra, người viết hộ có thể đồng thời là người làm chứng và nếu người viết hộ đồng thời được xác định là người làm chứng thì họ phải thỏa mãn các điều kiện của người làm chứng.

Tóm lại có thể khẳng định, di chúc do người để lại di sản tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy không cần người để lại di sản phải tự mình viết bản di chúc nhưng cần thêm điều kiện về người làm chứng, người viết hộ di chúc để chứng kiến và xác nhận di chúc. Đối với hình thức di chúc này khó có thể giữ bí mật nội dung di chúc nhưng sẽ có người hỗ trợ và chứng kiến quá trình lập di chúc.

Trên thực tế có những người lập di chúc thông qua sự hỗ trợ, tư vấn của một luật sư cá nhân. Luật sư là những người am hiểu và có kiến thức chuyên môn về quy định của luật nên sẽ đảm bảo cho việc lập di chúc được thực hiện đúng về các điều kiện và trình tự, thủ tục. Người lập di chúc cũng có thể tham khảo và thông qua sự hỗ trợ của công ty luật để soạn thảo di chúc. Công ty luật sẽ cử một luật sư hỗ trợ, tư vấn cho người để lại di sản để họ có thể lập di chúc một cách dễ dàng và trình tự thủ tục lập đúng quy định của luật. Công ty luật sẽ có thu phí cho những hoạt động tư vấn này. Đối với hoạt động lập di chúc thông qua sự hỗ trợ, tư vấn của văn phòng luật sư thì luật sư tư vấn sẽ là người viết thay cho người để lại di sản. Tác giả cho rằng đây chính là hình thức di chúc nhờ người viết hộ di chúc. Người viết hộ di chúc chính là luật sư tư vấn trực tiếp và viết thay di chúc cho người để lại di sản. Theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Luật sư 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015) có quy định luật sư được thực hiện tư vấn pháp luật. Do vậy việc thu phí của văn phòng luật sư là chi phí cho hoạt động tư vấn cho việc lập di chúc. Về dịch vụ pháp lý khác của luật sư tại Điều 30 Luật Luật sư có quy định cho phép luật sư *“xác nhận giấy tờ, các giao dịch hoặc giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác”*. Như vậy, theo quy định tại Điều 30 của Luật Luật sư và nếu xét đến vai trò, chức năng và nhiệm vụ của người làm chứng là để chứng kiến, xác nhận sự việc và nội dung di chúc thì luật sư chính là người làm chứng bên cạnh tư vấn cho việc lập di chúc. BLDS cũng như Luật Luật sư cũng không cấm người làm chứng không thể là luật sư thực hiện hoạt động tư vấn. Người làm chứng trong trường hợp này cũng chính là luật sư tư vấn trực tiếp chứ không phải văn phòng luật sư bởi lẽ việc làm chứng là nhiệm vụ chỉ cá nhân thực hiện được mà không phải dành cho pháp nhân.

Pháp luật Trung Quốc cũng có hai quy định có thể được xem là tương tự với pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết,

đánh máy đó là di chúc viết thay²¹⁴ và di chúc được in ra²¹⁵. Quy định trong pháp luật Trung Quốc về hình thức di chúc bằng văn bản loại này cũng không quá phức tạp và cũng không đưa ra quá nhiều điều kiện khắt khe về trình tự, thủ tục lập di chúc. Đối với pháp luật Trung Quốc quy định rất rõ về vấn đề làm chứng và viết hộ di chúc. Một bản di chúc nhờ người khác viết hộ cần có ít nhất hai người làm chứng và một trong hai người này sẽ là người viết bản di chúc. Sau đó người để lại di sản và người làm chứng, người viết hộ cùng ký tên vào bản di chúc có ghi ngày tháng năm lập di chúc vào từng trang.²¹⁶ Quy định trong pháp luật của Trung Quốc xác định người viết hộ di chúc đồng thời là người làm chứng và phải thỏa mãn những điều kiện của người làm chứng di chúc. Do đó đối với hình thức di chúc bằng văn bản có người viết hộ thì bên cạnh người viết hộ di chúc chỉ cần thêm một người làm chứng nữa là đủ.

Di chúc bằng văn bản đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy là một quy định mang tính cởi mở tạo điều kiện cho người để lại di sản có thêm sự lựa chọn khi để lại di sản theo di chúc mà cũng không tốn kém, có người thứ ba chứng kiến để xác thực nội dung di chúc nên di chúc đảm bảo được ý chí đích thực của người để lại di sản.

3.3.2 Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy

Thứ nhất, về cách gọi tên hình thức di chúc được đánh máy in ra hoặc nhờ người khác viết, đánh máy in ra.

Hiện nay quy định tại Điều 634 BLDS 2015 gọi tên hình thức di chúc này là di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Cách gọi tên loại hình di chúc này bắt đầu từ quy định trong BLDS 1995. Tuy nhiên cách gọi tên “di chúc bằng văn bản có người làm chứng” không thể hiện được bản chất của hình thức di chúc là phương tiện thể hiện ý chí của người để lại di sản mà đang đề cập đến điều kiện của hình thức di chúc. Mặt khác nếu đặt tên như vậy sẽ dễ nhầm lẫn với trường hợp di chúc của người bị hạn chế thể chất hoặc của người không biết chữ. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ cũng phải có người làm chứng nhưng sẽ có thêm điều kiện về công chứng hoặc chứng thực di chúc theo quy định tại khoản 3 Điều 630 BLDS 2015.

Ngoài ra, để có sự thống nhất trong mối quan hệ tương đồng về tên gọi giữa các loại hình thức di chúc bằng văn bản thì theo tác giả tên gọi của hình thức di chúc này nên được thay đổi. Hiện nay quy định tại Điều 633 BLDS 2015 về di chúc bằng văn

²¹⁴ Điều 1135 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

²¹⁵ Điều 1136 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

²¹⁶ Điều 1135 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

bản không có người làm chứng đã được tác giả kiến nghị nên được gọi tên là di chúc tự viết, Điều 635 BLDS 2015 gọi tên di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, Điều 638 BLDS 2015 gọi tên hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Tất cả các tên gọi của các loại hình di chúc bằng văn bản này đều sát nghĩa với hình thức thể hiện của di chúc.

BLDS Trung Quốc 2020 có hình thức di chúc tương tự như của Việt Nam nhưng được gọi tên là di chúc viết thay và di chúc được in ra. Đây là di chúc do một trong hai người làm chứng viết thay và những người làm chứng, người lập di chúc ký tên, ghi rõ ngày, tháng, năm lập di chúc.²¹⁷ Cách gọi tên như BLDS Trung Quốc 2020 là phù hợp thể hiện được tính chất của hình thức di chúc đó và sát nghĩa với nội dung điều luật.

Do vậy theo quan điểm của tác giả Điều 634 BLDS 2015 cần thay đổi tên gọi của điều luật thành ***“Điều 634. Di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy”*** thay cho tên gọi ***“Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng”***.

Thứ hai, về điều kiện của người làm chứng cho việc lập di chúc

(i) Người thừa kế theo pháp luật nên được phép làm chứng cho việc lập di chúc

Khoản 1 Điều 632 BLDS 2015 đã khẳng định *“người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc không được là người làm chứng”*. Quy định này về tổng quan là phù hợp. Bởi lẽ, người làm chứng nếu là người thừa kế dù khẳng định hay không khẳng định cũng khó có thể nói họ hoàn toàn khách quan trong quá trình làm chứng cho việc lập di chúc. Nhất là khi nội dung di chúc có thể bất lợi cho họ hoặc bất lợi cho người mà họ mong muốn được hưởng: chẳng hạn không cho người thừa kế hưởng di sản, cho hưởng di sản ít, kèm theo các điều kiện phải thực hiện để được hưởng di sản... Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh khác, quy định này hạn chế quyền làm chứng của tất cả người thừa kế theo di chúc và người thừa kế theo pháp luật liệu có phải quá khắt khe hay không. Bởi lẽ không phải người thừa kế nào cũng mang theo sự tiêu cực trong quá trình làm chứng di chúc dù di chúc đó không có lợi cho họ hoặc cho những người họ mong muốn được hưởng.

Trên thế giới, trước vấn đề *“liệu có nên chấp nhận một người thừa kế là người làm chứng hay không, vấn đề này đã gây tranh cãi trong vài thế kỉ và cuối cùng đã được giải quyết, trong phần khẳng định, bởi sự phán quyết của bảy vị thẩm phán vào năm 1883, trong đó luật La Mã đã được viện dẫn cho bên thắng kiện và theo luật La Mã, người thừa kế hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác có thể là người làm chứng”*²¹⁸.

Thực tế xảy ra khá nhiều trường hợp khi lập di chúc, người làm chứng là người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật. Trong quá trình xét xử, Tòa án

²¹⁷ Điều 1135 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđd* (số chú thích 171), tr.335).

²¹⁸ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđd* (số chú thích 10), tr.425.

cũng không chấp nhận người nhà hay người thân quen của người thừa kế theo di chúc là người làm chứng²¹⁹. Việc Tòa án xét xử các vụ án có người thừa kế theo pháp luật là người làm chứng và không công nhận di chúc là thực hiện theo đúng với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên theo quan điểm của tác giả, việc quy định người thừa kế không được là người làm chứng đang theo hướng hạn chế đi quyền làm chứng cho việc lập di chúc của người thừa kế theo pháp luật. Mặt khác quy định này cũng đặt người để lại di sản vào một tình cảnh khó khăn khi tìm người làm chứng để lập di chúc. Theo quan niệm phổ biến của người Việt Nam, việc thừa kế là vấn đề nội bộ trong gia đình nên nhiều khi gia đình và người lập di chúc không muốn cho người ngoài biết việc lập di chúc và nội dung di chúc. Vậy nên người làm chứng thường sẽ là những người thân thích của người lập di chúc, trong số những người này sẽ có những người thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc.

Quy định của pháp luật đang theo hướng là chỉ đặt niềm tin vào người ngoài thay cho những người trong dòng họ và pháp luật đang quy định theo hướng là nếu không kiểm soát được thì nên loại trừ. Không có gì chắc rằng người thừa kế sẽ không có sự tác động để ảnh hưởng đến nội dung di chúc. Tuy nhiên cũng không có gì bảo đảm rằng những người thừa kế lại hoàn toàn không có thiện chí đối với di chúc của người để lại di sản.

Đối với người thừa kế theo di chúc, quy định của pháp luật đang loại trừ họ không được làm người làm chứng cho việc lập di chúc theo quan điểm của tác giả là phù hợp. Người thừa kế theo di chúc là những người trực tiếp có quyền lợi trong nội dung di chúc. Do vậy cho họ làm chứng phần nhiều có khả năng ảnh hưởng đến tính khách quan trong việc ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản. Tuy nhiên đối với người thừa kế theo pháp luật thì khó có thể khẳng định rằng họ có thể là những người ảnh hưởng đến tính xác thực của nội dung di chúc. Bởi lẽ phạm vi những người thừa kế theo pháp luật khá rộng, từ hàng thừa kế thứ nhất đến hàng thừa kế thứ ba. Mà không phải cứ đương nhiên những người thừa kế theo pháp luật sẽ được hưởng thừa kế. Mặt khác, như đã phân tích ở trên, thực tiễn xảy ra rất nhiều trường hợp người làm chứng là những người thừa kế theo pháp luật vì đây là những người gần gũi nhất, thân thiết, tin cậy nhất của người để lại di sản. Do vậy, người để lại di sản thường hay nhờ những người thừa kế theo pháp luật làm chứng mà không có suy nghĩ gì thêm.

Quy định pháp luật Pháp cũng không cấm trường hợp người thừa kế làm chứng di chúc. Tại Điều 980 BLDS Pháp 1804 chỉ đặt ra điều kiện cho những người làm chứng là: phải hiểu tiếng Pháp, đã thành niên, biết ký tên và có đầy đủ các quyền dân sự. Họ chỉ cấm trong trường hợp hai vợ, chồng cùng là người làm chứng cho một di chúc. Những điều kiện đặt ra cho người làm chứng theo pháp luật của Pháp để đảm

²¹⁹ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.652.

bảo người làm chứng có đầy đủ năng lực để chứng kiến việc lập di chúc. Còn nếu muốn đảm bảo tính khách quan, để người làm chứng không thể hiện ý chí chủ quan của họ tác động vào nội dung di chúc thì pháp luật Pháp cũng ghi nhận ít nhất phải có hai người làm chứng cho việc lập di chúc.²²⁰

Tóm lại, nếu quy định tại khoản 1 Điều 632 BLDS 2015 “*người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc*” không được là người làm chứng là quy định mang tính khắt khe, không đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Bởi lẽ thực tiễn luôn luôn tồn tại việc người để lại di sản nhờ người thừa kế theo pháp luật là người làm chứng cho việc lập di chúc. Ngoài ra nếu căn cứ vào thói quen, phong tục của người Việt Nam luôn xác định việc thừa kế chỉ là việc nội bộ trong gia đình, họ hàng được biết và người lập di chúc thường chỉ nhờ những người trong gia đình để làm chứng cho di chúc. Mặt khác, không thể khẳng định rằng người thừa kế theo pháp luật là người làm chứng sẽ không mang tính khách quan trong việc làm chứng cho quá trình lập di chúc. Yếu tố khách quan của việc làm chứng có thể xác định bằng việc xem xét số lượng của người làm chứng ít nhất phải có hai người để khó có thể tác động vào nội dung di chúc. Từ đó, tác giả cho rằng pháp luật nên ghi nhận quyền làm chứng cho việc lập di chúc của những người thừa kế theo pháp luật.

(ii) *Người làm chứng phải là người biết đọc, biết viết ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc*

Ngôn ngữ để lập di chúc không bị giới hạn. Người lập di chúc có thể dùng tiếng Việt, tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài để lập di chúc. Đối với di chúc bằng văn bản đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy cần thêm người làm chứng thì họ là người chứng kiến sự việc lập di chúc cũng là người xác nhận nội dung di chúc. Thậm chí trong một số trường hợp người làm chứng cũng là người viết hộ di chúc. Với những nhiệm vụ này người làm chứng nếu không biết chữ, không hiểu ngôn ngữ của người lập di chúc thì không thể nào xác nhận, kiểm tra nội dung di chúc. Tuy nhiên khi quy định về những người không được là người làm chứng cho việc lập di chúc pháp luật lại không đề cập đến điều kiện này.

Có quan điểm xác định “*di chúc ở nước ta phải được viết lại trên văn bản do đó người làm chứng phải là người biết chữ và Dự thảo BLDS đã theo hướng này bằng cách bổ sung vào khoản 4 Điều 632*”²²¹. Theo một quan điểm khác cho rằng “*vì tính chất của di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc chết, không thể đổi chất nên đòi hỏi người làm chứng phải có khả năng xác nhận nội dung bản di chúc bằng khả năng nhận thức của mình*”²²². Trước kia quy định trong Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa

²²⁰ Điều 971, 973, 976 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.240, 241).

²²¹ Đỗ Văn Đại (chủ biên) (2020), *Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015*, Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, tr.574, 575.

²²² Nguyễn Thị Hồng Vân, *tlđđ* (số chú thích 198), tr.17.

1972 tại Điều 579 đã từng tồn tại điều kiện này và ghi rõ “*người làm chứng phải biết đọc và biết viết*”.

Từ điển Tiếng Việt không đưa ra định nghĩa về người biết chữ nhưng có định nghĩa về từ “mù chữ”. “Mù chữ” được giải thích là tình trạng “*không biết đọc, biết viết (tuy ở tuổi đáng lẽ đã được học)*”²²³. Có thể suy luận rằng người biết chữ là người có khả năng đọc và khả năng viết. Như vậy nếu đặt ra điều kiện cho người làm chứng là người phải biết chữ và phải có khả năng đọc, hiểu, viết được ngôn ngữ sẽ được để lại di sản thể hiện trong di chúc sẽ đảm bảo được người làm chứng có thể vừa là người viết hộ di chúc (nếu cần) và cũng là người hoàn toàn xác nhận được nội dung của di chúc được lập thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản hay không.

Kết luận: trên cơ sở hai bất cập về người làm chứng đã được phân tích ở trên thì quy định tại khoản 1 Điều 632 BLDS 2015 cần phải được sửa đổi, bổ sung như sau “*Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: 1. Người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc. 2. 3. 4. Người không biết đọc, không biết viết ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc*”.

3.4. Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực

3.4.1. Quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực

Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực là di chúc phải thông qua công chứng viên hoặc người có thẩm quyền của UBND cấp xã để công chứng, chứng thực tính xác thực của di chúc. Đây là loại hình di chúc được người để lại di sản yêu cầu, có tốn phí nhưng bù lại trình tự, thủ tục để công nhận di chúc này mang tính chặt chẽ, khách quan, tiện lợi. Người để lại di sản có thể đến Phòng công chứng, Văn phòng công chứng hoặc UBND để yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc²²⁴. Trường hợp khác nếu muốn, người để lại di sản có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc²²⁵. Đương nhiên để di chúc hợp pháp, di chúc có công chứng hoặc chứng thực phải thỏa mãn những điều kiện do luật quy định²²⁶.

Công chứng di chúc do tổ chức công chứng thực hiện. Chứng thực di chúc do cơ quan nhà nước thực hiện tại UBND cấp xã. Về bản chất, công chứng, chứng thực bảo đảm tính hợp pháp của di chúc. Do đó nếu di chúc được công chứng, công chứng viên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của di chúc.²²⁷ Nếu di chúc được chứng thực thì người có thẩm quyền chứng thực tại UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của di chúc.

²²³ Hoàng Phê, *tlđđ* (số chú thích 31), tr.642.

²²⁴ Điều 636 BLDS 2015.

²²⁵ Điều 639 BLDS 2015.

²²⁶ Đỗ Văn Đại, Nguyễn Hồ Bích Hằng (2013), “Di chúc có công chứng, chứng thực”, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 1, tr.58.

²²⁷ Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014.

Theo quy định tại Điều 636 BLDS 2015 thì thủ tục lập di chúc có công chứng hoặc chứng thực sẽ theo trình tự sau đây: người để lại di sản tuyên bố nội dung di chúc trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc để cho những người này ghi chép lại. Sau khi người để lại di sản xem xét lại bản ghi chép, họ ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc và công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực ký vào bản di chúc. Đây là yêu cầu về trình tự, thủ tục chung cho di chúc có công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên tùy vào trường hợp di chúc bằng văn bản được công chứng hay chứng thực thì sẽ có những quy định riêng theo luật chuyên ngành để áp dụng.

Nếu đây là những di chúc bằng văn bản được công chứng thì vấn đề ký tên hoặc điểm chỉ của người để lại di sản phải xem xét theo trình tự. Quy định trong Luật Công chứng 2014 có đề cập đến vấn đề ký tên và điểm chỉ tại khoản 2, 3 Điều 48. Theo đó luật quy định việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Với tinh thần này có thể hiểu chữ ký sẽ là lựa chọn đầu tiên. Nếu những di chúc có nội dung định đoạt tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì công chứng viên còn yêu cầu người lập di chúc phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các loại tài sản này.²²⁸ Mặt khác, đối với di chúc bằng văn bản có công chứng, người để lại di sản có thể yêu cầu công chứng viên đến chỗ ở của họ để lập di chúc với trình tự, thủ tục lập di chúc tương tự như di chúc được lập tại các tổ chức công chứng²²⁹.

Nếu đây là những di chúc được chứng thực chỉ có một lựa chọn duy nhất là người để lại di sản phải đến UBND cấp xã để yêu cầu chứng thực di chúc. Tương tự như di chúc bằng văn bản có công chứng, nếu trong di chúc định đoạt những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu chứng thực phải nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định²³⁰. Người để lại di sản phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực, trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ²³¹.

Hiện nay di chúc có công chứng hoặc chứng thực được quy định tại Điều 635, 636, 639 BLDS 2015. Từ ba điều luật này đang có hai quan điểm trái ngược nhau về trình tự, thủ tục lập di chúc. Quan điểm thứ nhất cho rằng, ba điều luật này là sự kết hợp với nhau, trong đó Điều 635 là điều luật giới thiệu cho di chúc được công chứng hoặc chứng thực “*người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.*” Còn hai Điều 636, 639 là hai trường hợp cụ thể của việc: công chứng hoặc chứng thực tại các nơi có quyền công chứng hoặc chứng thực hay là lập di chúc tại nhà

²²⁸ Khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014.

²²⁹ Điều 639 BLDS 2015.

²³⁰ Điểm c khoản 1 Điều 36 NĐ 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (NĐ 23/2015/NĐ-CP).

²³¹ Khoản 3 Điều 36 NĐ 23/2015/NĐ-CP.

và yêu cầu công chứng viên đến nhà công chứng di chúc.²³² Nếu hiểu theo cách này thì quy định tại ba điều luật này là sự liên kết và người để lại di sản không thể tự mình soạn sẵn di chúc tại nhà rồi mang đến tổ chức công chứng hoặc UBND cấp xã để yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc hoặc tự soạn tại nhà và yêu cầu công chứng viên đến công chứng di chúc đã soạn sẵn²³³. Có quan điểm còn xác định “*cho dù người lập di chúc có làm sẵn bản thảo di chúc đi nữa thì vẫn phải có mặt trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan có thẩm quyền chứng thực, đọc lại tờ di chúc (khoản 7 Điều 40 Luật Công chứng 2014). Sau đó công chứng viên hoặc công chức chứng thực di chúc sẽ xem xét các yêu cầu pháp lý để đồng ý công chứng, chứng thực hay từ chối. Sau khi đọc xong và thể hiện sự đồng ý toàn bộ nội dung, thì người lập di chúc phải ký tên vào từng trang của tờ di chúc*”.²³⁴

Tuy nhiên cách hiểu thứ hai thì hoàn toàn trái ngược, Điều 635 và Điều 636 BLDS 2015 là hai trình tự, thủ tục lập di chúc độc lập. Như vậy “*khi người lập di chúc tự mình đi công chứng, chứng thực thì bản di chúc là hợp pháp kể cả trường hợp họ không viết (đánh máy, chẳng hạn)*”, “*di chúc được lập tại cơ quan công chứng hoặc tại UBND cấp xã là trường hợp bản di chúc được lập tại cơ quan công chứng, chứng thực và người lập di chúc chỉ cần tuyên bố nội dung di chúc chứ không phải mang di chúc đến xin công chứng, chứng thực*”.²³⁵

Tuy nhiên xuất phát từ thực tiễn thì các công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực di chúc sẽ rất cẩn trọng trong việc công chứng hoặc chứng thực di chúc. Nếu người để lại di sản có mang di chúc sẵn có tại nhà đến yêu cầu công chứng thì trên thực tế công chứng viên sẽ không công chứng di chúc. Trường hợp nếu đây là chứng thực di chúc thì người có thẩm quyền chứng thực di chúc vẫn phải xem xét lại đây có phải là bản di chúc do đúng người để lại di sản lập hay không. Nếu đã xác định chính xác di chúc của chính người lập di chúc thì họ mới chứng thực di chúc. Mặt khác, pháp luật không cho phép người lập di chúc ủy quyền cho người khác mang di chúc của mình đến tổ chức công chứng yêu cầu công chứng²³⁶ hoặc đến UBND cấp xã để yêu cầu chứng thực di chúc²³⁷. Theo quy định tại Điều 56 Luật Công chứng 2014 khi yêu cầu chứng nhận bản di chúc, người lập di chúc phải nộp bản di chúc và xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân.

Đối với di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực thì ngoài người làm chứng cho việc lập di chúc còn có thêm công chứng viên hoặc người có thẩm quyền

²³² Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.472.

²³³ Khoản 1 Điều 636 BLDS 2015, khoản 2 Điều 639 BLDS 2015.

²³⁴ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.474.

²³⁵ Chu Xuân Minh, “Một số vấn đề cấp thiết cần lưu ý về áp dụng pháp luật dân sự”, Ủy ban châu Âu và Tòa án nhân dân tối cao, *Tài liệu tập huấn thi hành BLDS và BLTTDS*, Nxb. Chính trị quốc gia, 2008, tr.175. trong Đỗ Văn Đại, Nguyễn Hồ Bích Hằng, *tlđđ* (số chú thích 226), tr.56.

²³⁶ Phùng Trung Tập (2008), *Luật thừa kế Việt Nam*, Nxb. Hà Nội, tr.58.

²³⁷ Điều 23 ND 23/2015/NĐ-CP.

của UBND cấp xã xác nhận tính xác thực của di chúc. Hoạt động có sự tham gia của những người này để đảm bảo di chúc được thông qua một bên thứ ba xác định tính khách quan của bản di chúc, đảm bảo di chúc ghi nhận đúng ý chí của người để lại di sản. Theo quy định trong BLDS 2015²³⁸ và Luật Công chứng 2014²³⁹ thì người có thẩm quyền công chứng di chúc là công chứng viên và theo quy định khoản 9 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (NĐ 23/2015/NĐ-CP) quy định người thực hiện chứng thực di chúc là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã. Những người này phải thỏa mãn các điều kiện do luật định²⁴⁰.

Trên thực tế với những yêu cầu đặt ra của luật thì sự khác biệt về trình độ pháp lý giữa công chứng viên và người có thẩm quyền chứng thực là khá rõ rệt. Công chứng viên là người được đào tạo và có yêu cầu về kiến thức pháp luật. Nhưng người có thẩm quyền chứng thực (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã) có thể sẽ không am hiểu nhiều về pháp luật bởi lẽ họ là người thực hiện và quản lý rất nhiều việc, nhiều lĩnh vực trong phạm vi một xã. Do vậy, để giúp việc cho họ sẽ có các cán bộ tư pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể như để xác thực di chúc. Khi di chúc đã đảm bảo tính xác thực, cán bộ tư pháp mới yêu cầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã chứng thực di chúc. Mặc dù trình độ pháp lý của hai chủ thể có quyền xác thực di chúc là khác nhau nhưng cũng không thể loại trừ hình thức di chúc được chứng thực hoặc xác định giá trị pháp lý của di chúc có công chứng và di chúc có chứng thực có sự phân biệt. Có những địa phương ở vùng xa xôi hải đảo, vùng dân tộc thiểu số việc tìm tổ chức công chứng để công chứng di chúc là khó khăn hơn rất nhiều so với việc đến UBND để chứng thực. Ngoài ra với sự hiểu biết hoặc thói quen của người dân ở vùng nông thôn thì việc chứng thực di chúc tại UBND cấp xã lại thông dụng hơn so với công chứng di chúc.

Bên cạnh những điều kiện về tiêu chuẩn chung do luật chuyên ngành điều chỉnh thì công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực di chúc còn là những người không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 637 BLDS 2015. Quy định tại Điều 637 BLDS 2015 đề cập đến nhóm người có liên quan đến vấn đề thừa kế và có thể ảnh hưởng đến nội dung di chúc như: người thừa kế; người có cha, mẹ, vợ, chồng, con là người thừa kế; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc. Pháp luật loại trừ những người này do lo sợ họ có khả năng sẽ tác động vào nội dung di chúc dẫn đến di chúc thể hiện sai lệch đi ý chí của người để lại di sản.

Ở Việt Nam, di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực ngoài việc được lựa chọn bởi người để lại di sản thì trong một số trường hợp đặc biệt sẽ là bắt

²³⁸ Điều 636, 639 và khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

²³⁹ Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014.

²⁴⁰ Điều 8, 17, 34 Luật Công chứng 2014. Khoản 2 Điều 5 NĐ 23/2015/NĐ-CP.

buộc. Trường hợp đặc biệt đó là với người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ²⁴¹. Đây là những người vì lý do thể chất không bảo đảm hoặc không biết chữ sẽ làm hạn chế khả năng tự mình lập di chúc, do đó họ không thể nào lựa chọn hình thức di chúc tự viết. Mặt khác, cũng do lo ngại đến việc kiểm soát tính trung thực của nội dung di chúc khi nhờ người khác viết hộ hoặc đánh máy hộ di chúc do họ không thể tự mình kiểm tra lại nội dung di chúc nên đối với hình thức di chúc đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy in ra họ cũng không được phép lựa chọn để lập. Đặc biệt trong nhóm người này, riêng đối với người không đọc được, không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì cần có người làm chứng để chứng nhận bản di chúc bên cạnh công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc theo trình tự được quy định tại khoản 2 Điều 636 BLDS 2015.

Ở nước ngoài không tồn tại hình thức di chúc bằng văn bản có chứng thực do kết cấu cơ quan hành chính và thẩm quyền của cơ quan hành chính là khác biệt so với Việt Nam. Các quốc gia tồn tại hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng, đây là hình thức di chúc cơ bản và trên thực tế được áp dụng nhiều. Đối với di chúc có công chứng, theo quy định của pháp luật Nhật Bản thì không được ít hơn hai người làm chứng chứng kiến. Người để lại di sản sẽ thể hiện ý chí bằng lời cho công chứng viên. Công chứng viên ghi chép lại và đọc to cho người để lại di sản và người làm chứng nghe. Người để lại di sản và người làm chứng sẽ ký tên và đóng dấu xác nhận để xác thực di chúc là chính xác. Ngoài ra, khi người để lại di sản không thể ký tên, một công chứng viên sẽ ký thay có nêu rõ lý do đó, một công chứng viên khác sẽ được bổ sung để xác định di chúc đã được thực hiện theo các thủ tục được liệt kê trước đó, ký tên và đóng dấu của họ.²⁴²

Ở Pháp, di chúc có công chứng có thể là di chúc công khai hoặc di chúc bí mật. Đối với di chúc công khai chỉ khi nào tuân thủ các điều kiện cũng như các thủ tục theo quy định của luật thì một di chúc dưới dạng công chứng thư mới có hiệu lực. Đối với di chúc được công chứng thì việc công chứng di chúc phải do hai công chứng viên hoặc một công chứng viên và hai người làm chứng thừa nhận. Người lập di chúc đọc cho công chứng viên viết tay, hoặc giao cho người khác viết tay, hoặc đánh máy chữ. Sau khi viết xong thì phải đọc lại cho người lập di chúc nghe²⁴³. Sau đó, người lập di chúc ký tên trước mặt công chứng viên và người làm chứng²⁴⁴. Cuối cùng, công chứng viên và người làm chứng phải ký tên vào văn bản²⁴⁵. Ở Pháp, “*để lập di chúc công*

²⁴¹ Khoản 3 Điều 630 BLDS.

²⁴² Điều 969 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

²⁴³ Điều 971, 972 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.240).

²⁴⁴ Điều 973 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.241).

²⁴⁵ Điều 974 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.241).

*khai thường không có bất kỳ nhược điểm nào. Chi phí cho việc lập di chúc có công chứng tương đối rẻ, thường từ € 150 đến € 300 và vì công chứng viên có trình độ chuyên môn cao về luật thừa kế nên rủi ro vi phạm các thủ tục hoặc luật nội dung là rất ít. Các vấn đề về phiên dịch là rất hiếm. Tính xác thực của hình thức di chúc này cao hơn nhiều so với trường hợp của di chúc tự lập”.*²⁴⁶ Đối với di chúc bí mật cũng được công chứng nhưng nội dung của bản di chúc chỉ có người lập di chúc biết hoặc người viết hộ biết - nếu đây là di chúc nhờ người khác viết hộ²⁴⁷.

Ở một số tiểu bang của Canada, quy định đối với di chúc có công chứng còn có thêm một chủ thể nữa đó chính là người phiên dịch. Chẳng hạn, tiểu bang Québec quy định: “*Người khiếm thính không thể nói, không đọc, không viết được có thể lập di chúc công chứng với điều kiện người đó chuyển tải nguyện vọng của mình cho công chứng viên thông qua phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Người lập di chúc, trước sự chứng kiến của công chứng viên và người làm chứng, tuyên bố bằng cách thức tương tự rằng tài liệu mà người phiên dịch dịch cho người lập di chúc là di chúc của mình.*”²⁴⁸

3.4.2. Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực

Thứ nhất, đối với di chúc của người không đọc được hoặc không nghe được, không ký hoặc không điểm chỉ được

Theo quy định tại khoản 2 Điều 636 BLDS 2015 đối với người không đọc được hoặc không nghe được, không ký hoặc không điểm chỉ được vào bản di chúc phải lập di chúc có công chứng hoặc chứng thực. Trong quy định này BLDS 2015 sử dụng từ “*hoặc*” để sử dụng cho nhóm đối tượng khá đặc biệt muốn lập di chúc. Người để lại di sản có thể là người không đọc được hoặc không nghe được và từ đó có thể xảy ra trường hợp như sau. Người để lại di sản không đọc được nhưng có thể nghe được (ví dụ: người không biết chữ hoặc người biết chữ nhưng bị mù) hoặc người để lại di sản không nghe được nhưng có thể đọc được di chúc (ví dụ: người biết chữ nhưng bị điếc) và những người này không ký được hoặc không điểm chỉ được vào di chúc. Người lập di chúc nếu không nghe được thì vẫn có thể tự mình viết di chúc và tự ký được vào di chúc. Lúc này di chúc được lập đủ điều kiện của di chúc bằng văn bản tự tay viết và không cần phải bắt buộc nhờ người làm chứng và có công chứng hoặc chứng thực. Hoặc người không nghe được có thể lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản nhờ người khác lập với sự hiện diện của hai người làm chứng nếu họ không muốn tự mình viết di chúc và họ sẽ tự kiểm tra lại nội dung di chúc bằng cách đọc lại di chúc khi đã nhờ người khác lập xong. Quy định của pháp luật đối với trường hợp này đang hạn chế

²⁴⁶ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.373.

²⁴⁷ Điều 976 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi năm 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.241).

²⁴⁸ Khoản 1 Điều 722 BLDS Québec 1991 (tác giả tạm dịch).

đi quyền tự do lựa chọn hình thức di chúc của nhóm người không nghe được nếu bắt buộc họ chỉ có thể lập di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Vấn đề tiếp theo là theo quy định tại khoản 2 Điều 636 BLDS 2015 còn thêm điều kiện người lập di chúc không ký hoặc không điểm chỉ được vào di chúc. Theo quan điểm của tác giả, nếu người lập di chúc không ký được nhưng vẫn có thể điểm chỉ được hoặc ký được mà không điểm chỉ được vẫn có thể lựa chọn hình thức di chúc tự lập hoặc di chúc nhờ người khác lập. Do vậy quy định bắt buộc phải lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng, có công chứng, chứng thực sẽ chỉ dành cho người không đọc được, không ký và không điểm chỉ được.

Bên cạnh đó quy định tại khoản 2 Điều 636 BLDS 2015 còn chưa rõ ở nội dung *“nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận”*. Vậy vai trò của người làm chứng trong trường hợp này là được nhờ để làm gì, để ký hay là cả việc đọc lại nội dung và xác nhận lại nội dung di chúc. Bởi vì theo khoản 1 Điều 636 BLDS 2015 thì quy trình lập di chúc sẽ là việc công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực phải ghi chép lại nội dung di chúc và người lập di chúc sẽ xem lại nội dung này. Tuy nhiên với những người để lại di sản được quy định tại khoản 2 Điều 636 BLDS 2015 thì việc xem lại nội dung di chúc của họ là không khả thi nên cần phải có thêm người làm chứng. Vai trò của người làm chứng lúc này là việc xác nhận lại nội dung di chúc cho người lập di chúc để người lập di chúc biết rằng di chúc đã ghi nhận đúng ý chí của mình. Do đó, người làm chứng cần phải đọc lại nội dung di chúc cho người lập di chúc để người lập di chúc xác nhận lại nội dung di chúc của mình sau đó người làm chứng mới ký tên vào di chúc. Trong trường hợp người lập di chúc là người không đọc được và không nghe được di chúc thì vai trò của người làm chứng lại càng quan trọng. Người làm chứng phải là người xác nhận nội dung di chúc sau khi nội dung di chúc đã được công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực ghi lại từ ý chí của người lập di chúc.

Do đó trên cơ sở những phân tích trên, theo tác giả quy định tại khoản 2 Điều 636 BLDS 2015 cần phải được ghi nhận như sau *“Trường hợp người lập di chúc không đọc được di chúc, không ký và không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải **xác nhận lại nội dung di chúc** và ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã...”*. Quy định theo hướng này sẽ đảm bảo:

Chỉ có người không đọc được, không ký và không điểm chỉ được mới cần trình tự lập di chúc theo khoản 2 Điều 636 BLDS 2015, còn đối với những người bị hạn chế về thể chất khác họ có thể lập di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại khoản 1 Điều 636 BLDS 2015 và họ không cần có người làm chứng.

Vai trò của người làm chứng để hỗ trợ cho quá trình lập di chúc và xác nhận di chúc của người không đọc được, không ký và không điểm chỉ được quy định rõ ràng hơn.

Thứ hai, hình thức di chúc được niêm phong có công chứng hoặc chứng thực

Di chúc bí mật được ghi nhận trong pháp luật nhiều nước. Pháp luật Nhật Bản có di chúc được niêm phong và công chứng, đây có thể được xem là di chúc bí mật. Ở Nhật Bản trình tự lập di chúc bí mật theo các bước như sau: “(i) người lập di chúc ký tên và đóng dấu vào di chúc; (ii) người lập di chúc sẽ niêm phong di chúc; (iii) người lập di chúc phải nộp di chúc đã được niêm phong trước một công chứng viên và không ít hơn hai người làm chứng, kèm theo lời tuyên bố rằng đó là ý chí của mình, nêu rõ tên và địa chỉ; (iv) sau khi đã ghi ngày nộp giấy chứng nhận và lời khai của người lập di chúc trên di chúc được niêm phong, công chứng viên cùng với người lập di chúc và người làm chứng ký tên, đóng dấu”. Có thể xem đây là loại di chúc được lập mà có thể giữ bí mật nội dung di chúc, mặc dù có người làm chứng và có công chứng. Người làm chứng và công chứng viên chỉ là người chứng kiến, xác nhận quá trình lập di chúc của người để lại di sản còn nội dung của di chúc thì chỉ có người để lại di sản biết. Sau khi lập xong người lập di chúc sẽ tự mình niêm phong bản di chúc này. Đây là một quy định có sự kết hợp giữa di chúc tự lập và di chúc có công chứng, vừa có thể giữ bí mật nội dung vừa có thể có người xác định tính chính xác của bản di chúc. Mặt khác, vì đây là sự lựa chọn của người để lại di sản nên pháp luật cho phép trường hợp loại trừ đối với loại di chúc này mà không đảm bảo điều kiện về hình thức. Ngay cả một di chúc bằng văn bản được niêm phong và công chứng không đáp ứng các thủ tục quy định tại điều luật trước đó sẽ có hiệu lực như một di chúc tự lập, nếu được lập theo các thủ tục quy định tại Điều 968 BLDS Nhật Bản 1896²⁴⁹.

Các nước châu Âu thường có 3 loại hình di chúc bằng văn bản: di chúc tự lập, di chúc bí mật và di chúc công khai. Về cơ bản các thủ tục lập đối với các hình thức di chúc ở các nước châu Âu cũng sẽ là như nhau trên cơ sở cần có người làm chứng, cần có công chứng. Tuy nhiên đối mỗi nước sẽ có những ngoại lệ riêng²⁵⁰. Ở Pháp hiện nay vẫn tồn tại di chúc bí mật và loại hình di chúc này giống với di chúc ở Nhật Bản gọi là di chúc được niêm phong và có công chứng. Di chúc bí mật theo quy định của pháp luật Pháp được lập theo trình tự sau đây: (i) Người lập di chúc tự lập di chúc và di chúc hoặc phong bì đựng di chúc (nếu có) phải được dán kín, đóng dấu và niêm phong. (ii) Người lập di chúc đưa bản di chúc đã dán kín, đóng dấu và niêm phong cho công chứng viên và hai người làm chứng xem hoặc người lập di chúc sẽ dán kín, đóng dấu và niêm phong di chúc trước sự chứng kiến của những người làm chứng, công chứng viên và tuyên bố rằng nội dung ghi trong tờ giấy là di chúc của mình, tự mình

²⁴⁹ Điều 971 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

²⁵⁰ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmerman, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.64.

viết. Trong trường hợp nhờ người khác viết thì sau đó người lập di chúc phải kiểm tra lại nội dung di chúc và ký tên. Trong mọi trường hợp, người lập di chúc phải chỉ rõ kiểu chữ đã sử dụng (viết tay hoặc đánh máy). (iii) Công chứng viên sẽ lập một bản chứng nhận do chính công chứng viên hoặc giao cho người khác viết tay hoặc đánh máy, trong đó ghi rõ ngày, tháng, địa điểm lập, miêu tả hình thức gấp di chúc, con dấu và tất cả các thủ tục nêu trên. (iv) Di chúc này phải được người lập di chúc, công chứng viên và tất cả những người làm chứng ký tên.²⁵¹

Có quan điểm cho rằng thực chất di chúc bí mật được công chứng hoặc chứng thực ở Việt Nam đã có, đó là việc người lập di chúc tự lập di chúc ở nhà sau đó mang di chúc đi công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên đối với trường hợp này việc công chứng hoặc chứng thực là không đúng theo trình tự, thủ tục lập di chúc có công chứng hoặc chứng thực quy định tại Điều 636 BLDS 2015. Mặt khác, nếu công chứng viên có công chứng di chúc họ cũng sẽ yêu cầu được biết về nội dung di chúc bởi việc công chứng di chúc không chỉ là công chứng về chữ ký, điểm chỉ, xác nhận sự kiện lập di chúc mà còn xác nhận nội dung di chúc theo đúng trình tự, thủ tục luật định.²⁵² Trên thực tế, công chứng viên sẽ không công chứng một di chúc được lập sẵn tại nhà, dán kín có niêm phong dù là người lập di chúc có mang di chúc đến và xác nhận đây là di chúc của mình. Trường hợp nếu người lập di chúc mang di chúc được lập sẵn, dán kín và niêm phong đến UBND xã để yêu cầu di chúc được chứng thực thì người có thẩm quyền chứng thực cũng sẽ không chứng thực di chúc do di chúc lập không đúng trình tự, thủ tục luật định. Có quan điểm cho rằng *“trong trường hợp một người lập di chúc bí mật rồi để vào phong bì dán kín, niêm phong và gửi giữ tại cơ quan công chứng thì cũng không coi là thể thức lập di chúc và nếu di chúc này không được lập đúng các thể thức, thủ tục luật định thì cũng sẽ không có giá trị pháp lý nên đây cũng không xem là di chúc bí mật.”*²⁵³

Ở Việt Nam, nếu muốn giữ bí mật nội dung di chúc sẽ lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản tự viết theo quy định tại Điều 633 BLDS 2015. Còn nếu người lập di chúc muốn mang di chúc gửi giữ tại các tổ chức công chứng thì cơ quan, tổ chức gửi giữ di chúc vẫn có trách nhiệm phải giữ bí mật nội dung di chúc²⁵⁴ nhưng nội dung di chúc vẫn là đã được tiết lộ cho công chứng viên biết.

Trước đây Bộ Dân luật Việt Nam Cộng Hòa 1972 có quy định về di chúc bí mật đó là trường hợp chúc thư được niêm phong kín do người lập di chúc trình cho Chương khế trước mặt hai nhân chứng và khai rằng đó là chúc thư của mình, do mình

²⁵¹ Điều 976 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *tlđđ* (số chú thích 49), tr.241).

²⁵² Khoản 1 Điều 2, Điều 40 Luật Công chứng 2014.

²⁵³ Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.489.

²⁵⁴ Khoản 1 Điều 60 Luật Công chứng 2014.

viết lấy và thủ ký. Chương khế sẽ lập biên bản tiếp nhận, nếu người lập chúc vì lẽ gì không thể ký vào biên bản thì cũng phải ghi rõ.²⁵⁵

Hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam, nếu lập di chúc không có người làm chứng thì có thể giữ bí mật nội dung di chúc nhưng người để lại di sản phải tự mình viết bản di chúc. Còn nếu lựa chọn hình thức di chúc có người làm chứng hoặc di chúc có công chứng hoặc chứng thực thì sẽ có người thứ ba (là công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực, người làm chứng) xác nhận di chúc và biết về nội dung di chúc. Nếu bổ sung thêm hình thức di chúc được niêm phong thì người để lại di sản sẽ có thêm sự lựa chọn phù hợp với yêu cầu của họ và nâng cao tính xác thực cho di chúc khi di chúc vừa được giữ bí mật vừa được xác nhận bởi chủ thể thứ ba. Lúc này di chúc vẫn được công chứng hoặc chứng thực nhưng khác với trình tự công chứng hoặc chứng thực thông thường²⁵⁶, người để lại di sản sẽ tự mình lập di chúc trước sự chứng kiến của công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực sẽ xác nhận di chúc đúng là của người để lại di sản và được lập dưới sự chứng kiến của họ nhưng họ sẽ không biết về nội dung di chúc.

Quy định của pháp luật Việt Nam về di chúc được niêm phong có công chứng hoặc chứng thực có thể tham khảo quy định của pháp luật Nhật Bản và pháp luật của Pháp. Do đó BLDS 2015 có thể bổ sung thêm một quy định như sau để ghi nhận về di chúc được niêm phong có công chứng hoặc chứng thực như sau *“Người lập di chúc có thể tự viết di chúc sau đó niêm phong bản di chúc trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã và ít nhất một người làm chứng. Người lập di chúc đưa bản di chúc được niêm phong cho công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực và công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực sẽ lập bản chứng nhận với đầy đủ chữ ký của người lập di chúc, người làm chứng, công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực và những miêu tả cơ bản về di chúc đã được niêm phong (tự viết, cách gấp bản di chúc trong phong bì niêm phong). Sau đó công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực và người làm chứng ký tên vào phong bì niêm phong di chúc.”*

Ghi nhận bổ sung thêm hình thức di chúc với những điều kiện phù hợp sẽ giúp người lập di chúc có thêm sự lựa chọn cho việc lập di chúc của mình đồng thời vẫn đảm bảo di chúc là sự ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc.

²⁵⁵ Điều 578 Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa 1972.

²⁵⁶ Khoản 1 Điều 636 BLDS 2015.

3.5. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

3.5.1. Quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Quy định tại Điều 638 BLDS 2015 là hình thức di chúc đặt ra đối với những đối tượng đặc biệt, trong những tình huống đặc biệt. Quy định tại Điều 638 BLDS 2015 mang đến tính linh hoạt cho những người rơi vào các tình huống này có thể lập di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực.

Trường hợp thứ nhất, di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc. Quân nhân đang ở một đơn vị nhất định trong quân đội hoặc đang đóng quân ở hải đảo, nơi chỉ có quân đội, không có cơ quan công chứng, chứng thực; hoặc quân nhân đang làm một nhiệm vụ đặc biệt. Những người quân nhân này không thể yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc thì BLDS 2015 quy định di chúc của họ chỉ cần có sự xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên²⁵⁷ là thỏa mãn điều kiện về hình thức.

Trường hợp thứ hai, di chúc lập ra khi người lập di chúc đang đi trên tàu biển, máy bay, có xác nhận của chỉ huy phương tiện đó. Người có thẩm quyền xác nhận vào di chúc chính là người chỉ huy tàu biển, máy bay và thông thường là người chỉ huy tàu bay hoặc thuyền trưởng²⁵⁸. Điều kiện đặt ra phải là người đang đi trên tàu biển, máy bay có nghĩa là việc đi lại hoặc làm việc trên máy bay, tàu biển khi những phương tiện giao thông này đã rời sân bay, bến cảng nhưng chưa hạ cánh, cập bến và người để lại di sản muốn ngay lập tức lập di chúc.

Trường hợp thứ ba, di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở chữa bệnh đó. Đây là những bệnh nhân đang được điều trị hoặc điều dưỡng nội trú tại bệnh viện, các cơ sở chữa bệnh. Vì lý do nào đó người để lại di sản không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc.

Trường hợp thứ tư, di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị đó. Hoàn cảnh lập di chúc ở vùng sâu, vùng xa nên những người muốn lập di chúc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đi đến tổ chức công chứng hoặc UBND để công chứng, chứng thực di chúc.

²⁵⁷ Điều 1 Nghị định 44/2005/NĐ-CP ngày 05/04/2005 của Chính phủ quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

²⁵⁸ Điều 74 Luật Hàng không dân dụng 2019, Điều 52 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2018.

Trường hợp thứ năm áp dụng đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài là người đang có quốc tịch Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài²⁵⁹. Với hoàn cảnh ở nước ngoài việc công chứng hoặc chứng thực di chúc là điều không khả thi do vậy luật ghi nhận cho những cá nhân này có thể lập di chúc và yêu cầu cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao ở nước cá nhân đang cư trú xác nhận là được. “BLDS 2015 dùng thuật ngữ “*chứng nhận*” để đưa giá trị pháp lý của loại di chúc này trở về tương đương với di chúc được công chứng, chứng thực. Việc chứng nhận được hiểu theo nghĩa xác thực người lập di chúc đang là người sinh sống và làm việc hợp pháp tại nước ngoài. Hơn nữa, việc chứng nhận này sẽ được thực hiện bởi những người có chuyên môn, nghiệp vụ đánh giá tính hợp pháp của bản di chúc và điều này tạo nên sự cân bằng trong hoạt động chuyên môn của người thực hiện xác nhận di chúc.”²⁶⁰

Trường hợp thứ sáu áp dụng cho những người đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý biện pháp hành chính. Vì bị hạn chế quyền đi lại nên họ không thể yêu cầu tổ chức công chứng hoặc UBND cấp xã công chứng hoặc chứng thực di chúc. Lúc này người phụ trách những cơ sở đó có quyền xác nhận di chúc.

Điều 638 BLDS 2015 không quy định về trình tự, thủ tục để lập di chúc. Tuy nhiên với suy luận rằng, nếu di chúc được người lập di chúc tự viết thì không cần có người làm chứng, không cần có công chứng hoặc chứng thực. Nếu di chúc do người để lại di sản nhờ người khác lập thay thì chỉ cần ít nhất hai người làm chứng là đủ điều kiện. Theo đó tác giả cho rằng trình tự lập di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực sẽ theo trình tự của di chúc bằng văn bản được công chứng hoặc chứng thực. Điều đó có nghĩa những người để lại di sản sẽ thể hiện ý chí của mình trước mặt những người có thẩm quyền xác nhận di chúc và được họ ghi chép lại. Sau đó, họ sẽ xác nhận vào bản di chúc đó. Di chúc này có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực nhưng người xác nhận di chúc không phải là công chứng viên hay người có thẩm quyền chứng thực của UBND mà là những người được liệt kê tại Điều 638 BLDS.

Theo đánh giá chung, quy định tại Điều 638 BLDS 2015 mang lại cho người lập di chúc thêm sự lựa chọn về các hình thức di chúc bằng văn bản nhất là trong những điều kiện người lập di chúc không thể đến tổ chức công chứng hoặc UBND để công chứng, chứng thực di chúc. Di chúc được xác nhận bởi những người theo luật định được xem có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực. Chẳng hạn, một người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn lập di chúc tự viết và gửi về Việt Nam vẫn có thể được công nhận nếu thỏa mãn quy định tại khoản 2 Điều 681 BLDS 2015

²⁵⁹ Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/06/2016 của Bộ Ngoại giao – Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

²⁶⁰ Hoàng Thị Loan, *tlđd* (số chú thích 200), tr.41.

“hình thức di chúc được xác định theo pháp luật của nước lập di chúc nên người Việt Nam đang định cư ở nước nào thì lập di chúc theo quy định của nước đó. Nếu hình thức di chúc phù hợp với pháp luật của nước họ cư trú thì di chúc sẽ được công nhận tại Việt Nam.” Tuy nhiên nếu họ muốn lựa chọn hình thức di chúc có một bên thứ ba xác nhận thì họ có thể lựa chọn hình thức di chúc này. Quy định pháp luật về hình thức di chúc có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực không chỉ mang tính linh hoạt mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dễ dàng bày tỏ ý chí của mình ở mọi lúc, mọi nơi²⁶¹ và mở rộng thẩm quyền xác nhận di chúc cho nhiều chủ thể bên cạnh công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của tác giả việc lập di chúc này trên thực tế không dễ dàng để thực hiện trong một vài trường hợp. Nếu một người đang đi trên máy bay thì di chúc phải xin xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó là người chỉ huy tàu bay. Đây là điều khó thực hiện trên thực tế do người chỉ huy tàu bay đang thực hiện công việc và nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn chuyến bay đặt trên vai của họ²⁶² nên khó có việc họ sẽ đồng ý xác nhận di chúc. Người chỉ huy tàu bay phải xác thực nội dung di chúc của người lập di chúc, xác thực quá trình lập di chúc để đảm bảo di chúc thể hiện đúng ý chí của người lập di chúc. Điều đó sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy tàu bay và cũng tốn nhiều thời gian cho công việc này. Trong khi đó, nếu đang trên chuyến bay, người lập di chúc sẽ dễ dàng lựa chọn di chúc tự viết hoặc di chúc nhờ người khác viết hộ có người làm chứng với nhiều hành khách ở bên cạnh là người làm chứng. Trường hợp người lập di chúc là người bị hạn chế về thể chất hoặc là người không biết chữ bắt buộc phải lập di chúc có công chứng hoặc chứng thực thì cần đợi khi chuyến bay kết thúc để thực hiện thủ tục lập di chúc theo đúng quy định của luật. Trong các trường hợp như vậy, người chỉ huy tàu bay sẽ từ chối xác nhận vào di chúc.

Trường hợp một người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh cần có xác nhận của giám đốc bệnh viện. Đây cũng là điều khó có thể thực hiện được trên thực tế. Việc có thể gặp, yêu cầu và để giám đốc bệnh viện tiêu tốn khoảng thời gian cho quá trình chứng kiến việc lập di chúc, xác nhận nội dung di chúc sẽ là ít khi thực hiện được. Trong những trường hợp này thay vì lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực thì người lập di chúc nên lựa chọn hình thức di chúc bằng văn bản tự lập hoặc di chúc nhờ người khác lập và có người làm chứng sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. Người lập di chúc muốn lập di chúc

²⁶¹ Đinh Trung Tụng (chủ biên) (2005), *Bình luận những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2005*, Nxb. Tư pháp, tr.236.

²⁶² Điều 75,76 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2019.

có công chứng có thể yêu cầu công chứng viên đến tại giường bệnh trong bệnh viện để lập theo thủ tục lập di chúc tại Điều 639 BLDS 2015.

Do vậy, theo quan điểm của tác giả quy định tại Điều 638 BLDS 2015 đang mang lại cho người lập di chúc quyền tự do lựa chọn hình thức di chúc trong một số hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên để thực hiện quyền này trên thực tế trong một vài trường hợp sẽ hơi khó thực hiện và người lập di chúc cần xem xét hoàn cảnh cụ thể để có cho mình lựa chọn hình thức di chúc cho phù hợp đảm bảo di chúc có thể dễ dàng được tạo lập và lưu giữ được ý chí của họ theo đúng quy định của luật.

Ở nước ngoài cũng tồn tại hình thức di chúc bằng văn bản được lập bởi những chủ thể đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn và việc xác nhận di chúc được thực hiện bởi những chủ thể có khả năng trong hoàn cảnh đó. Pháp luật của Pháp có quy định về di chúc dành cho những người lính đang trong cuộc chiến được lập với sự xác nhận của một sỹ quan cấp tá hoặc bác sỹ quân y có quân hàm cùng cấp và trước hai người làm chứng; hoặc bởi hai cán bộ hậu cần hoặc sỹ quan quản lý hành chính; hoặc bởi một trong các viên chức hay sỹ quan đó và trước hai người làm chứng; hoặc bởi sỹ quan chỉ huy một phân đội độc lập trước sự có mặt của hai người làm chứng nếu trong phân đội đó không có sỹ quan cấp tá hoặc sỹ quan quản lý hành chính. Thậm chí các tù binh đang bị đối phương giam giữ cũng có quyền lập di chúc theo hình thức này.²⁶³

3.5.2. Bất cập và kiến nghị hoàn thiện thực tiễn áp dụng pháp luật về di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Hình thức di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực là một loại hình thức di chúc bằng văn bản đặc biệt được dành cho một số nhóm người ở hoàn cảnh không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc. Tuy nhiên, trong hoạt động xét xử tranh chấp thừa kế theo di chúc có vi phạm quy định về hình thức, có Tòa án đã áp dụng điều kiện của nhiều loại hình thức di chúc bằng văn bản cho một hoàn cảnh lập di chúc. Tác giả dẫn chứng một vụ việc đã được Tòa án xét xử áp dụng cả quy định về di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực với hình thức di chúc nhờ người khác viết hộ cho cùng một hoàn cảnh.

Vụ việc như sau: tháng 10/2018, ông Thảo Seo S bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đến ngày 05-12-2018 thì ông S chết. Trong thời gian chữa bệnh, ngày 18/11/2018 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ông Thảo Seo S đã nhờ anh họ của bà S (người đang chung sống với ông Thảo Seo S như vợ chồng) là ông Sùng A V viết hộ di chúc với nội dung để lại tài sản cho bà S gồm: 01 căn nhà xây cấp 4 làm trên diện tích đất khoảng 20m x 30m và 03ha đất rẫy đã trồng cà phê và cây điều, địa chỉ tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông. Bản di chúc có

²⁶³ Điều 93, Điều 981 BLDS Pháp 1804 (sửa đổi 2017), (được dịch từ Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, *ildd* (số chú thích 49), tr.242).

chữ ký của ông Thào Seo S, bà Sùng Thị S và người làm chứng Vàng A P, Sùng A V (đồng thời là người viết hộ di chúc), Thào A C, Thào A S và Thào Seo T (con riêng của bà G, vợ hợp pháp của ông Thào Seo S). Tại thời điểm lập di chúc người làm chứng anh Vàng A P không có mặt tại bệnh viện mà sau đó anh Thào Seo T đưa di chúc về nhà nhờ anh P ký. Tòa phúc thẩm xác định xét về hình thức, di chúc vi phạm quy định tại Điều 634 BLDS 2015 vì lý do người làm chứng là anh Vàng A P không chứng kiến việc lập di chúc mà vẫn ký tên là người làm chứng; còn di chúc vi phạm khoản 3 Điều 638 BLDS 2015 với lý do di chúc do ông S đang phải điều trị ở bệnh viện mà không có xác nhận của người phụ trách bệnh viện²⁶⁴. Tuy nhiên theo tác giả, hướng nhận định này của Tòa án là không hợp lý vì hai Điều 634 và 638 BLDS 2015 là áp dụng cho hai trường hợp khác nhau với loại hình thức di chúc được lựa chọn là khác nhau. Trong tình huống này không thể áp dụng đồng thời vào việc lập di chúc của ông S để bắt buộc di chúc của ông S phải tuân thủ điều kiện về hình thức di chúc của cả hai trường hợp. Để áp dụng pháp luật, tác giả cho rằng trong trường hợp trên chỉ cần xem xét một trong hai điều luật là Điều 634 hoặc Điều 638 BLDS 2015 để xác định di chúc của ông S có bị vi phạm quy định về hình thức hay không.

Nếu ông S lập di chúc có xác nhận của người đứng đầu cơ sở chữa bệnh do ông S đang điều trị ở bệnh viện thì không cần xem xét đến các điều kiện về người làm chứng vì khoản 3 Điều 638 BLDS 2015 không đòi hỏi điều kiện này. Tuy nhiên thực tiễn là ông S lập di chúc nhờ người khác viết và có người làm chứng nên chỉ cần áp dụng Điều 634 BLDS 2015 và không cần thêm điều kiện về xác nhận của người đứng đầu bệnh viện. Khi áp dụng Điều 634 BLDS 2015 trong tình huống này theo tác giả xét về hình thức thì di chúc của ông S đã đủ điều kiện do đã có nhờ người viết hộ. Ngoài ra, đã có đủ ít nhất hai người làm chứng không vi phạm điều kiện của người làm chứng là Thào A C, Thào A S và Thào Seo T.

Việc Tòa án áp dụng kết hợp cả hai điều luật để yêu cầu di chúc của ông S phải thỏa mãn các điều kiện này là không hợp lý. Mặt khác, nếu áp dụng kết hợp như vậy sẽ gây khó khăn cho người lập di chúc khi họ đang ở trong bệnh viện, trên tàu biển, trong quân đội...mà muốn lựa chọn hình thức di chúc nhờ người khác viết hộ di chúc theo Điều 634 BLDS 2015.

Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định có năm loại hình thức di chúc bằng văn bản cho người lập di chúc tùy vào từng điều kiện, hoàn cảnh của mình có thể lựa chọn loại hình thức di chúc mà mình muốn lập. Trong trường hợp nếu luật đã có quy định thì người lập di chúc phải tuân thủ theo loại hình di chúc đó. Mỗi một loại hình di chúc bằng văn bản có những yêu cầu về điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc là khác nhau. Do vậy, trong một hoàn cảnh không nên kết hợp các điều kiện về các loại hình thức di chúc khác nhau sẽ dẫn đến việc gây khó khăn hơn cho người lập di chúc. Trường hợp

²⁶⁴ Bản án số 05/2020/DS-PT ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông (Phụ lục IV).

nêu trên là một ví dụ rất cụ thể về vấn đề này. Chỉ trong một hoàn cảnh là người để lại di sản lập di chúc trong bệnh viện nhưng Tòa án lại áp dụng đồng thời cả Điều 634 và Điều 638 BLDS 2015 để yêu cầu di chúc phải thỏa mãn tất cả điều kiện đặt ra ở hai điều luật.

Từ những phân tích ở trên, tác giả kiến nghị trong hoạt động áp dụng pháp luật của thực tiễn cần phải xác định rõ về các điều kiện cho từng loại hình thức di chúc bằng văn bản và trong một hoàn cảnh nên xác định rõ ràng điều kiện về loại hình thức di chúc bằng văn bản nào cần được xem xét để giải quyết cho tranh chấp đó. Ở một hoàn cảnh không được áp dụng nhiều điều kiện của nhiều loại hình thức di chúc bằng văn bản. Hướng giải quyết như vậy sẽ đảm bảo sự thuận lợi cho người lập di chúc muốn ghi nhận ý chí của họ mà vẫn bảo vệ được ý chí của người lập di chúc.

3.6. Di chúc điện tử

Xã hội đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các phương tiện điện tử, kỹ thuật hiện đại ngày càng đa dạng và phong phú. Do vậy đã đến lúc di chúc cũng cần phải theo kịp, hình thức di chúc cũng cần thay đổi để phù hợp với xã hội, trao thêm quyền tự do lựa chọn cho người để lại di sản cũng như tạo điều kiện cho việc lập di chúc được thuận lợi hơn. Quy định pháp luật phải trả lời được các câu hỏi gắn liền với thực tiễn. Có cần thiết phải đưa ra các hình thức di chúc mới trong thời kỳ xã hội phát triển mạnh khoa học kỹ thuật? Một số yếu tố cấu thành hình thức di chúc có nên được hiện đại hóa? Có nên mở cửa cho việc số hóa di chúc và khả năng lập di chúc điện tử để đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới của luật di chúc?²⁶⁵ Đáp án của những câu hỏi này là kết quả của sự phù hợp giữa quy định pháp luật với thực tiễn cuộc sống. Ở thế giới và ở Việt Nam, khi đề cập đến di chúc điện tử đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc chấp nhận hay không chấp nhận hình thức di chúc điện tử nhưng không thể phủ nhận rằng *“chấp nhận di chúc điện tử sẽ là một thay đổi kỳ diệu với quy định pháp luật về di chúc nhưng sẽ không thay đổi sự chuyển giao tài sản của người để lại di sản sau khi họ chết”*²⁶⁶.

Hiện nay trên thế giới, càng ngày càng có nhiều nước quan tâm và dần dần chấp nhận di chúc điện tử bên cạnh hình thức di chúc bằng văn bản truyền thống (di chúc được lưu giữ ở định dạng văn bản thể hiện trên giấy, trên vải...). Các nước có ghi nhận di chúc điện tử đều xác định đây là một loại hình thức của di chúc bằng văn bản nhưng được thể hiện và lưu giữ bằng các thông điệp dữ liệu trên các phương tiện điện tử.

3.6.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về việc áp dụng di chúc điện tử

Đối với các nước châu Âu theo trường phái cổ điển, theo quan điểm truyền thống do đó hình thức di chúc được quy định khắt khe, thậm chí có một số quốc gia

²⁶⁵ Đurđić-Milošević, T. (2021), “Testamentary formalities in the time of pandemic”, *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC)*, số 5, tr.422.

²⁶⁶ Banta, Natalie M (2019), “Electronic Wills and digital assets: Reassessing formality in the digital age”, *Baylor Law Review*, Fall 2019, tập 71, số 3, tr.547-603.

chỉ ghi nhận một hình thức di chúc duy nhất là bằng văn bản. Ở những nước này không xem trọng hình thức di chúc thông qua các phương tiện điện tử.²⁶⁷ Mặc dù vậy cũng đã có quan điểm đề xuất về việc áp dụng di chúc điện tử. Chẳng hạn, ở Tây Ban Nha đã có nhiều quan điểm đề cập đến các phương tiện kỹ thuật hiện đại để áp dụng cho di chúc. Quan điểm này xác định *“việc sử dụng các máy móc và phương tiện điện tử để viết thì không được chấp nhận, mặc dù một vài ý kiến nhấn mạnh việc ủng hộ cho chữ ký điện tử hoặc thu âm giọng nói. Một nhà bình luận đã tiến xa hơn là yêu cầu chấp nhận di chúc bằng điện tử và nghe nhìn, bao gồm không những di chúc được viết bằng cây bút kỹ thuật số lên màn hình mà còn có thể được đánh máy trên máy tính bằng chữ ký số và lưu vào một đĩa CD.”*²⁶⁸

Đối với các nước ở châu Mỹ, châu Úc quan điểm mang tính cởi mở hơn và thừa nhận sự linh hoạt trong quy định về hình thức di chúc.

Ở Úc, quan điểm của các nhà lập pháp của tiểu bang Queensland đã thông qua giai đoạn dài để có sự thay đổi cách nhìn nhận về hình thức di chúc, từ những quy định mang tính khắt khe đến việc chấp nhận những cách lưu giữ ý chí phù hợp hơn với xã hội, tạo sự thuận tiện hơn trong quá trình lập di chúc. *“Tiểu bang Queensland, trước kia thừa nhận các quy định khắt khe về di chúc. Tuy nhiên người ta nhận thấy rằng các quy định khắt khe đó có thể làm mất đi một di chúc thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản. Do vậy, đến Đạo luật Thừa kế năm 1981 được sửa đổi, bổ sung năm 2006 đã loại bỏ sự tuân thủ đáng kể của nguyên tắc này. Tòa án lúc này có thể bỏ đi một số sự tuân thủ về hình thức trong một số trường hợp nhất định.”*²⁶⁹ Bên cạnh đó pháp luật ở tiểu bang Queensland định nghĩa văn bản theo nghĩa rất rộng bao gồm *“bất kỳ phương thức thể hiện hoặc tái tạo từ ngữ nào ở dạng dễ nhìn thấy.”*²⁷⁰ Điều này rất có ý nghĩa khi xem xét một số trường hợp di chúc được thể hiện bằng chữ viết nhưng đã được ghi lại và lưu trữ qua các thiết bị điện tử như DVD, máy tính và điện thoại di động²⁷¹. Từ cách hiểu như vậy khi một di chúc được thể hiện thông qua các phương tiện điện tử sẽ được chấp nhận ở tiểu bang Queensland.

Tương tự như vậy ở tiểu bang Tasmania, Úc cũng có quy định về văn bản hiểu theo nghĩa rộng, văn bản bao gồm *“(ii) đĩa, băng, hoặc bài báo khác mà từ đó âm thanh, hình ảnh, chữ viết hoặc thông điệp có thể được sao chép lại”*²⁷². Các định nghĩa của tiểu bang New South Wales về văn bản cũng xác định: *“(c) bất kỳ chất liệu gì từ đó âm thanh, hình ảnh hoặc chữ viết có thể được tái tạo dù có hoặc không có sự hỗ trợ*

²⁶⁷ Kenneth G C Reid, Marius J de Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.468.

²⁶⁸ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.83-84.

²⁶⁹ Kelly Purser, Tina Cockburn (2019), “Wills formalities in the twenty first century – Promoting testamentary intention in the face of societal change and advancements in technology: An Australian response to Professor Crawford”, *Wisconsin Law Review*, tr.46-64.

²⁷⁰ Điều 7 Đạo luật Tự do thông tin Queensland 1992 (tác giả tạm dịch).

²⁷¹ Kelly Purser, Tina Cockburn, *tlđđ* (số chú thích 268), tr.46-64. Xem thêm vụ án Radford v. White: trong vụ án này một video được ghi âm lại được xem là một di chúc.

²⁷² Điều 24 Đạo luật Di sản và Hành động Tasmania 1931 (tác giả tạm dịch).

của các phương tiện khác.”²⁷³ Đây là các quy định cơ bản để từ đó các tiểu bang của Úc chấp nhận di chúc điện tử là di chúc bằng văn bản bởi vì chữ viết được thể hiện và lưu giữ trên các phương tiện điện tử.

Sau đó thực tế đã có hai vụ việc cụ thể được Tòa án ở tiểu bang Queensland, một vụ việc ở tiểu bang Victoria xét xử. Các vụ việc này đều xảy ra vào năm 2013 với những di chúc được lập và lưu giữ trên thiết bị điện tử là đĩa DVD, điện thoại iphone. Mặc dù di chúc được lập bằng cách sử dụng các thiết bị công nghệ có vi phạm các quy định pháp luật về hình thức di chúc không phải trường hợp nào cũng được Tòa án chấp nhận nhưng việc dần ghi nhận trong một số trường hợp đã thay đổi nhận thức về các hình thức di chúc của pháp luật thừa kế.²⁷⁴

Ở Mỹ, thực tiễn xây dựng và áp dụng di chúc điện tử được phát triển theo hướng bắt đầu từ những vụ việc cụ thể được xét xử của Tòa án trong quá trình giải quyết về di chúc điện tử để đánh giá về những vụ việc này và từ đó có lựa chọn để đưa ra án lệ cho hình thức di chúc điện tử. Trên cơ sở có án lệ về di chúc điện tử và sự thông dụng của di chúc điện tử lúc này cơ quan lập pháp sẽ có cách đánh giá chính xác nhu cầu, vai trò cũng như hạn chế của hình thức di chúc điện tử để có thể xây dựng các quy định pháp luật phù hợp cho hình thức di chúc điện tử.

Năm 2013, ở tiểu bang Ohio, Tòa án đã đồng ý công nhận một di chúc được lập thông qua phương tiện điện tử đó là máy tính bảng Samsung có cài mật mã bảo vệ. Anh Javier khi đó đang ở trên giường bệnh trong bệnh viện đã đọc và sau đó lưu nội dung vào trong phương tiện điện tử này trước mặt sự hiện diện của hai người làm chứng đó là anh trai, Migue và Albia. Cũng giống Javier, hai người làm chứng sau đó cũng ký vào văn bản điện tử này bằng cách sử dụng bút cảm ứng của máy tính bảng. Tòa án sau đó không cần xem xét đến những bằng chứng hoặc sự kiện khác đã thừa nhận bản di chúc được lập thông qua máy tính bảng hội tụ đủ các điều kiện về hình thức và thừa nhận di chúc đó.²⁷⁵

Ở tiểu bang Michigan, Tòa phúc thẩm đã thừa nhận một trường hợp tương tự là di chúc được lập bởi anh Duane Horton, 21 tuổi thông qua một phần mềm Evernote²⁷⁶. Trong phần mềm này anh Duane lưu nội dung dưới tên gọi là ghi chú cuối cùng và ghi chú này không có ngày, tháng, không được ký tên, nhưng đoạn cuối có phần viết tay và cả thông tin tài khoản đăng nhập vào Evernote của anh Duane. Tài liệu điện tử được

²⁷³ Khoản 3 Điều 1 Luật Thừa kế New South Wales 2006 (tác giả tạm dịch).

²⁷⁴ Mariusz Zalucki (2019), “About the need to adjust the regulations regarding the form of will to the modern requirement”, *European Journal of Economics, Law and Politics*, tập 6, số 2, tr.7-8.

²⁷⁵ Paige Hall (2019), “Welcoming e-wills into the mainstream: the digital communication of testamentary intent”, *Nevada Law Journal*, Vol. 20.1, tr.346-348.

²⁷⁶ Phần mềm Evernote là bộ phần mềm, dịch vụ thiết kế sử dụng cho nhu cầu thu thập thông tin và lưu trữ thông tin. Những thông tin này được lưu trữ lại dưới dạng các ghi chú. Hiểu đơn giản nhất Evernote là phần mềm ghi chú hỗ trợ cho nhiều nhu cầu cụ thể của người dùng. Trong phần mềm Evernote ghi chú có thể là đoạn văn, danh sách, hình ảnh, chữ viết tay...và nhiều dữ liệu khác. Sử dụng Evernote giúp người dùng có thể lưu trữ mọi loại thông tin người dùng thu thập cho mục đích cụ thể của mình.

lưu trên Evernote của anh Duane bao gồm rất nhiều nội dung riêng tư và có cả việc định đoạt tài sản của anh Duane cho người thừa kế.²⁷⁷

Sau hai án lệ được ghi nhận đến năm 2019 Mỹ đã soạn thảo và công bố Luật Di chúc điện tử quy định cụ thể về những điều kiện và trình tự, thủ tục để lập di chúc điện tử. Luật Di chúc điện tử sau đó đã được xem xét và công nhận theo pháp luật của từng tiểu bang. Luật Di chúc điện tử có hiệu lực được áp dụng ở Washington vào ngày 1.1.2022. Nhưng đây không phải tiểu bang đầu tiên chấp nhận áp dụng Luật Di chúc điện tử. Utah đã chấp nhận Luật Di chúc điện tử từ trước đó và là tiểu bang đầu tiên chấp nhận di chúc điện tử. Nevada, Indiana, Arizona và Florida đã thông qua luật cho phép di chúc điện tử. California, khu vực của Columbia, New Hampshire, Texas và Virginia đã xem xét Luật Di chúc điện tử nhưng vẫn chưa thông qua luật. Trong đại dịch Covid-19, New York và Connecticut đã ban hành lệnh hành pháp cho phép công chứng điện tử tạm thời hoặc thực hiện di chúc²⁷⁸. Bắc Dakota và Colorado chấp nhận Luật Di chúc điện tử vào năm 2021, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ trở thành khu vực tài phán thứ năm trong năm 2021. Ngoài ra, các dự luật ban hành luật về di chúc điện tử đã được đưa ra ở Georgia, Massachusetts và quận Columbia. Các tiểu bang, bao gồm Arizona, Florida, Indiana và Nevada đã ban hành các Đạo luật về di chúc điện tử không dựa trên luật thống nhất.²⁷⁹ Mặc dù ở Mỹ không đề cập cụ thể rằng di chúc điện tử là một loại hình di chúc mới hay là một loại di chúc bằng văn bản nhưng những án lệ dẫn chứng đến việc xem đây là di chúc bằng văn bản với những chứng cứ rất rõ ràng²⁸⁰.

Không chỉ ở Mỹ, liên quan đến di chúc điện tử ở một số nước có những vụ án mà cơ quan tài phán Tòa án đã xét xử và chấp nhận, chẳng hạn như tại Canada, New Zealand, Nam Phi. Các vụ việc này xảy ra ở các khía cạnh khác nhau liên quan đến hình thức di chúc điện tử như chữ ký điện tử, tài liệu điện tử chưa được in ra mà được lưu trong một phần mềm trong điện thoại, tài liệu trong điện thoại, tài liệu được đính kèm trong email mà chưa được ký.²⁸¹ Ở những nước này họ cũng thông qua các bản án đã được Tòa án xét xử để ghi nhận di chúc điện tử khi luật chưa quy định.

Cụ thể ở Canada, một tài liệu ở file word chưa in ra trong vụ tranh chấp Rioux và Coulombe. Người để lại di sản đã để lại một bức thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể của mình với chỉ dẫn đến một phong bì chứa một đĩa máy tính. Trên đĩa được viết tay cụm từ: “Đây là di chúc của tôi/Jacqueline Rioux/Ngày 1 tháng 2 năm 1996.” Đĩa chỉ chứa một tệp điện tử bao gồm những hướng dẫn chưa được ký tên của một bản di chúc

²⁷⁷ Paige Hall, *tlđđ* (số chú thích 274), tr.348-349.

²⁷⁸Thompsan Mc Mullan (2020), “Will Electronic Wills Be the New Normal?”, <https://www.tmlaw.com/commentary/will-electronic-wills-be-the-new-normal/>, [truy cập 15/3/2023].

²⁷⁹Sherry Bosse Lueders, “What the Uniform Electronic Wills Act Changes About Wills in Washington”, <https://wabarnews.org/2022/09/07/uniform-electronic-wills-act-washington/>, [truy cập 26/4/2023].

²⁸⁰ Paige Hall, *tlđđ* (số chú thích 274), tr.346-348.

²⁸¹ Kimberley Martin TEP, *tlđđ* (số chú thích 153), tr.21-22.

được lập. Tệp đã được lưu vào bộ nhớ máy tính vào cùng ngày mà người để lại di sản đã viết trong nhật ký của cô rằng cô đã lập di chúc trên máy tính của mình. Tòa án ở tiểu bang Quebec xác định rằng di chúc không hoàn hảo phải “không nghi ngờ và rõ ràng là chứa mong muốn cuối cùng của người đã chết”. Lúc này Tòa án đã chấp nhận di chúc.

Ở Nam Phi, một tài liệu điện tử chưa ký trong vụ tranh chấp MacDonald và The Master. Một tài liệu điện tử chưa ký được lưu trữ trên máy tính văn phòng của người để lại di sản với nội dung định đoạt tài sản của mình. Trước khi tự sát, người lập di chúc (một chuyên gia công nghệ thông tin cấp cao của IBM) đã để lại bốn dòng chữ viết tay của chính mình trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Một trong những ghi chú có nội dung: “Tôi, Malcom Scott MacDonald, ID 5609. . ., tuyên bố rằng di chúc cuối cùng của tôi có thể được tìm thấy trên máy tính của tôi tại IBM trong thư mục C:/windows/mystuff/mywill/personal”. Sau đó Tòa án xem xét và thừa nhận di chúc của người này.²⁸² Di chúc được lập theo đúng quy định là phải được viết, ký tên và có sự làm chứng của hai người làm chứng, mỗi trang của di chúc phải được xác nhận bởi người để lại di sản. Tuy nhiên, yêu cầu cơ bản mà Tòa án dựa vào đó để xem xét các ngoại lệ là các file lưu giữ ý chí của người để lại di sản không phải là một bản thảo hoặc ghi chú hoặc một thảo luận sơ bộ về việc di chúc sẽ được lập mà đây phải là bản di chúc - thể hiện ý chí cuối cùng của người để lại di sản²⁸³.

Mặc dù ở các quốc gia này chưa có những quy định cụ thể ghi nhận nhưng trong thực tiễn xét xử đã công nhận di chúc điện tử là hình thức di chúc mà người để lại di sản có thể lựa chọn để lưu giữ lại ý chí của mình.

3.6.2. *Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về di chúc điện tử*

Ở Việt Nam, BLDS 2015 có hiệu lực vào ngày 01/01/2017 khi quy định về hình thức di chúc đã ghi nhận hai hình thức di chúc là bằng văn bản và bằng miệng. Trong đó di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc tự lập; di chúc được đánh máy hoặc nhờ người viết hoặc đánh máy; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực²⁸⁴. Trong những loại hình thức di chúc bằng văn bản được BLDS 2015 liệt kê thì đây là những văn bản hiểu theo nghĩa truyền thống, tức là những di chúc được thể hiện trên những chất liệu truyền thống với những điều kiện về chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di sản, người làm chứng, người viết hộ, người công chứng hoặc chứng thực tùy vào từng trường hợp.

Mặc dù trong các hình thức di chúc bằng văn bản được luật liệt kê có di chúc bằng văn bản được người để lại di sản tự đánh máy hoặc nhờ người khác đánh máy ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản trên các thiết bị điện tử. Luật cũng không quy

²⁸² Kimberley Martin TEP, *tlđđ* (số chú thích 153), tr.22.

²⁸³ Sizwe Snail and Nicholas Hall (2010), “Electronic Wills in South Africa”, *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, số 7, tr.68-69.

²⁸⁴ Điều 628 BLDS 2015.

định cụ thể sau khi di chúc được đánh máy xong cần phải in di chúc rồi sử dụng chữ ký “sống” để ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc hay có thể lưu giữ nội dung bản di chúc trên thiết bị điện tử và sử dụng chữ ký số để ký vào bản di chúc. Tuy nhiên với quy định về hình thức của giao dịch dân sự có xác định *“Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản, bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”*²⁸⁵. Quy định tại khoản 1 Điều 119 BLDS 2015 xác định giao dịch dân sự bằng văn bản là những văn bản truyền thống, thể hiện trên các chất liệu truyền thống như bản giấy. Còn nếu đây là những giao dịch dân sự được thể hiện trên các thông điệp dữ liệu trên các phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử sẽ được xác định là giao dịch bằng văn bản nhưng văn bản này được hiểu theo nghĩa rộng. Chẳng hạn hợp đồng được thể hiện và lưu giữ trên các phương tiện điện tử, sử dụng chữ ký điện tử thì đây cũng là những hợp đồng bằng văn bản nhưng được gọi tên là hợp đồng điện tử²⁸⁶ và sẽ được quy định cụ thể trong Luật Giao dịch điện tử với những đặc trưng khác biệt. Do đó, quy định về di chúc bằng văn bản do người để lại di sản tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác đánh máy theo quy định tại Điều 634 BLDS 2015 được hiểu là di chúc được tạo lập trên phương tiện điện tử nhưng sẽ phải in ra và được người để lại di sản, người làm chứng ký chữ ký “sống” hoặc điểm chỉ trên bản giấy di chúc đó. Từ đó có thể thấy BLDS 2015 chỉ mới ghi nhận di chúc bằng văn bản hiểu theo nghĩa truyền thống.

Trong thực tiễn xét xử, Tòa án cũng đang hiểu di chúc được người để lại di sản đánh máy hoặc nhờ người khác đánh máy quy định tại Điều 634 BLDS 2015 là văn bản giấy truyền thống mặc dù được tạo lập trên các thiết bị điện tử. Bởi lẽ để xác định di chúc điện tử cần rất nhiều thêm các điều kiện khác như mật mã bảo vệ, cách thức xác định người tạo lập... Trước đó Luật Giao dịch điện tử 2005 cũng khẳng định giao dịch điện tử không áp dụng cho các văn bản về thừa kế²⁸⁷. Do vậy có thể khẳng định di chúc được thể hiện dưới dạng các thông điệp dữ liệu trên các phương tiện điện tử (còn gọi là di chúc điện tử) chưa được pháp luật Việt Nam cũng như trong thực tiễn xét xử ghi nhận.

Đến thời điểm hiện nay và trong tương lai, khi việc sử dụng các phương tiện điện tử ở Việt Nam đã thông dụng. Một bộ phận người dân về cơ bản đã thành thạo trong cách sử dụng các phương tiện điện tử để phục vụ cho nhu cầu của mình trong đó có việc soạn thảo và lưu trữ văn bản. Ngoài ra, di chúc được lập và lưu trữ trên các phương tiện điện tử lại dễ dàng, nhanh chóng, khó bị thất lạc, khó bị hư hỏng. Với

²⁸⁵ Khoản 1 Điều 119 BLDS 2015.

²⁸⁶ Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005.

²⁸⁷ Điều 1 Luật Giao dịch điện tử 2005.

những ưu điểm như trên thiết nghĩ đã đến lúc Việt Nam nên cân nhắc xem xét đến việc thừa nhận di chúc điện tử. Theo quan điểm của tác giả, đây cũng chính là một bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam khi chưa bắt kịp để điều chỉnh phù hợp với sự phát triển và nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên nếu chấp nhận di chúc điện tử cũng cần phải giải quyết các thách thức khi đảm bảo di chúc điện tử là phương thức ghi nhận đúng ý chí của người lập di chúc.

Mỹ là một quốc gia tiên phong có một luật riêng ghi nhận về di chúc điện tử và được rất nhiều các tiểu bang áp dụng. Theo quy định của Luật Di chúc điện tử Mỹ có thể xác định *“di chúc điện tử là di chúc được tạo lập, lưu trữ và có thể đọc được dưới dạng văn bản trên các phương tiện điện tử”*²⁸⁸. Về cơ bản di chúc điện tử chỉ khác di chúc bằng văn bản truyền thống là việc tạo lập, lưu trữ và xem lại nội dung di chúc không bằng bản giấy mà thông qua các phương tiện điện tử.

Ở Mỹ việc sử dụng các văn bản điện tử trong nhiều lĩnh vực đã thông dụng nên di chúc điện tử sẽ được thể hiện dưới nhiều cách thức khác nhau. Di chúc điện tử ngoại tuyến là những di chúc được đánh giá đơn giản (đánh máy hoặc viết tay qua bút cảm ứng) vào một thiết bị điện tử của chính người lập di chúc, do người lập di chúc ký tên vào di chúc và được lưu trữ trên thiết bị điện tử có ổ cứng cục bộ. Di chúc thường không được in, chứng thực theo cách truyền thống hoặc tải lên trang mạng. Hay di chúc điện tử trực tuyến là di chúc được tạo hoặc lưu trữ bằng dịch vụ của bên thứ ba. Và di chúc điện tử được lập có tổ chức giám sát đủ điều kiện. Tổ chức giám sát này vì lợi nhuận cam kết trở thành người giám sát đủ điều kiện sẽ tạo lập, thực hiện và lưu trữ di chúc của người lập di chúc, tuân theo các quy tắc và quy định do luật đưa ra.²⁸⁹

Với cách hiểu này những di chúc được tạo lập và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử là di chúc điện tử. Một người trước khi chết tạo lập một file điện tử trong máy tính của mình để định đoạt tài sản mà không in ra bản giấy. Bản file được lưu trữ trong các thiết bị điện tử của người đó nếu đủ các điều kiện luật định kèm theo thì bản file này sẽ được xác định là một di chúc điện tử.

Điều kiện và trình tự thủ tục lập một di chúc điện tử để đảm bảo tính nguyên gốc của di chúc cần phải có chữ ký của người lập di chúc, tùy từng trường hợp có thể có thêm người làm chứng, di chúc phải được công chứng. Theo quy định của Luật Di chúc điện tử Mỹ có thể lập di chúc điện tử theo hai cách thức sau đây: (i) Người lập di chúc tự lập thông qua thiết bị điện tử. Di chúc phải được ký bởi người lập di chúc. (ii) Nếu người lập di chúc không tự mình lập mà nhờ người khác lập thì phải có chữ ký của người viết hộ di chúc trước sự chứng kiến trực tiếp của người lập di chúc và theo chỉ đạo của người lập di chúc. Đồng thời di chúc phải được ít nhất hai cá nhân ký với sự hiện diện trực tiếp hoặc sự hiện diện điện tử. Hai người này là người làm chứng cho

²⁸⁸ Điều 5 Luật Di chúc điện tử Mỹ 2019 (tác giả tạm dịch).

²⁸⁹ Kimberley Martin TEP, *tlđđ* (số chú thích 153), tr.23.

việc lập di chúc. Yêu cầu đối với người làm chứng là mỗi người trong số họ là cư dân của một tiểu bang và có địa chỉ thực tế tại một tiểu bang vào thời điểm ký. Ngoài chữ ký phải có lời chứng thừa nhận của người lập di chúc và người làm chứng. Ngoài ra, quy trình lập di chúc phải trước sự chứng kiến trực tiếp hoặc sự hiện diện điện tử của công chứng viên hoặc cá nhân khác được pháp luật trao quyền để công chứng xác nhận hồ sơ điện tử.²⁹⁰ Ở đây cách hiểu về sự hiện diện điện tử có nghĩa là mối quan hệ của hai hoặc nhiều cá nhân ở các địa điểm khác nhau giao tiếp trong thời gian thực với cùng mức độ như thể các cá nhân có mặt thực tế ở cùng một địa điểm. Đây là quy định chung ở Mỹ, nhưng tùy từng tiểu bang có thể sẽ có những quy định đặc thù. Chẳng hạn quy định về sự hiện diện điện tử tùy theo pháp luật từng tiểu bang có thể chấp nhận điều kiện này hoặc không. Ở tiểu bang Indiana bắt buộc tất cả các bên phải có sự hiện diện trực tiếp tại địa điểm lập di chúc nhưng tiểu bang Nevada cho phép làm chứng từ xa²⁹¹.

Ở tiểu bang Nevada có đặt ra các điều kiện cho di chúc điện tử, theo đó “*di chúc điện tử là di chúc được viết, tạo và lưu trữ trong hồ sơ điện tử và có ghi ngày, chữ ký điện tử và ít nhất một đặc điểm xác thực của người lập di chúc*”²⁹². Người lập di chúc hoặc người được chỉ định phải lưu giữ di chúc điện tử theo cách chỉ cho phép một người có quyền có bản sao mà người lập di chúc hoặc người được chỉ định phải lưu giữ và kiểm soát. Theo luật của tiểu bang Nevada, đặc điểm xác thực bao gồm một yếu tố sinh học duy nhất tương tự như dấu vân tay, quét võng mạc hoặc nhận dạng khuôn mặt hoặc giọng nói. Mặc dù công nghệ nhận dạng sinh trắc học đã tiến bộ đều đặn, việc kết hợp các đặc điểm xác thực như vậy thành văn bản điện tử vẫn chưa được phổ biến rộng rãi như những người soạn thảo luật của Nevada đã mong đợi.²⁹³

Ở tiểu bang Indiana, Luật Di chúc điện tử yêu cầu cả người lập di chúc và ít nhất hai người làm chứng ký vào di chúc bằng chữ ký điện tử. Theo luật của tiểu bang Arizona, di chúc điện tử có hiệu lực nếu nó bao gồm thông tin của người lập di chúc chữ ký, ngày và giờ ký. Khi thực hiện di chúc điện tử, tiểu bang Arizona vẫn yêu cầu hai nhân chứng phải có mặt để ký và xác nhận di chúc. Di chúc cũng phải bao gồm một bản sao giấy tờ do chính phủ cấp (thẻ căn cước) của người lập di chúc.²⁹⁴

Xét thấy quy định về cách thức lập di chúc điện tử gần như tương tự với di chúc bằng văn bản tự tay viết hoặc di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực. Tuy

²⁹⁰ Điều 5 Luật Di chúc điện tử Mỹ 2019 (tác giả tạm dịch).

²⁹¹ Francesca Torres (2021), “Electronic Wills: COVID-19 Relief or Inevitable trouble for California?”, *University of the Pacific Law Review*, No. 52, Vol. 2, tr.441.

²⁹² Nevada Revised Statute §133.085. 1(a)-(b), <https://law.justia.com/codes/nevada/2022/chapter-133/statute-133-085/>, [truy cập 30/8/2022].

²⁹³ Bodderly, Scott S. (2012), “Electronic Wills: Drawing a line in the sand against their validity”, *Real Property, Trust, and Estate Law Journal*, Chicago, số 47, tr.199.

²⁹⁴ Francesca Torres, *ltd* (số chú thích 290), tr.441.

nhiên điểm khác biệt là tất cả những công đoạn để ghi nhận, tạo lập và lưu trữ di chúc được thể hiện trên các thiết bị điện tử.

Bên cạnh đó để có những chứng cứ chứng minh tính xác thực của di chúc điện tử thì một cá nhân có thể tạo một bản sao giấy của di chúc điện tử bằng cách xác nhận rằng bản sao giấy của di chúc điện tử là bản sao hoàn chỉnh, đúng sự thật và chính xác của di chúc điện tử. Bản sao giấy của di chúc điện tử phải bao gồm những lời chứng tự chứng minh của người lập di chúc.²⁹⁵ Quy định này không bắt buộc cho người lập di chúc điện tử nhưng khuyến khích và đề xuất người lập di chúc có thể tạo lập bản giấy này để lưu trữ, tăng thêm độ xác thực cho di chúc điện tử.

Trên thực tế ở Mỹ khi người để lại di sản lập di chúc điện tử họ sẽ có bản giấy ghi tay lời chứng của họ để chỉ rõ di chúc điện tử được tạo lập và lưu trữ trên thiết bị điện tử nào, cách mở khóa mật mã ra sao để có thể đọc được nội dung của bản di chúc. Ngoài ra, trong bản giấy ghi tay này có lời chứng, có chữ ký tay của người lập di chúc về việc thừa nhận đây là di chúc của mình. Đã có đề xuất cho rằng nếu có bản viết tay lời chứng của người để lại di sản thì cần giao cho một trong số những người làm chứng, người lập hộ di chúc, luật sư, người thứ ba khác hoặc gửi giữ tại các tổ chức công chứng để đảm bảo tính khách quan²⁹⁶.

Trên cơ sở tham khảo pháp luật của Mỹ về di chúc điện tử, theo quan điểm của tác giả có thể ghi nhận hình thức di chúc điện tử tại Việt Nam khi người lập di chúc đã có thói quen sử dụng thiết bị điện tử để tạo lập văn bản, giao kết hợp đồng điện tử và sử dụng chữ ký điện tử để ký tên xác nhận vào văn bản đó. Hiện nay việc cá nhân sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử đã có và có những văn bản quy định cụ thể về loại chữ ký này²⁹⁷ cũng như có những tổ chức chứng thực chữ ký điện tử để đảm bảo tính xác thực của chữ ký đó²⁹⁸. Khi ghi nhận di chúc điện tử tại Việt Nam tác giả có các đề xuất sau đây để đảm bảo ghi nhận thêm một loại hình di chúc mới cho người để lại di sản có thêm sự lựa chọn trong quá trình lập di chúc nhưng vẫn đảm bảo di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

Thứ nhất, nguồn luật áp dụng cho di chúc điện tử

Luật Giao dịch điện tử 2005 đang được thảo luận sửa đổi, bổ sung để có thể theo kịp với sự phát triển của xã hội. Theo Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Giao dịch điện tử xác định “*quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định*”. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo

²⁹⁵ Điều 9 Luật Di chúc điện tử Mỹ 2019 (tác giả tạm dịch).

²⁹⁶ Nguyễn Thanh Thư (2021), “*Di chúc được lập thông qua các phương tiện điện tử*”, Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, số 145, tr.77.

²⁹⁷ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

²⁹⁸ Quyết định số 26/QĐ-BTTTT ngày 16/01/2023 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia.

Luật Giao dịch điện tử đã được mở rộng so với Luật Giao dịch điện tử 2005. Tuy nhiên trong Dự thảo Luật Giao dịch điện tử đã giải thích rõ giao dịch trong Luật Giao dịch điện tử là “*thỏa thuận, trao đổi, hợp đồng giữa các chủ thể về một vấn đề cụ thể*”.²⁹⁹ Do đó có thể thấy theo Dự thảo Luật Giao dịch điện tử hướng tới sẽ là những giao dịch mang tính chất thỏa thuận trao đổi giữa các bên. Nếu căn cứ vào quy định này trong Dự thảo Luật Giao dịch điện tử thì di chúc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Giao dịch điện tử do di chúc là một hành vi pháp lý đơn phương. Khi đề cập đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Giao dịch điện tử đối với lĩnh vực thừa kế đã có rất nhiều quan điểm quan ngại về vấn đề áp dụng, cách thức giải quyết của Tòa án, lộ trình áp dụng...³⁰⁰. Mặt khác, dựa vào kinh nghiệm của Mỹ đã ghi nhận di chúc điện tử thì họ không sử dụng Luật Giao dịch điện tử để điều chỉnh cho di chúc điện tử mà họ sẽ có Luật Di chúc điện tử hoặc dựa trên các án lệ để ghi nhận về di chúc điện tử. Ở Mỹ, trước khi có Luật Di chúc điện tử đã có các án lệ ghi nhận về hình thức di chúc này. Tuy nhiên khi Luật Di chúc điện tử ra đời vào năm 2019 đã tạo ra sự áp dụng pháp luật thống nhất hơn giữa các tiểu bang.

Ở Việt Nam Luật Giao dịch điện tử vẫn đang được xem xét đề sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với quá trình phát triển của xã hội. Trong tương lai khi Luật Giao dịch điện tử được thông qua sẽ không chắc chắn có áp dụng cho các văn bản thừa kế hay không theo đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử đối với tất cả các hoạt động của đời sống xã hội.³⁰¹ Tuy nhiên theo tác giả cho rằng nguồn luật áp dụng sẽ dựa trên cơ sở là sự ghi nhận trong BLDS 2015. BLDS khi quy định về hình thức di chúc có thể bổ sung thêm một loại hình thức di chúc điện tử vào trong nhóm các loại hình thức di chúc bằng văn bản. BLDS sẽ có điều luật làm rõ khái niệm di chúc điện tử, điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc điện tử.

Thứ hai, lộ trình để áp dụng di chúc điện tử tại Việt Nam

Hiện nay để áp dụng di chúc điện tử ở Việt Nam sẽ cần có lộ trình từng bước để xem xét tất cả các yếu tố về điều kiện của di chúc điện tử, trình tự thủ tục lập cho một di chúc điện tử, việc công chứng di chúc điện tử cũng như những yêu cầu của xã hội. Do vậy, để có thể xây dựng được quy phạm pháp luật cụ thể cho di chúc điện tử ở thời điểm hiện nay là chưa thể nhưng với quy định tại khoản 1 Điều 119 BLDS 2015 và các văn bản quy định về chữ ký số, xác thực chữ ký số sẽ là bước đầu cho Tòa án giải quyết các vụ việc có quá trình lập di chúc và lưu giữ di chúc trên các phương tiện điện tử. Trong những vụ việc thực tiễn nếu có đủ chứng cứ và yếu tố có thể xác định đây là di chúc điện tử thì Tòa án nên mạnh dạn ghi nhận loại hình di chúc này. Từ đó là cơ sở

²⁹⁹ Dự thảo Luật Giao Dịch điện tử (sửa đổi)
<https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/duthaovbpl/luatgiaodichdientu.pdf>, [truy cập 12/5/2023].

³⁰⁰ Bích Lan, Cần nhắc mở rộng phạm vi hoạt động áp dụng giao dịch điện tử đối với lĩnh vực đất đai, thừa kế, <https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=68742>, [truy cập 28/4/2023].

³⁰¹ Dự thảo 01 – Tờ trình về việc xây dựng Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) năm 2022.

cho việc ghi nhận án lệ để thừa nhận di chúc điện tử. Trong tương lai khi việc lập di chúc điện tử trở nên phổ biến và thuận lợi hơn ở Việt Nam thì lúc này quy định trong BLDS sẽ có bổ sung thêm một loại hình thức di chúc điện tử vào hình thức di chúc bằng văn bản.

Thứ ba, quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về di chúc điện tử

Trên cơ sở tham khảo quy định của pháp luật Mỹ cũng như những vụ việc thực tiễn đã được ghi nhận ở Mỹ, Canada, Úc và Nam Phi có thể xác định di chúc điện tử là di chúc được tạo lập, lưu trữ và có thể đọc được dưới dạng văn bản thông qua các phương tiện điện tử. Thay cho văn bản truyền thống (được thể hiện trên giấy hoặc trên chất liệu vật chất cụ thể) thì di chúc điện tử được khởi tạo, thực hiện và lưu giữ trên các thiết bị điện tử. Theo quan điểm của tác giả, để phù hợp với khả năng và điều kiện của Việt Nam, di chúc điện tử có thể được lập theo một trong hai cách sau đây:

Cách thứ nhất, người để lại di sản tự mình lập di chúc điện tử trên các thiết bị điện tử, dùng chữ ký số để ký vào di chúc điện tử, thiết lập mật mã bảo vệ cho di chúc điện tử.

Hoặc cách thứ hai, người để lại di sản có thể nhờ người lập hộ di chúc trên các thiết bị điện tử nhưng phải có sự hiện diện trực tiếp của ít nhất hai người làm chứng. Sau đó những người để lại di sản, người làm chứng xác nhận lại nội dung di chúc, ký tên vào bản di chúc và người để lại di sản thiết lập mật mã bảo vệ cho di chúc. Chữ ký của người để lại di sản và người làm chứng, người lập hộ di chúc là chữ ký số.

Di chúc điện tử vẫn phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện về thể thức như đối với một văn bản truyền thống về ngày, tháng, năm lập di chúc; vấn đề viết tắt, ký hiệu trong di chúc. Di chúc điện tử phải được người để lại di sản, người làm chứng ký vào từng trang của di chúc. Có thể xem xét áp dụng quy định pháp luật về chữ ký số trong các giao dịch điện tử³⁰² cho di chúc điện tử. Sau này khi Việt Nam đã phát triển hình thức công chứng tư điện tử thì có thể nghĩ đến việc công chứng di chúc điện tử và gửi giữ di chúc điện tử tại các tổ chức công chứng.

Ngoài ra, người để lại di sản có bản viết tay có lời chứng của người để lại di sản, người làm chứng về việc xác nhận sự tồn tại của di chúc điện tử được người để lại di sản tạo lập, xác nhận phương tiện điện tử chứa đựng di chúc điện tử, xác nhận cách thức bảo vệ di chúc điện tử và cách truy cập để đọc nội dung di chúc điện tử. Bản viết tay này có thể được giao cho người làm chứng, luật sư, người thứ ba khác hoặc gửi giữ tại các tổ chức công chứng.

Kết luận: Với những phân tích đã được chỉ ra, tác giả kiến nghị ở Việt Nam dần ghi nhận di chúc điện tử thông qua thực tiễn xét xử bằng việc ghi nhận án lệ về di chúc điện tử. Sau đó trên cơ sở phân tích, đánh giá những vụ việc thực tiễn đã xảy ra

³⁰² Điều 21, 22 Luật Giao dịch điện tử 2005 và Điều 8, 9 Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

BLDS nên có quy định bổ sung để ghi nhận di chúc điện tử là một loại hình thức di chúc bằng văn bản bên cạnh các loại hình thức di chúc bằng văn bản truyền thống đã được quy định. Do vậy, BLDS nên bổ sung điều luật với nội dung đề xuất tạm như sau **Điều...Di chúc điện tử** “1. Di chúc điện tử là di chúc được tạo lập, lưu trữ và có thể đọc được trên các thiết bị điện tử. 2. Người lập di chúc có thể tự mình lập di chúc trên các thiết bị điện tử, ký tên vào bản di chúc. Hoặc người lập di chúc có thể nhờ người khác lập hộ di chúc trên các thiết bị điện tử nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; người làm chứng xác nhận và ký vào bản di chúc. Sau đó, người lập di chúc thiết lập chế độ bảo mật cho nội dung di chúc và có bản viết tay có lời chứng của người lập di chúc, người làm chứng di chúc và những nội dung bảo mật của di chúc điện tử.”

Quy định cụ thể về điều kiện của di chúc điện tử, về quy trình và thủ tục lập di chúc điện tử cần được thực tiễn đánh giá để những quy định này phù hợp hơn. Tuy nhiên theo tác giả với những đề xuất ở trên là những điều kiện cơ bản để lập di chúc điện tử và bảo mật tốt nội dung di chúc điện tử. Sau này khi hoạt động công chứng điện tử ở Việt Nam phát triển có thể nghĩ đến việc công chứng di chúc điện tử và gửi giữ di chúc điện tử tại các tổ chức công chứng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Di chúc bằng văn bản được ghi nhận với nhiều loại hình đa dạng. Chủ thể để lại di sản với những khả năng tạo lập di chúc khác nhau, với những hoàn cảnh khác nhau sẽ có sự lựa chọn hoặc dựa vào quy định của luật để áp dụng hình thức di chúc cho phù hợp với từng điều kiện của họ. Do vậy có thể khẳng định hình thức di chúc bằng văn bản là hình thức di chúc cơ bản nhất.

Khi nghiên cứu về di chúc bằng văn bản có thể thấy tên gọi của di chúc bằng văn bản không có người làm chứng và di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo quy định của Điều 633, Điều 634 BLDS 2015 là chưa phù hợp. Cách gọi tên của hai loại hình thức di chúc chưa thể hiện rõ hình thức di chúc mà đang đề cập đến điều kiện của hình thức di chúc do vậy tác giả đề xuất nên đặt lại tên là di chúc tự viết và di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy.

Điều chỉ có thể là một điều kiện thay thế chữ ký của người lập di chúc nếu đây là di chúc tự viết. Tuy nhiên, những di chúc này phải có lời chứng của người lập di chúc để chắc chắn di chúc đã được người lập di chúc thừa nhận. Ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc tự tay viết mà người lập di chúc không biết thì tính xác thực của nội dung di chúc có thể bị nghi ngờ. Do vậy điều kiện quan trọng bên cạnh chữ viết, ký tên chính là việc người lập di chúc phải biết ngôn ngữ mà họ thể hiện trong di chúc. Bên cạnh đó, khi không thể và không có cơ sở để xác định yếu tố chữ viết thì Tòa án có thể căn cứ vào những bằng chứng khác để xác định đây có phải là di chúc do người lập di chúc viết như căn cứ vào những hành vi của người lập di chúc vào thời điểm họ còn sống, căn cứ vào lời khai của những thân, người quen trong gia đình để xác định ý chí của người lập di chúc khi họ còn sống.

Đối với di chúc nhờ người khác viết, đánh máy thì việc quy định người thừa kế theo pháp luật không được là người làm chứng di chúc đang theo hướng hạn chế đi quyền làm chứng cho việc lập di chúc. Do vậy nên ghi nhận người thừa kế theo pháp luật có thể là người làm chứng cho việc lập di chúc. Tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác và khách quan của việc làm chứng thì người là chứng phải là người biết viết, biết đọc ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc.

Người lập di chúc nếu không nghe được thì vẫn có thể tự mình viết di chúc và tự ký được vào di chúc. Lúc này di chúc được lập đủ điều kiện của di chúc bằng văn bản tự tay viết và không cần bắt buộc nhờ người làm chứng và có công chứng, chứng thực. Do vậy quy định bắt buộc phải lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng, có công chứng, chứng thực sẽ chỉ dành cho người không đọc được. Bên cạnh đó vai trò của người làm chứng trong trường hợp này cần phải đọc lại nội dung di chúc cho người lập di chúc để người lập di chúc xác nhận lại nội dung di chúc của mình.

BLDS Việt Nam quy định bổ sung thêm hình thức di chúc niêm phong có công chứng hoặc chứng thực cho người lập di chúc có thêm sự lựa chọn loại hình thức di chúc bằng văn bản mới. Đây có thể xem là loại hình di chúc bằng văn bản kết hợp của di chúc tự viết và di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Người lập di chúc có thể giữ bí mật nội dung di chúc và di chúc được một bên thứ ba xác thực.

Pháp luật Việt Nam quy định có năm loại hình thức di chúc bằng văn bản cho người lập di chúc tùy vào từng điều kiện của mình có thể lựa chọn hoặc tuân thủ theo loại hình di chúc nếu luật đã có quy định. Các loại di chúc bằng văn bản được lập trong những hoàn cảnh độc lập với điều kiện, trình tự thủ tục là khác nhau. Do vậy, trong thực tiễn xét xử ở một hoàn cảnh không nên kết hợp điều kiện của các loại hình thức di chúc bằng văn bản để yêu cầu di chúc phải thỏa mãn điều kiện về hình thức dẫn đến gây khó khăn cho người lập di chúc.

Thừa nhận di chúc điện tử là một hướng đi tất yếu phù hợp với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên việc áp dụng tại Việt Nam cần có lộ trình phù hợp. Di chúc điện tử là di chúc được tạo lập, lưu trữ và có thể đọc được dưới dạng văn bản trên các phương tiện điện tử. Điều kiện và trình tự thủ tục lập một di chúc điện tử để đảm bảo tính nguyên gốc của di chúc cần phải có chữ ký của người lập di chúc, có người làm chứng và chữ ký của người làm chứng. Nếu áp dụng vào Việt Nam có thể căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 119 BLDS 2015 và các văn bản quy định về chữ ký điện tử, xác thực chữ ký điện tử sẽ là cơ sở cho Tòa án giải quyết và có thể ghi nhận án lệ về di chúc điện tử. Trong tương lai nếu di chúc điện tử trở nên phổ biến và thuận lợi áp dụng Việt Nam thì quy định trong BLDS sẽ có bổ sung thêm một loại hình thức di chúc bằng văn bản là di chúc điện tử.

CHƯƠNG 4: HÌNH THỨC DI CHỨC MIỆNG

Chương 4 của luận án nghiên cứu về hình thức di chúc miệng bằng việc phân tích các vấn đề lý luận về hình thức di chúc miệng; phân tích quy định của pháp luật, thực trạng pháp luật khi áp dụng vào thực tiễn các điều kiện và trình tự, thủ tục lập di chúc miệng. Trên cơ sở những thực trạng này và với sự tham khảo kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài để đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc miệng. Những kiến nghị hoàn thiện di chúc miệng đảm bảo di chúc miệng là cơ sở để xác thực, lưu giữ ý chí đích thực của người lập di chúc và giúp di chúc được lập thuận lợi hơn.

4.1. Khái niệm, đặc điểm hình thức di chúc miệng

4.1.1. *Khái niệm hình thức di chúc miệng*

Đã có nhiều tác giả đưa ra các cách hiểu về hình thức di chúc miệng, một trong những hình thức di chúc cổ điển. Có thể hiểu di chúc miệng là *“sự bày tỏ bằng lời nói ý chí của người để lại di sản thừa kế lúc còn sống trong việc định đoạt khối di sản của mình cho người khác sau khi mình chết”*³⁰³. Hoặc *“sự thể hiện ý chí của cá nhân thông qua lời nói và được những người khác ghi lại bằng văn bản”*³⁰⁴, hoặc đây là *“di chúc thể hiện ý chí của người để lại di sản thông qua lời nói nhằm chuyển dịch tài sản của mình cho chủ thể khác sau khi chết”*³⁰⁵. Các cách mô tả về di chúc miệng đều xác định được đặc trưng của di chúc miệng đó chính là sự thể hiện ý chí ra bên ngoài bằng lời nói. Thông qua lời nói, người lập di chúc sẽ bày tỏ ý chí định đoạt tài sản của mình.

Trong hai hình thức di chúc được luật quy định thì di chúc miệng là hình thức di chúc không được thừa nhận phổ biến trên thế giới³⁰⁶. *“Nếu như di chúc bằng văn bản là hình thức di chúc được sử dụng phổ biến, có giá trị chứng cứ cao thì di chúc miệng là hình thức di chúc mang tính chất phòng ngừa - trao cho người lập di chúc cơ hội cuối cùng để lại ý nguyện định đoạt tài sản của mình, nên hình thức di chúc này không được phổ biến và không được khuyến khích dùng nhiều”*³⁰⁷. Do đó có thể xác định di chúc miệng là một hình thức đặc biệt của di chúc.

Ở Việt Nam, xuất phát từ tập quán lâu đời, khi một người sắp cận kề cái chết, xung quanh họ sẽ có những người ruột thịt, thân thích và họ sẽ để lại những lời căn dặn, trăng trối trước khi chết. Xét về mặt pháp lý, di chúc miệng là những lời “trăng trối” hay “dặn dò” của người sắp chết cho những người còn sống thực hiện ý nguyện cuối

³⁰³ Trường Đại học Luật Hà Nội, *tlđđ* (số chú thích 2), tr.319.

³⁰⁴ Lê Đình Nghi, *tlđđ* (số chú thích 7), tr.264.

³⁰⁵ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.587.

³⁰⁶ Phạm Văn Tuyết, *tlđđ* (số chú thích 156), tr.165.

³⁰⁷ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 221), tr.567.

cùng của họ về những vấn đề liên quan đến tài sản. Từ những lời căn dặn đó, con cháu của người đã chết sẽ tiến hành phân chia di sản.

Di chúc miệng ở giai đoạn phong kiến được lập một cách đơn giản, chỉ bằng lời nói truyền đạt lại việc định đoạt tài sản của người để lại di sản cho những người thừa kế và gia đình, họ hàng của họ cùng nghe. Di chúc miệng trong thời kỳ phong kiến còn có tên gọi là “lệnh” của cha, mẹ³⁰⁸ và dù có thừa nhận di chúc miệng nhưng nhà làm luật không quy định các điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực pháp lý³⁰⁹. Đến TT 81/TT-TANDTC thuật ngữ “lệnh” đã được thay thế bằng thuật ngữ “di chúc miệng” và có kèm điều kiện nhưng cũng chỉ một điều kiện là có thêm người làm chứng³¹⁰. Kể thừa những quy định này đến nay di chúc miệng ngày càng được hoàn thiện hơn và chặt chẽ hơn để đảm bảo việc ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản. Những điều kiện về ghi chép lại, người làm chứng, công chứng hoặc chứng thực được đặt ra.

Mặc dù ở Việt Nam đã thừa nhận từ rất lâu loại hình di chúc miệng nhưng quy định về nó vẫn còn một số điểm chưa thật sự phù hợp. “*Thực tế việc thừa nhận di chúc miệng từ những văn bản trước đó như PLTK, BLDS 1995, 2005 cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề*”³¹¹. Quy định di chúc miệng trong BLDS 2015 chặt chẽ để đảm bảo thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản. Tuy nhiên nếu xét cụ thể về các điều kiện hình thức để đảm bảo di chúc miệng hợp pháp thì nhiều quan điểm cho rằng vẫn còn có nhiều điều kiện khó có thể áp dụng vào thực tiễn. Có quan điểm theo hướng “*nội dung được sửa đổi, bổ sung trong BLDS 2015 về di chúc miệng vẫn chưa thật sự triệt để*”³¹². Và “*nếu chúng ta đặt ra những điều kiện khắt khe tới mức không còn di chúc miệng nào được thừa nhận trong thực tế thì phải xem xét lại vì điều đó đồng nghĩa với việc loại bỏ di chúc miệng ra khỏi hệ thống các loại di chúc được chấp nhận tại Việt Nam*”³¹³. Nếu có ghi nhận di chúc miệng nên quy định các điều kiện mang tính linh hoạt và khả thi hơn, bảo đảm di chúc miệng được ghi nhận cụ thể trên thực tế³¹⁴. Tuy nhiên cũng có quan điểm ngược lại với những quan điểm trên cho rằng các điều kiện của di chúc miệng cần phải chặt chẽ hơn bởi lẽ người để lại di sản trong tình trạng cận kề cái chết và nội dung di chúc được hai người làm chứng ghi chép lại. Do vậy nếu điều kiện không chặt chẽ thì sẽ trao quyền cho hai người làm chứng được xác định nội dung di chúc và có thể hai người làm chứng sẽ làm sai lệch nội dung di chúc.

³⁰⁸ Điều 388 Bộ luật Hồng Đức (được dịch từ Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Tá Nhí, *tlđđ* (số chú thích 116), tr.152).

³⁰⁹ Trần Quang Trung, *tlđđ* (số chú thích 79), tr.108.

³¹⁰ TT 81/TT-TANDTC.

³¹¹ Lương Thị Hợp (2014), “Một số vấn đề về áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về di chúc miệng trong thực tiễn”, *Tạp chí Tòa án nhân dân*, số 21 tháng 11/2014, tr.30.

³¹² Hoàng Thị Loan, *tlđđ* (số chú thích 200), tr.34.

³¹³ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.612.

³¹⁴ Nguyễn Thanh Thư (2020), “Hình thức di chúc miệng”, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 02/2020, tr.31.

Có thể nhận định di chúc miệng được xem là sự lựa chọn sau hình thức di chúc bằng văn bản, chỉ khi người lập di chúc lâm vào tình trạng không thể lập di chúc bằng văn bản mới có thể nghĩ đến di chúc miệng. Tóm lại có thể hiểu *di chúc miệng là sự thể hiện ý chí của cá nhân bằng lời nói theo những trình tự nhất định nhằm định đoạt tài sản của họ cho những người khác khi họ lâm vào những tình trạng theo luật định mà không thể lập di chúc bằng văn bản.*

4.1.2. Đặc điểm hình thức di chúc miệng

Khi nghiên cứu về hình thức di chúc miệng đã có quan điểm cho rằng thực chất di chúc miệng chính là di chúc bằng văn bản do người sắp chết lập vì hình thức cuối cùng để lưu giữ lại ý chí của người lập di chúc cũng dưới dạng văn bản. Xét về mặt lý luận, ranh giới để phân biệt di chúc bằng văn bản và di chúc miệng rất mờ nhạt. Nếu xem xét đến phương thức lưu giữ ý chí của người lập di chúc trong khoảng thời gian dài có thể thấy giữa các hình thức di chúc cũng có những mối liên hệ nhất định³¹⁵. Di chúc bằng văn bản được ghi nhận và lưu giữ dưới dạng văn bản. Di chúc miệng sau thủ tục lập luật định cũng được lưu giữ dưới dạng văn bản. Tuy nhiên pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới vẫn ghi nhận di chúc miệng là một hình thức di chúc độc lập bên cạnh di chúc bằng văn bản dựa vào những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, di chúc miệng là hình thức di chúc dự phòng cho hình thức di chúc bằng văn bản.

Ở thời kỳ La Mã, di chúc miệng được lập trước ít nhất 7 người làm chứng như di chúc theo án lệ. Di chúc miệng chỉ được lưu giữ thông qua trí nhớ của người làm chứng. Do đó người làm chứng đóng vai trò quan trọng hơn so với sự ghi chép lại trong văn bản. Khi luật càng hoàn thiện, di chúc miệng được giới hạn hơn ở những trường hợp được lập và các điều kiện về nó ngày càng khắt khe hơn³¹⁶. Ở Việt Nam không phải lúc nào cũng được lập di chúc miệng, chỉ trong trường hợp cận kề cái chết và không thể lập di chúc bằng văn bản³¹⁷. Pháp luật Nhật Bản cho phép lập di chúc miệng khi đang trong tình trạng đe dọa tới tính mạng³¹⁸. Pháp luật Trung Quốc cho phép cá nhân lập di chúc miệng khi đối mặt với nguy hiểm sắp xảy ra³¹⁹. Luật của tiểu bang Montana, Mỹ khi đề cập đến điều kiện này có liệt kê rất rõ ràng “*người để lại di sản vào thời điểm đó đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trên thực địa hoặc làm nhiệm vụ trên tàu và trong cả hai trường hợp trong sự suy ngẫm, sợ hãi hoặc nguy hiểm về cái chết thực sự; hoặc, người để lại di sản tại thời điểm đó cận kề cái chết ngay lập tức do chấn thương nhận được cùng ngày*”³²⁰. Những trường hợp được lập di chúc

³¹⁵ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.678.

³¹⁶ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.573.

³¹⁷ Khoản 1 Điều 629 BLDS 2015.

³¹⁸ Khoản 1 Điều 976 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

³¹⁹ Điều 1138 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

³²⁰ J. Howard Toelle, *tlđđ* (số chú thích 145), tr.20.

miệng là đã rơi vào hoàn cảnh cận kề cái chết, sự sống và cái chết chỉ nằm trong lần ranh và trạng thái tinh thần của người lập di chúc có thể hoang mang, sợ hãi, căng thẳng, lo lắng. Do đó có nhiều trường hợp họ sẽ có những quyết định ngay lập tức về việc chuyển dịch tài sản của mình cho người khác. Những quyết định về sự định đoạt tài sản có thể là những quyết định bộc phát của người lập di chúc mà sau này khi suy nghĩ lại người lập di chúc có thể thay đổi ý chí của họ. Tuy nhiên nếu đây là di chúc bằng văn bản thì hoàn cảnh lập di chúc của người để lại di sản sẽ có sự khác biệt. Người lập di chúc sẽ có sự chuẩn bị về điều kiện khách quan cũng như chủ quan. Việc lập di chúc bằng văn bản có thể đã được lên kế hoạch từ trước, có sự suy nghĩ kỹ càng trong nội dung di chúc cũng như trong việc lựa chọn loại hình thức di chúc bằng văn bản mà người để lại di sản muốn lập.

Chính vì thế luật cũng đã xác định một nguyên tắc là sau một khoảng thời gian kể từ ngày lập di chúc miệng, nếu người lập di chúc còn sống và minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ. Khoảng thời gian này bao lâu thì tùy thuộc vào quy định pháp luật của từng quốc gia. Nguyên tắc này để xác định đúng tính chất của di chúc miệng là loại hình di chúc mang tính chất dự phòng cho trường hợp khi người lập di chúc không thể lập di chúc bằng văn bản. Điều kiện này không tồn tại ở hình thức di chúc bằng văn bản.

Thứ hai, thể thức lập di chúc miệng không yêu cầu điều kiện về chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di sản.

Theo quy định từ Điều 633 đến Điều 636 BLDS 2015 di chúc bằng văn bản dù do người để lại di sản tự lập hay nhờ người khác lập, có công chứng hoặc chứng thực hay không thì đều bắt buộc sẽ có chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di sản. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di sản là bằng chứng để chứng minh di chúc được lập thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản và người để lại di sản đã xác nhận lại nội dung di chúc và đồng ý với bản di chúc. Đối với di chúc miệng thì theo quy định tại khoản 5 Điều 630 BLDS 2015 việc xác thực nội dung di chúc hoàn toàn phụ thuộc vào bản ghi chép lại của hai người làm chứng. Người làm chứng không cần phải đọc lại nội dung di chúc cho người để lại di sản nghe và cũng không yêu cầu người để lại di sản phải ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào bản ghi chép. Do đó trong văn bản ghi lại ý chí của người để lại di sản không cần có chữ ký hoặc điểm chỉ của người để lại di sản. Có thể thấy thể thức lập di chúc bằng văn bản và di chúc miệng là khác biệt.

Thứ ba, hình thức di chúc miệng xuất phát từ phong tục tập quán.

Sự ghi nhận hình thức “di chúc miệng” là sự gọi tên xuất phát từ phong tục tập quán với di chúc được truyền miệng khi người sắp chết thể hiện ý chí trước mặt những người trong gia đình, dòng họ. Việc di chúc miệng được ghi chép lại vào văn bản chỉ là một điều kiện trong quá trình lập di chúc để nhằm đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí đó. Quá trình lưu giữ nội dung di chúc miệng thông qua văn bản sẽ đảm bảo có chứng

cứ vững chắc và an toàn hơn so với việc phụ thuộc vào sự ghi nhớ của người làm chứng. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc có thể sẽ diễn ra sau một khoảng thời gian rất dài tùy thuộc vào từng gia đình. Nhưng nội dung di chúc đã được lưu giữ bằng văn bản sẽ là cách thức bảo vệ chính xác ý chí của người để lại di sản.

4.2. Các trường hợp được lập di chúc miệng

4.2.1. Quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về các trường hợp được lập di chúc miệng

Theo pháp luật Việt Nam, di chúc miệng tưởng chừng được lập rất đơn giản nhưng để di chúc miệng ghi nhận chính xác và đúng ý chí của người lập di chúc, di chúc hợp pháp và có thể có hiệu lực pháp luật thì BLDS 2015 đặt ra những điều kiện rất khắt khe³²¹. Việc lập di chúc miệng “*chỉ phát sinh trong những trường hợp đặc biệt*”³²². Quy định chặt chẽ về điều kiện để được quyền lập di chúc miệng là cần thiết. Bởi lẽ di chúc miệng chỉ có thể được xem là hình thức cứu cánh cho những người để lại di sản muốn thể hiện quyền định đoạt tài sản của họ nhưng không còn cách nào khác là phải thể hiện bằng miệng. Nếu không quy định về điều kiện được quyền lập di chúc miệng thì dẫn đến ai muốn thể hiện ý chí định đoạt tài sản của mình trước khi chết cũng có thể lựa chọn di chúc miệng sẽ làm di chúc miệng không thể hiện đúng với mong muốn của nhà lập pháp ban đầu là di chúc miệng chỉ được sử dụng trong trường hợp cần thiết và rất hạn chế sử dụng. Người để lại di sản muốn lập di chúc miệng khi thỏa mãn hai điều kiện sau đây: *thứ nhất*, người để lại di sản ở vào hoàn cảnh bị cái chết đe dọa và *thứ hai*, khả năng họ không thể lập di chúc bằng văn bản³²³.

Tuy nhiên như thế nào là rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì BLDS 2015 không giải thích. Như vậy nếu diễn giải từ quy định này có thể hiểu tính mạng một người bị đe dọa theo hai hướng như sau. Thứ nhất, một người có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe trong lúc hấp hối gần đất xa trời, bị tai nạn mà không thể cứu chữa chỉ có thể nói vài lời trần trối cuối cùng, bị bệnh và đang ở giai đoạn gần kề cái chết...Hoặc cách hiểu thứ hai là trong tình trạng sức khỏe bình thường nhưng hoàn cảnh khách quan dẫn đến người đó tính mạng bị đe dọa như: bị lạc trong rừng mà không thể liên hệ được với bên ngoài, tàu đi biển bị bão tố, đang bị thảm họa, tai nạn, thiên tai nào đó...và ở hai hoàn cảnh này họ không thể lập di chúc bằng văn bản.

Hiện nay theo luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về những điều kiện hoàn cảnh đặc biệt cũng như chưa có quy định đặc thù về những đối tượng làm việc trong những môi trường rủi ro cao có thể ảnh hưởng đến tính mạng có được lập di chúc miệng hay không. Tuy nhiên quy định tại khoản 1 Điều 629 BLDS 2015 đã khẳng

³²¹ Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.616.

³²² Nguyễn Hồng Nam, *tlđđ* (số chú thích 164), tr.30.

³²³ Khoản 1 Điều 629 BLDS 2015.

định khi tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Đây là quy định được xem là mang tính khái quát cao có thể áp dụng trong mọi trường hợp, đối với mọi đối tượng và mọi loại tài sản khác nhau để đảm bảo người để lại di sản có thể lập di chúc miệng, trừ trường hợp luật có quy định khác³²⁴. Hơn nữa, hoàn toàn hợp lý khi luật cho phép một người đang cận kề cái chết, tính mạng bị đe dọa được dùng lời nói thể hiện ý nguyện của mình nhưng không cần thiết phải quan tâm nguyên nhân của việc tính mạng bị đe dọa là gì, bệnh tật hay nguyên nhân nào khác như quy định trong BLDS 2005. “*Bởi lẽ nguyên nhân không quan trọng điều quan trọng là hệ quả tính mạng bị cái chết đe dọa*”³²⁵.

Mặc dù vậy không phải mọi cá nhân khi bị đe dọa tính mạng và không thể lập di chúc bằng văn bản đều có quyền lập di chúc miệng. Ở đây BLDS 2015 đã loại trừ một số nhóm người không thể lập di chúc miệng đó là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, người bị hạn chế về thể chất, người không biết chữ³²⁶. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi suy nghĩ của họ còn non nớt, cần phải cho họ khoảng thời gian cân nhắc suy tính trước khi lập di chúc để định đoạt tài sản và cần phải hỏi ý kiến của những người như cha, mẹ, người giám hộ cho người chưa thành niên để xác định những người này có đồng ý cho họ được quyền lập di chúc không. Trong khi đó, di chúc miệng được lập khi ở vào những hoàn cảnh cấp thiết, tính mạng bị đe dọa, sự sống và cái chết là mong manh và như vậy sẽ khó cho nhóm người chưa thành niên có được suy nghĩ cân trọng để định đoạt tài sản sẽ dành cho ai. Đối với người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ thì khả năng đề tự mình xác nhận lại nội dung của họ sau khi được người làm chứng hoặc người viết hộ lập hộ di chúc là khó nên luật quy định di chúc của họ lập phải được thể hiện thành văn bản, có người làm chứng và có công chứng hoặc chứng thực.

Trong thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam, Tòa án xem xét điều kiện để người để lại di sản lập di chúc miệng khá linh hoạt. Một vụ việc được Tòa án giải quyết và đã công nhận di chúc miệng được lập thì hoàn cảnh lập di chúc miệng khá đặc biệt. Nguyên đơn trong vụ kiện cho rằng đây không phải là mong muốn lập di chúc mà chỉ lời tâm sự, chia sẻ của ông Hảo khi được chúc tết, nhưng Tòa án sau khi xem xét tình tiết của vụ việc và lời khai của người làm chứng đã xác định hoàn cảnh lập di chúc miệng là phù hợp. Cuối cùng Tòa án xác định đây là mong muốn định đoạt tài sản của ông Hảo trước khi chết chứ không phải chỉ là lời chia sẻ. Vụ việc cụ thể như sau: Ngày 03/02/2016 khi cán bộ đại diện các ban ngành của phường đến chúc tết ông Hảo do ông Hảo bị bệnh suy tim lâu ngày nên rất yếu. Tuy nhiên, ông Hảo vẫn nói chuyện, trao đổi với các bà và thời điểm này ông đã thể hiện mong muốn định đoạt tài

³²⁴ Khoản 2 Điều 630; khoản 3 Điều 630 BLDS 2015.

³²⁵ Đỗ Văn Đại, *tlđd* (số chú thích 73), tr.615.

³²⁶ Khoản 3, 4 Điều 630 BLDS 2015.

sản của mình cho người thừa kế là anh Thông dưới sự chứng kiến của bà Nguyệt, bà Liên, bà Thuận. Cụ thể ông Hảo có nói lại là: *“Cứ biết vậy thôi nhưng tôi vẫn trình bày với các bà vậy để nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhờ các bà biết ý tôi mà giúp đỡ cho cháu”*. Đến ngày 04/02/2016 ông Hảo phải vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu và đến 16h cùng ngày ông Hảo chết. Tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều xác định tại thời điểm ngày 03/02/2016 ông Hảo rất yếu và không thể tự mình lập di chúc được nhưng đầu óc ông Hảo vẫn minh mẫn, tỉnh táo. Ngoài ra, Tòa án cũng xác định không thể nói đây là lời chia sẻ, nói chuyện vui được vì khi bản thân ông Hảo hiểu được tình trạng sức khỏe của mình đã rất yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa nên ông đã bày tỏ mong muốn trong cuộc gặp mặt này. Ngoài ra, có bằng chứng chứng minh ý nguyện này của ông Hảo cũng phù hợp với thực tế khi ông Hảo đã giao toàn bộ các giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhà đất của ông cho anh Thông giữ.³²⁷

Từ những lập luận này di chúc miệng đã được công nhận. Trong vụ việc này có thể thấy mặc dù lời nói của ông Hảo được thể hiện trong một cuộc nói chuyện với một số người thân đến thăm ông Hảo khi sức khỏe ông yếu nhưng Tòa án dựa vào lời khai của người làm chứng, lời nói của ông Hảo và chứng cứ khác để chứng minh ý chí và mong muốn của ông là muốn để lại tài sản cho anh Thông (ông đã giao toàn bộ giấy tờ nhà đất cho anh Thông giữ) nên đã xác định đây là di chúc miệng của ông Hảo chứ không phải là ý định muốn lập di chúc của ông. Theo quan điểm của tác giả, hướng giải quyết của Tòa án là hợp lý vì khi ông Hảo thể hiện mong muốn của mình, mặc dù chưa nói đây là di chúc nhưng sức khỏe ông đã yếu, mong muốn của ông về tài sản giao cho anh Thông được thể hiện rất rõ ràng và ngay sau đó ông đã phải nhập viện điều trị và qua đời. Do vậy, khi xét đến hoàn cảnh lập di chúc theo quy định tại khoản 1 Điều 629 BLDS 2015 là phù hợp.

Theo pháp luật nước ngoài, những nước có ghi nhận di chúc miệng thì sẽ giới hạn điều kiện ở chủ thể được quyền lập di chúc miệng và/hoặc điều kiện về hoàn cảnh được lập di chúc miệng. Ở Anh, *“quyền lập di chúc của cá nhân không bị chế độ phong kiến làm gián đoạn. Nhưng người dân chỉ có thể được lập di chúc bằng miệng cho đến khi có Điều lệ về gian lận. Kể từ khi có quy chế này, cá nhân chỉ được lập di chúc miệng trong lúc hấp hối. Di chúc miệng đã bị bãi bỏ ở Anh theo Đạo luật năm 1837, trừ trường hợp đối với những người lính đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và những thủy thủ đang ở trên biển.”*³²⁸ Như vậy có thể thấy hiện nay ở Anh chỉ áp dụng di chúc miệng cho những người lính đang thực hiện nhiệm vụ và những thủy thủ đang trên tàu. Đây là nhóm đối tượng được giới hạn do đặc thù nghề nghiệp và những rủi ro

³²⁷ Bản án số 407/2020/DSPT ngày 21/10/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (Phụ lục V).

³²⁸ Daniel H. Redfearn (1957), *Practical Treatise on the Law of Wills and administrations of estate in Florida*, Nxb. Harrison Co; chỉnh sửa lần thứ 3, Chương 1.

về sự sống, cái chết có thể ảnh hưởng đến họ rất bất ngờ. Có thể thấy di chúc miệng ở Anh được áp dụng rất hạn chế.

Trong pháp luật dân sự Hà Lan, quy định về di chúc miệng tồn tại trong những trường hợp khẩn cấp như sau: “(a) di chúc khẩn cấp trong quân đội; (b) di chúc được thực hiện trên máy bay hoặc tàu vượt biển (gọi là di chúc Titanic); và (c) di chúc trong trường hợp thảm họa”³²⁹. Đối với pháp luật của Hà Lan không giới hạn điều kiện của chủ thể được lập di chúc miệng nhưng nêu rõ điều kiện về hoàn cảnh để có thể lập di chúc miệng. Những trường hợp có thể lập di chúc miệng là đang rơi vào những hoàn cảnh khẩn cấp, tính mạng có thể bị đe dọa: đang trong thảm họa; đang trên máy bay, tàu biển có sự cố; người lính trong quân đội đang thực hiện nhiệm vụ có sự cố khẩn cấp xảy ra.

“Ở Mỹ có 17 khu vực pháp lý quy định về hình thức di chúc miệng. Di chúc miệng được xem là một hình thức cuối cùng khi một cá nhân không thể lập di chúc bằng văn bản và cũng hiếm khi được sử dụng”³³⁰. Di chúc miệng tại các khu vực này chỉ được giới hạn cho các binh lính, thủy thủ, những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong các lực lượng vũ trang hoặc ít nhất là những người trong cơn đau sắp xảy ra cái chết hoặc bệnh tật ở giai đoạn cuối. Luật tiểu bang New York quy định “(1) Một thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ khi đang phục vụ trong quân đội hoặc hải quân trong một cuộc chiến được tuyên bố hoặc không công bố, hoặc xung đột vũ trang khác mà các thành viên của các lực lượng vũ trang đang tham gia; (2) một người phục vụ cùng hoặc đi cùng với một lực lượng vũ trang tham gia vào nghĩa vụ quân sự hoặc hải quân thực sự trong cuộc chiến tranh đó hoặc xung đột vũ trang khác; (3) một thủy thủ khi đi biển.”³³¹ Tiểu bang Bắc Carolina quy định “Di chúc miệng là một di chúc được thực hiện bằng miệng bởi một người đang trong thời kỳ ở giai đoạn cuối của bệnh tật hoặc sắp xảy ra nguy cơ tử vong và người đó không qua khỏi bệnh tật hoặc nguy cơ sắp xảy ra”³³². Luật của tiểu bang Montana khi đề cập đến điều kiện này có liệt kê rất rõ ràng “Người để lại di sản vào thời điểm đó đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trên thực địa hoặc làm nhiệm vụ trên tàu, và trong cả hai trường hợp trong sự suy giảm, sợ hãi hoặc nguy hiểm về cái chết thực sự; hoặc, người để lại di sản phải có, tại thời điểm đó, với hy vọng cái chết ngay lập tức do chấn thương nhận được cùng ngày”³³³. Với cách diễn dịch này có thể hiểu tính mạng bị đe dọa có thể liên quan đến sức khỏe hoặc liên quan đến hoàn cảnh làm cho người để lại

³²⁹ Điều 4:98 BLDS Hà Lan 1992 (tác giả tạm dịch).

³³⁰ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.373.

³³¹ New York Consolidated Laws (2010), Estates, Powers and Trusts Law, <https://law.justia.com/codes/new-york/2010/ept/article-3/part-2/3-2-2/>, [truy cập 21/12/2021].

³³² North Carolina General Statutes (2019), Chapter 31 – Wills, Article 1 - Execution of Will, Section 31-3.5 Nuncupative will, <https://law.justia.com/codes/north-carolina/2022/chapter-31/article-1/section-31-3-5/>, [truy cập 21/12/2021].

³³³ J. Howard Toelle, *tlđđ* (số chú thích 145), tr.20.

di sản cận kề cái chết. Quy định pháp luật của các tiểu bang vừa mang tính cụ thể, diễn dịch vừa mang tính khái quát về điều kiện hoàn cảnh của người muốn lập di chúc miệng. Tùy vào pháp luật của từng tiểu bang để căn cứ vào điều kiện của chủ thể được lập di chúc và/hoặc điều kiện của hoàn cảnh lập di chúc để trao quyền lập di chúc miệng cho những trường hợp luật định.

Đối với quy định của pháp luật một số nước châu Á thì điều kiện để được lập di chúc miệng sẽ căn cứ vào hoàn cảnh của người để lại di sản mà không giới hạn ở chủ thể được quyền lập di chúc miệng. Những trường hợp đều có liên quan trực tiếp và cấp bách đến sự sống của người để lại di sản. Quy định của pháp luật Nhật Bản đã liệt kê về những trường hợp đặc biệt trong quá trình lập di chúc. *“Trong trường hợp một con tàu gặp thảm họa, một người ở trên con tàu đó và trong tình trạng cận kề cái chết có thể lập di chúc bằng miệng...”*³³⁴. Hoặc trường hợp *“nếu một người đang trong tình trạng cận kề cái chết vì bệnh tật hoặc lý do khác dự định lập di chúc, người đó có thể lập di chúc miệng”*³³⁵. Pháp luật Trung Quốc thì quy định *“Người lập di chúc có thể lập di chúc miệng khi đối mặt với nguy hiểm sắp xảy ra.”*³³⁶ Các quy định của các nước Nhật Bản, Trung Quốc mang tính chất tương đồng với quy định của pháp luật Việt Nam.

Tóm lại, quy định về điều kiện để lập di chúc miệng trong BLDS 2015 của Việt Nam và các nước Nhật Bản, Trung Quốc mang tính khái quát bởi lẽ họ thừa nhận di chúc miệng được lập bởi tất cả mọi người khi ở vào những hoàn cảnh đặc biệt, trừ một số nhóm người đặc biệt mà luật có quy định khác. Còn quy định pháp luật về điều kiện để lập di chúc miệng ở các nước châu Âu, Mỹ theo hướng cụ thể, dựa vào những hoàn cảnh nhất định dành cho những nhóm đối tượng đặc biệt. Tuy nhiên dù là quy định mang tính khái quát hay cụ thể vào từng trường hợp, pháp luật các nước đều khẳng định di chúc miệng là hình thức di chúc mang tính chất dự phòng và chỉ được tạo lập khi người lập di chúc trong tình trạng cận kề cái chết và không thể lập được di chúc bằng văn bản.

4.2.2. Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các trường hợp được lập di chúc miệng

Quy định của pháp luật Việt Nam về những trường hợp được lập di chúc miệng mặc dù khá bao quát nhưng vẫn chưa hoàn thiện do vẫn đang hạn chế đi quyền được lập di chúc miệng của một số nhóm cá nhân đặc biệt, cụ thể là các trường hợp sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp người lập di chúc không thể nói được

³³⁴ Điều 979 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

³³⁵ Khoản 1 Điều 976 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

³³⁶ Điều 1138 BLDS Trung Quốc 2020 (được dịch từ Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên, *tlđđ* (số chú thích 171), tr.335).

Di chúc miệng có thể hiểu là ý chí của người để lại di sản được thể hiện bằng lời nói. Tuy nhiên nếu người để lại di sản không thể nói được thì họ không thể chuyển tải ý chí của mình đến những người khác.

Quy định của pháp luật dân sự Nhật Bản vẫn công nhận về trường hợp này và cho phép được lập di chúc miệng “1. Trong trường hợp một con tàu gặp thảm họa, một người ở trên con tàu đó và trong tình trạng cận kề cái chết có thể lập di chúc bằng miệng với sự tham dự của ít nhất hai người làm chứng. 2. Trong trường hợp một người không thể nói để lập di chúc theo quy định khoản 1, người lập di chúc sẽ làm như vậy thông qua một phiên dịch viên”³³⁷. Như vậy dù người để lại di sản không thể nói được vẫn có thể thông qua người phiên dịch viên để thể hiện ý chí của họ. Quy định này là phù hợp bởi lẽ chỉ cần có thể thể hiện ý chí để định đoạt tài sản của mình thì dù thông qua phương tiện nào hay phải thông qua một người trung gian cũng vẫn nên thừa nhận và cho phép họ được lập di chúc.

Bên cạnh đó, pháp luật của Đức cũng cho phép người không nói được có quyền lập di chúc miệng. “Ở Đức, theo quyết định của Tòa án Hiến pháp liên bang về quyền tự do lập di chúc và không phân biệt đối xử, luật đã được thay đổi cho phép các tuyên bố bằng ngôn ngữ cơ thể, chẳng hạn thông qua âm thanh và cử chỉ”³³⁸. Những cử chỉ, hành vi của con người được thể hiện ra bên ngoài để truyền tải ý chí có thể là căn cứ để xem xét ý chí của người để lại di sản.

Di chúc miệng được hiểu là di chúc được người lập di chúc thể hiện ý chí của họ bằng lời nói. Thông qua ngôn ngữ của mình, họ sẽ bộc lộ mong muốn định đoạt tài sản của họ và được người làm chứng ghi chép lại để lưu giữ mong muốn này. Tuy nhiên nếu chỉ hiểu di chúc miệng đúng theo diễn dịch của từng từ ngữ thì tác giả cho rằng sẽ không bao quát nhiều trường hợp phát sinh. Như vậy có thể dẫn đến việc một người cận kề cái chết, không thể lập di chúc bằng văn bản và cũng không thể nói được (như bị câm) nhưng vẫn có thể diễn đạt bằng hành vi (ngôn ngữ cử chỉ) những mong muốn của mình lại không thể lập di chúc để định đoạt tài sản. Thiết nghĩ khi giải thích quy định di chúc miệng nên hiểu theo nghĩa rộng, ngoài việc ghi nhận ý chí bằng lời nói, thông qua âm thanh còn có thể ghi nhận bằng hành vi, thông qua ngôn ngữ cử chỉ.

Pháp luật dân sự Việt Nam cần cân nhắc để ghi nhận thêm về trường hợp này. Một người không thể nói được khi nói đến vấn đề di chúc miệng dường như là hơi gượng gạo nhưng thực tế không bằng lời nói, họ vẫn có thể thể hiện ý chí của họ bằng các ngôn ngữ khác, như bằng hành vi. Tuy nhiên để người làm chứng và những người khác có thể hiểu được ý chí của người để lại di sản thì cần có điều kiện đặt ra là phải làm sao có một người trung gian có thể chuyển tải đúng nhất ý chí của người để lại di sản. Lúc này cần có người gọi là phiên dịch viên để thông dịch ngôn ngữ của người lập

³³⁷ Điều 979 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

³³⁸ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.462.

di chúc. Luật Nhật Bản có quy định chỉ cần một người là phiên dịch viên và người để lại di sản sẽ thể hiện ý chí của mình thông qua một phiên dịch viên³³⁹. Người phiên dịch viên sẽ là người giải thích những cử chỉ của người lập di chúc thành ngôn ngữ viết cho người làm chứng hoặc chính người phiên dịch viên khác ghi chép lại. Những người phiên dịch viên là những người dựa vào sự thể hiện của cử chỉ, hành vi thông qua đôi tay của người để lại di sản (người để lại di sản không nói được) để ghi nhận lại ý chí của họ. Người phiên dịch viên rất cần thiết bởi lẽ chỉ những người phiên dịch viên mới có thể hiểu được ý chí đích thực của người để lại di sản và chỉ họ mới có thể chuyển tải chính xác ý chí này vào trong văn bản giấy hoặc đến những người khác.

Ở Việt Nam, người phiên dịch đã được quy định trong hoạt động tố tụng dân sự và hình sự để bảo vệ quyền lợi cho đương sự, bị can, bị cáo, người có quyền và lợi ích liên quan. Trong hoạt động tố tụng dân sự người phiên dịch được hiểu là người biết chữ của người khuyết tật nhìn. Hoặc người phiên dịch là người biết nghe, nói bằng ngôn ngữ, ký hiệu của người khuyết tật nghe, nói³⁴⁰. Người này phải không thuộc những trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 82 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) 2015. Trong hoạt động tố tụng hình sự, người phiên dịch được hiểu là người biết được cử chỉ, hành vi của người câm, người điếc, biết chữ của người mù³⁴¹ và họ cũng không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 70 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2015. Có thể nói người phiên dịch có nhiệm vụ hỗ trợ cho những người không thể trình bày ý nghĩ mong muốn của mình bằng lời nói. Do vậy các quy định về quyền, nghĩa vụ cũng như điều kiện của người phiên dịch là để đảm bảo họ trung thực, khách quan trong việc chuyển tải thông tin.

Trên cơ sở quy định trong BLTTDS 2015 và BLTTHS 2015 có thể thấy người phiên dịch cần phải đảm bảo yếu tố trung thực, khách quan trong quá trình chuyển tải ý chí. Đối với hoạt động lập di chúc của người không nói được, người phiên dịch cũng cần phải đảm bảo yếu tố khách quan, trung thực để ghi nhận lại chính xác ý chí của người lập di chúc. Nhiệm vụ của người phiên dịch được xem là tương tự như đối với nhiệm vụ của người làm chứng di chúc. Do vậy, theo tác giả cho rằng có thể áp dụng những quy định của người làm chứng di chúc tại Điều 632 BLDS 2015 cho người phiên dịch.

Bên cạnh đó, trình tự lập di chúc miệng dành cho người không nói được cần phải chặt chẽ để đảm bảo người phiên dịch viên truyền tải chính xác ý chí của người lập di chúc. Bởi lẽ trong trường hợp này, người hiểu được mong muốn, nguyện vọng của người lập di chúc chỉ có duy nhất là người phiên dịch viên. Từ đó tác giả nhận thấy chỉ có một người phiên dịch viên để chuyển tải ngôn ngữ cử chỉ thành ngôn ngữ

³³⁹ Khoản 2 Điều 979 BLDS Nhật Bản 1896 (tác giả tạm dịch).

³⁴⁰ Khoản 2 Điều 81 BLTTDS 2015.

³⁴¹ Khoản 6 Điều 70 BLTTHS 2015.

viết là khó xác thực ý chí của người lập di chúc vì lúc này người lập di chúc trong tình trạng cận kề cái chết khó kiểm duyệt lại nội dung di chúc đã được ghi lại. Nếu chỉ có một người phiên dịch viên có thể hiểu được mong muốn của người để lại di sản thì không thể kiểm chứng được tính khách quan trong quá trình phiên dịch. Do đó, cần phải có ít nhất hai người có thể hiểu được ngôn ngữ cử chỉ của người không nói được để có sự kiểm tra, khách quan trong quá trình phiên dịch. Để thuận tiện cho quá trình lập di chúc khi cần phải có cả người phiên dịch và cả người làm chứng trong quá trình lập di chúc miệng. Tác giả cho rằng người làm chứng nên đồng thời là người phiên dịch để đảm bảo có thể hiểu được ngôn ngữ cử chỉ của người để lại di sản cũng vừa có thể tạo sự khách quan trong quá trình ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản.

Ngoài ra, nếu pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền lập di chúc miệng cho người không nói được thì nhóm người bị hạn chế về thể chất đang được liệt kê tại khoản 3 Điều 630 BLDS 2015 cần phải loại trừ những người này. Bởi lẽ người không nói được là người bị hạn chế về thể chất và hiện nay người bị hạn chế về thể chất chỉ có thể được lập di chúc bằng văn bản, có người làm chứng, có công chứng hoặc chứng thực.

Tóm lại, việc ghi nhận quyền lập di chúc miệng cho người không thể nói được là một quy định mang tính nhân văn, đảm bảo quyền bình đẳng trong việc định đoạt tài sản của cá nhân sau khi chết. Khi luật đã ghi nhận quyền lập di chúc miệng cho người không thể nói được thì quy định về điều kiện trình tự thủ tục lập di chúc cho nhóm đối tượng này cần phải được bổ sung để đảm bảo di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc. Do đó tại khoản 3 Điều 630 BLDS 2015 nên được quy định *“Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải..., trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này”* và khoản 5 Điều 630 BLDS nên được ghi nhận lại như sau *“Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Trường hợp người lập di chúc không thể nói được thì hai người làm chứng phải đồng thời là người phiên dịch để phiên dịch ý chí của người lập di chúc. Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.”*

Thứ hai, đối với di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

Theo quy định tại khoản 2 Điều 630 BLDS 2015 *“Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc”*. Quy định này khẳng định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có quyền được lập di chúc và di chúc bắt buộc phải lập thành văn bản. Ngoài ra, việc lập di chúc cần có sự đồng ý của người giám hộ hoặc cha, mẹ. Với quy định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải lập di chúc bằng văn bản theo tác giả cho rằng xuất phát từ quan

điểm của nhà lập pháp xác định độ tuổi từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi là độ tuổi vẫn chưa có đủ sự nhận thức chín chắn nhất định. Do đó việc lập di chúc bằng văn bản để đảm bảo những người để lại di sản đã có sự chuẩn bị và suy nghĩ thấu đáo. Do vậy để bảo vệ quyền lợi cho người lập di chúc, việc lập di chúc phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Tuy nhiên, quy định này cũng sẽ hạn chế đi quyền được lập di chúc bằng miệng của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi. Giả sử trong trường hợp người trong độ tuổi từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi ở vào hoàn cảnh cận kề cái chết, họ không thể lập di chúc bằng văn bản nhưng muốn bằng lời nói để định đoạt tài sản của mình. Lúc họ thể hiện ý chí có sự đồng ý về việc lập di chúc của cha mẹ hoặc người giám hộ và có sự hiện diện của những người làm chứng khác thì họ vẫn không thể lập di chúc miệng.

Quy định tại khoản 4 Điều 21 và khoản 2 Điều 625 BLDS 2015 ghi nhận cho cá nhân từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được quyền lập di chúc khi đã có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật tức là ghi nhận quyền tự do định đoạt tài sản của họ sau khi họ chết. Khi đã ghi nhận cho người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được quyền lập di chúc dựa trên sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của họ thì không có lý do gì phải hạn chế đi quyền lựa chọn hình thức di chúc mà họ muốn lập. Độ tuổi có thể là thước đo của sự chín chắn nhưng không phải chưa đủ tuổi thành niên là người không chín chắn. Mặt khác, ý muốn định đoạt tài sản dù thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói cũng chưa chắc là sự thể hiện mong muốn nhất thời, chưa được suy nghĩ thấu đáo của người lập di chúc. Một người mong muốn để lại tài sản cho ai, cho bao nhiêu có thể đã được suy nghĩ cân trọng nhưng họ vẫn chưa lập di chúc. Khi họ ở vào hoàn cảnh chỉ có thể lập di chúc miệng thì bằng lời nói, ý chí của họ sẽ được ghi nhận. Nếu vậy, loại trừ người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không được lập di chúc miệng là không hợp lý.

Do vậy với những phân tích trên, theo quan điểm tác giả quy định tại khoản 2 Điều 630 BLDS 2015 nên được ghi nhận theo hướng như sau *“Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc”*. Hướng quy định này sẽ không yêu cầu người lập di chúc từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi chỉ có thể lập di chúc bằng văn bản. Quy định này ghi nhận quyền tự do ý chí của những người lập di chúc trong nhóm độ tuổi đặc biệt được lựa chọn hình thức di chúc sao cho phù hợp với hoàn cảnh của họ cũng như đảm bảo quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong quyền tự định đoạt tài sản của cá nhân sau khi chết.

4.3. Trình tự, thủ tục lập di chúc miệng

4.3.1. Giai đoạn ghi chép lại di chúc miệng

(i) Quy định và thực tiễn áp dụng pháp luật về giai đoạn ghi chép lại di chúc miệng

Ghi chép lại là một thủ tục quan trọng để lưu giữ ý chí của người lập di chúc. Nhiệm vụ ghi chép lại di chúc miệng được đặt ra cho người làm chứng để đảm bảo ý chí của người lập di chúc đã được ghi nhận và lưu giữ chính xác. Đối với thủ tục ghi chép lại di chúc miệng cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, về thời điểm ghi chép lại di chúc miệng

Nếu hiểu di chúc miệng theo cách diễn dịch từ ngữ có thể xác định di chúc miệng là di chúc được người để lại di sản thể hiện ý chí bằng lời nói và nội dung di chúc là căn cứ vào trí nhớ của người làm chứng. Tuy nhiên *“nếu ý chí chỉ được thể hiện bằng lời nói sẽ luôn luôn bị rơi vào tình trạng mỏng manh về tính xác thực, vì lời nói gió bay và nhất là người nói ra điều đó đã chết nên dễ bị người khác bóp méo”*³⁴². Mặt khác nếu không được ghi chép lại thì qua thời gian có thể nội dung trong di chúc sẽ được người làm chứng chuyển tải lại bị sai lệch do quên, do nhớ nhầm, do cố ý... Do vậy khoản 5 Điều 630 BLDS 2015 có quy định bắt buộc người làm chứng phải ghi chép lại nội dung di chúc miệng vào văn bản. Thời điểm ghi chép lại ý chí cuối cùng của người để lại di là *“ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng...”*³⁴³. Quy định ngay sau khi có thể hiểu là tại thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí thì người làm chứng phải ghi chép lại. Khi quy định thời điểm này có thể hiểu thời điểm ghi chép lại phải là ngay tức khắc, không được để thời gian sau. Nếu người làm chứng không ghi chép lại ngay mà để một khoảng thời gian mới ghi chép lại có thể ảnh hưởng đến sự sai khác trong ý chí của người để lại di sản và sự ghi chép lại của người làm chứng. Nếu xem xét về khía cạnh trên thì quy định này là phù hợp, bởi lẽ lời nói gió bay, để qua một thời gian sự ghi nhớ đôi khi sẽ bị sai lệch. Tuy nhiên đó chỉ là cách hiểu giải thích theo từng từ ngữ được quy định trong luật. Hiện nay không có văn bản nào giải thích rõ hơn về thời điểm ghi chép lại di chúc miệng.

Thứ hai, đối với hình thức bản ghi chép

Theo pháp luật Việt Nam, khi xem xét đến hình thức bản ghi chép có hai vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất, bản ghi chép sẽ là bản chính hay bản thảo. Vấn đề thứ hai, việc ghi chép lại sẽ thể hiện bằng văn bản cụ thể và liệu rằng có nên xem xét đến việc thể hiện bằng những phương tiện khác, ví dụ như bản ghi âm, ghi hình.

Đối với vấn đề thứ nhất, hiện nay quy định trong BLDS 2015 không đề cập đến việc ghi chép lại thì đây phải là bản chính hay có thể là bản thảo hay không. Tuy nhiên do luật có quy định là phải mang văn bản đó đi công chứng hoặc chứng thực chữ ký

³⁴² Phạm Văn Tuyết, *tlđđ* (số chú thích 156), tr.166.

³⁴³ Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong vòng 5 ngày³⁴⁴ nên đây không thể là bản thảo mà phải là bản chính được ghi chép lại hoàn chỉnh. Tuy nhiên trong vòng 5 ngày làm việc chưa mang đi công chứng hoặc chứng thực thì bản thảo (nếu có) có được chấp nhận không thì thực tiễn xét xử đã có trường hợp này và Tòa án đã công nhận di chúc.

Thực tiễn cho thấy trong một bản án tại “Bút lục 221 Bà Lang khai “...lúc này, tình trạng sức khỏe của ông Nam đang mệt; khi viết xong tôi có đọc cho ông Nam nghe. Tờ giấy này tôi bỏ vì viết thảo, sang ngày hôm sau tôi mới viết lại rồi đưa cho cô Linh. Tôi xác nhận chữ ký và chữ viết trong di chúc miệng ngày 6/2/2002 là của tôi. Tại phiên tòa sơ thẩm (bút lục 350) bà Lang trình bày “do tình trạng ngặt nghèo của ông Nam nên tôi viết nháp sơ sài nên tôi viết lại. Quan điểm của Tòa sơ thẩm cho rằng không chấp nhận bản thảo. Tuy nhiên quan điểm của Tòa phúc thẩm cho rằng: Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Linh cùng các nhân chứng đã xuất trình bản thảo do bà Lang viết nhưng cấp sơ thẩm nhận định rất đơn giản là chưa đủ căn cứ để xác định là bản chính, không đưa ra lập luận chặt chẽ để bác bỏ chứng cứ này...”³⁴⁵. Tòa phúc thẩm xác định bản thảo có thể được xem là một chứng cứ có giá trị để có thể xác định hiệu lực của di chúc miệng. Theo tác giả, dù là bản thảo hay bản chính nhưng nếu văn bản đó thể hiện ý chí của người lập di chúc miệng thì nên công nhận văn bản này. Quy định như vậy sẽ mang tính linh hoạt, cởi mở hơn, vẫn thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản và phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, việc ghi chép lại phải thể hiện bằng văn bản cụ thể, bởi lẽ theo quy định trong BLDS 2015 thì bản ghi chép lại sẽ được mang đi công chứng hoặc chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Thực tiễn xét xử phù hợp với quy định của pháp luật. Tại một vụ việc trong quá trình giải quyết của Tòa án tại cấp sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, anh K không xuất trình được văn bản ghi chép lại nội dung di chúc miệng của bà E. Trong đơn kháng cáo có nêu nội dung bà E di chúc miệng về việc giao đất cho anh sử dụng được bà nêu ra trước khi chết, tại phiên tòa phúc thẩm anh K nêu bà E để lại di chúc miệng từ năm 1986 và trước khi chết khoảng một năm bà có nói lại với mọi người. Trên thực tế đến năm 2005 bà E mới chết nên trong trường hợp bà E có di chúc miệng, thì di chúc cũng bị coi là không hợp pháp vì nội dung di chúc không được thể hiện bằng văn bản ghi chép lại của người làm chứng và di chúc để lại quá thời hạn quy định của pháp luật cho phép.³⁴⁶ Vụ việc này nếu không đề cập đến thời gian bà E thể hiện ý chí với thời điểm bà E chết là đã

³⁴⁴ Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

³⁴⁵ Bản án số 14/2006/DSPT ngày 15/2/2006 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.580-582.

³⁴⁶ Bản án số 09/2017/DSPT ngày 28/7/2017 về tranh chấp chia thừa kế của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-tranh-chap-chia-thua-ke-so-092017dspt-1861>, [truy cập 21/7/2019].

quá ba tháng mà bà E vẫn còn minh mẫn sáng suốt thì đối với hình thức di chúc miệng đã vi phạm quy định về vấn đề ghi chép lại ý chí của người để lại di sản thừa kế. Bà E có thể hiện ý chí trước mặt nhiều người và nhiều lần nhưng ý chí này không được ghi chép lại thành văn bản. Do đó Tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm đã không công nhận di chúc miệng này.

Đối với vấn đề thứ hai, nếu bản ghi chép lại không thể hiện bằng văn bản giấy mà thể hiện bằng bản ghi âm, ghi hình thì luật không ghi nhận. *“Trong trường hợp người lập di chúc thể hiện bằng miệng và lưu lại bằng bản ghi âm, ghi hình thì hiện nay BLDS 2015 chưa thừa nhận. Nhiều quan điểm cho rằng những bản ghi âm, ghi hình rất khó xác định và rất dễ bị giả mạo”*³⁴⁷. Như vậy, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận việc ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản bằng các bản ghi âm, ghi hình. Trong một vụ việc xét xử ở thực tiễn Tòa án cũng xác định việc ghi chép lại phải bằng văn bản và có công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Trong một vụ việc: Ông T trình bày trước khi qua đời, mẹ ông là cụ Yên đã lập di chúc định đoạt toàn bộ tài sản của bà cho cháu đích tôn T1 (con trai ông), di chúc này hiện bà N đang cất giữ. Ông T đã cung cấp cho Tòa án 01 chiếc USB có chứa đoạn video mà mẹ ông đã di chúc lại cho cháu Tú. Tòa án đã nhận định: chiếc USB có chứa đoạn video ghi lại cảnh mẹ ông đã di chúc lại cho cháu Tú không được công nhận là di chúc hợp pháp. Căn cứ vào các quy định trong BLDS thì di chúc của cụ Yên được thể hiện dưới dạng đoạn video chưa đáp ứng điều kiện của di chúc hợp pháp vì vậy di sản sẽ được chia thừa kế theo quy định pháp luật.³⁴⁸ Ở bản án này Tòa án căn cứ vào việc di chúc được ghi lại bằng một đoạn video được lưu trong một USB và Tòa án nhận định rằng *“có thể thấy, di chúc miệng cũng được xem là một hình thức của di chúc nhưng điều kiện để công nhận di chúc miệng hợp pháp khắt khe hơn rất nhiều so với di chúc bằng văn bản. Do vậy, chiếc USB có chứa đoạn video ghi lại cảnh mẹ ông đã di chúc lại cho cháu Tú không được công nhận là di chúc hợp pháp. Căn cứ vào các quy định trên thì di chúc của cụ Yên được thể hiện dưới dạng đoạn video chưa đáp ứng điều kiện của di chúc hợp pháp vì vậy di sản sẽ được chia thừa kế theo quy định pháp luật.”* Tòa án không công nhận hình thức của bản ghi chép lại được thể hiện bằng một đoạn video do không thỏa mãn những điều kiện về ghi chép lại, công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

(ii) Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ghi chép lại di chúc miệng

Thứ nhất, về thời điểm ghi chép lại di chúc miệng

Như đã phân tích ở trên, thời điểm người làm chứng ghi chép lại ý chí của người để lại di sản là *ngay sau khi* người để lại di sản thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại. Khi quy định thời điểm này có thể hiểu thời điểm ghi chép lại

³⁴⁷ Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *tlđđ* (số chú thích 37), tr.488.

³⁴⁸ Bản án số 78/2023/DSPT ngày 14/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (Phụ lục VI).

phải là ngay tức khắc, không được để thời gian sau. Nếu người làm chứng không ghi chép lại ngay mà để một khoảng thời gian mới ghi chép lại có thể ảnh hưởng đến sự sai khác trong ý chí của người để lại di sản và sự ghi chép lại của người làm chứng. Nếu xem xét về khía cạnh trên thì quy định này là phù hợp, bởi lẽ lời nói gió bay, để qua một thời gian sự ghi nhớ đôi khi sẽ bị sai lệch. Tuy nhiên, trên thực tế nếu cách hiểu *ngay sau khi* sát với ngôn từ của điều luật sẽ gây khó khăn rất nhiều để thừa nhận di chúc miệng có hiệu lực pháp luật. Nhiều những trường hợp ngay tại thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí, người làm chứng không có điều kiện để ghi chép lại mà sau đó họ mới có thể ghi chép lại. Nếu để sau đó mới ghi chép lại thì không đúng với quy định về thời điểm ghi chép lại di chúc miệng.

Xét đến thực tiễn xét xử, nếu cách hiểu *ngay sau khi* sát với ngôn từ của điều luật sẽ gây khó khăn rất nhiều để thừa nhận di chúc miệng có hiệu lực pháp luật. Nhiều trường hợp ngay tại thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí, người làm chứng ghi chép lại ngay lời nói này vào văn bản. Nhưng cũng có trường hợp, người làm chứng sau khi nghe xong hết mới ghi chép ý chí của người để lại di sản vào văn bản. Hoặc có trường hợp sau đó một khoảng thời gian, người làm chứng mới ghi chép lại. Việc ghi chép lại cũng phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện, hoàn cảnh ngay tại thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí của họ. Có những trường hợp không có phương tiện ngay lập tức để ghi chép lại thì cũng khó cho người làm chứng nếu đòi hỏi phải ghi ngay lại vào văn bản. Thực tiễn xét xử của Tòa án đã có trường hợp Tòa án cân nhắc về thời điểm phải ghi chép lại di chúc miệng. Trong một vụ việc được giải quyết, Tòa án đã đưa ra quan điểm cho rằng “*Cấp sơ thẩm lập luận bản chính viết thảo đã bỏ, ngày hôm sau 2 nhân chứng viết lại cho bà Linh, bà Tỵ cho nên tờ di chúc miệng là không đúng quy định pháp luật, là phải xem xét lại bởi lẽ cụm từ **ngay sau đó** là bao lâu thì không có văn bản hướng dẫn cụ thể. Luật không có quy định cụ thể thì không có cơ sở nào bác bỏ di chúc miệng đã được bà Lang, bà Hương ghi chép lại cùng ký tên và ngay hôm sau đã đưa lại cho các con ông Nam*”³⁴⁹. Như vậy cấp phúc thẩm đã xác định ngày hôm sau, sau thời điểm người để lại di sản chết, người làm chứng mới ghi chép lại nội dung trong bản di chúc là vẫn hợp pháp. Hướng giải quyết của thực tiễn trong trường hợp này là phù hợp. Bởi lẽ ngày hôm sau ghi chép lại nhưng vẫn thể hiện đúng ý chí của người để lại di sản thì nên công nhận bản di chúc này.

Trong một vụ việc khác thì Tòa án xác định “*ngày 03/02/2016 ông Hào có di chúc miệng với các bà Liên, Nguyệt, Thuận. Ngày 04/02/2016 ông Hào chết. Ngày 05/02/2016 bà Liên, bà Thuận đã ghi lại di chúc miệng của ông Hào và đã ký tên, điểm chỉ trong giấy xác nhận di chúc miệng tại Văn phòng Luật sư Trường Giang. Sau đó, cán bộ công chứng đã đưa hai văn bản trên về trụ sở Văn phòng Công chứng Bảo*

³⁴⁹ Bản án số 14/2006/DSPT ngày 15/2/2006 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong Đỗ Văn Đại, *tlđd* (số chú thích 73), tr.580-582.

Việt để lập lời chứng đóng dấu và trả văn bản công chứng cho công dân.”³⁵⁰ Mặc dù tình huống này phải cách 2 ngày kể từ thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí, người làm chứng mới ghi chép lại di chúc miệng nhưng Tòa án vẫn công nhận di chúc miệng thỏa mãn điều kiện về thời gian ghi chép lại.

Ngoài ra, có những trường hợp người làm chứng đã rất cẩn thận, họ sử dụng thiết bị điện tử để ghi âm, ghi hình mong muốn định đoạt tài sản của người để lại di sản để sau này có thể ghi chép lại. Việc làm này cũng tránh đi sự sai lệch về nội dung của bản di chúc miệng nếu chỉ dựa vào sự ghi nhớ của người làm chứng.

Theo pháp luật nước ngoài, ở Mỹ luật của tiểu bang Wiscosin quy định *“Di chúc miệng sẽ không được thừa nhận trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm người để lại di sản chết, cũng như sẽ không được thừa nhận sau 6 tháng kể từ thời điểm được thể hiện bằng lời trừ khi được viết ra trong vòng 6 ngày sau khi được thể hiện ra ngoài bằng miệng”*³⁵¹. Quy định này không bắt buộc người làm chứng phải viết lại ý chí của người để lại di sản ngay mà chỉ cần viết trong vòng 6 ngày kể từ thời điểm người lập di chúc miệng thể hiện ý chí. Khoảng thời gian 6 ngày cũng là một khoảng thời gian khá dài nhưng xét theo khả năng ghi nhớ của con người thì vẫn có thể lưu giữ cơ bản và nếu có những phương tiện kỹ thuật hỗ trợ thì việc ghi chép lại không hề sai khác so với ý chí được thể hiện ban đầu. Theo luật tiểu bang Montana, Mỹ có quy định *“các lời nói phải được lập thành văn bản trong vòng ba mươi ngày sau khi chúng được nói và sẽ không được công nhận trừ khi được cung cấp trong vòng sáu tháng kể từ khi thể hiện ý chí để đảm bảo rằng đây là bằng chứng cho sự bệnh tật của người để lại di sản”*.³⁵² Quy định này cho khoảng thời gian ghi chép lại lâu hơn là lập thành văn bản trong vòng 30 ngày sau khi được người để lại di sản nói ra. Tất cả các khoảng thời gian này theo tác giả cho rằng đã được cân nhắc đảm bảo rằng người làm chứng vẫn còn có thể nhớ chi tiết, chính xác để chuyển tải vào văn bản. Pháp luật của Chilê theo hướng *“di chúc miệng chỉ phải viết lại dưới dạng văn bản trong thời hạn 30 ngày sau khi người lập di chúc chết.”* Ở Chilê có nhiều quan điểm thống nhất rằng việc ghi chép lại di chúc miệng không nhất thiết phải là ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, có thể cho người làm chứng một *“khoảng thời gian hợp lý”*³⁵³.

Vì vậy theo tác giả, việc ghi chép lại di chúc miệng không nhất thiết phải là ngay sau khi người thể hiện di chúc miệng thể hiện ý chí. Quy định này mang tính hình thức vì không phải trường hợp nào người làm chứng cũng viết lại ngay hoặc có điều kiện để có thể viết lại ngay. Mặt khác cũng không phải trong mọi trường hợp đều

³⁵⁰ Bản án số 407/2020/DSPT ngày 21/10/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (Phụ lục V).

³⁵¹ Thomas A. Byrne (1926), “Outline of the Law of Wills”, 10 Marq. Law Review. 220, tr.220.

³⁵² J. Howard Toelle, *tlđđ* (số chú thích 145), tr.20.

³⁵³ Paul Vasilescu, Rapport général – Successions et familles, in Successions, tr.46 trong Đỗ Văn Đại, *tlđđ* (số chú thích 73), tr.602.

có thể kiểm tra được việc liệu người làm chứng có viết lại ngay hay không, hay phải sau đó một khoảng thời gian người làm chứng mới viết lại vào bản giấy.

Ngoài ra, điều kiện về trình tự để lập di chúc miệng không đặt ra yêu cầu về việc đọc lại nội dung di chúc miệng cho người lập di chúc nghe và không yêu cầu người lập di chúc ký tên hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Mong muốn định đoạt tài sản của người để lại di sản được ghi chép lại ngay sau khi họ thể hiện ý chí chỉ nhằm mục đích chuyển tải ý chí của họ một cách chính xác và nội dung di chúc được lưu giữ lâu dài. Do vậy, không cần ngay sau khi người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng di chúc phải được ghi chép lại mà có thể trong một khoảng thời gian ngắn ý chí được ghi chép lại thì vẫn đảm bảo được hai mục đích trên.

Với những dẫn chứng và phân tích ở trên, tác giả đề xuất thời điểm ghi chép lại theo hướng có thể cho người làm chứng một khoảng thời gian hợp lý để họ ghi chép lại, không nhất thiết phải là ngay sau khi người để lại di sản thể hiện ý chí. Ngoài ra, nếu có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại để lưu trữ lại lời nói của người để lại di sản (như các bản ghi âm, ghi hình) thì khoảng thời gian có kéo dài cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến tính chính xác của việc ghi nhận lại ý chí người để lại di sản. Khoảng thời gian hợp lý đó có thể là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày người để lại di sản thể hiện ý chí của mình. Đây là khoảng thời gian người làm chứng có thể thu xếp các điều kiện và khả năng lưu giữ thông tin của trí nhớ cũng vẫn còn tốt để có thể tiến hành ghi chép lại ý chí của người di chúc miệng. Khoảng thời gian 5 ngày làm việc cũng là khoảng thời gian phù hợp để lúc đó khi người làm chứng đã ghi chép lại, họ có thể mang di chúc đi công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của họ.

Tác giả kiến nghị khoản 5 Điều 630 BLDS 2015 được sửa đổi, bổ sung như sau *“Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Trường hợp người lập di chúc không thể nói được thì hai người làm chứng phải đồng thời là người phiên dịch để phiên dịch ý chí của người lập di chúc. **Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ** và di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”*

Thứ hai, về hình thức của bản ghi chép lại

BLDS 2015 đã quy định di chúc miệng là việc người để lại di sản thể hiện ý chí của họ thông qua lời nói nhưng lời nói này phải được người làm chứng ghi nhận lại vào văn bản.³⁵⁴ Hiện nay luật Việt Nam chưa ghi nhận việc lưu giữ lại ý chí thông qua bản ghi âm và hình. Những bản ghi âm và hình có thể được xem xét là chứng cứ để

³⁵⁴ Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

chứng minh sự tồn tại ý chí của người để lại di sản³⁵⁵ nhưng không phải là hình thức của di chúc hoặc là một điều kiện của hình thức di chúc mà luật ghi nhận.

Thực tiễn xét xử cũng đã có trường hợp tồn tại bản video nhưng Tòa án không ghi nhận đó là di chúc miệng³⁵⁶. Tuy nhiên trong thực tiễn xét xử, ở một vụ việc khác thì Tòa án lại có thừa nhận bản ghi âm để ghi nhận di chúc miệng. Vụ việc như sau: cụ Đ mất năm 1997 để lại di chúc hợp pháp bằng miệng cho ông H do cụ Đ bị ốm vì bệnh ung thư nên rất minh mẫn đến khi chết. Trước khi chết vài ngày cụ có dặn dò lại các con là cho ông H toàn bộ nhà đất. Hôm dặn dò có cả bà T, bà H, ông H cùng ba nhân chứng là bà C (hàng xóm), ông L, ông Th (là cháu gọi cụ Đ bằng cậu). Ngoài ra, còn có nhân chứng cho biết khi còn sống cụ Đ cũng nói nếu Nhà nước lấy đất và đền bù bằng tiền thì cụ cho con trai (ông H) để xây nhà thờ cúng tổ tiên (nhân chứng là ông Kh, bút lục 46). Những lời trần trối của cụ Đ được những người làm chứng ghi âm lại. Tại kết quả giám định của Bộ Công an đã kết luận đó là cuộn băng gốc và chính bà H, bà T cũng xác nhận giọng nói trong băng là của cụ Đ và của bà T (bút lục 43). Song do trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên sau khi cụ Đ mất các nhân chứng đã không ghi chép lại lời dặn đó thành văn bản. Trong băng ghi âm cũng thể hiện rõ khi cụ Đ thể hiện ý chí không cho hai con gái tài sản thì bà T khuyên cụ Đ: *“Chúng con không đòi hỏi gì đâu ông ạ, trước sau thì để cho thằng H vì nó không có nhà. Không phải như người khác mà tranh nhau đâu, ông yên tâm”*. Từ nhận định trên Hội đồng xét xử đã chấp nhận di chúc miệng của cụ Đ là có hiệu lực pháp luật và quyết định chia di sản của cụ Đ theo di chúc mà cụ để lại.³⁵⁷

Ở vụ việc này di chúc miệng được lập đã không được những người làm chứng ghi chép lại sau đó mang bản ghi chép để công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Mà lời của người lập di chúc chỉ được ghi âm lại thì đây là một căn cứ để Tòa án xác định là chứng cứ để thừa nhận di chúc miệng. Hướng giải quyết của Tòa án trong trường hợp này mang tính linh hoạt và theo tác giả là phù hợp khi có bằng chứng chứng minh đã tồn tại ý chí của người để lại di sản và ý chí đó được ghi nhận một cách chính xác, mặc dù luật không thừa nhận bản ghi âm, ghi hình.

BLDS 2015 đã quy định di chúc miệng là việc người để lại di sản thể hiện ý chí của họ thông qua lời nói nhưng lời nói này phải được người làm chứng ghi nhận lại vào văn bản³⁵⁸. Hiện nay luật Việt Nam chưa ghi nhận việc lưu giữ lại ý chí thông qua bản ghi âm và hình. Những bản ghi âm và hình có thể được xem xét là chứng cứ để chứng minh sự tồn tại ý chí của người để lại di sản³⁵⁹ nhưng không phải là hình thức

³⁵⁵ Điều 94 BLTTDS 2015.

³⁵⁶ Bản án số 78/2023/DSST ngày 14/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định (Phụ lục VI).

³⁵⁷ Bản án dân sự sơ thẩm số 22/DSST ngày 12/11/2001 của Tòa án nhân dân huyện T trong Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang, *tlđd* (số chú thích 45), tr.390-394.

³⁵⁸ Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

³⁵⁹ Điều 94 BLTTDS 2015.

của di chúc hoặc là một điều kiện của hình thức di chúc mà luật ghi nhận. Theo quan điểm của tác giả cần ghi nhận bản ghi âm và hình là một điều kiện bổ sung bên cạnh việc ghi chép lại di chúc miệng vào văn bản. Bản ghi âm và hình là bằng chứng rất rõ ràng cho nội dung của di chúc. Thay cho những bản ghi chép lại của người làm chứng được thể hiện bằng bản giấy thì bản ghi âm và hình cũng chứa đựng nội dung di chúc và được thể hiện, lưu trữ bằng những bản file. Định dạng chứa đựng và lưu trữ khác nhau (bản giấy, bản file) nhưng không làm thay đổi mục đích của việc lưu trữ lại nội dung di chúc. Mặt khác, về mặt chứng cứ thì giá trị pháp lý của hai bản giấy và bản file được xem là như nhau. Do vậy không nên chỉ ghi nhận bản ghi chép lại bằng bản giấy mà không thừa nhận bản ghi âm và hình.

Tuy nhiên nếu luật ghi nhận bản ghi âm và hình thì cần xem xét đến các điều kiện cho bản ghi âm và hình để tránh những bản này có thể bị làm giả. Đặc biệt hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, con người có thể làm giả giọng nói của một người và cắt ghép vào hình ảnh của họ bằng trí tuệ nhân tạo. Do vậy, khi ghi nhận bản ghi âm và hình thì những bản ghi âm và hình này phải chứa đựng đầy đủ mong muốn của người lập di chúc được thể hiện thông qua hình ảnh và âm thanh của người lập di chúc. Đồng thời với đó là việc người lập di chúc và người làm chứng phải ghi lại danh tính bằng lời nói và hình ảnh của mình cùng ngày, tháng, năm trong bản ghi âm và hình. Bản ghi âm và hình sẽ được giám định để xác định tính xác thực trước khi công nhận di chúc miệng.

Bên cạnh đó thay cho thủ tục công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng cho bản ghi chép của di chúc miệng, do đây là bản ghi âm và hình cần quy định bản ghi âm và hình này được lập dưới sự chứng kiến của công chứng viên. Trong trường hợp này, có thể yêu cầu công chứng viên đến tận nơi của người để lại di sản lập di chúc để xác nhận bản ghi âm và hình. Với sự chứng kiến quá trình tạo lập và xác nhận bản ghi âm và hình của công chứng viên sẽ tạo sự khách quan và đảm bảo di chúc ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

Do đây là một phương thức ghi nhận ý chí của người lập di chúc mới (bằng bản ghi âm và hình) so với phương thức ghi nhận truyền thống bằng văn bản của hình thức di chúc miệng nên việc công nhận hình thức mới của bản ghi chép lại nên bắt đầu từ thực tiễn xét xử của Tòa án và từ đó có thể xem xét, đánh giá để có án lệ phù hợp. Đây là một hướng đi phù hợp với sự phát triển của xã hội và cũng tạo điều kiện lợi cho việc lập di chúc miệng. Người để lại di sản, người làm chứng sẽ có thêm một lựa chọn trong quá trình ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản. Bên cạnh bản ghi chép lại trong vòng 5 ngày làm việc được người làm chứng mang đi công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của họ thì ý chí có thể được ghi nhận bằng bản ghi âm và hình có thêm sự chứng kiến và xác nhận của công chứng viên.

Trên cơ sở những phân tích trên, tác giả có kiến nghị đối với hình thức của bản ghi chép lại di chúc miệng có thể là bản ghi âm và hình nội dung của di chúc do người để lại di sản thể hiện. Đồng thời với đó là lời chứng khẳng định của người để lại di sản, lời chứng khẳng định của hai người làm chứng xác nhận di chúc chính xác là của người để lại di sản. Bản ghi âm và hình phải chứa đựng đầy đủ các thông tin của người để lại di sản; người làm chứng; ngày, tháng, năm lập di chúc do chính những người này thể hiện. Quá trình tạo lập bản ghi âm và hình sẽ được công chứng viên chứng kiến và xác nhận bản ghi âm và hình. Hình thức của bản ghi âm và hình của di chúc miệng nên được ghi nhận từ hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật bằng án lệ.

4.3.2. Giai đoạn công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng

(i) Quy định pháp luật về giai đoạn công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng

Đối với di chúc miệng, dù ghi nhận bằng lời nói nhưng cuối cùng để đảm bảo di chúc thể hiện đúng với ý chí của người để lại di sản và lưu giữ được qua một khoảng thời gian thì ý chí của người để lại di sản phải được ghi chép lại. Việc dùng lời nói chỉ là từ giai đoạn chuyển tải ý chí của người để lại di sản ra bên ngoài cho người làm chứng nắm được mong muốn của họ. Đến giai đoạn sau đó ý chí này phải được ghi nhận lại bằng văn bản. Để đảm bảo bản ghi chép lại được xác thực là chính xác thì bản ghi chép đó phải được công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

BLDS 2015 có quy định “*trong 5 ngày làm việc...di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng*”³⁶⁰. Thời gian 5 ngày làm việc là thời gian để người làm chứng có thể chuẩn bị cho bản di chúc, sắp xếp công việc để đi công chứng hoặc chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của họ. Đây là nhiệm vụ của người làm chứng sau khi họ đã làm chứng cho quá trình người để lại di sản thể hiện mong muốn định đoạt tài sản ra bên ngoài và được ghi chép lại. Việc công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp này là việc xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của những người làm chứng. Bởi lẽ công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực không chứng kiến giai đoạn người để lại di sản thể hiện nội dung bản di chúc nên không thể xác nhận nội dung của di chúc. Nếu yêu cầu công chứng hoặc chứng thực di chúc thì chỉ có thể yêu cầu xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của những người làm chứng. Quy định này được xem là phù hợp với công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc vì không thể yêu cầu công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực xác nhận vấn đề mà họ không chứng kiến.

³⁶⁰ Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015.

Trong quá trình lập di chúc khi người để lại di sản cận kề cái chết, thông qua lời nói họ thể hiện ý chí của mình cho hai người làm chứng khi chép lại vào văn bản. Sau đó, người làm chứng mới mang đi công chứng hoặc chứng thực. Như vậy, từ giai đoạn đầu để tạo lập di chúc đến khi có bản ghi chép lại ý chí của người để lại di sản chỉ có hai người làm chứng là tham gia vào quá trình ghi nhận lại nội dung di chúc. Công chứng viên cũng như người có thẩm quyền chứng thực di chúc chỉ biết đến di chúc khi di chúc được mang đi công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Chính vì trình tự như vậy, có quan điểm lo ngại rằng nếu công chứng viên chỉ có vai trò xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng thì vô tình đã trao quyền định đoạt di sản vào hai người làm chứng và như vậy sẽ có thể có rủi ro cho nội dung di chúc nếu hai người làm chứng có thỏa thuận với nhau.

Tuy nhiên theo quan điểm của tác giả, di chúc miệng được lập trong hoàn cảnh người lập di chúc đang cận kề cái chết, không thể lập di chúc bằng văn bản. Do vậy việc tìm kiếm được hai người làm chứng thỏa điều kiện làm chứng để lập di chúc có đôi khi đã khó nên cũng khó có thể yêu cầu phải có sự tham gia trực tiếp của công chứng viên hoặc cán bộ tư pháp để sau này xác nhận nội dung di chúc mà công chứng, chứng thực. Mặt khác, khi công chứng viên hoặc cán bộ tư pháp không chứng kiến việc lập di chúc thì không thể yêu cầu họ công chứng hoặc chứng thực nội dung di chúc và việc lập di chúc. Họ chỉ có thể xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Chính từ thực tiễn này, BLDS 2015 đã sửa đổi nội dung này so với quy định của BLDS 2005. Trong BLDS 2015 ghi nhận nội dung công chứng hoặc chứng thực là chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Trên thực tế, khi người để lại di sản thể hiện ý chí của mình ngoài người làm chứng ghi nhận ý kiến của người lập di chúc sẽ còn có những người khác trong gia đình vây quanh xung quanh để lắng nghe mong muốn của người sắp chết. Mặt khác, người làm chứng cũng có thể ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản thông qua bản ghi âm, ghi hình. Những người trực tiếp chứng kiến, bản ghi âm, ghi hình sẽ là những bằng chứng chứng minh cho việc chuyển tải ý chí của người để lại di sản bằng lời nói thành văn bản thông qua ghi chép lại của người làm chứng. Những bằng chứng này sẽ là cơ sở (nếu cần) để có thể xác thực nội dung di chúc bên cạnh bản di chúc được người làm chứng ghi chép lại.

Quy định pháp luật Việt Nam hiện nay về vấn đề này theo quan điểm của tác giả đã chặt chẽ vì không nên thêm quá nhiều điều kiện không khả thi dẫn đến di chúc không có khả năng thực hiện. Mặt khác, nếu cho rằng di chúc được lập không đúng ý chí của người lập di chúc thì trong quá trình xét xử Tòa án sẽ căn cứ vào những chứng cứ khác để xác định ý chí của người lập di chúc. Thực tế, luật quy định có hai người làm chứng nhưng khi người lập di chúc cận kề cái chết thì thông thường bên cạnh họ sẽ có người thân trong gia đình. Tòa án có thể dựa vào lời khai của những người thân

cũng là một chứng cứ để xác định nội dung di chúc. Hoặc Tòa án dựa vào hành vi lúc còn sống của người lập di chúc để xác định mong muốn đích thực của người lập di chúc.

Hiện nay bên cạnh việc công chứng hoặc chứng thực còn có hoạt động của một tổ chức là Văn phòng thừa phát lại để xác nhận sự kiện thực tế nào đó diễn ra bằng cách lập vi bằng. Trên thực tế có những gia đình khi người để lại di sản cận kề cái chết và để ghi nhận lại sự kiện lập di chúc gia đình đã yêu cầu thừa phát lại đến chứng kiến và xác nhận sự việc. Tuy nhiên vi bằng thừa phát lại lập khi chứng kiến người để lại di sản thể hiện ý chí của mình bằng lời nói trước khi chết không xem là một hình thức di chúc. Theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại (NĐ 08/2020/NĐ-CP) có ghi nhận vi bằng do thừa phát lại lập là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của NĐ này³⁶¹. Do vậy, khi người để lại di sản lập di chúc miệng bên cạnh hai người làm chứng có thể xuất hiện của thừa phát lại để ghi nhận lại sự kiện. Vi bằng là bằng chứng pháp lý chứng minh có sự kiện lập di chúc xảy ra, ai là người để lại di sản, ai là người làm chứng. Thừa phát lại được xem là bên thứ ba xác nhận sự việc. Vi bằng được thừa phát lại lập sẽ được đăng ký tại Sở Tư pháp. Việc đăng ký đảm bảo vi bằng có giá trị pháp lý và vi bằng được xem là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật³⁶². Theo quy định trong NĐ 08/2020/NĐ-CP về những trường hợp thừa phát lại không được lập vi bằng bao gồm “*xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực*”.³⁶³ Như vậy thừa phát lại là người chứng kiến việc người để lại di sản thể hiện ý chí bằng lời nói cho người làm chứng xác nhận nội dung và ghi chép lại nhưng thừa phát lại không có thẩm quyền xác nhận nội dung di chúc. Hay nói cách khác thừa phát lại chỉ xác nhận sự kiện xảy ra chứ không xác nhận được nội dung của di chúc đó. Điều đó dẫn đến vi bằng không thể xem là một hình thức di chúc. Bởi vai trò của hình thức di chúc là nơi chứa đựng nội dung di chúc, hình thức di chúc là phương tiện để xác thực nội dung di chúc. Vi bằng chỉ có thể là chứng cứ để chứng minh có sự kiện lập di chúc.

Trình tự thủ tục lập di chúc miệng phải theo đúng quy định trong BLDS 2015 mới thỏa mãn điều kiện về hình thức. Nhưng nếu có sự chứng kiến của thừa phát lại sẽ có thêm bằng chứng chứng minh sự kiện thực tế xảy ra để Tòa án xem xét nếu cần.

³⁶¹ Khoản 3 Điều 2 NĐ 08/2020/NĐ-CP.

³⁶² Khoản 3 Điều 36 NĐ 08/2020/NĐ-CP.

³⁶³ Khoản 4 Điều 37 NĐ 08/2020/NĐ-CP.

(ii) Bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng

Điều kiện công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng là để tăng thêm độ xác thực cho di chúc miệng. Tuy nhiên, có những di chúc miệng được lập trong tình huống người lập di chúc cận kề cái chết, không thể lập di chúc bằng văn bản và hoàn cảnh để người làm chứng có thể công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của họ là điều khó khăn. Nếu trong trường hợp không thể công chứng hoặc chứng thực được chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc theo quy định của luật thì nên thông qua một tổ chức khác để xác thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Theo quan điểm của tác giả, việc xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng không nhất thiết phải bắt buộc thông qua công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực. Tác giả phân tích dẫn chứng một số trường hợp sau.

Trong trường hợp một người sắp chết đang điều trị trong cơ sở y tế, nếu đã thông qua người làm chứng để ghi nhận lại nội dung di chúc và ghi chép nội dung di chúc vào văn bản thì theo quy định của BLDS 2015 người làm chứng cần mang di chúc đến tổ chức công chứng hoặc UBND để xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Trong trường hợp này thay vì phải đến tổ chức công chứng hoặc UBND nên cho phép người làm chứng được nhờ người đứng đầu cơ sở y tế xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của họ. Việc yêu cầu người đứng đầu cơ sở chữa bệnh, cơ sở y tế xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ thay vì phải đến tổ chức công chứng hoặc UBND trong nhiều trường hợp sẽ dễ dàng và ít tốn kém hơn.

Trường hợp khác nếu người lập di chúc đang ở nơi xa xôi hẻo lánh, ở biên giới, hải đảo do hạn chế về phương tiện đi lại nên việc công chứng, chứng thực sẽ rất khó khăn. Trong những trường hợp này nếu chỉ vì di chúc không được công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong thời hạn 5 ngày làm việc mà không thỏa mãn điều kiện về hình thức của di chúc miệng sẽ không hợp lý.

Nếu người lập di chúc đang trên tàu biển cần lập di chúc miệng và khoảng thời gian để công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng cũng không thể thực hiện được trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm người để lại di sản thể hiện ý chí của mình thì cần cho phép người chỉ huy tàu biển được phép xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Đây là chỉ là một vài trường hợp tác giả liệt kê để chỉ rõ những hoàn cảnh khó khăn có thể xảy ra dẫn đến việc công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng khó hoặc không thể thực hiện được nếu yêu cầu phải có công chứng việc hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc xác nhận trong khoảng thời gian luật quy định.

Khi nghiên cứu về hình thức di chúc bằng văn bản có di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại Điều 638 BLDS 2015 đã căn cứ vào hoàn cảnh của người lập di chúc để cho phép người để lại di sản được linh động lựa chọn hình thức này thay cho việc công chứng hoặc chứng thực di chúc. Việc xác thực di chúc không phải là công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực thì di chúc vẫn có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. Vậy đối với di chúc miệng, khi chỉ cần xác thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng mà hoàn cảnh khó có thể đi đến tổ chức công chứng hoặc UBND thì nên chăng cho phép những người làm chứng cũng có thể yêu cầu những người đứng đầu tương tự như quy định tại Điều 638 BLDS 2015 xác nhận.

Tác giả cho rằng, việc xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng nhằm mục đích xác định bản di chúc này chính xác do người làm chứng ghi lại và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Việc xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng là việc không quá khó khăn mà các cá nhân khác không phải công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực không thể làm được. Do vậy việc mở rộng thêm cho những nhóm người khác bên cạnh công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực di chúc được quyền xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng là phù hợp. Việc mở rộng nhóm đối tượng này cũng giúp việc thực hiện trình tự lập di chúc miệng được dễ dàng, thuận lợi mà cũng không làm mất đi tính xác thực của di chúc.

Từ những lý do trên, quy định tại khoản 5 Điều 630 BLDS có thể ghi nhận bổ sung thêm nội dung *“Trường hợp di chúc không thể được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng thì người làm chứng có thể yêu cầu người phụ trách bệnh viện, cơ sở chữa bệnh của người lập di chúc; hoặc người chỉ huy tàu biển nếu người lập di chúc đang trên tàu biển; hoặc cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước người lập di chúc đang sống; hoặc yêu cầu người đứng đầu cơ quan nơi quản lý người làm chứng xác nhận.”*

(iii) Kiến nghị bổ sung quy định xem xét mức tài sản, loại tài sản để lập di chúc miệng với thủ tục rút gọn

Luật Việt Nam chỉ quy định khái quát về hoàn cảnh được quyền lập di chúc miệng đó là cận kề cái chết và không thể lập di chúc bằng văn bản. Như vậy di chúc miệng chỉ được lập khi xem xét đến hoàn cảnh của người lập di chúc là cận kề cái chết và khả năng của họ là không thể lập di chúc bằng văn bản. Khi những người ở vào hoàn cảnh và điều kiện này họ sẽ lập di chúc với trình tự là phải có sự chứng kiến của người làm chứng để ghi chép lại di chúc và người làm chứng yêu cầu công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong thời gian 5 ngày làm việc.

Tuy nhiên đối với luật ở một số tiểu bang của Mỹ bên cạnh những di chúc miệng được lập theo trình tự đầy đủ do luật định, người để lại di sản còn có thể lập di chúc miệng với thủ tục rút gọn hơn so với yêu cầu thông thường nếu thỏa mãn điều kiện về tài sản. “*Hầu hết các đạo luật chỉ cho phép định đoạt động sản hoặc bất động sản cá nhân, và thậm chí sau đó, một số đạo luật buộc phải giới hạn tiền tệ đối với số tài sản có thể được chuyển giao bằng di chúc miệng theo thủ tục rút gọn*”³⁶⁴. Chẳng hạn, tiểu bang Washington quy định quyền lập di chúc miệng định đoạt tài sản cá nhân của một người sẽ có giá trị không quá \$ 1000³⁶⁵, tiểu bang Tennessee cũng quy định là \$ 1000, tuy nhiên đối với những người đang hoạt động trong quân đội, không quân hoặc hải quân trong thời gian chiến tranh thì tổng số tiền có thể là \$ 10.000³⁶⁶. Với tiểu bang New Hampshire, con số này thậm chí không được vượt quá \$ 100³⁶⁷. Ở tiểu bang Montana, di chúc miệng không cần phải được viết cũng không được tuyên bố cũng không được chứng thực với bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng cho tài sản cá nhân. Số tiền được để lại không được vượt quá giá trị \$1000. Di chúc miệng phải được chứng minh bởi hai nhân chứng có mặt trong quá trình tạo lập di chúc, một trong số họ đã được người lập di chúc yêu cầu làm chứng rằng đó là ý muốn của người lập di chúc.³⁶⁸ Đây là một quy định khá đặc biệt so với các nước khi xem xét đến loại tài sản, giá trị tài sản để cho phép người để lại di sản được lập di chúc miệng với thủ tục rút gọn thay vì tuân thủ đầy đủ các trình tự thủ tục của di chúc miệng thông thường.

Đây là một loại hình di chúc hướng đến sự đơn giản về thủ tục cho người để lại di sản khi muốn định đoạt tài sản với giá trị nhỏ. Khi người lập di chúc cận kề cái chết muốn lập di chúc miệng mà không cần phải thông qua những thủ tục rườm rà. Tài sản trong trường hợp này phải là tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng của người lập di chúc và giá trị tài sản nhỏ. Giá trị tài sản nhỏ là bao nhiêu thì theo pháp luật của từng tiểu bang để xác định, cũng như có thể căn cứ vào chủ thể để xác định. Về thủ tục lập di chúc miệng khá đơn giản, chỉ cần có hai người làm chứng chứng kiến quá trình lập di chúc và di chúc này cũng không cần phải ghi chép lại hay không cần phải tuyên bố, chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định này thiết nghĩ cũng là một quy định giúp cho người để lại di sản khi muốn lập di chúc miệng có thể lập một cách thuận lợi.

³⁶⁴ Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann, *tlđđ* (số chú thích 10), tr.373-374.

³⁶⁵ Washington revised code (2019), title 11 – Probate and trust law, 11.12 – Will, 11.12.025 – Nuncupative wills, <https://law.justia.com/codes/washington/2019/title-11/chapter-11-12/section-11-12-025>, [truy cập ngày 29/8/2020].

³⁶⁶ Tennessee code (2010), title 32 – Wills, chapter 1 – Execution of wills, part 1 – Execution generally, 32-1-106 – Nuncupative will, <https://law.justia.com/codes/tennessee/2010/title-32/chapter-1/part-1/32-1-106>, [truy cập ngày 29/8/2020].

³⁶⁷ New Hampshire statutes (2010) title 54 – Probate courts and decedents’ Estates, chapter 551 – Wills, section 551:16 validity.

³⁶⁸ J. Howard Toelle, *tlđđ* (số chú thích 145), tr.20.

Mục đích của việc ghi nhận di chúc miệng là để đảm bảo những người có tài sản đã lâm vào tình cảnh cận kề cái chết không thể lập di chúc bằng văn bản như thông thường vẫn có thể thể hiện quyền định đoạt tài sản sau khi họ chết bằng lời nói. Do vậy, nếu giá trị tài sản nhỏ, tài sản chỉ thuộc sở hữu của riêng bản thân họ, không có tranh chấp thì việc lập di chúc theo thủ tục đơn giản là sự giản tiện rất hợp lý cũng như không có những tranh chấp không đáng có giữa những người thừa kế theo di chúc.

Đây là một quy định mang tính đơn giản hóa thủ tục và cũng rất thuận tiện cho người để lại di sản, cho người làm chứng, cho người thừa kế theo di chúc. Theo quan điểm của tác giả, luật Việt Nam cần ghi nhận căn cứ này như một điều kiện để đơn giản hóa thủ tục giúp việc lập di chúc miệng được dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc.

Như vậy một người muốn lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho người khác có thể lựa chọn loại hình di chúc bằng văn bản phù hợp với họ. Tuy nhiên nếu họ ở vào hoàn cảnh cận kề cái chết, không thể lập di chúc bằng văn bản và nếu yếu tố tài sản có thể cân nhắc nên chăng cần ghi nhận cho phép họ được lựa chọn lập di chúc miệng với thủ tục đơn giản. Dầu vậy, vấn đề khó khăn khi thừa nhận hình thức di chúc miệng được lập theo thủ tục đơn giản này chính là việc xác định những loại tài sản nào có thể được định đoạt, giá trị những tài sản được giới hạn đến đâu.

Nếu căn cứ vào điều kiện ở Việt Nam, tác giả cho rằng khi thừa nhận thủ tục lập di chúc miệng theo hướng giản tiện này cần xem xét tài sản được định đoạt trong di chúc chỉ có thể là tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng của người lập di chúc. Tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng của người lập di chúc là căn cứ đầu tiên và cơ bản để người lập di chúc dễ dàng và thuận lợi trong quá trình định đoạt tài sản theo di chúc miệng. Sẽ không xảy ra các vấn đề xác định phần tài sản được định đoạt trong khối tài sản chung với người khác, khó có những tranh chấp xảy ra. Vấn đề thứ hai là giá trị tài sản nhỏ, theo suy nghĩ gợi ý của tác giả nên dựa vào mức lương cơ sở do Nhà nước quy định để xác định mức tối đa³⁶⁹. Dựa vào thu nhập, điều kiện sống hiện nay của người Việt Nam để xác định một số tiền cụ thể và ghi nhận là nhỏ sẽ là không phù hợp vì mức sống vật giá luôn thay đổi sau một khoảng thời gian. Do đó, dựa vào mức lương cơ sở để xác định sẽ đảm bảo tính chất ổn định hơn khi cuộc sống thay đổi theo thời gian. Vì vậy, tác giả đưa ra đề xuất mức tài sản tối đa cho người để lại di sản muốn định đoạt tài sản theo loại hình di chúc có trình tự, thủ tục lập rút gọn là không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Với định giá tài sản như vậy thiết nghĩ là phù hợp để có thể định đoạt bằng di chúc miệng mà không cần thiết phải

³⁶⁹ Hiện nay pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với tổn thất về tinh thần do không và khó xác định được cụ thể mức thiệt hại nên căn cứ vào mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định để xác định mức tối đa trong trường hợp các bên không thỏa thuận được theo quy định tại khoản 2 Điều 590, khoản 2 Điều 591, khoản 2 Điều 592, khoản 3 Điều 606, khoản 3 Điều 607 BLDS 2015. Điều 27 Luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước 2017.

thông qua thủ tục ghi chép lại, không cần công chứng hoặc chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Trên cơ sở các phân tích trên, tác giả kiến nghị quy định tại khoản 5 Điều 630 BLDS 2015 nên ghi nhận bổ sung như sau *“Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì **người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Trường hợp di sản là tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng của người lập di chúc và giá trị không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người lập di chúc chỉ cần thể hiện ý chí trước mặt ít nhất hai người làm chứng và hai người làm chứng xác nhận đó là ý chí của người lập di chúc**”*.

Việc bổ sung quy định này mang lại sự thuận lợi trong quá trình lập di chúc cho người để lại di sản, người làm chứng và người thừa kế theo di chúc.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Di chúc miệng là hình thức di chúc được lập khi người lập di chúc ở vào hoàn cảnh không thể lập di chúc bằng văn bản và cận kề cái chết do vậy di chúc miệng là hình thức di chúc trừ bị cho di chúc bằng văn bản. Nếu di chúc bằng văn bản được ghi nhận đa dạng với nhiều loại hình di chúc và ở những loại hình khác nhau sẽ có những điều kiện về hoàn cảnh, trình tự, thủ tục lập di chúc là khác nhau. Đối với di chúc miệng chỉ được lập trong một hoàn cảnh nên trình tự, thủ tục lập di chúc miệng theo một thể thức duy nhất.

Sau quá trình phân tích quy định pháp luật Việt Nam, tham khảo pháp luật nước ngoài, xem xét một số thực tiễn áp dụng pháp luật về di chúc miệng, quy định của luật hiện hành nên sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau đây để đảm bảo di chúc miệng ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc và có thể khả thi thực hiện trên thực tế.

(i) Thời điểm để người làm chứng ghi chép lại di chúc miệng là “ngay sau khi” người để lại di sản thể hiện ý chí của mình được xác định khó khả thi. Không phải trong mọi trường hợp ngay khi người để lại di sản thể hiện ý chí của mình thì người làm chứng đều có các điều kiện để ghi chép lại. Trí nhớ của hai người làm chứng vẫn có thể lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn. Mặt khác, bên cạnh trí nhớ của người làm chứng thì việc ghi âm, ghi hình cũng là một phương thức để tạm lưu giữ lại ý chí của người để lại di sản. Do vậy, tác giả kiến nghị thời điểm ghi chép lại di chúc miệng là trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày người để lại di sản thể hiện ý chí cuối cùng.

(ii) Hình thức bản ghi chép lại ngoài thể hiện bằng bản giấy có thể ghi nhận thêm bản ghi âm và hình dựa trên thực tiễn xét xử đã có. Bản ghi âm và hình có lời nói và hình ảnh của người lập di chúc định đoạt tài sản của mình, có hình ảnh và lời chứng xác thực của người làm chứng dưới sự chứng kiến và có xác nhận của công chứng viên có thể thay thế cho bản giấy được viết của người làm chứng.

(iii) Bên cạnh việc công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng nên mở rộng phạm vi những người có quyền xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng là người đứng đầu cơ sở y tế (nếu người để lại di sản đang ở trong cơ sở y tế) hoặc người chỉ huy tàu biển nếu người lập di chúc đang trên tàu biển; hoặc cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước người lập di chúc đang sống; hoặc yêu cầu người đứng đầu cơ quan nơi quản lý người làm chứng xác nhận trong trường hợp người làm chứng không thể hoặc không tìm được tổ chức công chứng, UBND để thực hiện việc công chứng, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của mình.

(iv) Để đảm bảo quyền bình đẳng trong việc định đoạt tài sản cho người có tài sản trước khi họ chết, quy định di chúc miệng nên bổ sung thêm các trường hợp sau.

Người lập di chúc rơi vào hoàn cảnh không thể lập di chúc bằng văn bản, cận kề cái chết mà không thể nói được thì nên ghi nhận cho họ quyền lập di chúc miệng thông qua việc thể hiện ý chí ra bên ngoài bằng hành vi và người thông dịch sẽ thông dịch và ghi chép lại vào văn bản. Do đó để thuận lợi khi lập di chúc trong hoàn cảnh này người thông dịch viên chính là người làm chứng để đảm bảo sự khách quan, trung thực khi ghi nhận lại ý chí của người để lại di sản thừa kế. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi đã được luật ghi nhận cho quyền lập di chúc bằng văn bản để định đoạt tài sản thì không có lý do gì khi họ lâm vào tình trạng cận kề cái chết không thể lập di chúc bằng văn bản lại không được phép lập di chúc miệng.

(v) Di sản nếu là tài sản thuộc sở hữu riêng của người lập di chúc và giá trị tài sản không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định được định đoạt trong di chúc miệng thì cần ghi nhận cho người lập di chúc miệng với thủ tục đơn giản. Di chúc được lập chỉ cần dưới sự chứng kiến của hai người làm chứng để xác thực nội dung di chúc. Quy định này đảm bảo sự thuận lợi trong quá trình lập di chúc cho người để lại di sản, người làm chứng mà vẫn đảm bảo di chúc được xác thực về nội dung.

KẾT LUẬN

Hiểu theo nghĩa rộng hình thức di chúc là một phạm trù pháp lý bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các điều kiện, trình tự thủ tục lập di chúc tùy vào từng loại hình thức di chúc. Hiểu theo nghĩa hẹp, hình thức di chúc là một phương thức để ghi nhận và xác thực nội dung di chúc.

Hình thức di chúc và nội dung di chúc có mối liên hệ với nhau. Nội dung di chúc được người lập di chúc thể hiện ra và được ghi nhận lại bằng hình thức di chúc. Hình thức di chúc chứa đựng nội dung di chúc và ngược lại, nội dung di chúc ảnh hưởng đến hình thức di chúc ở những điều kiện về trình tự, thủ tục lập di chúc. Hình thức di chúc và nội dung di chúc là hai yếu tố tạo nên một bản di chúc để đảm bảo ghi nhận chính xác ý chí của người để lại di sản.

Pháp luật về hình thức di chúc bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Sự tự do ý chí của người lập di chúc; phong tục tập quán, đặc tính đặc trưng của xã hội từng thời kỳ; chủ thể lập di chúc; tài sản được định đoạt trong di chúc; hoàn cảnh lập di chúc. Tất cả các yếu tố này tác động đến việc xây dựng các điều kiện và trình tự, thủ tục cho từng hình thức di chúc và từng loại hình thức di chúc.

Di chúc bằng văn bản và di chúc miệng là hai hình thức di chúc truyền thống. Ranh giới để phân biệt hoàn toàn hai hình thức di chúc bằng văn bản và di chúc miệng là khá mờ nhạt nếu dựa vào phương thức lưu giữ ý chí của người lập di chúc. Bởi lẽ cả hai hình thức này cuối cùng đều được lưu giữ bằng văn bản. Tuy nhiên nếu căn cứ vào phong tục tập quán về sự hình thành nên hình thức di chúc, căn cứ vào hoàn cảnh lập di chúc, căn cứ vào thể thức lập di chúc thì hai hình thức di chúc là khác biệt. Mặt khác, di chúc bằng văn bản được ghi nhận với nhiều loại hình đa dạng. Người lập di chúc được tự do lựa chọn loại hình thức di chúc phù hợp, trừ trường hợp luật có quy định khác. Do vậy có thể khẳng định hình thức di chúc bằng văn bản là hình thức di chúc cơ bản nhất. Di chúc miệng là hình thức di chúc trừ bị cho di chúc bằng văn bản khi người lập di chúc cận kề cái chết và không thể lập di chúc bằng văn bản.

Quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản cần sửa đổi, bổ sung một số điều kiện để đảm bảo di chúc bằng văn bản là phương thức ghi nhận, xác thực ý chí của người lập di chúc và đảm bảo di chúc được lập thuận tiện hơn. Cụ thể bao gồm các vấn đề sau:

(i) Cách gọi tên của hai loại hình di chúc bằng văn bản “di chúc không có người làm chứng” và “di chúc bằng văn bản có người làm chứng” theo Điều 633 và Điều 634 BLDS 2015 chưa phù hợp và tác giả kiến nghị tên gọi nên đổi thành “di chúc tự viết” và “di chúc được đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy”.

(ii) Tác giả kiến nghị bổ sung thêm điều kiện điểm chỉ bên cạnh điều kiện chữ ký. Nếu những di chúc được người lập di chúc điểm chỉ thì cần có lời chứng thể hiện

sự đồng ý của người lập di chúc. Người lập di chúc tự viết phải biết ngôn ngữ mà họ thể hiện trong di chúc. Bên cạnh đó, khi không thể và không có cơ sở để xác định yếu tố chữ viết thì Tòa án có thể căn cứ vào những bằng chứng khác để xác định đây là di chúc do người để lại di sản lập.

(iii) Luật cần ghi nhận cho phép người thừa kế theo pháp luật được làm người làm chứng và người làm chứng phải là người biết đọc, biết viết ngôn ngữ được thể hiện trong di chúc.

(iv) Quy định bắt buộc phải lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng, có công chứng hoặc chứng thực sẽ chỉ dành cho người không đọc được. Bên cạnh đó vai trò của người làm chứng trong trường hợp này cần phải đọc lại nội dung di chúc cho người lập di chúc để người lập di chúc xác nhận lại nội dung di chúc của mình.

(v) Bổ sung ghi nhận thêm hình thức di chúc niêm phong được công chứng hoặc chứng thực để người lập di chúc có thêm sự lựa chọn loại hình thức di chúc bằng văn bản.

(vi) Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định năm loại hình thức di chúc bằng văn bản cho người lập di chúc tùy vào từng điều kiện của mình có thể lựa chọn hoặc tuân thủ theo loại hình di chúc nếu luật đã có quy định. Do vậy, trong một hoàn cảnh không nên kết hợp điều kiện của nhiều loại hình thức di chúc dẫn đến sự khó khăn trong quá trình lập di chúc của người để lại di sản.

(vii) Thừa nhận di chúc điện tử là một hướng đi tất yếu phù hợp với sự phát triển của xã hội. Việt Nam cần xem xét để ghi nhận hình thức di chúc này theo một lộ trình phù hợp.

Khi nghiên cứu về di chúc miệng, quy định của pháp luật hiện hành nên sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau đây để đảm bảo di chúc miệng ghi nhận chính xác ý chí của người lập di chúc và giúp cho việc lập di chúc được thuận tiện hơn.

(i) Thời điểm để người làm chứng ghi chép lại di chúc miệng là “ngay sau khi” người để lại di sản thể hiện ý chí của mình được xác định khó khả thi. Do vậy, tác giả kiến nghị thời điểm ghi chép lại di chúc miệng là trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày người để lại di sản thể hiện ý chí cuối cùng.

(ii) Hình thức bản ghi chép lại ngoài thể hiện bằng bản giấy có thể ghi nhận thêm bản ghi âm và hình dựa trên thực tiễn xét xử đã có. Bản ghi âm và hình có lời nói, hình ảnh của người lập di chúc định đoạt tài sản của mình, có hình ảnh và lời chứng xác thực của người làm chứng dưới sự chứng kiến và có xác nhận của công chứng viên có thể thay thế cho bản giấy được người làm chứng viết ra.

(iii) Bên cạnh việc công chứng viên, người có thẩm quyền chứng thực công chứng, chứng thực chữ ký, điểm chỉ của người làm chứng nên mở rộng phạm vi những người có quyền xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng là người đứng đầu cơ sở y tế (nếu người để lại di sản thừa kế đang ở trong cơ sở y tế) hoặc người chỉ

huy tàu biển nếu người lập di chúc đang trên tàu biển; hoặc cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước người lập di chúc đang sống; hoặc yêu cầu người đứng đầu cơ quan nơi quản lý người làm chứng xác nhận.

(iv) Ghi nhận quyền lập di chúc miệng cho người lập di chúc không thể nói được ở vào hoàn cảnh cận kề cái chết mà không thể lập di chúc bằng văn bản. Ghi nhận quyền lập di chúc miệng cho người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi họ lâm vào tình trạng cận kề cái chết, không thể lập di chúc bằng văn bản.

(v) Di sản nếu là tài sản thuộc sở hữu riêng của người lập di chúc và giá trị tài sản không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định được định đoạt trong di chúc miệng thì cần ghi nhận cho người lập di chúc miệng với thủ tục đơn giản.

Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được, tác giả mong muốn luận án sẽ góp một phần nhỏ để xây dựng hệ thống các vấn đề lý luận về hình thức di chúc, hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc để đảm bảo hình thức di chúc là phương tiện để ghi nhận và lưu giữ chính xác ý chí của người lập di chúc, giúp cho di chúc được lập một cách thuận lợi hơn và thừa kế theo di chúc đạt được mục tiêu bảo vệ sự đoàn kết gia đình, trật tự và đạo đức xã hội.

NHỮNG CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN

1. Nguyễn Thanh Thư (2019), Hình thức của di chúc trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Bộ luật Dân sự mới của Việt Nam, góc nhìn Pháp – Việt* (GS. Grimaldi Michel và GS. Đỗ Văn Đại (chủ biên)), Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam.
2. Nguyễn Thanh Thư (2020), “Hình thức di chúc miệng”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 02 (132).
3. Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (2021), “Hình thức di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* số 14 (438).
4. Nguyễn Thanh Thư (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Trần Khắc Qui (thành viên chính) (2021) , “*Pháp luật về điều kiện hợp pháp của di chúc*”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Đại học Cần Thơ.
5. Nguyễn Thanh Thư (2021), “Di chúc được lập thông qua các phương tiện điện tử”, *Tạp chí Khoa học pháp lý* số 06 (145).
6. Nguyễn Thanh Thư (2023), “Di chúc điện tử - Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và việc áp dụng ở Việt Nam”, Hội nghị khoa học trẻ “*Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số*” được tổ chức vào ngày 23/10/2023 do Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Quy Nhơn đồng tổ chức.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Văn bản pháp luật

* Văn bản pháp luật Việt Nam

1. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (thông qua ngày 9/11/1946).
2. Bộ luật Hồng Đức (1470 – 1497).
3. Bộ luật Gia Long (Hoàng Việt luật lệ) 1813.
4. Bộ luật Dân sự Bắc kỳ 1931.
5. Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật 1936.
6. Bộ Dân luật Việt Nam Cộng hòa (Sắc Luật số 028-TT/SLU) ngày 20/12/1972.
7. Bộ luật Dân sự (Luật số 44-L/CTN) ngày 28/10/1995.
8. Bộ luật Dân sự (Luật số 33/2005/QH11) ngày 14/06/2005.
9. Bộ luật Dân sự (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015.
10. Bộ luật Tố tụng Dân sự (Luật số 92/2015/QH13) ngày 25/11/2015.
11. Bộ luật Tố tụng Hình sự (Luật số 101/2015/QH13) ngày 27/11/2015.
12. Bộ luật Hàng hải Việt Nam (Luật số 95/2015/QH13) ngày 25/11/2015.
13. Luật Hôn nhân và gia đình 1959.
14. Luật Giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11) ngày 29/11/2005.
15. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Luật số 66/2006/QH11) ngày 29/06/2006.
16. Luật Công chứng (Luật số 82/2006/QH11) ngày 29/11/2006.
17. Luật Công chứng (Luật số 53/2014/QH13) ngày 20/6/2014.
18. Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH13) ngày 29/11/2013.
19. Luật Nhà ở (Luật số 65/2014/QH13) ngày 25/11/2014.
20. Luật Luật sư (Luật số 03/VBHN-VPQH) ngày 31/12/2015.
21. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật số 10/2017/QH14) ngày 20/06/2017.
22. Pháp lệnh Thừa kế 1990 (số 44-LCT/HĐNN8) ngày 10/9/1990.
23. Nghị định 44/2005/NĐ-CP ngày 05/04/2005 của Chính phủ quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.
24. Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
25. Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
26. Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

27. Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.
28. Thông tư 81/TT-TANDTC ngày 24/07/1981 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế.
29. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao – Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
30. Sắc lệnh 47/SL ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
31. Sắc lệnh 97/SL ngày 22/5/1950 của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
32. Chỉ thị 772/CT-TATC ngày 10/7/1959 của Tòa án nhân tối cao về vấn đề đình chỉ áp dụng luật pháp cũ của đế quốc và phong kiến.
33. Quyết định số 115/QĐ ngày 08/03/1965 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thể lệ gửi tiền tiết kiệm “gửi gọn có gọn, có thời hạn, có lãi”.

*** Văn bản pháp luật nước ngoài**

34. Bộ luật Dân sự Pháp 1804, sửa đổi năm 2017 (Bản dịch của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (2018), *Bản dịch Bộ luật Dân sự Pháp*).
35. Bộ luật Dân sự Nhật Bản 1896 (bản tiếng Anh năm 2018).
36. Bộ luật Dân sự Quebec 1991 xem tại <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/ccq-1991>.
37. Bộ luật Dân sự Hà Lan 1992 xem tại <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm>.
38. Bộ luật Dân sự Tây Ban Nha 2012 xem tại <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/05/Spain-Spanish-Civil-Code-2012-eng.pdf>.
39. Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020 (Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên (2021), *Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020 – Bản dịch và lược giải*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội).
40. Đạo luật Diễn giải và Hành động Tasmania 1931 xem tại <https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1931-059>.
41. Đạo luật Tự do thông tin Queensland 1992 xem tại <https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/2006-07-01/act-1992-042>.
42. Luật Thừa kế New South Wales 2006 xem tại <https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-2006-080#ch.2>.

43. Luật Di chúc điện tử Mỹ 2019 xem tại https://www.uniformlaws.org/committees/community-home/librarydocuments?attachments=&communitykey=a0a16f19-97a8-4f86-afc1-b1c0e051fc71&defaultview=&libraryentry=606404de-a959-404e-ab2d-0180a0f66457&libraryfolderkey=&pageindex=0&pagesize=12&search=&sort=most_recent&viewtype=row.

B. Văn bản khác

44. Quyết định số 26/QĐ-BTTTT ngày 16/01/2023 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia.
45. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Tài liệu tham khảo

*** Tiếng Việt**

46. Phạm Kim Anh (chủ nhiệm đề tài) (2011), *Pháp luật về thừa kế ở Việt Nam từ thế kỷ XV đến nay*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
47. Hồ Thị Vân Anh (2015), “Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế theo di chúc”, *Tạp chí Nghề luật*, số 2, tháng 3 năm 2015, tr.42-47.
48. Hồ Thị Vân Anh (2017), *Pháp luật thừa kế thời kỳ nhà Lê, nhà Nguyễn và sự vận dụng trong hoàn thiện pháp luật thừa kế ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
49. Huỳnh Công Bá (2020), *Định chế Hôn nhân và gia đình thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa – Tài sản*, Nxb. Thuận Hóa.
50. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), *Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin*, Nguyễn Viết Thông (chủ biên), Nxb. Chính trị quốc gia.
51. Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
52. Bộ Tư pháp – Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, *Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời Pháp thuộc*, Nxb. Chính trị quốc gia.
53. Bản dịch - Bộ luật Dân sự, Thương mại Thái Lan (1995), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
54. Lê Mai Chi (2019), *Hình thức của di chúc*, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
55. Lê Thị Danh (2009), *Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

56. Đỗ Văn Đại, Nguyễn Hồ Bích Hằng (2013), “Di chúc có công chứng, chứng thực”, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 1 (74), tr.54-61.
57. Đỗ Văn Đại (2013), “Hình thức bắt buộc của hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam: Những bất cập và hướng hoàn thiện”, *Tạp chí Luật học*, số 2 (153), tr.3-14.
58. Đỗ Văn Đại (2019), *Luật thừa kế Việt Nam – Bản án và bình luận bản án (Tập 1)*, Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.
59. Đỗ Văn Đại (chủ biên) (2020), *Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015*, Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam.
60. Nguyễn Ngọc Điện (1999), *Một số suy nghĩ về thừa kế trong Luật Dân sự Việt Nam*, Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.
61. Nguyễn Ngọc Điện (2009), *Giáo trình Luật La Mã*, Nxb. Chính trị quốc gia.
62. Nguyễn Ngọc Điện (2016), *Giáo trình Luật Dân sự - Tập 2*, Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
63. Nguyễn Ngọc Điện (2021), *Giáo trình Luật Hôn nhân gia đình – Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế, Tập 2*, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
64. Nguyễn Ngọc Điệp (2001), *Những điều cần biết về quyền thừa kế*, Nxb. Phụ nữ.
65. Nguyễn Trọng Điệp, Cao Thị Hồng Giang (2016), “Những giới hạn của tự do ý chí và vấn đề bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay”, *Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học*, tập 32, số 2 năm 2016, tr.11-15.
66. Viên Thế Giang, Bùi Hữu Toàn (đồng chủ biên) (2020), *Giáo trình Nhập môn Luật học*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
67. Grimaldi Michel, Đỗ Văn Đại (đồng chủ biên), *Bộ luật Dân sự mới của Việt Nam, góc nhìn Pháp – Việt*, Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam.
68. Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Kim Lan (2016), “Hiệu lực về hình thức của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015”, *Tạp chí Luật học*, số 12 (199), tr.11-19.
69. Nguyễn Minh Hằng (2019), “Bình luận về vụ án giải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc miệng”, *Tạp chí Nghề Luật*, số 2 năm 2019, tr.72-77.
70. Thái Vĩnh Hằng (2010), *Nhà nước và pháp luật tư sản đương đại – Lý luận và thực tiễn*, Nxb. Tư pháp.
71. Phan Trung Hiền (2020), *Lý luận về Nhà nước và pháp luật - Tập 1*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.
72. Vũ Văn Hiền (1960), *Chế độ tài sản trong gia đình Việt Nam – Di sản, Tập II-Quyển thứ ba*, Bộ Giáo dục quốc gia xuất bản.

73. Lương Thị Hợp (2014), “Một số vấn đề về áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về di chúc miệng trong thực tiễn”, *Tạp chí Tòa án nhân dân*, số 21 năm 2014, tr.30-34.
74. Hội đồng quốc gia Việt Nam, *Từ điển Bách khoa Việt Nam - Tập 3*, Nxb. Từ điển Bách khoa.
75. Lê Minh Hùng (1995), *Vấn đề di chúc trong pháp luật thừa kế của nước ta hiện nay*, Luận văn thạc sĩ luật học, Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
76. Lê Minh Hùng (2010), *Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
77. Nguyễn Thị Hoa Huệ (2017), *Người làm chứng cho việc lập di chúc theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
78. Nguyễn Đình Huy (2001), “Quyền thừa kế trong luật La Mã cổ đại”, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 4 (11), tr.52-55.
79. Nguyễn Ngọc Huy (1989), *Quốc triều Hình luật - Quyển A*, Nxb. Viet Publisher.
80. Trần Đại Khâm (1968), *Ấn lệ vụng tập*, Nhà sách Khai Trí.
81. Phạm Công Lạc (1998), “Ý chí trong giao dịch dân sự”, *Tạp chí Luật học*, số 5, tr.6-9, 24.
82. Lê Khánh Linh, Trương Huỳnh Nga, Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Thảo Anh, Trần Kiên (2021), *Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020 – Bản dịch và lược giải*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
83. Hoàng Thế Liên (chủ biên) (2010), *Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 - Tập 3*, Nxb. Chính trị quốc gia.
84. Hoàng Thị Loan (2016), “Một số bất cập và hướng hoàn thiện quy định về hình thức của di chúc trong Bộ luật Dân sự”, *Tạp chí Luật học*, số 11, tr.34-43.
85. Hoàng Thị Loan (2019), *Điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam*, Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội.
86. Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hồng Trinh (2018), “Ý chí và tự do ý chí trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng”, *Tạp chí Pháp luật và thực tiễn*, số 35, tr.1-10.
87. Tưởng Duy Lượng (2007), “Bàn về điều kiện hình thức của giao dịch theo quy định Bộ luật Dân sự 2005”, *Tạp chí Nghề Luật*, số 5, tr.28-30.
88. Tưởng Duy Lượng (2017), *Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử*, Nxb. Tư pháp.
89. Vũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân (1968), *Danh từ và tài liệu Dân luật và Hiến luật*, Tủ sách Đại học Sài Gòn.

90. Vũ Văn Mẫu (1973), *Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử*, Quyển 1 – Tập 1.
91. Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái (1997), *Lịch sử các học thuyết chính trị pháp lý*, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
92. Đỗ Đức Minh (2014), “Tìm hiểu học thuyết pháp luật tự nhiên”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 6 (262), tr.15-23.
93. Nguyễn Hồng Nam (2005), *Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự*, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
94. Nguyễn Hồng Nam (2005), “Người viết hộ di chúc”, *Tạp chí Tòa án nhân dân*, số 22 năm 2005, tr.19-23.
95. Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Tá Nhí (dịch nghĩa) (2002), *Quốc Triều Hình Luật (Bộ luật Hồng Đức)*, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh.
96. Lê Đình Nghị (2009), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1*, Nxb. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
97. Phạm Duy Nghĩa (2004), *Chuyên khảo Luật Kinh tế*, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội.
98. Lưu Thị Phần (2021), “Hình thức của di chúc trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 20 (444), tr.50-56.
99. Hoàng Phê (chủ biên) (1993), *Từ điển tiếng Việt*, Nxb. Khoa học xã hội.
100. Hoàng Thị Kim Quế, Nguyễn Đăng Dung (2016), *Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
101. Phùng Trung Tập (2008), *Luật thừa kế Việt Nam*, Nxb. Hà Nội.
102. Nguyễn Quốc Thắng (phiên âm, dịch nghĩa), Nguyễn Văn Tài (hiệu đính), *Lê Triều Hình Luật (Bộ luật Hồng Đức)*, Nxb. Văn hóa thông tin.
103. Nguyễn Quyết Thắng (2002), *Lược khảo Hoàng Việt Luật lệ*, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
104. Phạm Thị Duyên Thảo (2021), “Xã hội học xây dựng pháp luật”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 10 (434), tr.3-11.
105. Nguyễn Thị Phương Thảo (2022), *Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và thực tiễn áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội*, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
106. Triệu Khắc Thái (2016), *Hình thức di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành – những bất cập và kiến nghị*, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
107. Phan Văn Thiết (1961), *Dân luật tu tri*, Nhà sách Khai Trí.
108. Lê Tuấn Tú (2013), “Hình thức di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005”, *Tạp chí Pháp luật và thực tiễn*, số 6 năm 2013.

109. Nguyễn Văn Tiến (2017), “Hình thức di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 – Một số vấn đề cần hoàn thiện”, *Tạp chí Khoa học kiểm sát*, số 3 (17), tr.39-46.
110. Nguyễn Minh Tuấn (2014), *Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới*, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội.
111. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) (2016), *Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*, Nxb. Tư pháp.
112. Phạm Văn Tuyết (2003), *Thừa kế theo di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự*, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
113. Phạm Văn Tuyết (2007), *Thừa kế quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng*, Nxb. Chính trị quốc gia.
114. Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang (2017), *Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp*, Nxb. Tư pháp.
115. Phạm Kiều Tùng (2018), *Triết học luật pháp* (Bản dịch), Nxb. Tri thức.
116. Đinh Trung Tụng (chủ biên) (2005), *Bình luận những nội dung mới của Bộ luật Dân sự năm 2005*, Nxb. Tư pháp.
117. Nguyễn Thanh Thư (2020), “Hình thức di chúc miệng”, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 2 (132), tr.23-31.
118. Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyên, Trần Khắc Qui (2021), *Pháp luật về điều kiện hợp pháp của di chúc*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Cần Thơ.
119. Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Tuyên (2021), “Hình thức di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 14 (438), tr.44-48.
120. Nguyễn Thanh Thư (2021), “Di chúc được lập thông qua các phương tiện điện tử”, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam*, số 06 (145), tr.70-77.
121. Phạm Thị Trang (2014), “Nghiên cứu so sánh về hình thức di chúc theo quy định của pháp luật dân sự Nhật Bản và pháp luật dân sự Việt Nam”, *Tạp chí Kiểm sát*, số 6 năm 2014, tr.39-44, 64.
122. Trần Quang Trung (2010), *Nhận diện quyền dân sự trong Bộ luật Hồng Đức*, Nxb. Lao Động, Thành phố Hồ Chí Minh.
123. Trung tâm Liên kết Đào tạo – Trường Đại học Cần Thơ (2017), *Luật Dân sự 1*, Nxb. Đại học Cần Thơ.
124. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật (2011), *Văn hóa pháp luật – Những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành*, Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương (đồng chủ biên), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

125. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2019), *Giáo trình Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và thừa kế*, Lê Minh Hùng (chủ biên), Nxb. Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam.
126. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam*, Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga (đồng chủ biên), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.
127. Trường Đại học Luật Hà Nội (2019), *Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam - Tập 1*, Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn (đồng chủ biên), Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội.
128. Nguyễn Thị Hồng Vân (2020), “Một số vấn đề về người làm chứng cho việc lập di chúc”, *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 335, tr.15-19.
129. Viện Đông Nam Á (1995), *Một số luật tục và luật cổ ở Đông Nam Á*, Nxb. Văn hóa thông tin.
130. Viện Ngôn ngữ học (2016), *Từ điển tiếng Việt*, Nxb. Hồng Đức.
131. Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), *Đại từ điển tiếng Việt*, Nxb. Văn hóa - Thông tin.

*** Tiếng Anh**

132. Barry Nicholas (2017), *Introduction to Roman Law*, Oxford University Press.
133. Banta, Natalie M. (2019), “Electronic Wills and digital assets: Reassessing formality in the digital age”, *Baylor Law Review*, Vol. 71, No. 3, tr.547-603.
134. Bodderly, Scott S. (2012), “Electronic Wills: Drawing a line in the sand against their validity”, *Real Property, Trust, and Estate Law Journal*, Chicago, No. 47, tr.197-212.
135. Daniel H. Redfearn (1957), *Practical Treatise on the Law of Wills and administrations of estate in Florida*, Harrison Co., Edition 3, Chapter 1.
136. Francesca Torres (2021), “Electronic Wills: COVID-19 Relief or Inevitable Trouble for California?”, *University of the Pacific Law Review*, 14, No. 52, Vol. 2, tr.436-455.
137. FA. Hayek (2011), *The constitution of Liberty: The definitive edition*, University of Chicago Press.
138. Gary, Susan N, Orlando J. and Marian H. Hollis (2021), “The electronic Wills act: facing the inevitable”, *Real Property, Trust, and Estate Law Journal*, Chicago, Vol. 55, No. 3, tr.305-346.
139. Henry Campbell Black (1968), *Black Law Dictionary - fourth edition*, West Publishing Co.
140. James M. Morton, Jr. (1894), “The theory of Inheritance”, *Harvard Law Review*, Vol. 8, No. 3, tr.161-167.
141. Jens Beckert (2008), *Inherited Wealth*, Princeton University Express.

142. J. Howard Toelle (1951), “Succession Under Montana Law”, *12 Montana Law Review*, Vol.20, tr.20-35.
143. Kelly Purser, Tina Cockburn (2019), “Wills formalities in the twenty first century – Promoting testamentary intention in the face of societal change and advancements in technology: An Australian response to Professor Crawford”, *Wisconsin Law Review*, No. 6, Vol. 269, tr.46-65.
144. Kenneth G C Reid, Marius J De Waal, Reinhard Zimmermann (2011), *Comparative Succession Law - Volume I, Testamentary Formalities*, Oxford University Press.
145. Lindsay Dean Breach (2013), “*The Civil Law Influence on the Evolution of Testamentary Succession*”, Thesis of Master of Law, University of Canterbury.
146. Marett Leiboff and Mark Thomas (2009), *Legal Theories – Contexts and Practices*, Thomson Reuters.
147. Mc Carthy Frankie (2020), *Succession Law, Law Essentials*, University of Sherbrooke Press.
148. Musyoka, William (2010), *A Casebook on the Law of Succession*, African Books Collective.
149. Neil MacCormick (1997), *Legal Reasoning and Legal Theory*, Larendon Press. Oxford.
150. Nowell D. Bamberger (2008), “Are military testamentary instruments unconstitutional? Why compliance with state testamentary formality requirement remains essential”, *Military Law Review*, No. 196, tr.91-128.
151. Paige Hall (2019), “Welcoming e-wills into the mainstream: the digital communication of testamentary intent”, *Nevada Law Journal*, Vol. 20, No.1, tr.340-372.
152. Sizwe Snail and Nicholas Hall (2010), “Electronic Wills in South Africa”, *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, No. 7, tr.67-70.
153. Tamara Đurđić-Milošević (2021), “*Testamentary formalities in the time of pandemic*”, EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC), No. 5, tr.422-443.
154. Thomas A. Byrne (1926), “Outline of the Law of Wills”, *Law Review*, 10 Marq, tr.220-235.

D. Tài liệu từ Internet

*** Tiếng Việt**

155. Dự thảo Luật Giao Dịch điện tử (sửa đổi)
<https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/duthaovbpl/luatgiaodichdientu.pdf>, [truy cập 12/5/2023].

156. Trần Thị Thu Hoài (2019), “Những nội dung cốt yếu trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh/-/2018/814305/nhung-noi-dung-cot-yeu-trong-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh.aspx>, [truy cập 29/9/2023].
157. Bùi Quang Hưng, “Di chúc của người hạn chế thể chất”, <http://trungtamdichuc.com/di-chuc-cua-nguoi-han-che-the-chat.html>, [truy cập 25/9/2021].
158. Bích Lan, “Cần nhắc mở rộng phạm vi hoạt động áp dụng giao dịch điện tử đối với lĩnh vực đất đai, thừa kế”, <https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=68742>, [truy cập 28/4/2023].
159. Chu Xuân Minh, “Di chúc hợp pháp không có công chứng, chứng thực”, <https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/di-chuc-hop-phap-khong-co-cong-chung-chung-thuc>, [truy cập 23/3/2021].
160. Kiều Thanh, “Quyền tự định đoạt của người lập di chúc”, <https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Quyền-tu-dinh-doat-cua-nguoi-lap-di-chuc-7690/>, [truy cập 28/4/2021].
161. Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2014), <https://baochinhphu.vn/toan-van-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-102169104.htm>, [truy cập 29/9/2023].
162. <https://www.congbobanan.toaan.gov.vn>.
163. <https://www.thuvienphapluat.vn>.

*** Tiếng Anh**

164. Kimberley Martin TEP (2020), “Technology and Wills – The Dawn of a New Era”, https://www.step.org/sites/default/files/media/files/2020-08/Technology-and-Wills_The-Dawn-of-a-New-Era.pdf?fbclid=IwAR2AOBem_3Qrp8qXiuDy6TBMSvVkrqYnOyVBHxD1Ep fExAUDhGUn8MQB7Ck, [truy cập 21/12/2021].
165. Mark Glover (2018), “A Social Welfare Theory of Inheritance Regulation”, *Utah Law Review*, No. 2 session 4, <https://dc.law.utah.edu/ulr/vol2018/iss2/4>, [truy cập 08/09/2021].
166. Mariusz Załucki (2019), “About the Need to Adjust the Regulations Regarding the Form of Will to the Modern Requirements”, *European Journal of Economics, Law and Politics*, Vol. 6, No. 2, <https://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2019/06/6-2-1.pdf>, [truy cập 10/09/2022].
167. New York Consolidated Laws (2010), “Estates, Powers and Trusts Law”, <https://law.justia.com/codes/new-york/2010/ept/article-3/part-2/3-2-2/>, [truy cập 21/12/2021].

168. Nevada Revised Statutes (2022), “Chapter 133 – Wills NRS 133.085 - Electronic will”, <https://law.justia.com/codes/nevada/2022/chapter-133/statute-133-085/>, [truy cập 30/8/2022].
169. North Carolina General Statutes (2019), “Chapter 31 – Wills, Article 1 - Execution of Will, Section 31-3.5 Nuncupative will”, <https://law.justia.com/codes/north-carolina/2022/chapter-31/article-1/section-31-3-5/>, [truy cập 21/12/2021].
170. Rafael Domingo (2017), “The Roman Law of succession - An overview”, SSRN Electronic Journal, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2989061, [truy cập 28/4/2023].
171. Sherry Bosse Lueders (2020), “What the Uniform Electronic Wills Act Changes About Wills in Washington”, <https://wabarnews.org/2022/09/07/uniform-electronic-wills-act-washington/>, [truy cập 26/4/2023].
172. Thompsan Mc Mullan (2020), “Will Electronic Wills Be the New Normal?”, <https://www.t-mlaw.com/commentary/will-electronic-wills-be-the-new-normal/>, [truy cập 15/3/2023].
173. <https://www.legifrance.gouv.fr>.
174. <https://www.uniformlaws.org>.

PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản án số 113/2019/DS-PT ngày 30/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
2. Phụ lục II: Bản án số 21/2019/DSST ngày 14/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
3. Phụ lục III: Quyết định sơ thẩm số 01/2022/QĐST-VDS ngày 17/1/2022 của Tòa án nhân dân huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc.
4. Phụ lục IV: Bản án số 05/2020/DS-PT ngày 26/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.
5. Phụ lục V: Bản án số 407/2020/DSPT ngày 21/10/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội.
6. Phụ lục VI: Bản án số 78/2023/DSPT ngày 14/7/2023 về tranh chấp thừa kế tài sản của tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

PHỤ LỤC I

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG BẢN ÁN 113/2019/DS-PT NGÀY 30/09/2019 VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ TÀI SẢN

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; xét xử phúc thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số 106/2019/TLPT-DS ngày 01 tháng 8 năm 2019 về “*Tranh chấp về thừa kế tài sản*”. Do Bản án Dân sự sơ thẩm số 12/2019/DS-ST ngày 24/5/2019 của Tòa án nhân thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 205/2019/QĐ-PT ngày 27/8/2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1964; Anh Huỳnh Đức D, sinh năm 1964. Địa chỉ: số nhà 729/2, đường T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn T1, sinh năm 1966. Địa chỉ: số 159/2 TQT, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*Giấy ủy quyền ngày 04/9/2019 được Văn phòng công chứng Đỗ Văn T2 chứng nhận, số công chứng: 10597, quyển số 07TP/CC-SCC/HĐGD*) (có mặt).

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1942. Địa chỉ: Số nhà 643A, đường T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình T3, sinh năm; 1975. Địa chỉ; 643A T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*Giấy ủy quyền ngày 23/9/2019 được Văn phòng công chứng Nguyễn Văn B chứng nhận, số công chứng: 3376, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD*).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

3.1. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1961. Địa chỉ: số nhà 70, đường PNT, phường L, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (có mặt)

3.2. Chị Nguyễn Thị T4, sinh năm 1967. Địa chỉ: Số nhà 643A đường T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình T3, sinh năm: 1975. Địa chỉ; 643A T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*Giấy ủy quyền ngày 23/9/2019 được Văn phòng công chứng Trần Quốc Ph chứng nhận, số công chứng: 013621, quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD*).

3.3. Anh Nguyễn Đình D1, sinh năm 1970. Địa chỉ: Số nhà 165/57, đường CQ, phường NCT, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đình T3, sinh năm: 1975. Địa chỉ; 643A T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*Giấy ủy quyền ngày 23/9/2019 được Văn phòng công chứng Trần Quốc Ph chứng nhận, số công chứng: 013621, quyển số 03TP/CC-SCC/HĐGD*).

3.4. Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1973. Địa chỉ: số nhà 54/4, đường LTK, phường 1, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm: 1961. Địa chỉ: phường LP, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*Giấy ủy quyền ngày 24/5/2019 được Văn phòng công chứng Quận H2 chứng nhận, số công chứng: 2924, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD*).

3.5. Anh Nguyễn Đình T3, sinh năm 1975. Địa chỉ: Số nhà 643A, đường T, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T3: Luật sư Quảng Khoa T5 – Công ty Luật TNHH MTV TC & A thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

3.6. **Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh BT.**

Địa chỉ: Số nhà 131, đường Quốc lộ 13, phường HBC, quận TĐ, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông hạm Văn D3, sinh năm: 1969. Chức vụ: Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Dương Minh T6, sinh năm: 1978 (có mặt).

3.7. **Chi cục thi hành án dân sự thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng**

Địa chỉ: Hẻm 206, đường HTK, phường 2, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt).

4. Người tham gia tố tụng khác:

4.1. Ông Lê Tấn Tr; Địa chỉ: Số 232 Đ, phường 2, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt).

4.2. Ông Mai Lê B, sinh năm 1975; Địa chỉ: Thôn 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt).

***Người kháng cáo:** Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T3.

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Theo đơn khởi kiện đề ngày 24/11/2014, đơn khởi kiện bổ sung ngày 31/12/2014, ngày 11/02/2015; đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện ngày 24/9/2018, ngày 02/10/2018, đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện ngày 10/5/2019 và những lời trình bày của nguyên đơn; người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn thể hiện như sau:

Ngày 06/8/2014, ông Nguyễn Đình M lập di chúc định đoạt $\frac{1}{2}$ (một nửa) tài sản là căn nhà diện tích 104m² gắn liền với quyền sử dụng đất diện tích 250m² thuộc thửa 340 tờ bản đồ F. 135.IV.C, địa chỉ thửa đất: Số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 201906, do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th là tài sản chung vợ chồng.

Trước đó, vào năm 2012, ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th có thể chấp căn nhà và đất nêu trên để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH HĐ (*viết tắt là công ty HĐ*); địa chỉ: Số nhà 35, đường 40, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh vay tiền tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh BT, quận TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh (*viết tắt là Ngân hàng BT*).

Ngày 20/8/2014, ông Nguyễn Đình M qua đời. Di chúc công bố vào ngày 18/10/2014 tại địa chỉ: Số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Do phát sinh tranh chấp nên ngày 24/11/2014, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố BL giải quyết: “*Chia tài sản chung sau ly hôn để khai nhận thừa kế theo di chúc*”.

Cũng trong thời gian này, Công ty HĐ không có khả năng trả nợ, nên Ngân hàng BT đã bán khoản nợ do Công ty HĐ vay cho Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ

chức tín dụng Việt Nam (*viết tắt là Công ty mua bán nợ*) và chuyển giao tài sản thế chấp bảo lãnh nêu trên cho Công ty mua bán nợ.

Công ty mua bán nợ đã khởi kiện Công ty HĐ ra Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để đòi nợ và yêu cầu xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh.

Ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm bằng bản án số 105/2017/KDTM- ST.

Ngày 08/6/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm bằng bản án số 565/2018/KDTM- T. Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, tài sản chung của ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th còn có diện tích đất nông nghiệp 415m² và tài sản là cây trồng gắn liền với đất thuộc thửa 410, tờ bản đồ F.135.IV.C đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH.075177, thửa đất tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Nay nguyên đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố BL giải quyết:

Công nhận Di chúc do ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp một phần đối với phần di sản thừa kế là $\frac{1}{2}$ (*một nửa*) tài sản là căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 201906 do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th đề nguyên đơn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc.

Chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với diện tích đất nông nghiệp 415m² và tài sản là cây trồng gắn liền với đất thuộc thửa 410, tờ bản đồ F.135.IV.C đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH.075177 tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*tài sản chung của ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th*).

2. Bị đơn bà Nguyễn Thị Th trình bày: Bà không công nhận bản di chúc do ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp. Bà Th đề nghị Tòa án chia di sản thừa kế của ông M theo pháp luật cho 06 người con của bà với ông M gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Đình D1, Nguyễn Thị H và Nguyễn Đình T3.

Riêng thửa đất 410, do bà Th có $\frac{1}{2}$ trong đó nên bà Th yêu cầu nhận tài sản bằng hiện vật. Mặt khác do các con bà Th (*trừ chị Ng ra*) đều thống nhất tặng cho lại bà Th phần di sản thừa kế được nhận theo pháp luật nên bà Th đề nghị Tòa án giao toàn bộ thửa đất 410 này cho bà Th được toàn quyền sử dụng, bà Th đồng ý thanh toán giá trị bằng tiền cho bà Ng theo kỹ phân tương ứng.

Về các nội dung khác thì bà Th nhất trí với trình bày của nguyên đơn.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Chị Nguyễn Thị M, chị Nguyễn Thị T4, anh Nguyễn Đình D1, chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Đình T3 thống nhất với ý kiến của bà Nguyễn Thị Th.

Ngân Hàng Nông Nghiệp và hát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh BT trình bày: Ngày 28/01/2019, Chi cục thi hành án dân sự quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định về việc ủy thác thi hành án cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng để thi hành đối với bên phải thi hành án là Công ty HĐ. Theo đó, các đồng thừa kế của ông Nguyễn Đình M có trách nhiệm bàn giao căn nhà để thực hiện thi hành án và $\frac{1}{2}$ giá trị tài sản thế chấp là nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 201906, do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn

Thị Th dùng để thanh toán khoản nợ vay của Công ty HĐ cho Ngân hàng BT. Hiện tại tài sản này vẫn chưa được phát mãi để thu hồi nợ cho ngân hàng. Do bận công việc nên đại diện Ngân hàng đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục vắng mặt.

Chi cục thi hành án dân sự thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng trình bày: Thực hiện công việc được ủy thác, ngày 14/3/2019, Chi cục thi hành án dân sự thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định thi hành án số 95/2019/QĐ- THADS đối với Công ty HĐ phải có trách nhiệm trả cho Agribank -Chi nhánh BT số tiền 3.287.833.000 đồng và tiền lãi phát sinh. Do Công ty HĐ không thanh toán nợ cho ngân hàng nên ngân hàng yêu cầu phát mãi nhà đất tại số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố BL đang xử lý việc thi hành án theo quy định của pháp luật. Do bận công việc nên đại diện Chi cục thi hành án dân sự thành phố BL đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục vắng mặt.

4. Người làm chứng:

Ông Lê Tấn Tr trình bày: Ngày 06/8/2014, ông Nguyễn Đình M có đến Văn phòng Luật sư Lê Tấn Tr; địa chỉ: Số 232, đường Đ , phường 2, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*lúc đó ông Tr đang làm trưởng văn phòng*) nhờ ông tư vấn lập di chúc. Ông M đưa toàn bộ hồ sơ liên quan để ông tư vấn. Sau khi tư vấn xong, ông M nhờ ông Tr soạn thảo nội dung di chúc và ông Tr đã soạn thảo nội dung di chúc theo ý nguyện của ông M. Trong khi soạn thảo bản di chúc ông Tr có giải thích cho ông M biết để bản di chúc có giá trị pháp lý thì phải có từ 02 người làm chứng trở lên. Lúc này có ông Mai Lê B (*ông B và ông Tr là thành viên góp vốn Công ty TNHH tư vấn xây dựng VTP*) đến gặp ông Tr để bàn việc công ty. Ông Tr hỏi ông M có đồng ý để ông B là người làm chứng hay không thì ông M đồng ý. Sau khi soạn thảo xong bản di chúc, ông Tr in ra và đưa cho ông M đọc lại, ông M đọc xong, ông Tr hỏi ông M có cần sửa đổi hay bổ sung gì không, ông M trả lời không. Ông Tr in thêm 01 bản nữa vì ông M yêu cầu lập 02 bản có nội dung giống nhau và đưa cho ông M bản thứ hai có nội dung giống bản thứ nhất. Sau khi đọc xong ông Tr nói ông M ký và ghi rõ họ tên vào hai bản di chúc. Trong khi ký, ông Tr thấy tay ông M run rẩy nên chữ viết không được rõ ràng. Vì vậy, ông Tr nói ông M phải điểm chỉ vào hai bản di chúc. Sau đó ông Tr ký vào hai bản di chúc với tư cách là người làm chứng thứ nhất, ông Tr đưa ông B ký vào hai bản di chúc với tư cách là người làm chứng thứ hai. Ký xong ông Tr giao hai bản di chúc cho ông M và ông M ra về. Ông Tr tiếp tục làm việc với ông B.

Ông Mai Lê B trình bày: Vào khoảng 09 giờ sáng ngày 06/8/2018 ông B có đến nhà ông Lê Tấn Tr, địa chỉ số 232, đường Đ , phường 2, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng để làm việc liên quan đến công việc của Công ty TNHH tư vấn xây dựng VTP vì ông B và ông Tr là thành viên góp vốn công ty. Khi ông B vào nhà ông Tr thì đã thấy ông Tr đang làm việc cùng ông Nguyễn Đình M về việc tư vấn lập di chúc cho ông M. Trong lúc chờ đợi để làm việc với ông Tr thì ông M có nhờ làm chứng giúp ông về việc lập di chúc vì nghe ông Tr tư vấn cho ông việc lập di chúc cần phải có hai người làm chứng thì mới có giá trị pháp lý và ông B đã đồng ý. Sau khi di chúc được ông Tr soạn thảo xong, có đưa cho ông M xem, ông Tr có hỏi ông M cần bổ sung, chỉnh sửa gì không thì ông M nói là không. Ông Tr đã in di chúc thành hai bản đưa cho ông M ký. Trong lúc ký bản di chúc vì tay ông M run rẩy nên chữ ký ngoằn ngoèo không ngay thẳng nên ông Tr yêu cầu ông M điểm chỉ. Sau khi ông M ký và điểm chỉ xong ông Tr ký và đưa cho ông B đọc nội dung làm chứng và ký vào bản di chúc người làm chứng. Hai bản di chúc được đưa cho ông M và ông M xin chào ra về. Ông B ở lại làm việc với ông Tr đến cuối buổi.

Về chi phí tố tụng: chi phí giám định chữ viết hết 9.180.000đ; chi phí đo vẽ, xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá hết 5.827.100đ. Tại phiên tòa sơ thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Minh đồng ý chịu toàn bộ chi phí giám định chữ viết (*đã quyết toán xong*). Nguyên đơn đồng ý chịu toàn bộ chi phí đo vẽ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá (*đã quyết toán xong*).

Tòa án đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng không thành.

Tại bản án sơ thẩm số 12/2019/DS-ST ngày 24/5/2019 của Tòa án nhân thành phố BL đã xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vợ chồng bà Nguyễn Thị Ng và ông Huỳnh Đức D về việc “*Tranh chấp về thừa kế tài sản*” với bị đơn bà Nguyễn Thị Th.

- Xác định hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Đình M gồm có 06 người con đẻ của ông M với bà Th là: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Đình D1, Nguyễn Thị H và Nguyễn Đình T3.

- Xác định di sản thừa kế của ông Nguyễn Đình M là $\frac{1}{2}$ (*một nửa*) căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ: số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*thửa 340 tờ bản đồ F.135.IV.C, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 201906, do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th*); và $\frac{1}{2}$ (*một nửa*) diện tích đất nông nghiệp + tài sản là cây trồng gắn liền với đất (*thửa 410, tờ bản đồ F.135.IV.C đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH. 075177 tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th*).

- Công nhận di chúc ông M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp một phần đối với phần di sản thừa kế là $\frac{1}{2}$ (*một nửa*) tài sản bằng hiện vật là căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 201906, do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th để nguyên đơn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc.

- Ông D và bà Ng được khai nhận di sản thừa kế khi Công ty TNHH HD trả hết nợ cho Agribank, lúc đó Agribank có trách nhiệm giải chấp, trả lại cho bà Nguyễn Thị Th và nguyên đơn bản chính giấy tờ tài sản thế chấp được liệt kê tại mục 1.2 Điều 2 của Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba số 6110-LCL-201200423 ngày 17/9/2012 hoặc khi cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền phát mãi tài sản nêu trên thì nguyên đơn được nhận $\frac{1}{2}$ giá trị bằng tiền.

- Giao cho bà Nguyễn Thị Th được quyền sử dụng diện tích đất nông nghiệp 415m² và được quyền sở hữu tài sản là cây trồng gắn liền với đất thuộc thửa 410, tờ bản đồ F.135.IV.C đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH. 075177 tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Th có trách nhiệm đăng ký biến động về đất đai theo quy định của pháp luật.

Buộc bà Nguyễn Thị Th có trách nhiệm thanh toán cho các đồng thừa kế thứ nhất của ông M gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Đình D1, Nguyễn Thị H và Nguyễn Đình T3 mỗi người số tiền là 138.585.750 đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo, trách nhiệm thi hành án của các bên đương sự.

Ngày 05/6/2019, nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ng kháng cáo yêu cầu được hưởng phần di sản thừa kế bằng hiện vật đối với diện tích đất nông nghiệp, cụ thể (415m² : 2 phần) : 6 người = 34,5m².

Ngày 07/6/2019, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T3 kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm không công nhận bản di chúc lập ngày 06/8/2014 của ông Nguyễn Đình M là hợp pháp.

Tại phiên tòa hôm nay, Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu được chia 34,5m² đất nông nghiệp. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T3 đề nghị Hội đồng xét xử không công nhận bản di chúc lập ngày 06/8/2014 của ông Nguyễn Đình M là hợp pháp.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến về việc chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại giai đoạn phúc thẩm cũng như tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời nêu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng theo hướng: Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ng về việc yêu cầu được hưởng phần di sản thừa kế bằng hiện vật đối với diện tích đất nông nghiệp 415m² và tài sản là cây trồng gắn liền với đất tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Đình T3, không công nhận Di chúc do ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu công nhận Di chúc do ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp một phần đối với phần di sản thừa kế là $\frac{1}{2}$ (một nửa) tài sản là căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tọa lạc số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 201906 do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th để nguyên đơn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc. Đồng thời, chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với diện tích đất nông nghiệp 415m² và tài sản là cây trồng gắn liền với đất đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH. 075177 tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (tài sản chung của ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th). Bị đơn không công nhận Di chúc do ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp, đồng ý chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với diện tích đất nông nghiệp 415m² thừa 410, đề nghị được nhận toàn bộ diện tích này và thanh toán bằng giá trị cho các đồng thừa kế còn lại. Vì vậy đã dẫn đến tranh chấp. Cấp sơ thẩm xác định “*Tranh chấp về thừa kế tài sản*” là đúng pháp luật.

[2] Qua xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ thì thấy rằng:

[2.1] Đối với kháng cáo của nguyên đơn:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định: “*Thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch là đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu là 500 m²*” “1. Các thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 3 Quyết định này phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải tiếp giáp với đường đi (hoặc quy hoạch đường đi) có chiều rộng mặt đường $\geq 3,5$ m;

...

3. Việc tách thửa để phân chia tài sản có liên quan đến quyền sử dụng đất do thừa kế..... nếu không đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì không được tách thửa mà phân chia theo giá trị quyền sử dụng đất hoặc đồng quyền sử dụng”

Chị Ng yêu cầu được hưởng phần di sản thừa kế bằng hiện vật đối với diện tích đất nông nghiệp, cụ thể (415m² : 2 phần) : 6 người = 34,5m² là không phù hợp với quy hoạch và hạn mức sử dụng đất. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của chị Ng.

[2.2] Đối với kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T3 thì thấy rằng:

Theo Khoản 3 Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định “*Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.*” Nội dung bản di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho người thừa kế, do vậy để di chúc có hiệu lực pháp luật thì di chúc được thể hiện bằng văn bản phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, hình thức theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định số 2671/GĐ-C54 ngày 27/11/2015 của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (BL157) và bản kết luận giám định số 2067/C54B ngày 06/10/2016 của hân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh (BL 261) đều kết luận “*Không đủ cơ sở/không kết luận được chữ ký và chữ viết mang tên Nguyễn Đình M trên tờ di chúc lập ngày 06/8/2014 so với chữ viết và chữ ký trên các mẫu so sánh có phải do cùng một người ký, viết ra hay không*”. Cấp sơ thẩm căn cứ vào biên bản xác minh và công văn của Bệnh viện ung bướu trong đó thể hiện việc ông M điều trị ngoại trú thời gian trước ngày 06/8/2014, từ ngày 07/8/2014 ông M nhập viện thì vẫn tỉnh táo, đi lại được (BL176) để xác định ông M minh mẫn, tỉnh táo khi lập di chúc và chấp nhận bản di chúc lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp là chưa đủ cơ sở vững chắc.

Như vậy, bản di chúc lập ngày 06/8/2014 không đảm bảo đầy đủ về mặt hình thức, nội dung theo quy định và cũng không đủ căn cứ để xem xét đối với chữ ký và chữ viết trên di chúc, nên xét yêu cầu kháng cáo của anh Nguyễn Đình T3 là có cơ sở chấp nhận, không công nhận bản di chúc lập ngày 06/8/2014 của ông Nguyễn Đình M là hợp pháp. Do bản di chúc không hợp pháp nên được coi là không có di chúc, khi đương sự khởi kiện thì giải quyết chia di sản thừa kế theo pháp luật.

Quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm, bà Th có yêu cầu chia di sản thừa kế của ông M theo pháp luật đối với tài sản là nhà và đất tại số 643A, đường TP. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chưa thụ lý đối với yêu cầu này của bà Th nên không có cơ sở để cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết. Trong trường hợp các đương sự có yêu cầu chia thừa kế đối với tài sản trên thì được quyền khởi kiện bằng vụ án khác.

Từ những phân tích trên thấy rằng, không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn chị Ng, chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Anh T3, sửa bản án sơ thẩm theo hướng đã nhận định là phù hợp.

[3] Về án phí sơ thẩm: Nguyên đơn phải chịu án phí đối với phần yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận. Bị đơn bà Th là người cao tuổi nên được miễn án phí theo quy định. Các đồng thừa kế phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên giá trị di sản được nhận.

[4] Về án phí phúc thẩm: Chị Ng phải chịu án phí phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận. Anh T3 không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ng, chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Đình T3. Sửa bản án dân sự sơ thẩm, xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vợ chồng chị Nguyễn Thị Ng và anh Huỳnh Đức D về việc “*Tranh chấp về thừa kế tài sản*” với bị đơn bà Nguyễn Thị Th.

- Xác định hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Đình M gồm có 06 người con đẻ của ông M với bà Th là: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Đình D1, Nguyễn Thị H và Nguyễn Đình T3.

- Xác định di sản thừa kế của ông Nguyễn Đình M là ½ (một nửa) căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (*thửa 340 tờ bản đồ F.135.IV.C, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 201906, do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th*); và ½ (một nửa) diện tích đất nông nghiệp + tài sản là cây trồng gắn liền với đất (*thửa 410, tờ bản đồ F.135.IV.C đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH. 075177 tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th*).

- Giao cho bà Nguyễn Thị Th được quyền sử dụng diện tích đất nông nghiệp 415m² và được quyền sở hữu tài sản là cây trồng gắn liền với đất thuộc thửa 410, tờ bản đồ F.135.IV.C đã được Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp năm 1996, giấy chứng nhận số: HH. 075177 tại địa chỉ số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Th có trách nhiệm đăng ký biến động về đất đai theo quy định của pháp luật.

Buộc bà Nguyễn Thị Th có trách nhiệm thanh toán cho các đồng thừa kế thứ nhất của ông M gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Đình D1, Nguyễn Thị H và Nguyễn Đình T3 mỗi người số tiền là 138.585.750đ (*một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn, bảy trăm năm mươi đồng*).

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc công nhận di chúc ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 là hợp pháp một phần đối với phần di sản thừa kế là ½ (*một nửa*) tài sản bằng hiện vật là căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Số 643A, đường TP, phường B, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AD 201906, do Ủy ban nhân dân thị xã BL cấp ngày 06/3/2006 đứng tên ông Nguyễn Đình M và bà Nguyễn Thị Th.

Tuyên bố di chúc do ông Nguyễn Đình M lập ngày 06/8/2014 tại Văn phòng luật sư Lê Tấn Tr bị vô hiệu.

3. Về án phí: Nguyên đơn chị Nguyễn Thị Ng, anh Huỳnh Đức D phải chịu 300.000đ án phí dân sự thẩm và 300.000đ án phí dân sự phúc thẩm nhưng được trừ vào số tiền 30.800.000đ tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001257 ngày 08/4/2015, số 0002628 ngày 11/10/2018 và số 0005481 ngày 17/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BL. Hoàn trả cho chị Ng, anh D số tiền 30.200.000đ tạm ứng án phí.

Miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho bị đơn bà Nguyễn Thị Th.

Buộc các đồng thừa kế thứ nhất của ông M gồm Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Ng, Nguyễn Thị T4, Nguyễn Đình D1, Nguyễn Thị H và Nguyễn Đình T3 mỗi người phải nộp 6.929.287đ án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho anh Nguyễn Đình T3 số tiền 300.000đ tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0005497 ngày 20/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố BL.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

PHỤ LỤC II

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 21/2019/DS-ST
Ngày 14-11-2019
V/v tranh chấp về thừa kế tài sản

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

<i>Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:</i>	Ông Đào Minh Đa
<i>Các Hội thẩm nhân dân:</i>	Ông Nguyễn Thanh Điền Ông Huỳnh Văn Diễm

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Kim Thoa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Xông – Kiểm sát viên.

Trong các ngày 13 và 14/11/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 28/2019/TLST-DS ngày 23/4/2019 về “tranh chấp thừa kế tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 36/2019/QĐST-DS ngày 22/10/2019 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Lê Văn T, sinh năm 1964; địa chỉ: 4/3, khu phố Đ, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Lê Trần Vân A; địa chỉ: Số 119, đường T2, phường P, thành phố T3, tỉnh Bình Dương (văn bản ủy quyền ngày 09/4/2019); có mặt.

- Bị đơn: Bà Lê Ngọc M11, sinh năm 1966; địa chỉ: Số 28A/1B, khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Lê Văn H1, sinh năm 1957; quốc tịch: Hoa Kỳ
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết O, sinh năm 1959; quốc tịch: Hoa Kỳ

Cùng địa chỉ thường trú: 1041 T4, T5, Hoa Kỳ; địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: 4/3, khu phố Đ, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương;

Người đại diện hợp pháp của ông H: Chị Đàm Thị Minh T6, sinh năm 1995; địa chỉ: Số 119, đường T2, phường P, thành phố T3, tỉnh Bình Dương (văn bản ủy quyền ngày 23/4/2019); có mặt.

Người đại diện hợp pháp của bà O: Chị Nguyễn Ngọc Ái N, sinh năm 1999; địa chỉ: Số 119, đường T2, phường P, thành phố T3, tỉnh Bình Dương (văn bản ủy quyền ngày 10/6/2019); có mặt.

3. Bà Vương Thị M2, sinh năm 1979; địa chỉ: 12/2, khu phố B1, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

4. Chị Lê Ngọc T7, sinh năm 1992; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

5. Anh Lê Hoàng S, sinh năm 1994; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Cùng địa chỉ: 4/3, khu phố Đ, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo nội dung các đơn khởi kiện ngày 09/4/2019, lời khai trong quá trình tố tụng, nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày:

Vợ chồng cụ Lê Văn X chết năm 2015 và cụ Nguyễn Thị H2, chết năm 2002 có 03 con chung:

1. Ông Lê Văn H1, sinh năm 1957;

2. Ông Lê Văn T, sinh năm 1964;

3. Bà Lê Ngọc M1, sinh năm 1966.

Ngoài những người con nêu trên thì cụ X và cụ H2 không có con riêng, con nuôi; cha mẹ cụ X, cụ H2 đều đã chết trước cụ X, cụ H2.

Cụ X, cụ H2 có để lại quyền sử dụng đất diện tích 1.710,39 m² (trong đó có 300m² đất thổ cư) thửa đất số A và B, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Cơ quan U huyện (nay là thị xã) T1 cấp ngày 25/7/1994 (đổi lần 1, được cấp lại ngày 24/01/1998 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ vào sổ: C/SDĐ/CQ-BH, thửa đất mới số D và E, diện tích 1.945m²; đổi lần 2, được cấp lại ngày 26/01/2007 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ vào sổ: K/BH, thửa đất số D và E, diện tích 1.739m²).

Năm 2000, khi cụ H2 còn sống, cụ X và cụ H2 chuyển nhượng cho nhiều người (thửa đất số E), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và một phần diện tích đất bị giải tỏa làm đường. Ngoài ra, cụ X và cụ H2 tặng cho con gái là bà Lê Ngọc M1 diện tích 345m² (có 80m² đất thổ cư) thuộc một phần thửa E (mặt tiền tỉnh lộ I), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận cho bà M1. Sau khi chuyển nhượng đất, cụ X và cụ H2 xây nhà trọ (10 căn) trên thửa đất số E và giao cho bà M1 quản lý, thu tiền trọ cho đến nay.

Ông T sống chung với cụ H2 và cụ X tại thửa đất số D. Sau khi cụ H2 chết (năm 2000) thì vợ chồng ông H, bà O (định cư tại Hoa Kỳ) gửi tiền về cho cụ X sinh sống và giúp cụ X xây lại nhà (01 trệt, 01 lầu như hiện tại) trên thửa

đất số D. Ngày 17/8/2002, cụ X lập di chúc để lại cho vợ chồng ông H, bà O thừa đất số D và nhà gắn liền đất, nội dung di chúc có ghi: “...Nguyên tôi có thừa đất thổ cư với tổng diện tích 660m² thừa đất số...tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1, tỉnh Bình Dương có tứ cận: Đông giáp bờ sáu ghé, tây giáp đường xe bò, nam giáp tỉnh lộ I, bắc giáp bà T8; ... đưa con lớn đã xuất cảnh sang nước ngoài hiện nó cấp dưỡng và lo toàn bộ cho gia đình, tôi và đưa con thứ ba hiện đang chung sống trong gia đình.. nay tôi đã lớn tuổi thường hay bệnh đau không biết số phận ra sao nên tôi giao lại thừa đất và nhà cửa nói trên cho vợ chồng con trai lớn Lê Văn H và Nguyễn Thị Tuyết O...”

Hiện nay, diện tích đất còn lại theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2007 (đăng ký biến động ở trang 4) thửa D diện tích 553m² (có 73,5m² đất thổ cư, nhà 01 trệt, 01 lầu trên đất do ông T quản lý); thửa E diện tích 193,7m² (44m² đất thổ cư, có 10 căn nhà trọ do bà M1 quản lý). Nguyên đơn thống nhất theo kết quả đo đạc ngày 02/10/2019 của Văn phòng Đo tỉnh Bình Dương; thửa D diện tích 547,7m²; thửa E diện tích 206,7m² (trong đó có 1,1m² liền ranh và chưa rõ ràng về ranh giới với đất người khác nên nguyên đơn không tranh chấp); thống nhất kết quả định giá ngày 11/9/2019.

Nguyên đơn đồng ý tính giá trị nhà xây dựng trên thửa đất E (xây dựng sau khi cụ H2 chết) là tài sản chung của cụ X và cụ H2; xác định cụ X lập di chúc trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt; chữ viết, chữ ký trong di chúc đúng là của cụ X. Tuy nhiên, tài sản là của chung cụ X và cụ H2 nên yêu cầu cầu Tòa án tuyên vô hiệu 1/2 di chúc liên quan đến tài sản của cụ H2, 1/2 di chúc liên quan đến tài sản của cụ X đối với nhà và đất (thửa D) có hiệu lực. cụ X và cụ H2 không để lại nghĩa vụ về tài sản sau khi chết, nguyên đơn không yêu cầu xem xét công sức bảo quản di sản, chi phí tang lễ, mồ mả của cụ X, cụ H2; đề nghị Tòa án chia di sản thừa kế của cụ X và cụ H2 theo di chúc và theo pháp luật.

Theo bản tự khai ngày 17/6/2019, ngày 09/8/2019 và ngày 04/11/2019, bị đơn bà M1 trình bày:

Bị đơn bà M1 thống nhất với nguyên đơn về quan hệ huyết thống và tài sản thừa kế do cụ X, cụ H2 để lại. Bà M1 được cụ X, cụ H2 cho diện tích đất 361m² của thửa đất số E; ông T cũng được cụ X, cụ H2 cho 01 phần đất ở nơi khác vì không thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cụ X nên bà M1 không rõ; ông H ở Hoa Kỳ nên chưa được cho đất.

Khi còn sống, cụ X, cụ H2 đã chuyển nhượng cho nhiều người thửa đất số E, diện tích còn lại hơn 200m² và có nhà trọ trên đất mà Tòa án có xuống đo đạc; nhà trọ do bà M1 quản lý, khai thác từ khi xây dựng cho đến nay. Nhà ở của cụ X (trên thửa đất số D) do ông H gửi tiền về xây nhưng là nhà thờ nên không đồng ý chia thừa kế.

Đối với di chúc: Đúng là chữ viết, chữ ký của cụ X nhưng bà M1 không rõ, không đồng ý chia thừa kế; không có yêu cầu gì khác.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Người đại diện hợp pháp của Ông Lê Văn H1 và người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị Tuyết O thống nhất với ý kiến và yêu cầu chia thừa kế của nguyên đơn ông Lê Văn T.

Bà Vương Thị M2, chị Lê Ngọc T7, anh Lê Hoàng S (vợ và con ông Lê Văn T) thống nhất ý kiến và yêu cầu chia thừa kế của nguyên đơn ông Lê Văn T.

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn ông Lê Văn T trình bày: Thống nhất với lời trình bày của người đại diện của ông T đã khai trong quá trình tố tụng, khi cụ X còn sống có cho riêng ông T 400m² đất ở nơi khác (ông T đã chuyển nhượng cho người khác), ông H chưa được cho đất.

Người đại diện hợp pháp của ông T yêu cầu Tòa án chia thừa đất số D và tài sản trên đất cho ông T và vợ chồng ông H, bà O đồng sở hữu, đồng thời xác định tỷ lệ sở hữu cho từng người, trường hợp giá trị tài sản nhận nhiều hơn phần chia cho bà M1 (thừa E và tài sản gắn liền) thì ông H thanh toán giá trị chênh lệch cho bà M1.

Người đại diện hợp pháp của ông H thống nhất ý kiến và yêu cầu của ông T.

Người đại diện hợp pháp của bà O thống nhất ý kiến và yêu cầu của ông T; phần thừa kế của bà O được hưởng theo di chúc bà O tự nguyện cho lại ông H (chồng bà O).

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương:

Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Các đương sự đều thống nhất về quan hệ hôn nhân và huyết thống, và di sản do cụ Lê Văn X và cụ Nguyễn Thị H2 để lại. Di chúc do cụ Lê Văn X lập ngày 17/8/2002 là có hiệu lực 1/2 đối với di sản do cụ Lê Văn X để lại về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa D, tờ bản đồ H (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m²; đo đạc thực tế 547,4m² (có 73,5m² đất thổ cư) tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007. Tại phiên tòa, nguyên đơn và người đại diện hợp pháp của ông H, bà O đề nghị Tòa án giao kỹ phần thừa kế của bà O theo di chúc cho ông H; ông H thanh toán chênh lệch cho bị đơn bà M1; giao cho ông T, ông H là đồng sở hữu đất và nhà gắn liền thửa đất E và ghi rõ tỷ lệ sở hữu của từng người.

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của ông T, ông H, bà O, tuyên vô hiệu 1/2 di chúc liên quan đến tài sản của cụ H2, 1/2 di chúc liên quan đến tài sản của cụ X đối với nhà và đất (thửa D) có hiệu lực và chia thừa kế tài sản còn lại của cụ X, cụ H2 theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tố tụng: Nguyên đơn ông Lê Văn T khởi kiện bị đơn bà Lê Ngọc M1 yêu cầu chia thừa kế tài sản; vụ án có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ông Lê Văn H1, bà Nguyễn Thị Tuyết O cùng cư trú tại Hoa Kỳ nên theo quy định tại Điều 26, điểm c khoản 1 Điều 37, Điều 469 của Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Quá trình tố tụng, bị đơn bà M1 có mặt và có ý kiến tại phiên đối chất, xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạc và định giá, có mặt tại buổi họp công khai chứng cứ và hòa giải nhưng đều không ký các văn bản tố tụng. Tuy nhiên, toàn bộ các văn bản tố tụng bà M1 yêu cầu được nhận bản sao để có ý kiến chính thức bằng văn bản độc lập của riêng cá nhân bà M1, Tòa án đã cấp toàn bộ các văn bản tố tụng, các chứng cứ của vụ án cho bà M1, bà M1 không khiếu nại hành vi tố tụng, các văn bản tố tụng của Tòa án; do đó, quyền và nghĩa vụ của bà M1 trong quá trình tố tụng đối với vụ án được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Bà M1 đã có ý kiến bằng văn bản và ý kiến của bà M1 tại phiên tòa đều thống nhất cơ bản với ý kiến của nguyên đơn; về di chúc bà M1 thừa nhận do cụ X viết nhưng không hiểu, nhà để thờ cúng nên không đồng ý chia thừa kế.

[2] Về nội dung:

Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thống nhất về những người thừa kế ở hàng thứ nhất của cụ X, cụ H2 và thống nhất về di sản do cụ X, cụ H2 để lại.

Như vậy, cụ Xê và cụ H2 có 02 người con là 03 thừa kế ở hàng thứ nhất gồm: Ông Lê Văn H1, ông Lê Văn T và bà Lê Ngọc M1.

Tài sản do cụ H2, cụ X để lại là quyền sử dụng đất diện tích 1.710,39m² (trong đó có 300m² đất thổ cư) tại ấp Đ, xã B, huyện T1 nay thuộc khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1, tỉnh Bình Dương. Quyền sử dụng đất 1.710,39m² được cấp cho cá nhân cụ Lê Văn X theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 25/7/1994 (thửa đất số A và B); cụ X đăng ký đổi lại giấy chứng nhận và được cấp lại ngày 24/01/1998 (số vào sổ: C/SDĐ/CQ-BH, thửa đất số D và E, diện tích 1.945m²) và cấp đổi lại lần hai ngày 26/01/2007 (số vào sổ: K/BH, thửa đất số D và E, diện tích 1.739m²). Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã T1 cung cấp toàn bộ hồ sơ cấp đất nhưng không có ý kiến trả lời Tòa án lý do vì sao quyền sử dụng đất của cá nhân cụ X thành quyền sử dụng đất của hộ cụ X. Hồ sơ cấp đất cho cụ X thể hiện: 02 lần cấp đổi lại năm 1998 và 2007, cơ quan có thẩm quyền ghi cấp đất cho “hộ ông Lê Văn X” nhưng trong hồ sơ không có văn bản thỏa thuận của “hộ ông Lê Văn X” hoặc ý chí của “ông Lê Văn X giao đất lại cho hộ gia đình” là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Tuy nhiên, trong vụ án này các đương sự (đồng thời là thành viên hộ gia đình ông Lê Văn X) không tranh chấp về quyền sử dụng đất của hộ gia đình và đều thống nhất quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng cụ X, cụ H2 là đúng bản chất của quan hệ tài sản và phù

hợp với pháp luật nên Tòa án ghi nhận quyền sử dụng đất tranh chấp là di sản thừa kế do cụ X, cụ H2 để lại.

Nhà trên đất (02 thửa D và E) các đương sự thống nhất là tài sản chung của cụ X, cụ H2 nên Tòa án ghi nhận.

[3] Các đương sự thống nhất khi cụ H2 còn sống, cụ X và cụ H2 chuyển nhượng cho nhiều người (thửa đất số E), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và một phần diện tích đất bị giải tỏa làm đường. Ngoài ra, cụ X và cụ H2 tặng cho con gái là bà Lê Ngọc M1 diện tích 361m² thuộc một phần thửa E (mặt tiền tỉnh lộ I), đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận cho bà M1, số vào sổ: V/BH ngày 25/3/2008 (diện tích theo giấy chứng nhận 361m²). Sau khi chuyển nhượng đất, cụ X và cụ H2 xây nhà trọ (10 căn) trên thửa đất số E và cho bà M1 quản lý, thu tiền trọ cho đến nay. Ông T sống chung với cụ H2 và cụ X tại thửa đất số D. Sau khi cụ H2 chết (năm 2000) thì vợ chồng ông H, bà O (định cư tại Hoa Kỳ) gửi tiền về cho cụ X sinh sống và giúp cụ X xây lại nhà (01 trệt, 01 lầu như hiện tại) trên thửa đất số D. Tại biên bản xác minh ngày 12/11/2019, Chi nhánh Văn phòng Đ thị xã T1 xác định: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp ngày 26/01/2007, thửa đất E có 149,7m² đất nông nghiệp và 44m² đất ở; thửa đất E có 479,5m² đất nông nghiệp và 73,5m² đất ở.

Hiện nay, các đương sự thống nhất di sản thừa kế do cụ X và cụ H2 để lại được đo đạc, định giá như sau:

[4] Thửa đất E, diện tích 205,6m² (có 44m² đất thổ cư), trên đất có 10 căn phòng trọ (bà M1 quản lý, cho công nhân thuê) được định giá như sau:

Đất thổ cư: 44m² x 15.000.000 đồng/m² = 660.000.000 đồng; đất nông nghiệp: 205,6m² - 44m² = 161,6m² x 12.000.000 đồng/m² = 1.939.200.000 đồng.

10 căn nhà trọ: 145,6m² x 2.213.400 đồng/m² x 45% = 145.021.968 đồng; sân xi măng trị giá 6.708.000 đồng.

Tổng giá trị nhà, đất (thửa đất số E) = 2.750.929.968 đồng.

[5] Thửa đất E, diện tích 547,4m² (có 73,5m² đất thổ cư), trên đất có nhà cấp III (ông T ở và quản lý) được định giá như sau:

Đất thổ cư: 73,5m² x 35.000.000 đồng/m² = 2.572.500.000 đồng.

Đất nông nghiệp và hành lang đường bộ: 547,4m² - 73,5m² = 473,9m² x 31.000.000 đồng/m² = 14.690.900.000 đồng.

Nhà: 214,6m² x 2 = 429,2m² x 8.720.000 đồng/m² x 50% = 1.871.312.000 đồng.

Mái che 52,5m² + hàng rào + cổng sắt = 165.719.500 đồng.

Tổng giá trị nhà, đất, tài sản trên đất (thửa đất số D) là 19.300.431.500 đồng.

[6] Tổng giá trị di sản do cụ X, cụ H2 để lại bằng 22.051.361.468 đồng; các đương sự đều thống nhất là tài sản chung của cụ H2, cụ X; không có chứng cứ cũng như ý kiến nào khác xác định công sức của hai cụ đối với khối tài sản chung là khác nhau; do đó, theo quy định của pháp luật, cụ X và cụ H2, mỗi người để lại di sản trị giá 11.025.680.734 đồng.

[7] Cụ H2 chết trước cụ X, nên phần di sản của cụ H2 được chia cho 04 thừa kế (cụ X và 03 người con ông H, ông T và bà M1), mỗi thừa kế được hưởng di sản trị giá: 2.756.420.183 đồng. Do đó, phần di sản cụ X để lại trị giá: 13.782.100.917 đồng.

[8] Di chúc do cụ X lập ngày 17/8/2002, cụ X lập di chúc với nội dung như sau: “...*Nguyên tôi có thửa đất thổ cư với tổng diện tích 660m² thửa đất số ...tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1, tỉnh Bình Dương có tứ cận: Đông giáp bờ sáu nghé, tây giáp đường xe bò, nam giáp tỉnh lộ I, bắc giáp bà T8; ... đưa con lớn đã xuất cảnh sang nước ngoài hiện nó cấp dưỡng và lo toàn bộ cho gia đình, tôi và đưa con thứ ba hiện đang chung sống trong gia đình.. nay tôi đã lớn tuổi thường hay bệnh đau không biết số phận ra sao nên tôi giao lại thửa đất và nhà của nói trên cho vợ chồng con trai lớn Lê Văn H và Nguyễn Thị Tuyết O...*”. Di chúc do cụ X viết ngày 17/8/2002 nhưng cơ quan U xã (nay là phường) B2, huyện (nay là thị xã) T1 xác nhận ngày 16/8/2002 là có sai sót. Kết quả xác minh của Tòa án tại biên bản ngày 16/10/2019, người có thẩm quyền đã xác nhận chính họ ký xác nhận trong di chúc, thời điểm xác nhận di chúc, cụ X hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, ngày tháng năm ghi trong di chúc do cán bộ văn phòng ghi nên không biết có sai sót. Theo yêu cầu của Tòa án về việc cung cấp chứng cứ là hồ sơ, sổ sách lưu trữ có nội dung xác nhận liên quan đến di chúc, tại Văn bản số G/UBND-VX ngày 12/9/2019, Cơ quan U phường B2 trả lời Tòa án là không tìm ra hồ sơ lưu trữ. Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, 03 thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất (các đương sự trong vụ án) của cụ X đều khai nhận đúng chữ viết, chữ ký của cụ X trong di chúc, thời điểm lập di chúc năm 2002 sức khỏe cụ X rất tốt, tinh thần sáng suốt, minh mẫn....Do đó, có căn cứ xác định di chúc do cụ X lập ngày 17/8/2002 thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của cụ X. Nội dung di chúc chỉ đề cập đến nhà và thửa đất số D do cụ X đang ở, nhà và tài sản gắn liền thửa đất E là tài sản chung của cụ X và cụ H2 nên di chúc chỉ có giá trị đối với tài sản của cụ X (tức là có giá trị đối với 1/2 đất và tài sản khác gắn liền của thửa đất số D).

Vậy, vợ chồng ông H và bà O được hưởng di sản thừa kế của cụ X theo di chúc là giá trị của 1/2 nhà, đất và tài sản khác gắn liền của thửa đất số D là: 19.300.431.500 đồng: 2 = 9.650.215.750 đồng; phần di sản còn lại của cụ X (đất và tài gắn liền thửa đất số E và hưởng phần thừa kế từ cụ H2) là: 13.782.100.917 đồng - 9.650.215.750 đồng = 4.131.885.167 đồng.

[9] Cụ X, cụ H2 không để lại nghĩa vụ về tài sản, các đương sự không yêu cầu tính bất kỳ chi phí nào khác trước khi chia thừa kế; do đó phần di sản của cụ X và cụ H2 để lại trị giá: 2.756.420.183 đồng x 3 + 4.131.885.167 đồng = 12.401.145.716 đồng, được phân chia theo quy định của pháp luật thừa kế cho

03 kỷ phần ông H, bà M1 và ông T, mỗi kỷ phần trị giá 4.133.715.238 đồng. Bà M1 đang quản lý đất và nhà trọ trên đất của thửa đất E nên giao cho bà M1 được quyền quản lý đất và sở hữu nhà trọ trên đất của thửa đất E (giá trị tài sản bà M1 nhận là 2.750.929.968 đồng, bà M1 còn được nhận thêm là 1.382.785.270 đồng); giao cho vợ chồng ông H, bà O và ông T đồng sở hữu nhà và quản lý sử dụng thửa đất số D là phù hợp với thực tế sử dụng.

[10] Tại phiên tòa: Người đại diện hợp pháp của bà O tự nguyện cho lại ông H kỷ phần thừa kế bà O hưởng theo di chúc của cụ X; người đại diện hợp pháp của ông T và người đại diện hợp pháp của ông H thống nhất ông H thanh toán giá trị chênh lệch về tài sản cho bà M1, theo đó tăng thêm tỷ lệ sở hữu tài sản của ông H trong phần tài sản chung giữa ông H và ông T. Xét sự tự nguyện của đương sự là không trái pháp luật và đạo đức xã hội nên Tòa án ghi nhận.

Vậy, ông T, ông H được nhận thừa kế đất, nhà và tài sản gắn liền của thửa đất E trị giá 19.300.431.500 đồng; ông H có trách nhiệm thanh toán giá trị chênh lệch cho bà M1 trị giá 1.382.785.270 đồng; ông H, ông T là đồng sở hữu nhà, đất và tài sản gắn liền của thửa đất số D, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ vào sổ: K/BH cấp ngày 26/01/2007 (diện tích theo giấy chứng nhận 553m², đo đạc thực tế 547,4 m² (có 73,5m² đất thổ cư); trong đó ông T được sở hữu tỷ lệ 21,417%, ông H được sở hữu tỷ lệ 78,583% (bao gồm phần ông H, bà O được hưởng theo di chúc của cụ X, ông H được hưởng theo pháp luật của cụ H2 và phần ông H thanh toán chênh lệch cho bà M1).

Quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là có căn cứ, đúng pháp luật.

[12] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá: Các đương sự phải chịu theo quy định pháp luật.

[13] Về án phí dân sự sơ thẩm: Các đương sự phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 5, Điều 26, khoản 3 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37; các Điều: 147, 157, 165, 266 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ các Điều: 623, 643, 650, 659, 660 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lê Văn T về việc “tranh chấp thừa kế tài sản”.

1.1. Tuyên bố di chúc do cụ Lê Văn X lập ngày 17/8/2002 có hiệu lực 1/2 đối với di sản do cụ Lê Văn X để lại về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa D, tờ bản đồ X (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m²; đo đạc

thực tế 547,4m² (có 73,5m² đất thổ cư, nay gọi là đất ở) tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007.

Hủy 1/2 di chúc do cụ Lê Văn X lập ngày 17/8/2002 đối với di sản do cụ Lê Văn X để lại về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa D, tờ bản đồ X (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m²; đo đạc thực tế 547,4m² (có 73,5m² đất thổ cư, nay gọi là đất ở) tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007.

1.2. Chia di sản do cụ Lê Văn X và cụ Nguyễn Thị H2 để lại như sau:

Bà Lê Ngọc M1 được quản lý, sử dụng diện tích đo đạc thực tế 205,6m² (có 44m² đất thổ cư, nay gọi là đất ở) và tài sản gắn liền với đất (10 phòng trọ, sân xi măng); đất thuộc thửa E (diện tích theo giấy chứng nhận 193,7m²), tờ bản đồ X tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007.

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Tuyết O về việc cho lại ông Lê Văn H1 phần tài sản thừa kế mà bà Nguyễn Thị Tuyết O được hưởng theo di chúc đối với tài sản là một phần thửa đất số D và một phần tài sản gắn liền thửa đất số D, tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương.

Chia cho ông Lê Văn T, Ông Lê Văn H1 được quyền quản lý, sử dụng diện tích đất đo đạc thực tế 547,4 m² (có 73,5m² đất thổ cư, nay gọi là đất ở) và tài sản gắn liền với đất (nhà, mái che, tường rào...); đất thuộc thửa D (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m²), tờ bản đồ X tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007.

1.3. Ông Lê Văn H1 phải bồi thường giá trị chênh lệch tài sản cho bà Lê Ngọc M1 số tiền 1.382.785.270 đồng (một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi năm nghìn, hai trăm bảy mươi đồng).

1.4. Ông Lê Văn T và Ông Lê Văn H1 là đồng sở hữu nhà, đất diện tích đo đạc thực tế 547,4 m² (có 73,5m² đất thổ cư, nay gọi là đất ở) và tài sản gắn liền với đất (nhà, mái che, tường rào...); đất thuộc thửa D (diện tích theo giấy chứng nhận là 553m²), tờ bản đồ X tọa lạc tại ấp Đ, xã B, huyện T1 (nay là khu phố Đ 1, phường B2, thị xã T1), tỉnh Bình Dương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ: K/BH cấp cho hộ ông Lê Văn X ngày 26/01/2007; trong đó ông Lê Văn T sở hữu tỷ lệ 21,417%; ông Lê Văn H1 sở hữu tỷ lệ 78,583%.

(Kèm theo sơ đồ bản vẽ).

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ vào sổ: K/BH cấp ngày 26/01/2007 để cấp lại cho các đương sự sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá: Ông Lê Văn T phải chịu 3.300.000 đồng (ba triệu, ba trăm nghìn đồng); khấu trừ tạm ứng ông Lê Văn T đã nộp; bà Lê Ngọc M1 phải chịu 3.300.000 đồng (ba triệu, ba trăm nghìn đồng) để trả cho ông Lê Văn T.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Lê Ngọc M1 phải chịu 112.133.715 đồng (một trăm mười hai triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm mười lăm đồng).

Ông Lê Văn T phải chịu 112.133.715 đồng (một trăm mười hai triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, bảy trăm mười lăm đồng), khấu trừ số tiền 7.068.950 đồng (bảy triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi đồng) tạm ứng ông T đã nộp theo Biên lai thu số R ngày 22/4/2019 của Cục T9 tỉnh Bình Dương. Ông Lê Văn T còn phải chịu 105.064.765 đồng (một trăm lẻ năm triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn, bảy trăm sáu mươi lăm đồng).

Ông Lê Văn H1 phải chịu 121.784.072 đồng (một trăm hai mươi một triệu, bảy trăm tám mươi tư nghìn, không trăm bảy mươi hai đồng).

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tổng đạt hợp lệ./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Cục T9 tỉnh Bình Dương;
- Các đương sự;
- Tổ HCTP TAND tỉnh Bình Dương;
- Lưu: Hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Đào Minh Đa

PHỤ LỤC III

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VT
TỈNH VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/QĐST-VDS

VT, ngày 17 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v Yêu cầu công nhận di chúc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VT, TỈNH VĨNH PHÚC

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đỗ Thị Minh Bình.

Thư ký phiên họp: Ông Lê Xuân Chín - Thư ký Tòa án nhân dân huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện VT tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Văn Đạo - Kiểm sát viên

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện VT mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 87/2021/TLST-VDS ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc yêu cầu công nhận di chúc theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 101/2021/QĐST-VDS ngày 14 tháng 12 năm 2021, gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- *Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:* Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1949; địa chỉ: Tổ dân phố NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc (có mặt)

Người đại diện theo uỷ quyền của ông Nguyễn Văn T: Anh Nguyễn Tuấn M, sinh năm 1975; địa chỉ: Tổ dân phố NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản uỷ quyền ngày 05/4/2021), (có mặt)

- *Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn T:* Bà Trần Thị Ng, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (có mặt)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

Anh Nguyễn Tuấn M, sinh năm 1975 (có mặt)

Chị Đào Thị Hồng Th, sinh năm 1976 (vắng mặt)

Cháu Nguyễn Tuấn A, sinh năm 2000 (vắng mặt)

Địa chỉ: TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc

Người đại diện theo uỷ quyền của chị Th và cháu A: Anh Nguyễn Tuấn M, sinh năm 1975, địa chỉ: Tổ dân phố NT, thị trấn VT huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản uỷ quyền ngày 16/11/2021), (có mặt)

Người làm chứng:

Bà Nguyễn Thị T1, sinh năm 1961 (vắng mặt)

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn VT huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Tiến Như, sinh năm 1956 (vắng mặt)

Địa chỉ: TDP NT, thị trấn VT huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

Trong đơn yêu cầu việc dân sự và các lời khai tại Tòa án người yêu cầu ông Nguyễn Văn T, người đại diện theo uỷ quyền của ông T là anh Nguyễn Tuấn M trình bày: Ông Nguyễn Văn T là cháu họ của cụ Nguyễn Thị Sửu (đã chết năm 2002), bố mẹ cụ Sửu là cụ Nguyễn Văn Gia và cụ Nguyễn Thị Tin đều đã chết từ lâu. Cụ Gia và cụ Tin sinh được một mình cụ Sửu và cụ bị khiếm khuyết về thể hình (người lùn chỉ cao có 0,8 mét), bản thân cụ Sửu không có chồng, không có con và không có anh chị em ruột. Khi cụ Sửu còn sống ở vào thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT trên đất có 01 ngôi nhà đất, nguồn gốc nhà và đất là của bố mẹ cụ Sửu để lại cho cho cụ. Khoảng năm 1990 được sự đồng ý của anh chị em trong họ, trong chi cụ Nguyễn Văn Tho (tên gọi khác là Sau bố ông T) nên gia đình ông T đã tự nguyện chăm sóc, phụng dưỡng cụ Sửu. Ngày 14/8/1991 cụ Sửu đã được UBND huyện Vĩnh Lạc (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT. Theo bản đồ VN 2000 là thửa đất số 122, tờ bản đồ số 61, diện tích 179,4m² ở TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên bà Nguyễn Thị Sửu.

Năm 1995 ngôi nhà đất của cụ Sửu bị hư hỏng được sự đồng ý của cụ Sửu nên ông T đã phá ngôi nhà trên của cụ Sửu để xây 01 ngôi nhà cấp 4 (02 gian nhà ngói) cho cụ Sửu ở. Ngày 15/8/2000 cụ Nguyễn Thị Sửu gọi ông T và ông Nguyễn Tiến Như (trưởng thôn), bà Nguyễn Thị T1 (em gái ông T) sang nhà và định đoạt toàn bộ thửa đất của cụ cho ông T nội dung cụ thể như sau: *“Tôi có 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Nay tôi đã già yếu không biết sống chết ngày nào. Vậy tôi lập di chúc giao quyền thừa kế cho cháu là Nguyễn Văn T con ông Sau, cháu tôi là Nguyễn Văn T được toàn quyền thừa kế, định đoạt 2 gian nhà và diện tích đất nói trên”*. Cụ Sửu lập di chúc dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn

Tiến Như, bà Nguyễn Thị T1. Mục đích cụ Sứu để lại di chúc trên cho ông T là vì khi cụ Sứu còn sống không có chồng, không có con và gia đình ông T đã trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cụ Sứu.

Do cụ Sứu tuổi cao không viết được di chúc nên đã nhờ người khác viết hộ, còn ai là người viết di chúc (di chúc viết tay) cho cụ Sứu thì ông T không biết. Ông T xác nhận chữ ký dưới mục người lập di chúc là của cụ Nguyễn Thị Sứu, sau khi lập di chúc cụ Sứu có được nghe đọc lại và thông qua toàn bộ nội dung di chúc, di chúc phù hợp ý chí của cụ khi còn sống. Khi lập di chúc cụ Sứu minh mẫn, sáng suốt và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép gì lý do ông T ký tên tại mục người được thừa kế tại di chúc thừa kế ngày 15/8/2000 là vì. Sau khi cụ Sứu và những người làm chứng là ông Nguyễn Tiến Như, bà Nguyễn Thị T1 ký vào di chúc thì ông T mới được công bố nội dung di chúc và ký vào mục người được thừa kế. Ngoài di chúc lập ngày 15/8/2000 cụ Sứu không có di chúc nào khác để lại tài sản cho ai khác. Ngoài tài sản là thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² đất thổ cư tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT nay là TDP NT thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên cụ Sứu thì cụ không còn tài sản nào khác. Sau khi cụ Sứu lập di chúc thừa kế ngày 15/8/2000 cụ đã giao cho ông T giữ di chúc này, di chúc trên chỉ được lập 01 bản ông T đã nộp bản chính cho Tòa án.

Để tiện cho việc chăm sóc cụ Sứu nên năm 2001 ông T đã cho gia đình anh Nguyễn Tuấn M, chị Đào Thị Hồng Th và các con sang ở với cụ Sứu, khi sang ở với cụ Sứu ông T và anh M có xây thêm 01 gian nhà và 01 gian bếp, năm 2002 cụ Sứu chết ông T là người đứng ra lo mai táng. Sau khi cụ Sứu chết ông T và anh M là người quản lý sử dụng nhà đất của cụ Sứu. Năm 2012 vợ chồng anh M, chị Th xây 01 ngôi nhà hai tầng trên thửa đất của cụ Sứu ông T không có ý kiến gì đối với các công trình, tài sản do vợ chồng anh M, chị Th xây dựng. Nay ông T yêu cầu Tòa án công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứu lập có hiệu lực.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Tuấn M đồng thời là người đại diện theo uỷ quyền của chị Đào Thị Hồng Th, cháu Nguyễn Tuấn A trình bày: Anh là cháu họ của cụ Nguyễn Thị Sứu, bố mẹ cụ Sứu là cụ Nguyễn Văn Gia và cụ Nguyễn Thị Tin (đã chết từ lâu) cụ Sứu không có chồng, không có con, không có anh chị em ruột. Khoảng năm 1990 được sự đồng ý của anh chị em trong họ, trong chi cụ Nguyễn Văn Tho (tên gọi khác là Sau) nên bố anh ông Nguyễn Văn T cùng gia đình đã tự nguyện chăm sóc, phụng dưỡng cụ Sứu. Về nguồn gốc đất của cụ Sứu như bố anh ông T đã trình bày trên là đúng.

Năm 1995 nhà đất của cụ Sửu bị hư hỏng và được sự đồng ý của cụ Sửu nên ông T đã phá dỡ ngôi nhà cũ của cụ để xây 02 gian nhà cấp 4 cho cụ Sửu ở. Năm 2001 vợ chồng anh chuyển sang ở hẳn với cụ Sửu để tiện cho việc chăm sóc cụ, khi sang ở vợ chồng anh có xây thêm 01 gian nhà và 01 gian bếp. Năm 2002 cụ Sửu chết ông T là người đứng ra mai táng, sau khi cụ Sửu chết toàn bộ nhà đất của cụ do ông T và vợ chồng anh quản lý sử dụng. Năm 2012 vợ chồng anh phá nhà cũ đi để xây 01 ngôi nhà 02 tầng trên thửa đất của cụ Sửu và sử dụng từ đó đến nay không có tranh chấp với ai, tiền xây nhà là của vợ chồng anh tích cóp mà có. Các con của vợ chồng anh là cháu Nguyễn Tuấn A, cháu Nguyễn Thu Trang khi đó còn nhỏ không có công sức đóng góp gì. Năm 2018 vợ chồng anh được biết ngày 15/8/2000 cụ Sửu có lập 01 di chúc để lại cho ông T (bố anh) thừa đất của cụ Sửu mà hiện nay vợ chồng anh đang quản lý sử dụng, nội dung di chúc như ông T đã trình bày trên. Hiện nay vợ chồng anh là người đang thờ cúng cụ Sửu, thuê đất hàng năm do vợ chồng anh nộp cho Nhà nước đối với diện tích đất của cụ Sửu.

Nay anh yêu cầu Tòa án công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sửu lập có hiệu lực. Đối với phần tài sản trên đất là ngôi nhà 02 tầng do vợ chồng anh xây dựng thì không đề nghị Tòa án giải quyết.

Ông Nguyễn Tiến Như vắng mặt nhưng theo biên bản lấy lời khai ngày 15/11/2021 ông Như trình bày: Ông là người cùng thôn với cụ Nguyễn Thị Sửu và ông Nguyễn Văn T, năm 1999 ông làm trưởng thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT (nay là TDP NT, thị trấn VT, huyện VT tỉnh Vĩnh Phúc) đến năm 2008 thì ông không làm trưởng thôn nữa. Ngày 15/8/2000, cụ Nguyễn Thị Sửu gọi ông và bà Nguyễn Thị T1 (cháu cụ Sửu) đến nhà cụ và nói, cụ có tài sản là 01 thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² cùng 02 gian nhà cấp IV trên đất tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT nay là TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên cụ Nguyễn Thị Sửu. Nguyên vọng của cụ Sửu để lại toàn bộ tài sản trên cho ông Nguyễn Văn T là cháu họ của cụ. Khi sang nhà cụ Sửu gồm có ông, cụ Sửu, bà T1 và ông T chứng kiến việc cụ Sửu định đoạt di sản của cụ cho ông T. Theo ý chí của cụ Sửu khi còn sống thì cụ để lại cho ông T toàn bộ quyền sử dụng 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04 tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT nay là TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Cụ Sửu lập di chúc có nội dung “*Tôi có 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Nay tôi đã già yếu không biết sống chết ngày nào. Vậy tôi lập di chúc*

giao quyền thừa kế cho cháu là Nguyễn Văn T con ông Sau, cháu tôi là Nguyễn Văn T được toàn quyền thừa kế, định đoạt 2 gian nhà và diện tích đất nói trên”.

Tại thời điểm cụ Sứ lập di chúc thì cụ hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, không bị lừa dối, ép buộc gì. Cụ Sứ lập di chúc đúng với ý chí khi còn sống của cụ là để lại cho ông Nguyễn Văn T 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Ông T được toàn quyền định đoạt 02 gian nhà và toàn bộ diện tích đất trên. Do tuổi cao, cụ Sứ không tự viết được di chúc mà nhờ người viết hộ, còn ai viết hộ cho cụ thì ông không biết. Khi lập xong di chúc, cụ Sứ và những người có mặt đều được nghe đọc và thông qua nội dung di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 và công nhận nội dung di chúc là đúng. Sau khi thông qua nội dung di chúc cụ Sứ ký nhận tại mục người lập di chúc, những người làm chứng là ông và bà T1 ký nhận tại mục người làm chứng, nội dung di chúc là hợp pháp. Ông đã được Tòa án cho xem bản chính di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứ có chữ ký của cụ Sứ là người lập di chúc, người được thừa kế là ông Nguyễn Văn T, người làm chứng là ông và bà Nguyễn Thị T1. Ông xác nhận toàn bộ nội dung di chúc, chữ ký, chữ viết của người làm chứng là đúng. Việc những người làm chứng ký nhận trong nội dung di chúc của cụ Sứ là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc gì.

Nay ông Nguyễn Văn T yêu cầu Tòa án công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứ lập có hiệu lực. Quan điểm của ông xác nhận toàn bộ nội dung di chúc của cụ Sứ là hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án công nhận di chúc của cụ Sứ là có hiệu lực để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của ông T và do công việc nên ông Như xin được giải quyết vắng mặt.

Bà Nguyễn Thị T1 vắng mặt nhưng theo bản tự khai ngày 16/11/2021 bà T1 trình bày: Bà là cháu họ của cụ Nguyễn Thị Sứ, ngày 15/8/2000 cụ Nguyễn Thị Sứ gọi bà và ông Nguyễn Tiến Như (trưởng thôn) đến nhà cụ và nói, nội dung cụ Sứ nói như ông Như trình bày trên là đúng. Nguyên vọng của cụ Sứ là để lại toàn bộ tài sản trên cho ông Nguyễn Văn T là cháu họ của cụ. Khi sang nhà cụ Sứ có bà, ông Như, cụ Sứ và ông T có mặt chứng kiến việc cụ Sứ định đoạt di sản của cụ cho ông T. Theo ý chí của cụ Sứ khi còn sống thì cụ để lại cho ông T toàn bộ quyền sử dụng 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04 tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT nay là TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

số A 847105 ngày 14/8/1991. Cụ Sứ lập di chúc có nội dung như ông T và ông Như trình bày trên là đúng.

Tại thời điểm cụ Sứ lập di chúc thì cụ hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, không bị lừa dối, ép buộc gì. Cụ Sứ lập di chúc đúng với ý chí khi còn sống của cụ là để lại cho ông Nguyễn Văn T toàn bộ 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Ông T được toàn quyền định đoạt 02 gian nhà và toàn bộ diện tích đất trên. Do tuổi cao, cụ Sứ không tự viết được bản di chúc mà nhờ người viết hộ, còn ai viết hộ cho cụ Sứ thì bà không biết. Khi lập xong di chúc, cụ Sứ và những người có mặt đều được nghe đọc và thông qua nội dung di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 và công nhận nội dung di chúc là đúng. Sau khi thông qua nội dung di chúc cụ Sứ ký nhận tại mục người lập di chúc, những người làm chứng là bà và ông Như ký nhận dưới mục người làm chứng nội dung di chúc là hợp pháp. Bà đã được Tòa án cho xem bản chính di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứ có chữ ký của cụ Sứ là người lập di chúc, người được thừa kế là ông Nguyễn Văn T, người làm chứng có bà và ông Nguyễn Tiên Như. Bà xác nhận toàn bộ nội dung di chúc, chữ ký, chữ viết của người làm chứng là đúng. Việc những người làm chứng ký nhận trong nội dung di chúc của cụ Sứ là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc gì.

Nay ông Nguyễn Văn T yêu cầu Tòa án công nhận bản di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứ lập có hiệu lực. Quan điểm của bà xác nhận toàn bộ nội dung di chúc của cụ Sứ là hợp pháp, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Tòa án công nhận di chúc của cụ Sứ là có hiệu lực để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của ông T và do công việc bận nên bà T1 xin được giải quyết vắng mặt.

Tại phiên họp người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn T, bà Trần Thị Ng, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trình bày: Ông Nguyễn Văn T là cháu họ của cụ Nguyễn Thị Sứ (chết năm 2002), trú tại TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 14/8/1991 cụ Sứ được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² đất thổ cư tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc nay là TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên bà Nguyễn Thị Sứ. Hiện nay theo bản đồ VN là thửa số 122, tờ bản đồ số 61, diện tích 179,4m².

Do cụ Sứ bị khiếm khuyết về mặt hình thức chỉ cao có 0,8 mét, bản thân cụ Sứ không có chồng, không có con, không có anh chị em ruột, bố mẹ cụ Sứ là cụ Nguyễn

Văn Gia và Nguyễn Thị Tin đều đã chết từ lâu. Nên khoảng năm 1990 được sự đồng ý của anh chị em trong họ, trong chi cụ Nguyễn Văn Tho (tên gọi khác là Sau) và bản thân vợ chồng ông T đã tự nguyện chăm sóc, phụng dưỡng cụ Sứu nên từ năm 1990 trở đi việc chăm sóc, phụng dưỡng cụ Sứu đều do gia đình ông T. Đến năm 1995 ngôi nhà đất của cụ Sứu hư hỏng nặng, được sự đồng ý của cụ nên ông T đã phá dỡ ngôi nhà trên của cụ để xây dựng 01 ngôi nhà ngói 2 gian nhà cấp 4 để cụ ở.

Ngày 15/8/2000 cụ Nguyễn Thị Sứu gọi ông T và ông Nguyễn Tiến Như (trưởng thôn), bà Nguyễn Thị T1 (cháu họ) sang nhà và định đoạt toàn bộ thừa đất của cụ cho ông T nội dung cụ thể như sau: *“Tôi có 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Nay tôi đã già yếu không biết sống chết ngày nào. Vậy tôi lập di chúc giao quyền thừa kế cho cháu là Nguyễn Văn T con ông Sau, cháu tôi là Nguyễn Văn T được toàn quyền thừa kế, định đoạt 2 gian nhà và diện tích đất nói trên”*. Việc cụ Sứu lập di chúc dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Tiến Như (trưởng thôn) và bà Nguyễn Thị T1 (cháu họ) ký người làm chứng cho cụ viết di chúc và để thừa đất của cụ cho ông T, nguyện vọng của cụ phù hợp với nội dung của di chúc nên ông Như, bà T1 đã ký xác nhận.

Do đó năm 2001 con trai ông T là anh Nguyễn Tuấn M sang ở với cụ Sứu để tiện việc chăm sóc. Khi sang ở với cụ Sứu ông T và anh M có xây dựng thêm 01 gian nhà, 01 gian bếp. Năm 2002 cụ Sứu chết ông T là người đứng ra lo mai táng, hiện nay ông T và các con đang thờ cúng cụ Sứu. Sau khi cụ Sứu chết toàn bộ thừa đất do ông T và anh M quản lý sử dụng và không tranh chấp với ai. Năm 2012, vợ chồng anh M xây dựng 01 ngôi nhà hai tầng trên thừa đất của cụ Sứu và quản lý sử dụng từ đó cho đến nay không có tranh chấp với ai.

Tại phiên họp ông Nguyễn Văn T vẫn giữ nguyên yêu cầu đề nghị Tòa án huyện VT công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứu lập có hiệu lực bởi các lý do sau: Theo quy định tại Điều 649 và 650 Bộ luật dân sự năm 2005, Điều 627 và 628 Bộ luật dân sự năm 2015 đây là di chúc bằng văn bản do người khác viết hộ, cụ Sứu có ký và ghi họ tên, có người làm chứng và có chứng thực của UBND có thẩm quyền. Mặc dù cụ Sứu không ký và ghi họ tên trước mặt những người làm chứng xong theo người làm chứng là ông Nguyễn Tiến Như (trưởng thôn) thì đích thân cụ Sứu mời ông sang nhà cụ và đưa bản di chúc cụ đã lập nhờ ông ký xác nhận, lúc đó cụ Sứu hoàn toàn minh mẫn và khỏe mạnh, nguyện vọng của cụ Sứu nói với ông phù hợp với nội dung bản di chúc nên ông đã ký xác nhận. Bà Nguyễn Thị T1 xác nhận bà là cháu họ cụ Sứu, bà được cụ Sứu gọi sang nhà

làm chứng và là người ký làm chứng vào bản di chúc của cụ Sứ. Lý do bà ký vì trước đó cụ Sứ đã gặp và nói nguyện vọng trao đất cho Tiến và nhờ bà ký xác nhận khi cụ lập di chúc. Anh Nguyễn Tiến Mạnh là chất cụ Sứ cũng thừa nhận thời điểm lập di chúc cụ Sứ hoàn toàn minh mẫn và khỏe mạnh.

Về ý thức chủ quan của người lập di chúc: Do cụ Sứ không lập gia đình không có con, không có anh chị em ruột, bố mẹ cụ đều chết trước cụ, ông T và gia đình trực tiếp chăm sóc cụ Sứ, nên cụ Sứ đã có ý nguyện trao tài sản là đất cho ông T thể hiện tại nhiều thời điểm như: Ông T là người đóng thuế và khi cụ Sứ còn sống ông T đi kê khai để sang tên đất nhưng do vướng mắc về thủ tục hành chính nên chưa sang tên được. Với những sự kiện nêu trên đã thể hiện ý chí của cụ Sứ về việc cho ông T hưởng tài sản thuộc sở hữu của mình là nhất quán, xuyên suốt trong một khoảng thời gian dài từ năm 1995 đến khi bản di chúc được cụ Sứ thiết lập ngày 15/8/2000, phù hợp với quy định tại Điều 647, 648 Bộ luật dân sự năm 2005. Mặc dù hình thức của di chúc chưa tuân thủ đúng quy định tại Điều 656, 658 Bộ luật dân sự năm 2015 xong diễn biến của việc lập di chúc và nội dung của di chúc phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng thực của cụ Sứ trong việc chuyển giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho ông T; khi lập di chúc cụ Sứ không bị lừa dối, ép buộc nên ý chí, nguyện vọng của cụ Sứ cần được tôn trọng.

Về nội dung của di chúc: Trong di chúc cụ Sứ đã định đoạt toàn bộ tài sản nhà, đất cho ông T: *“Tôi có 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Nay tôi đã già yếu không biết sống chết ngày nào. Vậy tôi lập di chúc giao quyền thừa kế cho cháu là Nguyễn Văn T con ông Sau, cháu tôi là Nguyễn Văn T được toàn quyền thừa kế, định đoạt 2 gian nhà và diện tích đất nói trên”*. Về diện và hàng thừa kế của cụ Sứ thì chỉ có một mình cụ ngoài ra không có ai khác. Vì vậy đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn T.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết việc dân sự như sau: Thẩm phán, Thư ký đã tuân theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết việc dân sự từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm mở phiên họp giải quyết việc dân sự và đề nghị: Căn cứ khoản 10 Điều 27, khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 40, Điều 361, 369 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 646, 647, 648, 656 của Bộ luật dân sự năm 2005; Khoản 1 Điều 212; Điều 624, 625, 626, 628 của Bộ luật dân sự năm 2015. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn T về việc yêu cầu Tòa án công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của

cụ Nguyễn Thị Sửu lập có hiệu lực.

Về lệ phí: Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Ông Nguyễn Văn T không phải chịu lệ phí Tòa án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện VT nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Ông Nguyễn Văn T có đơn yêu cầu Tòa án công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sửu lập có hiệu lực. Đây là việc dân sự theo quy định tại khoản 10 Điều 27, khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc.

Về sự vắng mặt của chị Th, cháu A đã có lời khai, bản tự khai và giấy ủy quyền cho anh M; Về sự vắng mặt của bà T1, ông Như đã có lời khai, bản tự khai và đơn xin giải quyết vắng mặt. Vì vậy căn cứ vào Điều 367 của Bộ luật tố tụng dân sự Tòa án tiến hành phiên họp vắng mặt đối với chị Th, cháu A, bà T1, ông Như là đúng trình tự pháp luật.

[2] Về nội dung vụ việc: Ông Nguyễn Văn T yêu cầu Tòa án công nhận di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sửu lập có hiệu lực nhận thấy: Bố mẹ cụ Nguyễn Thị Sửu là cụ Nguyễn Văn Gia và cụ Nguyễn Thị Tin (đã chết từ lâu), cụ Gia và cụ Tin sinh được một người con là cụ Nguyễn Thị Sửu ngoài ra hai cụ không có con riêng hay con nuôi nào khác. Cụ Sửu khi còn sống thì không có chồng, không có con và không có anh chị em ruột nên cụ ở một mình tại thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² ở thôn NT, xã Vũ Di, huyện VT trên đất có 01 ngôi nhà đất, nguồn gốc nhà và đất là của bố mẹ cụ Sửu để lại cho cho cụ. Thửa đất trên cụ Sửu đã được UBND huyện Vĩnh Lạc (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 14/8/1991 đứng tên bà Nguyễn Thị Sửu. Theo bản đồ VN 2000 là thửa đất số 122, tờ bản đồ số 61, diện tích 179,4m² ở TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng năm 1990 được sự đồng ý của các anh, chị em trong họ, trong chi cụ Nguyễn Văn Tho (tên gọi khác là Sau) nên gia đình ông Nguyễn Văn T đã tự nguyện chăm sóc, phụng dưỡng cụ Sửu. Năm 1995 ngôi nhà của cụ Sửu bị hư hỏng và được sự đồng ý của cụ Sửu nên ông T đã phá dỡ ngôi nhà cũ của cụ để xây 01

ngôi nhà cấp 4 (02 gian nhà ngói) cho cụ Sứ ở. Do cụ Sứ tuổi đã cao không viết được di chúc nên có nhờ người khác viết hộ di chúc thừa kế ngày 15/8/2000 có nội dung: “*Tôi có 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m², diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 847105 ngày 14/8/1991. Nay tôi đã già yếu không biết sống chết ngày nào. Vậy tôi lập di chúc giao quyền thừa kế cho cháu là Nguyễn Văn T con ông Sau, cháu tôi là Nguyễn Văn T được toàn quyền thừa kế, định đoạt 2 gian nhà và diện tích đất nói trên*”. Khi lập di chúc cụ Sứ minh mẫn, sáng suốt và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép gì, cụ Sứ có được nghe thông qua toàn bộ nội dung di chúc phù hợp ý chí của cụ, ngoài di chúc trên cụ Sứ không có di chúc nào khác và không để lại tài sản cho ai khác. Di chúc có người làm chứng là ông Nguyễn Tiến Như (trưởng thôn), bà Nguyễn Thị T1 (cháu họ) sau đó cụ Sứ đã giao cho ông T giữ di chúc trên.

Năm 2001 ông T cho vợ chồng anh Nguyễn Tuấn M, chị Đào Thị Hồng Th (con trai con dâu ông T) sang ở với cụ Sứ, khi sang ở với cụ Sứ ông T và anh M đã xây thêm 01 gian nhà và 01 gian bếp. Năm 2002 cụ Sứ chết ông T là người đứng ra lo toàn bộ mai táng phí cho cụ Sứ, sau khi cụ Sứ chết ông T và anh M là người quản lý sử dụng nhà đất của cụ Sứ. Năm 2012 vợ chồng anh M, chị Th đã phá nhà cũ đi để xây 01 ngôi nhà 02 tầng trên thửa đất của cụ Sứ và sử dụng từ đó đến nay không có tranh chấp với ai. Tiền xây nhà là của vợ chồng anh M chị Th, hiện nay anh chị là người đang thờ cúng cụ Sứ và thuê đất hàng năm do anh M, chị Th đóng cho Nhà nước.

Căn cứ biên bản xác minh ngày 01/12/2021 UBND thị trấn VT cho biết, theo sổ mục kê đất số 01, trang số 78, tờ bản đồ số 04 lập năm 1999 lưu tại UBND thị trấn VT cụ Nguyễn Thị Sứ có thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² đất. Bản đồ 299 đo đạc năm 1991 cụ Sứ có thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² đất. Sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ trang số 7, số thứ tự 70 lập năm 1999 cụ Sứ có thửa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² đất tại thôn NT, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) nay là TDP NT, thị trấn VT, huyện VT cấp theo GCNQSDĐ số A 847105. Theo bản đồ VN 2000 đo đạc năm 2010 thì cụ Nguyễn Thị Sứ có thửa đất số 122, tờ bản đồ số 61, diện tích 179,4m². Trong đó có 162m² đất ở và 17,4m² đất trồng cây lâu năm tại TDP NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc đứng tên cụ Nguyễn Thị Sứ. Lý do diện tích đất của cụ Sứ tăng thêm so với bản đồ 299 là do thông tin thửa đất thay đổi, do đo đạc bản đồ hệ toạ độ VN 2000 đã được Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh VT xác nhận ngày 19/02/2021 trong giấy chứng nhận QSDĐ của cụ Sứ. Ủy ban nhân dân thị

trần VT không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai gì đối với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên cụ Nguyễn Thị Sửu.

Theo trích lục khai tử số 34/TLKT- BS ngày 01/3/2021 thể hiện cụ Nguyễn Thị Sửu, sinh năm 1911 chết năm 2002, cụ Sửu từ khi sinh ra và lớn đều sinh sống tại TDP NT, thị trấn VT, huyện VT. Khi còn sống cụ Sửu không có chồng, không có con và ông Nguyễn Văn T có mối quan hệ là cháu họ của cụ Sửu. Đối với việc khi cụ Sửu còn sống có để lại di chúc thừa đất số 76, tờ bản đồ số 04, diện tích 162m² đất ở TDP NT, thị trấn VT, huyện VT cho ai hay không địa phương không rõ vì không thông qua địa phương.

Về quá trình sử dụng đất sau khi cụ Nguyễn Thị Sửu chết thì ông T cùng gia đình anh Nguyễn Tuấn M (con trai ông T) quản lý, sử dụng toàn bộ thừa đất đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên cụ Nguyễn Thị Sửu. Ông T và gia đình anh M có xây dựng thêm phần công trình tài sản trên đất là ngôi nhà hai tầng, xây dựng năm 2012 cùng các công trình tài sản khác có trên đất. Từ khi cụ Sửu chết gia đình ông T là người trực tiếp quản lý đất và nộp thuế sử dụng đất ở hàng năm. Nay ông Nguyễn Văn T đề nghị Tòa án công nhận di chúc lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sửu lập có hiệu lực pháp luật, đề nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

[3] Việc ông Nguyễn Văn T yêu cầu Toà án công nhận di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sửu lập có hiệu lực. Xét thấy, trong quá trình giải quyết việc dân sự thì bố mẹ cụ Sửu là cụ Nguyễn Văn Gia và cụ Nguyễn Thị Tin đều đã chết từ lâu, cụ Gia và cụ Tin sinh được một người con là cụ Sửu ngoài ra không có con riêng hay con nuôi nào khác. Bản thân cụ Sửu khi còn sống là người bị khiếm khuyết về thể hình (người lùn chỉ cao có 0,8 mét), nhưng cụ không có bệnh gì lý liên quan đến thần kinh trí óc vẫn minh mẫn, cụ Sửu không có chồng, không có con và không có anh chị em ruột. Còn ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị T1 là cháu họ của cụ Sửu. Khi cụ Sửu còn sống đã lập di chúc thừa kế ngày 15/8/2000 để lại 02 gian nhà cấp 4 nằm trên diện tích đất 162m² cho ông T được toàn quyền thừa kế, định đoạt. Tuy di chúc trên của cụ Sửu lập chưa tuân thủ đúng về mặt hình thức theo quy định tại Điều 656, 658 của Bộ luật Dân sự năm 2005, xong việc lập di chúc và nội dung của di chúc đã phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của cụ Sửu trong việc chuyển giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho ông T. Hơn nữa khi lập di chúc cụ Sửu hoàn toàn minh mẫn và khỏe mạnh, không bị ai lừa dối hay ép buộc gì nên ý chí và nguyện vọng của cụ Sửu cần được tôn trọng. Ngoài di chúc trên thì cụ Sửu không có di chúc nào khác và không để lại tài sản cho ai

khác. Thực tế năm 2002 cụ Sứ chết thì gia đình ông T đứng ra lo toàn bộ mai táng phí cho cụ Sứ. Mặt khác kể từ sau khi cụ Sứ chết năm 2002 cho đến nay toàn bộ nhà đất của cụ Sứ do ông T và vợ chồng anh M, chị Th (con trai con dâu ông T) quản lý, sử dụng hàng năm vẫn thực hiện việc nộp thuế cho Nhà nước và không có tranh chấp với ai. Điều này cũng được những người làm chứng xác nhận như lời khai của ông Nguyễn Tiến Như và bà Nguyễn Thị T1. Nên việc ông T yêu cầu Toà án công nhận di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứ lập có hiệu lực là có căn cứ và phù hợp với quy định tại Điều 646, 647, 648, 656 của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 624, 625, 626, 628 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Vì vậy cần chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Văn T về việc yêu cầu công nhận di chúc thừa kế của cụ Nguyễn Thị Sứ lập ngày 15/8/2000 có hiệu lực.

Ý kiến đề nghị của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn T và của Kiểm sát viên tại phiên họp về việc giải quyết việc dân sự là có căn cứ, được xem xét khi quyết định.

[4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, ông Nguyễn Văn T là người cao tuổi và là thương binh nên không phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 10 Điều 27, khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 40, Điều 361, 369, 370, 372 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 646, 647, 648, 656 của Bộ luật dân sự năm 2005; Khoản 1 Điều 212; Điều 624, 625, 626, 628 của Bộ luật dân sự năm 2015.

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Văn T về việc, yêu cầu công nhận di chúc thừa kế lập ngày 15/8/2000 của cụ Nguyễn Thị Sứ được lập tại gia đình ở thôn NT, thị trấn VT, huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc có hiệu lực.

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Văn T không phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 10

ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- VKSND huyện VT;
- UBND TT VT;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ + Văn phòng.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(đã ký)

Đỗ Thị Minh Bình

PHỤ LỤC IV

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG BẢN ÁN 05/2020/DS-PT NGÀY 26/02/2020 VỀ YÊU CẦU HỦY DI CHÚC

Ngày 26-02-2020, tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 96/2019/TLPT-DS ngày 23 tháng 12 năm 2019 về “Yêu cầu hủy di chúc” do bản án dân sự sơ thẩm số: 07/2019/DS-ST ngày 22/07/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 09/2020/QĐ-PT ngày 10 tháng 02 năm 2020, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Vàng Thị G, địa chỉ: Bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – Vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Anh Và Bá B, địa chỉ: Bản N, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông (Theo văn bản ủy quyền số 506, quyền số 01/2019/TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 16-5-2019).

- Bị đơn: Bà Sùng Thị S; địa chỉ: Bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – Có mặt.

Người phiên dịch cho bà Sùng Thị S: Ông Lâu Bá P; địa chỉ: Ban D tỉnh Đắk Nông – Có mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Sùng A V; địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, TP. G, tỉnh Đắk Nông (Theo văn bản ủy quyền số 60, quyền số 01/2020 – SCT/CK,ĐC, ngày 20-02-2019) – Có mặt.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Phạm Thị T, là Luật sư Văn phòng luật sư N, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông - Có mặt. - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Anh Thào Seo T; anh Thào A P; cùng trú tại: Bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – Có mặt.

Chị Thào Thị P; chị Thào Thị S; chị Thào Thị O; chị Thào Thị T, cùng trú tại: Bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – Đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Người làm chứng: Anh Thào Seo H; anh Ma Seo P; anh Vàng A C; cùng địa chỉ: Bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – Có mặt.

Anh Vàng A P; chị Thào Thị T; anh Sùng Văn C; cùng địa chỉ: Bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – Vắng mặt.

Người kháng cáo: Bị đơn bà Sùng Thị S

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 15 tháng 3 năm 2019, quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Vàng Thị G và người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn anh Và Bá B trình bày:

Bà Vàng Thị G và ông Thào Seo S chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 6 năm 1986, không đăng ký kết hôn, được hai bên gia đình tổ chức lễ cưới. Thời điểm sống chung với ông S thì bà G đang mang thai con riêng với người khác được khoảng 05 tháng. Đến ngày 01-11-1986 bà G sinh con là Thào Seo T. Ngoài ra ông bà còn có 05 con chung là: Thào Thị P, sinh năm 1990; Thào A P, sinh năm 1993; Thào Thị S, sinh năm 1996; Thào Thị O, sinh năm 1999 và Thào Thị T, sinh năm 2001.

Quá trình chung sống bà G và ông S cùng các con đã tạo lập được khối tài sản chung khoảng 03 ha đất rẫy và 02 thửa đất ở, đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Viết tắt GCNQSDĐ), tọa lạc tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông.

Năm 2015 ông S có quan hệ với người phụ nữ khác bị gia đình bắt được nên yêu cầu ông làm bản cam kết không tái phạm nữa, sau đó vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ông S lấy tiền của gia đình và vay mượn thêm của các con để xây một ngôi nhà xây cấp 4 trên diện tích đất 20m x 30m để ở riêng. Đến khoảng tháng 8 năm 2018 ông S đưa bà Sùng Thị S về ở trong căn nhà mới xây, vợ con không đồng ý nhưng vì ông S bị bệnh nên chưa kịp giải quyết.

Ngày 18-11-2018, ông S đang điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông thì bà Sùng Thị S đưa ông Sùng A V là anh họ của bà S đến bệnh viện bắt ông S viết di chúc để lại toàn bộ tài sản gồm khoảng 03 ha đất rẫy và 01 căn nhà xây cấp 4 trên diện tích đất khoảng 20 x 30m tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông cho bà Sùng Thị S, trong khi đất rẫy bà G và các con đang quản lý, sử dụng nhưng không hề biết. Sau khi ông S chết bà Sùng Thị S căn cứ vào bản di chúc này để chiếm nhà và đất rẫy của bà G. Nay bà G cho rằng việc ông S lập di chúc để lại tài sản cho bà Sùng Thị S là không đúng quy định của pháp luật với những lý do sau: Tài sản chung giữa vợ chồng ông S, bà G và các con tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân nhưng ông S tự ý lấy tài sản chung của gia đình để lại cho bà Sùng Thị S mà không được sự đồng ý của bà và các con là không đúng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà. Do đó, bà làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố bản di chúc lập ngày 18-11-2018 giữa ông Thảo Seo S và bà Sùng Thị S bị vô hiệu.

Bị đơn bà Sùng Thị S trình bày:

Trước khi ông Thảo Seo S xin cưới bà Sùng Thị S làm vợ thì giữa ông S, bà S đã lập bản cam kết ngày 24-10-2017 tại nhà ông Sùng A L, cụm a, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. Nội dung bản cam kết thể hiện ông S, bà Vàng Thị G chung sống với nhau không đăng ký kết hôn và đã có con chung. Do vợ chồng mâu thuẫn đã bỏ nhau và thỏa thuận chia tài sản có sự chứng kiến của hai bên nội, ngoại, chính quyền thôn và anh Thảo Seo H, Vàng A P. Biên bản chia tài sản đã bị thất lạc, nên không thể cung cấp cho Tòa án được. Vì vậy, toàn bộ tài sản gồm khoảng 03 hecta đất rẫy đã trồng điều và cà phê; 01 ngôi nhà xây cấp 4 trên diện tích đất (20m x 30m) tại bản S, xã Đ là tài sản riêng của ông Thảo Seo S.

Khoảng tháng 8-2018, bà S và ông S đến Ủy ban nhân dân (Viết tắt UBND) xã Đ để làm thủ tục xin đăng ký kết hôn, nhưng không được chấp nhận vì ông S, bà G tự ý thỏa thuận ly hôn tại thôn bản không có giá trị pháp lý, nên ông bà không đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do bà S có nguyện vọng được ở lại xã Đ để làm ăn sinh sống với ông S, nên Công an xã Đ cho bà S nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của ông S và tự ý ghi tên bà S vào mục quan hệ với chủ hộ là vợ.

Tháng 10-2018, ông Thảo Seo S bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đến ngày 05-12-2018 thì ông S chết. Trong thời gian chữa bệnh, ngày 18-11-2018 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông ông Thảo Seo S đã nhờ anh họ của bà S là ông Sùng A V viết di chúc để lại tài sản cho bà S gồm: 01 căn nhà xây cấp 4 trên diện tích đất khoảng 20m x 30m và 03ha đất rẫy đã trồng cà phê và cây điều, địa chỉ tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông. Bản di chúc có chữ ký của ông Thảo Seo S, bà Sùng Thị S và người làm chứng Vàng A P, Sùng A V, Thảo A C, Thảo A S và Thảo Seo T.

Bà S thừa nhận nội dung bản di chúc không rõ ràng, mang tính ràng buộc bà S, không cho bà S đi lấy chồng, nếu bà S vi phạm ý chí của ông S thì bà S mất hết tài sản được thừa kế. Bà S xác định toàn bộ tài sản ông S để lại cho bà S là tài sản riêng của ông S, nên bà S được quyền quản lý, sử dụng. Do đó, bà không chấp nhận việc bà G yêu cầu huỷ di chúc, đề nghị

Tòa án bác đơn khởi kiện của bà G và công nhận bản di chúc được lập ngày 18-11-2018 của ông S là hợp pháp.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Thào Seo T (Con bà G) trình bày:

Gia đình anh chuyển từ xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông đến bản S, xã Đ, huyện T sinh sống từ năm 2001, được Trung Đoàn 720 cấp đất rẫy và đất ở để lập nghiệp. Thời gian sau bố mẹ anh mua thêm khoảng 01 hecta đất rẫy và 01 thửa đất ở diện tích 20 x 30m, tại bản S, xã Đ, huyện Tuy Đức.

Trong thời gian bố anh bị bệnh và đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, bà S nhờ người viết di chúc để lại tài sản gồm 03 hecta đất rẫy đã trồng điều và cà phê; 01 căn nhà xây cấp 4 trên diện tích đất 20m x 30m cho bà Sùng Thị S. Tại bệnh viện anh có mặt nhưng do ông V nói không rõ ràng và do bố anh bảo ký vào di chúc nên anh cũng ký, anh nghĩ ký vào sẽ quản lý giúp tài sản cho bố mẹ, nhưng sau khi bố chết thì anh mới biết việc mình ký vào di chúc là sai. Đề nghị Tòa án hủy di chúc theo yêu cầu của bà Vàng Thị G, lý do tài sản bố anh để lại cho bà Sùng Thị S là tài sản chung của ông S, bà G và các con, nhưng bố anh tự ý quyết định phần tài sản của mẹ và các con là không đúng.

Anh Thào A P (con bà G và ông S) trình bày:

Về nguồn gốc tài sản mà ông Thào Seo S đã lập di chúc để lại cho bà Sùng Thị S như anh Thào Seo T đã trình bày ở trên là đúng. Thời điểm lập di chúc anh cũng có mặt, ông Sùng A V (anh họ của bà S) bảo anh ký vào di chúc nhưng anh không ký vì nghe ông V nói không rõ ràng nên sợ mất đất của bố mẹ. Nay bà Vàng Thị G khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy di chúc anh hoàn toàn đồng ý, lý do toàn bộ tài sản bố anh để lại cho bà Sùng Thị S là tài sản chung của bố mẹ và các con, nhưng bố anh tự ý quyết định phần tài sản của mẹ và các con là không đúng.

Chị Thào Thị O; Thào Thị P; Thào Thị S; Thào Thị T (con bà G và ông S) trình bày:

Các chị đều thống nhất với ý kiến trình bày của bà G và anh Thào Seo T và Thào A P, không có ý kiến gì thêm.

Tại bản án sơ thẩm số: 07/2019/DS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vàng Thị G đối với bà Sùng Thị S. Tuyên bố di chúc do bà Sùng Thị S xuất trình, có nội dung ông Thào Seo S để lại tài sản gồm 03 hecta đất rẫy và 01 diện tích đất ở trên đất có 01 ngôi nhà xây cấp 4, tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông cho bà Sùng Thị S, được lập ngày 18-11-2018 là vô hiệu.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 31-7-2019, bà Sùng Thị S làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu khởi kiện, người kháng cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và lời khai như trong quá trình giải quyết tại cấp sơ thẩm, đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn cho rằng bản di chúc ông Thào Seo S để lại tài sản cho bà Sùng Thị S lập ngày 18-11-2018 có nội dung vi phạm điểm b khoản 1 Điều 630 của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, hiện nay cha mẹ ông S vẫn còn sống, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không đưa cha mẹ ông S vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mặt khác, giữa bà S và ông S có một thời gian chung sống với nhau, bà S đã bán tài sản của bà ở huyện Đắk Glong để góp tiền với ông S làm nhà, đầu tư trồng cây cà phê, cao su sử dụng chung một thời gian, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm cũng không điều tra xác minh làm rõ công sức đóng góp của bà S trong phần di sản ông S để lại là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310

của Bộ luật Tố tụng dân sự chấp nhận kháng cáo của bà Sùng Thị S, huỷ bản án sơ thẩm số: 07/2019/DS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức giải quyết lại theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến:

- Về tố tụng: Người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm.

- Về nội dung: Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Sùng Thị S, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Xét yêu cầu kháng cáo của bà Sùng Thị S, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy:

[1]. Ông Thảo Seo S và bà Vàng Thị G chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 6 năm 1986, không đăng ký kết hôn, được hai gia đình tổ chức lễ cưới. Theo quy định tại điểm a khoản 3 của Nghị quyết số 35/2000/QH10, ngày 09-6-2000 thì trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; nếu có yêu cầu ly hôn thì được giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Như vậy, ông S, bà G chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1986, mặc dù không đăng ký kết hôn nhưng vẫn được pháp luật thừa nhận là quan hệ vợ chồng. Sau khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, ông bà chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết ly hôn và chia tài sản chung theo quy định của pháp luật. Việc ông S và bà S chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2017 là vi phạm điểm c khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

[2]. Đối với bản di chúc lập ngày 18-11-2018, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, ông Thảo Seo S đã nhờ ông Sùng A V lập di chúc với nội dung để lại tài sản gồm khoảng 03 ha đất rẫy và 01 căn nhà xây cấp 4 trên diện tích đất khoảng 20 x 30m tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông cho bà Sùng Thị S. Bản di chúc có chữ ký của ông Thảo Seo S, bà Sùng Thị S và người làm chứng Vàng A P, Sùng A V, Thảo A C, Thảo A S và Thảo Seo T (BL 55, 56).

[2.1]. Về hình thức của di chúc: Ông S đang điều trị tại bệnh viện và nhờ người khác viết bản di chúc nhưng không có xác nhận của người phụ trách bệnh viện. Mặt khác tại thời điểm lập di chúc người làm chứng anh Vàng A P không có mặt tại bệnh viện, sau đó anh Thảo Seo T đưa di chúc về nhà nhờ anh P ký là vi phạm Điều 634 và khoản 3 Điều 638 của Bộ luật Dân sự.

[2.2]. Về nội dung của di chúc: Đối với tài sản ông S lập di chúc để lại cho bà S có nguồn gốc do Trung đoàn 720 cấp khoảng 01ha, gia đình ông S khai hoang thêm khoảng 01ha và mua của anh Nguyễn Trọng T 01ha; đất ở gồm có 02 thửa đã làm nhà trong đó: 01 căn nhà hiện nay bà G cùng các con đang quản lý sử dụng, có nguồn gốc do Trung Đoàn 720 cấp và 01 căn nhà ông S lập di chúc để lại cho bà S, có nguồn gốc do ông S, bà G mua vào năm 2005, đều là tài sản chung của vợ chồng ông S, bà G và các con. Tại thời điểm lập di chúc, ông Thảo Seo S không có chứng cứ chứng minh tài sản ông để lại cho bà S là tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng của ông. Đây là tài sản được tạo lập trong thời gian ông S và bà G chung sống với nhau, là tài sản chung hợp nhất, có quyền ngang nhau trong việc sử dụng, định đoạt. Ông S, bà G chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho ly hôn và phân chia tài sản chung. Bà G cũng không có văn bản uỷ quyền cho ông S chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Do đó, ông S không có quyền tự định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Việc ông S tự mình định đoạt tài sản chung của vợ chồng là vi phạm Điều 213 của Bộ luật Dân sự. Mặt khác, nội dung bản di chúc ông S ra điều kiện bà S không được lấy người đàn ông nào khác, nếu tái lại cuộc

đời mới thì đi ra khỏi nhà; nếu con hoặc anh em ruột ai đến chăm sóc, lo cuộc sống cho bà S đến tuổi già thì tài sản thuộc quyền thừa kế cho người đến chăm lo. Ngoài ra còn có các điều kiện khác đã được thể hiện trong bản di chúc (BL 55, 56). Như vậy, nội dung của di chúc đã vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 630 của Bộ luật Dân sự.

[3]. Bà S cho rằng trước khi ông bà chung sống với nhau, ông S và bà G đã thỏa thuận chia tài sản, biên bản chia tài sản được lập tại nhà trưởng thôn anh Ma Seo P, do Công an viên Vàng A C trực tiếp lập. Tuy nhiên, lời khai của ông Ma Seo P và Vàng A C đều thể hiện từ năm 2015 đến nay các anh không tham gia việc chia tài sản chung giữa ông Thảo Seo S và bà Vàng Thị G. Năm 2015 các anh có lập biên bản về việc ông Thảo Seo S đi ngoại tỉnh với người khác ở xã Q, huyện Đ bị bà G và các con bắt quả tang, nên chở ông S về nhà thôn trưởng để lập biên bản, nội dung ông S cam kết với dòng họ gia đình từ nay không đi ngoại tỉnh nữa (BL 84, 85). Quá trình giải quyết bà S không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào chứng minh giữa ông S, bà G đã tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết phân chia tài sản cho ông S, bà G, lời khai của bà cũng không được bà G cùng các con của bà G thừa nhận. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự theo những chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án quy định tại khoản 4 Điều 91 của Bộ luật Tố tụng dân sự và tuyên bố di chúc của ông Thảo Seo S lập ngày 18-11-2018 bị vô hiệu là có căn cứ, đúng pháp luật. Do đó, kháng cáo của bà S là không có căn cứ. Tuy nhiên, bà S là người dân tộc thiểu số ở xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nên được miễn nộp tiền án phí quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà S phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là không phù hợp. Vì vậy, cần chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà S, sửa bản án sơ thẩm về phần án phí dân sự sơ thẩm.

[4]. Xét quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tại phiên tòa là có căn cứ chấp nhận. Quan điểm đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn là không có căn cứ bởi lẽ: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu hủy di chúc, nên cấp sơ thẩm chỉ xem xét di chúc có hợp pháp hay không, chứ không yêu cầu chia di sản thừa kế, nên không cần thiết phải đưa cha mẹ ông S vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, đồng thời cũng không cần thiết phải điều tra, xác minh làm rõ công sức đóng của bà S trong phần di sản ông S để lại. Trường hợp bà S có đầy đủ chứng cứ chứng minh bà có góp tiền cho ông S làm nhà và trồng cây trên đất thì bà có quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác.

[5]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do bản án bị sửa và bà S là đối tượng được miễn án phí, nên bà S không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309, khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 624, điểm b khoản 1 Điều 630; Điều 634; khoản 3 Điều 638 của Bộ luật dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà Sùng Thị S, sửa bản án sơ thẩm số: 07/2019/DS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông về phần án phí dân sự sơ thẩm.

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Vàng Thị G đối với bà Sùng Thị S.

1. Tuyên bố di chúc có nội dung ông Thào Seo S để lại tài sản gồm 03 hecta đất rẫy và diện tích đất ở, trên đất có 01 căn nhà xây cấp 4, tại bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông cho bà Sùng Thị S, lập ngày 18-11-2018 bị vô hiệu.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Miễn toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bà Sùng Thị S. Trả lại cho bà Vàng Thị G 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0000705 ngày 18-3-2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

3. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Sùng Thị S không phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

PHỤ LỤC V

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bản án số: 407/2020/DSPT
Ngày: 21/10/2020
V/v: “*Tranh chấp chia thừa kế*”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Như Lâm

Các Thẩm phán: Bà Hoàng Thị Thu Lan
Ông Đỗ Minh Hoàng

- *Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà Hoàng Thị Thu Hiền – Thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Mai Thanh- Kiểm sát viên.

Ngày 21/10/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 369/2019/DSPT ngày 02/12/2019 về việc “*Tranh chấp chia thừa kế*”;

Do bản án dân sự sơ thẩm số 39/2019/DS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 53/2020/QĐ-PT ngày 11/02/2020 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn:

1.1. Bà Phạm Thị Vượng; sinh năm: 1954. Vắng mặt tại phiên tòa.

1.2. Bà Phạm Thị Liễu; sinh năm: 1959. Vắng mặt tại phiên tòa.

Bà Vượng, bà Liễu cùng trú tại: Số 5 phố Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 6 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

1.3. Ông Phạm Văn Vỹ; sinh năm: 1961. Vắng mặt tại phiên tòa.

Trú tại: Số 44 Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 5 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

1.4. Bà Phạm Thị Uyên; sinh năm: 1965. Vắng mặt tại phiên tòa.

Trú tại: Số 18 phố Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 3 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

1.5. Ông Phạm Văn Dân; sinh năm: 1966. Vắng mặt tại phiên tòa.

Trú tại: Số 5 phố Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 6 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền của các đồng nguyên đơn:

1. Bà Trần Thị Bích Hợp; sinh năm: 1962. Có mặt tại phiên tòa

Trú tại: Số 5 Tổ 6 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Ông Trần Quốc Hùng; sinh năm: 1987. Vắng mặt tại phiên tòa.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 9 tầng 37 A7 khu đô thị An Bình, thành phố Giao Lưu, 232 phố Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Văn Vỹ là Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng; người đại diện theo pháp luật ông Lê Hiếu - Chức vụ: giám đốc; công ty cử bà Đoàn Thị Hồng, sinh năm: 1995 tham gia phiên tòa; địa chỉ liên hệ: Tầng 7 số nhà 31 tổ 6A, phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Bà Hồng có mặt tại phiên tòa.

2. Bị đơn: Anh Đoàn Văn Thông; sinh năm: 1970; hộ khẩu thường trú: Thôn Nội, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội; trú tại: Số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, vụ án có nội dung như sau:

Tại đơn khởi kiện ngày 20/10/2017, đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện ngày 07/5/2019, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, các đồng nguyên đơn – bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân do anh Trần Quốc Hùng là đại diện trình bày:

Cụ Nguyễn Hữu Hành và cụ Cao Thị Tít kết hôn có ba người con chung là bà Nguyễn Thị Thái (sinh năm: 1929), ông Nguyễn Văn Hảo (sinh năm: 1937), ông Nguyễn Hữu Hòa (sinh năm: 1947). Cụ Hành, cụ Tít chết đã lâu. Bà Thái chết năm 1988, ông Hòa chết năm 1968, ông Hảo chết năm 2016. Ông Hảo, ông Hòa không có vợ, con. Bà Thái có chồng là Phạm Văn Dân, có 05 người con chung là Phạm Thị Vượng, Phạm Thị Liễu, Phạm Văn Vỹ, Phạm Thị Uyên, Phạm Văn Dân. Ông Dân chết năm 2005.

Ông Hảo có một căn hộ tại số 448B Nhà D5 Tập thể Quỳnh Lôi nay là số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Năm 2016 ông Hảo đột ngột qua đời, khi chết không để lại di chúc. Anh Đoàn Văn Thông là người ở nhờ đã làm thủ tục mai táng và hiện đang chiếm giữ nhà đất của ông Hảo. Sau khi biết tin ông Hảo mất các ông bà đã xuống có đơn với tổ dân phố và nói chuyện với anh Thông để các ông bà được đứng ra làm ma cho ông Hảo nhưng không được sự đồng ý. Sau khi mai táng cho ông Hảo xong, các ông bà đã nhiều lần xin anh Thông bàn giao tro cốt của ông Hảo để các ông bà chôn cất nhưng anh Thông không đồng ý và cũng không cho ông bà vào nhà. Ngôi nhà của ông Hảo còn là nơi thờ cúng ông bà ngoại và cậu liệt sỹ. Vậy mà anh Thông đã tự ý chiếm đoạt nhà, việc mai táng để cậu yên nghỉ chưa thực hiện xong. Nay ông bà làm đơn đề nghị Tòa án xem xét, buộc anh Thông trả lại nhà

đất tại số 448D Nhà D Tập thể Quỳnh Lôi, nay là số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho các ông bà. Buộc anh Thông phải bàn giao lại tro cốt của ông Hảo, không gây cản trở để gia đình ông bà đưa ông Hảo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 07/5/2019 các ông bà có đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, cụ thể: xin rút lại yêu cầu buộc anh Đoàn Văn Thông trả lại tro cốt của ông Nguyễn Văn Hảo để làm thủ tục mai táng tại quê nhà, thay vào đó ông bà yêu cầu Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng phân chia di sản thừa kế mà ông Nguyễn Văn Hảo để lại.

Đề nghị Tòa án phân chia cho ông Phạm Văn Dân được hưởng hiện vật toàn bộ di sản trên và ông Dân có trách nhiệm thanh toán giá trị kỷ phần cho bà Vượng, bà Liễu, bà Uyên, ông Vỹ. Ngoài ra các đồng nguyên đơn không có yêu cầu nào khác.

Tại bản tự khai, đơn trình bày, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là anh Đoàn Văn Thông trình bày:

Từ năm 1993 anh được tuyển vào đào tạo diễn viên tại Nhà hát cải lương Trung ương nay là Nhà hát cải lương Việt Nam, anh được ông Nguyễn Văn Hảo nhận làm con nuôi. Lý do ông Hảo không lập gia đình là vì bệnh tật nên đã nhận anh làm con nuôi để chăm sóc, giúp đỡ và ông Hảo tạo điều kiện giúp đỡ anh ăn học cho tới khi anh trưởng thành, đi làm có lương. Còn anh giúp ông Hảo khi ốm đau bệnh tật, đi viện, sửa chữa nhà cửa. Khi ông Hảo lâm bệnh nhiều lần anh phải đưa ông đi bệnh viện chữa trị bệnh tim mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi ông Hảo còn sống, hàng năm vào dịp tết thanh minh anh đều đưa ông về quê ở Cổ Nhuế để thắp hương các cụ. Ông Hảo có ba chị em, em trai là Nguyễn Hữu Hòa – Liệt sỹ đã hy sinh trong kháng chiến tại mặt trận phía Nam, còn chị gái là Nguyễn Thị Thái đã mất cách đây mấy chục năm. Khi chị gái còn sống giữa hai chị em có mâu thuẫn tranh chấp tới mức đoạn tuyệt tình cảm, từ mặt nhau. Nay chỉ có mấy người anh em họ liên quan về phía nhà ông chú của ông Hảo, rất nhiều lần anh cho ông Hảo đi viện anh đều gọi điện báo cho mấy cô chú biết nhưng không có ai đến. Ngày mùng 04/02/2016 anh phải đưa ông Hảo vào viện cấp cứu và đến 16h ông Hảo mất tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến trưa ngày hôm sau có cô Thúy là chị em bên nội của ông Hảo và con trai tới đòi lo tang cho ông Hảo mặc kệ lời giải thích của bà con xóm phố và các bác cán bộ Ủy ban nhân dân phường nói về lời căn dặn của ông Hảo. Anh đã trả lại cho mẹ con cô Thúy giấy tờ và chìa khóa nhà. Nhưng đến 19h mẹ con cô Thúy báo lại là họ hàng bên nội đã bàn bạc không lo tang cho ông Hảo vì sợ không làm đúng như lời căn dặn và di chúc của ông Hảo và trả lại giấy tờ, chìa khóa để anh lo tang lễ cho ông theo đúng nguyện vọng của ông. Trước ngày ông Hảo mất 01 ngày, vào chiều ngày 03/02/2016 có ba đồng chí cán bộ phường là bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt (Bí thư Chi bộ Cụm dân cư số 4), bà Lê Thị Liên (Trưởng ban công tác mặt trận Cụm dân cư số 4), bà Dương Thị Thuận (Tổ trưởng Tổ 4B), ba bà đến chúc tết vì ông Hảo thuộc diện gia đình chính sách, thờ cúng liệt sỹ, lúc đó ông Hảo đã dặn dò và nói nguyện vọng của ông. Đó chính là di chúc của ông Hảo đã được cán bộ phường xác nhận và công chứng tại trụ sở Văn phòng Luật sư Trường Giang và trụ sở Văn phòng Công chứng Bảo Việt. Ông Hảo đã dặn dò và nói nguyện vọng sau cùng của ông là cho anh căn nhà tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường

Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ trước đó, ông Hảo đã đưa cho anh giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà do Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cấp ngày 26/01/2011 đứng tên ông Hảo và các giấy tờ khác như sổ lương, sổ bảo hiểm, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Ông Hảo nhờ các ông bà cán bộ phường Quỳnh Lôi giúp đỡ và đó chính là lời di chúc bằng miệng của ông.

Khi anh đang làm thủ tục chuẩn bị lo tang lễ cho ông Hảo thì xuất hiện chị Trần Thị Bích Hợp tự giới thiệu là cháu dâu họ bên ngoại đến đòi chia sẻ cúng viếng và tang lễ, cản trở việc anh lo tang và đòi chìa khóa nhà, đòi lấy nhà của ông Hảo và chỗ thờ cúng liệt sỹ, nhiều lần gọi điện đe dọa, xúc phạm anh. Ủy ban nhân dân phường Quỳnh Lôi đã cử các ban ngành có thẩm quyền cùng bà con khu phố đã quyết định là anh đứng ra lo tang lễ cho ông Hảo theo đúng nguyện vọng của ông. Khi còn sống không thấy ông Hảo nhắc đến tên chị Hợp. Vì vậy, anh cũng không biết chị Hợp là ai. Nguyên vọng của anh là mong Tòa án xem xét, giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật.

Tại Đơn yêu cầu phản tố ngày 24/6/2019, anh Đoàn Văn Thông trình bày:

Anh đề nghị Tòa án công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo do bà Lê Thị Liên, bà Dương Thị Thuận xác nhận ngày 05/02/2016 tại Văn phòng Luật sư Trường Giang được Văn phòng Công chứng Bảo Việt chứng nhận có hiệu lực pháp luật.

Tại Đơn đề nghị ngày 09/7/2019, đại diện của các đồng nguyên đơn – anh Trần Quốc Hùng trình bày ý kiến về yêu cầu phản tố:

Các đồng nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu phản tố của bị đơn và giấy xác nhận di chúc miệng của bà Thuận, bà Liên lập ngày 05/02/2016 vì:

+ Ngày 03/02/2016 nhân dịp tết Nguyên đán, bà Thuận, bà Liên đến thăm và chúc tết ông Hảo là diện chính sách thờ cúng liệt sỹ. Khi đó, ông Hảo có tâm sự rằng ông có ý nguyện để lại tài sản cho anh Đoàn Văn Thông. Tại thời điểm này ông Hảo vẫn khỏe mạnh, sáng suốt và minh mẫn, ông chưa có ý định lập di chúc hay đem tài sản tặng cho bất kỳ ai. Mặc dù, tại thời điểm này ông Hảo có đủ điều kiện về sức khỏe, ý chí để có thể lập di chúc, hơn nữa bà Liên, bà Thuận còn khuyên ông Hảo lập di chúc để đem chứng thực tại phường xã nhưng lúc này ông Hảo chưa muốn lập. Như vậy, việc ông Hảo có ý nguyện để lại tài sản cho anh Thông chỉ là dự định chưa phải là ý chí cuối cùng của ông. Theo khoản 1 Điều 629 Bộ luật Dân sự quy định về điều kiện để lập di chúc miệng là khi tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Lúc này ông Hảo chưa bị đe dọa đến tính mạng, ông vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ, bình thường với mọi người, ý nguyện để lại tài sản cho anh Thông chỉ là câu chuyện vui giữa ông Hảo và các vị khách đến chơi nhà, do vậy giấy xác nhận di chúc miệng do bà Thuận và bà Liên tự lập ra ngày 05/02/2016 không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 629 Bộ luật Dân sự.

+ Theo quy định tại khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự quy định di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng

thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Tại thời điểm ông Hảo thể hiện ý chí cuối cùng của mình, ông Hảo không mời bà Liên, bà Thuận đến nhà để chứng kiến việc để lại di chúc cho anh Thông, ông Hảo cũng không nói với bà Thuận, bà Liên là sẽ để lại tài sản cho anh Thông. Giấy xác nhận di chúc miệng của bà Thuận, bà Liên được lập nên chỉ là câu chuyện vui khi hai bà đến chơi nhà trong dịp tết nguyên đán. Mặt khác, khi ông Hảo chết, bà Thuận, bà Liên không xác nhận di chúc miệng ngay thời điểm đó mà mãi đến ngày 05/02/2016 sau khi ông Hảo chết hai ngày, bà Thuận, bà Liên mới đi xác nhận là có di chúc miệng và đem đi công chứng. Như vậy, di chúc miệng mà bà Thuận, bà Liên xác nhận không đảm bảo đủ điều kiện về di chúc miệng hợp pháp mà pháp luật quy định.

+ Giấy xác nhận của bà Thuận được chứng thực tại hai nơi, một là tại trụ sở Văn phòng Luật sư Trường Giang và trụ sở Văn phòng Công chứng Bảo Việt. Việc một văn bản chứng thực tại hai địa điểm khác nhau là không đúng quy định pháp luật về công chứng, chứng thực. Việc này càng chứng tỏ việc lập giấy xác nhận di chúc miệng này là sự dối phó, hợp thức hóa của anh Thông để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông Hảo.

Vì vậy, đề nghị Tòa án bác bỏ yêu cầu phản tố của bị đơn, tuyên giấy xác nhận di chúc miệng này không có giá trị pháp lý.

Tại các bản tự khai người làm chứng là bà Dương Thị Thuận, bà Lê Thị Liên trình bày:

Ngày 03/02/2016 (tức ngày 25 tết âm lịch) các bà gồm có: Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Bí thư chi bộ, bà Lê Thị Liên - Trưởng ban công tác mặt trận, bà Dương Thị Thuận - Tổ trưởng Tổ 4B, đến nhà ông Nguyễn Văn Hảo là gia đình thờ cúng liệt sĩ, để chúc tết gia đình chính sách. Sau khi các bà chúc tết xong thì ông Hảo có nói với các bà: Ông đang bị đau ở ngực (vì lâu nay ông Hảo mắc bệnh suy tim), ông nói tôi không biết có còn sống được bao lâu nữa nên tôi có giao sổ đỏ, các giấy tờ khác cho cháu Thông lâu nay vẫn ở đây với tôi và tôi đã coi cháu như con sau này tôi có chết thì cháu lo ma cho tôi và nó đưa tôi về quê nhà nó ở Mỹ Đức vì tôi không có vợ con nên nếu tôi có chết nhờ các bà lãnh đạo phường cùng cháu Thông lo liệu cho tôi. Sau khi ông Hảo nói xong thì bà Nguyệt có động viên và nhắc ông Hảo phải đi chữa bệnh, còn việc có cho cháu Thông tài sản thì ông phải ra phường làm thủ tục sang tên quyền sở hữu. Khi ông Hảo nói với các bà, ông Hảo hoàn toàn tỉnh táo nhưng sau đó anh Thông đưa ông Hảo đi bệnh viện Thanh Nhàn và đến chiều ngày 04 tháng 02 năm 2016 (tức ngày 26 Tết) thì ông Hảo chết tại bệnh viện.

Ngày 05/02/2016 bà Liên và bà Thuận đã ra Văn phòng Luật sư Trường Giang để làm thủ tục lập di chúc miệng cho ông Hảo, do bà Nguyệt đi lại khó khăn nên không đi và Luật sư cũng hướng dẫn chỉ cần hai người làm chứng là được nên bà Nguyệt không cùng xác nhận di chúc miệng của ông Hảo. Văn phòng Luật sư đã hướng dẫn về mặt thủ tục, tư vấn cho các bà, sau đó giới thiệu Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Bảo Việt và mời Công chứng viên đến Văn phòng Luật sư Trường Giang làm thủ tục chứng nhận di chúc miệng của ông Hảo.

Khi ông Hảo còn sống các bà chỉ thấy bà Nguyễn Thị Bích là em họ bên nội của ông Hảo thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi ông Hảo ngoài ra các bà không thấy bất kì ai khác đến thăm nom chăm sóc ông Hảo. Hàng ngày có anh Thông chăm lo chăm sóc cho ông Hảo, hai người coi nhau như bố con. Ông Hảo có nói chuyện và giới thiệu với các bà là anh Đoàn Văn Thông là con nuôi của ông. Các bà thấy anh Thông thường xuyên ở nhà ông Hảo chăm sóc ông Hảo rất tận tâm, coi như người cha của mình. Vì là công tác mặt trận nên các bà mới quen biết ông Hảo và anh Thông chứ các bà không có mối quan hệ họ hàng gì. Vì điều kiện sức khỏe nên các bà xin được vắng mặt trong toàn bộ quá trình Tòa án giải quyết vụ án, các buổi làm việc, phiên họp và hòa giải, các phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án.

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai, người làm chứng là bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt trình bày:

Bà giữ chức Bí thư chi bộ khu dân cư D (nay là địa bàn dân cư số 4) phường Quỳnh Lôi từ năm 2012 đến năm 2017. Hàng năm đại diện các đoàn thể của khu dân cư có tổ chức đến thăm và chúc tết gia đình chính sách. Ông Nguyễn Văn Hảo (trú tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai) là gia đình thờ cúng liệt sỹ nên thuộc diện gia đình chính sách của địa phương. Ông Hảo thờ em trai là liệt sỹ Nguyễn Hữu Hòa. Chiều ngày 03/02/2016 (tức ngày 25/12/2015 âm lịch) bà cùng bà Dương Thị Thuận là tổ trưởng và bà Lê Thị Liên là trưởng ban công tác mặt trận địa bàn dân cư số 4, ba người đại diện của tổ dân cư đến chúc tết gia đình ông Nguyễn Văn Hảo. Sau khi chúc tết xong, ông Hảo có nói với các bà là: “Hiện tôi rất đau ngực (vì ông bị bệnh suy tim từ lâu), không biết sống chết được bao lâu, tôi đã dặn cháu Thông (anh Đoàn Văn Thông, sống với ông Hảo từ lâu, coi nhau như bố con), lâu nay vẫn ở với tôi, tôi coi như con, khi nào tôi chết thì cháu Thông đứng ra lo ma cho tôi và đưa tôi về quê nhà cháu để chôn, tôi đã về quê để thăm gia đình cháu, tôi rất ưng, tôi cũng đã xem đất ở quê của cháu Thông, tôi thấy rất tốt. Thông là người lo tang lễ cho tôi, còn nhà đất của tôi ở đây tôi cho cháu Thông. Tôi đã đưa Sổ đỏ quyền sử dụng đất và các giấy tờ cho cháu Thông”. Bà có nói thêm với ông Hảo là ông phải ra phường làm giấy ủy quyền cho cháu Thông và động viên ông Hảo đi khám bệnh. Ông Hảo có nói lại là: “Cứ biết vậy thôi nhưng tôi vẫn trình bày với các bà vậy để nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhờ các bà biết ý tôi mà giúp đỡ cho cháu”. Khi đó sức khỏe của ông Hảo yếu và rất mệt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, minh mẫn. Khi ông Hảo dặn lại các bà như vậy thì không có anh Thông ở đó. Đến 16h ngày hôm sau (26 tết) ông Hảo mất tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Bà Thuận đã thông báo cho tôi tin đó. Sau đó bà Liên, bà Thuận có trao đổi với bà về việc ra phường công chứng để xác nhận lại di chúc miệng của ông Hảo. Nhưng bà từ chối vì bà bị đau chân, đi lại khó khăn mà bà là bí thư chi bộ, còn ông Hảo không phải là đảng viên, chỉ là công dân của tổ dân phố nên bà Liên, bà Thuận đứng ra xác nhận là phù hợp. Vì vậy mà bà đã không ra phòng công chứng để xác nhận di chúc miệng của ông Hảo cùng bà Liên, bà Thuận. Về mối quan hệ của ông Hảo và anh Thông, từ nhiều năm nay anh Thông ở cùng ông Hảo, có mối quan hệ thân thiết, anh Thông ở cùng chăm sóc hàng ngày và đưa ông Hảo đi khám chữa bệnh khi ông Hảo ốm đau. Ông Hảo vẫn nhận anh Thông là con của ông khi nói chuyện với các bà nhưng không làm thủ tục nhận con nuôi. Ông Hảo không có vợ con, quê ở Cổ

Nhuế. Quá trình sống ở đây, bà không thấy anh em họ hàng nào của ông Hảo qua lại, chỉ có bà Nguyễn Thị Bích là em họ thỉnh thoảng có qua lại thăm nom ông, ngoài ra không có ai khác. Về việc giấy tờ nhà đất và các giấy tờ khác của ông Hảo, từ sau khi ông Hảo mất, anh Thông có gọi điện báo tin cho anh em bên nội của ông Hảo. Khi anh em ông Hảo xuống thì anh Thông có giao giấy tờ nhà đất và các giấy tờ khác của ông Hảo cho anh em ông Hảo. Sau đó phía anh em ông Hảo không thống nhất được việc lo mai táng cho ông Hảo nên lại giao lại cho anh Thông, vì vậy anh Thông đã đứng ra lo ma chay cho ông Hảo và đưa đi hỏa táng ở Văn Điển. Anh Thông sống ở địa phương rất tốt, nhiệt tình tham gia phong trào của địa phương, chấp hành tốt chính sách và quy định của địa phương. Vì điều kiện sức khỏe nên bà xin được vắng mặt trong toàn bộ quá trình Tòa án giải quyết vụ án, các buổi làm việc, phiên họp và hòa giải, các phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án.

Tại bản tự khai, người làm chứng ông Đào Duy Hoàng - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Bảo Việt trình bày:

Ngày 05/02/2016, Luật sư Lê Đăng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trường Giang có liên hệ với Văn phòng Công chứng Bảo Việt với mục đích là chứng thực việc lập di chúc miệng của cụ Nguyễn Văn Hảo cho hai bà Dương Thị Thuận và bà Lê Thị Liên. Văn phòng Công chứng Bảo Việt đã cử ông là Công chứng viên thực hiện việc chứng thực đó. Ông đã đến Văn phòng Luật sư Trường Giang, tại đó bà Dương Thị Thuận và bà Lê Thị Liên đã viết Giấy xác nhận di chúc miệng của cụ Nguyễn Văn Hảo ghi lại ý nguyện của cụ Hảo, sau khi lập Giấy xác nhận di chúc miệng đó, hai bà đã ký tên xác nhận trước mặt ông, sau đó ông đưa hai Giấy xác nhận trên về Văn phòng Công chứng lập lời chứng đóng dấu và trả văn bản công chứng cho công dân.

Về quan hệ, ông là Công chứng viên không có bất cứ quan hệ thân thiết hay quan hệ xã hội nào với bà Liên, bà Thuận, ông Thông, ông Hảo. Ông cam đoan việc chứng thực chữ ký, điểm chỉ tại hai văn bản Giấy xác nhận di chúc miệng là khách quan, đúng sự thật, đúng quy định pháp luật. Vì điều kiện công tác nên ông xin được vắng mặt tại các buổi làm việc, phiên tòa tham gia xét xử vụ án.

Tại bản tự khai, người làm chứng ông Lê Đăng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trường Giang trình bày:

Ngày 05 tháng 02 năm 2016 Văn phòng Công chứng Bảo Việt có chứng thực Giấy xác nhận di chúc miệng cho bà Lê Thị Liên, bà Dương Thị Thuận đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Hảo tại địa phương chết không để lại di chúc. Hai văn bản này ghi chứng thực tại trụ sở Văn phòng Công chứng Bảo Việt và Văn phòng Luật sư Trường Giang. Thời điểm đó, sau khi ông Hảo chết, hai bà Lê Thị Liên, Dương Thị Thuận đến Văn phòng Luật sư Trường Giang hỏi về di chúc miệng của ông Hảo, ông đã tư vấn và giới thiệu cho Công chứng viên Đào Duy Hoàng - Văn phòng Công chứng Bảo Việt. Trong quá trình thực hiện việc công chứng, bà Liên, bà Thuận cùng Công chứng viên Hoàng có thực hiện tại Văn phòng Luật sư Trường Giang. Ông đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Ông xin được vắng mặt tại các buổi làm việc, các phiên tòa xét xử vụ án.

Bản án dân sự sơ thẩm số 39/2019/DSST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã Xứ:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân đối với anh Đoàn Văn Thông về việc chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông Nguyễn Văn Hảo là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Đoàn Văn Thông đối với bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân về việc yêu cầu công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo là hợp pháp.

3. Công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo do bà Lê Thị Liên và bà Dương Thị Thuận ghi chép lại tại Giấy xác nhận di chúc miệng ngày 05/2/2016, được Văn phòng Công chứng Bảo Việt chứng thực ngày 05/02/2016 là hợp pháp.

4. Di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo có hiệu lực pháp luật từ ngày 04/02/2016.

5. Về nội dung di chúc: Xác định anh Đoàn Văn Thông là người thực hiện nghĩa vụ lo tang lễ cho ông Nguyễn Văn Hảo và đưa ông Nguyễn Văn Hảo về quê anh Đoàn Văn Thông tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để chôn cất.

Xác định anh Đoàn Văn Thông là người được hưởng thừa kế di sản là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của ông Nguyễn Văn Hảo.

Anh Đoàn Văn Thông có trách nhiệm đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên nhà đất theo quy định pháp luật.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bác các yêu cầu khác của các đương sự.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí, quyền kháng cáo, quyền thi hành án của các đương sự.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ngày 20/9/2019 các đồng nguyên đơn kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm sửa toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng chia thừa kế theo pháp luật đối với căn nhà số 9, ngách 204/3 phố Hồng Mai, Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Tại phiên hôm nay:

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Văn Vỹ- nguyên đơn là chị Đoàn Thị Hồng trình bày vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu kháng cáo

và trình bày luận cứ để bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử Bác yêu cầu phản tố của bị đơn ông Đoàn Văn Thông theo đơn phản tố ngày 24/6/2019; buộc ông Đoàn Văn Thông trả lại căn nhà số 9, ngách 204/3 phố Hồng Mai, Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Để các nguyên đơn thờ cúng ông Hòa, ông Hảo.

Người đại diện theo ủy quyền của các đồng nguyên đơn là bà Trần Thị Bích Hợp trình bày thống nhất với lời trình bày của bà Đoàn Thị Hồng không có ý kiến gì khác.

Bị đơn là anh Đoàn Văn Thông giữ nguyên yêu cầu phản tố và đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết nội dung vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm:

Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa thực hiện đúng, đầy đủ các bước tố tụng theo quy định của pháp luật kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi nghị án.

Các đương sự chấp hành đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Đơn kháng cáo của các đồng nguyên đơn làm trong hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí đầy đủ nên được coi là hợp lệ về hình thức.

Về nội dung: Sau khi phân tích nội dung vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa Nhận thấy:

1. Về hình thức: Các đồng nguyên đơn làm đơn kháng cáo trong hạn luật định, đã nộp dự phí kháng cáo về hình thức là hợp lệ.

Tại phiên tòa ngày hôm nay các đương sự không xuất trình được thêm tài liệu, chứng cứ gì mới.

2. Về nội dung: xét kháng cáo của các đồng nguyên đơn.

2.1. Về huyết thống:

Ông Nguyễn Văn Hảo sống không có vợ con, bố mẹ đẻ của ông Nguyễn Văn Hảo là cụ Nguyễn Hữu Hành và cụ Cao Thị Tít đã chết từ lâu. Ông Hảo có ba chị em ruột là bà Nguyễn Thị Thái, sinh năm: 1929 và ông Nguyễn Hữu Hòa, sinh năm: 1947. Bà Thái chết năm 1988, ông Hòa chết năm 1968 là liệt sỹ. Ông Hòa không có vợ con, bà Thái có chồng là ông Phạm Văn Dẫn, sinh năm: 1923; ông Dẫn chết năm 2005. Bà Thái và ông Dẫn có 05 người con đẻ là: bà Phạm Thị Vượng, sinh năm: 1957; bà Phạm Thị Liễu, sinh năm: 1959; ông Phạm Văn Vỳ,

sinh năm: 1961; bà Phạm Thị Uyên, sinh năm: 1965; ông Phạm Văn Dân, sinh năm: 1966 ngoài ra bà Thái không có con đẻ, con nuôi nào khác. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 xác định bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân là người thuộc hàng thừa kế thứ ba của ông Nguyễn Văn Hảo. Vì vậy, bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế đối với tài sản của ông Hảo là phù hợp với Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

2.1. Về thời hiệu khởi kiện:

Ông Nguyễn Văn Hảo chết ngày 04/02/2016, căn cứ khoản 1 Điều 633 Bộ luật Dân sự năm 2005; Hội đồng xét xử xác định thời điểm mở thừa kế của ông Nguyễn Văn Hảo là ngày 04/02/2016. Ngày 26/10/2017 bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông Nguyễn Văn Hảo. Căn cứ Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 vụ án còn thời hiệu khởi kiện.

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 20/10/2017 các bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân đề nghị Tòa án chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông Hảo, yêu cầu anh Đoàn Văn Thông trả lại nhà số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và trả lại tro cốt của ông Hảo cho các ông bà.

Ngày 07/5/2019 các đồng nguyên đơn có Đơn sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện, nội dung: Xin rút yêu cầu buộc anh Đoàn Văn Thông trả lại tro cốt của ông Nguyễn Văn Hảo để các ông bà mai táng tại quê nhà và thay vào đó là yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Văn Hảo theo quy định pháp luật. Việc rút một phần yêu cầu khởi kiện và thay đổi yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn là phù hợp với Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 nên Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận là có căn cứ.

2.3. Về di sản thừa kế :

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như các lời trình bày của các đương sự Hội đồng xét xử xét thấy di sản của ông Nguyễn Văn Hảo để lại là nhà đất tại địa chỉ Căn hộ 448b, nhà D5, Tập thể Quỳnh Lôi (số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) đã được Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 455534 ngày 26/01/2011 đứng tên ông Nguyễn Văn Hảo. Ngoài ra ông Hảo không để lại tài sản nào khác.

2.4. Xét yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật của các đồng nguyên đơn và yêu cầu phản tố của bị đơn:

Các đồng nguyên đơn yêu cầu Tòa án phân chia di sản thừa kế của ông Nguyễn Văn Hảo để lại là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật. Cụ thể, phân chia cho ông Phạm Văn Dân được hưởng hiện vật toàn bộ di sản trên và ông Dân có trách nhiệm thanh toán giá trị kỷ phần cho bà Vượng, bà Liễu, bà Uyên, ông Vỹ. Ngoài ra các đồng nguyên đơn không có yêu cầu nào khác.

Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, các đồng nguyên đơn không chấp nhận, không đồng ý hai giấy xác nhận di chúc miệng do bà Lê Thị Liên, bà Dương Thị Thuận tự viết ra ngày 05/02/2016 vì không đáp ứng điều kiện quy định của Bộ luật Dân sự. Đề nghị Tòa án bác yêu cầu phản tố của bị đơn, tuyên hai giấy xác nhận di chúc miệng không có giá trị pháp lý.

Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm bị đơn là anh Đoàn Văn Thông xuất trình cho Tòa án hai bản Giấy xác nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo do bà Lê Thị Liên và bà Dương Thị Thuận ghi lại tại Văn phòng Luật sư Trường Giang và được Văn phòng Công chứng Bảo Việt chứng thực ngày 05/2/2016. Anh Thông cho rằng đó chính là di chúc của ông Hảo đã được cán bộ phường xác nhận và công chứng tại trụ sở Văn phòng Luật sư Trường Giang và trụ sở Văn phòng Công chứng Bảo Việt. Anh Thông đề nghị Tòa án công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo tại hai Giấy xác nhận trên là hợp pháp.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy Về mối quan hệ của ông Hảo và anh Thông: Qua lời khai của anh Thông bà Liên, bà Thuận, bà Nguyệt, bà Bích (em họ của ông Hảo) thì giữa anh Thông và ông Hảo tuy không đến cơ quan Nhà nước để làm thủ tục nhận cha – con nuôi nhưng do ông Hảo không có vợ con nên từ nhiều năm nay anh Thông đã qua lại sinh sống cùng ông Hảo, hai người nhận nhau là bố con. Hằng ngày anh Thông đi làm còn tối về với ông Hảo, chăm sóc ông khi ốm đau, đưa ông đi khám chữa bệnh. Khi ông Hảo chết anh Thông là người đứng ra lo ma chay cho ông Hảo.

Về sức khỏe của ông Hảo tại thời điểm lập di chúc miệng: Bà Liên, bà Thuận, bà Nguyệt cùng trình bày: Ngày 03/02/2016 khi cán bộ đại diện các ban ngành của phường đến chúc tết ông Hảo, do ông Hảo bị bệnh suy tim lâu ngày nên rất yếu. Tuy nhiên, ông Hảo vẫn nói chuyện, trao đổi với các bà được. Đến ngày 04/02/2016 ông Hảo phải vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu và đến 16h cùng ngày ông Hảo chết. Như vậy, có thể xác định tại thời điểm ngày 03/02/2016 ông Hảo rất yếu và không thể tự mình lập di chúc được nhưng đầu óc ông Hảo vẫn minh mẫn, tỉnh táo.

Về người làm chứng là bà Lê Thị Liên, bà Dương Thị Thuận, bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt: Bà Liên, bà Thuận, bà Nguyệt không có quan hệ họ hàng với ông Hảo, không phải là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của ông Hảo, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung ý nguyện, di chúc của ông Hảo. Các bà đều là những người đại diện các ban ngành có uy tín tại địa phương nơi ông Hảo sinh sống. Vì vậy, việc bà Liên, bà Thuận là người làm chứng là phù hợp với Điều 654 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Về việc ghi chép lại di chúc miệng và công chứng: Theo quy định của pháp luật thì việc lập di chúc miệng phải trước mặt ít nhất hai người làm chứng, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.

Ngày 03/02/2016 ông Hảo có di chúc miệng với các bà Liên, Nguyệt, Thuận. Ngày 04/02/2016 ông Hảo chết. Ngày 05/02/2016 bà Liên, bà Thuận đã ghi lại di chúc miệng của ông Hảo và đã ký tên, điền chỉ trong Giấy xác nhận di chúc miệng tại Văn phòng Luật sư Trường Giang Giang. Sau đó, cán

bộ công chứng đã đưa hai văn bản trên về trụ sở Văn phòng Công chứng Bảo Việt để lập lời chứng đóng dấu và trả văn bản công chứng cho công dân.

Như vậy, việc ghi chép lại di chúc miệng và việc công chứng này là phù hợp với Điều 44, Điều 46 Luật Công chứng năm 2014 và khoản 5 Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Về nội dung di chúc miệng: Nguyên vọng của ông Hảo là giao tài sản của mình là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội cho anh Đoàn Văn Thông, anh Thông có nghĩa vụ đứng ra lo tang lễ và đưa ông Hảo về quê của anh Thông tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để chôn cất. Hội đồng xét xử xét thấy nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội được Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 455534 ngày 26/01/2011 đứng tên ông Nguyễn Văn Hảo. Nhà đất trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông Hảo. Vì vậy, ông Hảo có quyền định đoạt tài sản của mình. Thực tế sau khi ông Nguyễn Văn Hảo mất anh Đoàn Văn Thông đã thực hiện các nội dung đúng như di chúc miệng mà ông Nguyễn Văn Hảo để lại,

Hội đồng xét xử xét thấy những lời ông Hảo nói với bà Nguyệt, bà Liên, bà Thuận cho thấy đó là mong muốn, nguyện vọng và ý chí của ông Hảo khi bản thân ông hiểu được tình trạng sức khỏe của mình đã rất yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nguyên đơn cho rằng đó là lời nói chuyện, tâm sự với những người khách đến chơi nhà trong dịp tết không phù hợp với thực tế vì sau khi nói với các bà Nguyệt, bà Liên, bà Thuận hôm trước thì hôm sau ông Hảo chết. Rõ ràng, ý nguyện này của ông Hảo cũng phù hợp với việc trên thực tế ông Hảo đã giao toàn bộ các giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhà đất của ông cho anh Thông giữ.

Từ những phân tích trên, có đủ cơ sở xác định di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo do bà Lê Thị Liên và bà Dương Thị Thuận ghi chép lại được Văn phòng Công chứng Bảo Việt chứng thực là hợp pháp, phù hợp với các Điều 651, 652, 654 Bộ luật Dân sự năm 2005. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân đối với anh Đoàn Văn Thông về việc chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông Nguyễn Văn Hảo là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Đoàn Văn Thông đối với bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân về việc yêu cầu công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo là hợp pháp là có căn cứ. Như vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các đồng nguyên đơn. Nhận định của cấp sơ thẩm là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Về án phí:

Án phí sơ thẩm:

Do không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các đồng nguyên đơn nên các đồng nguyên đơn phải chịu án phí không có giá ngạch là 300.000 đồng.

Bà Vượng, bà Liễu là người cao tuổi (trên 60 tuổi) nên được miễn án phí dân sự dân sự sơ thẩm.

Bị đơn là anh Thông được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phản tố đã nộp.

Án phí phúc thẩm: Do giữ nguyên bản án sơ thẩm nên ông Vỹ, bà Uyên, ông Dân phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Bà Vượng, bà Liễu là người cao tuổi (trên 60 tuổi) nên được miễn án phí dân sự dân sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Khoản 1 Điều 308; Điều 147; Điều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự;

- Căn cứ vào Điều 5, khoản 5 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39, Điều 71, Điều 72, khoản 1 Điều 147, Điều 186, Điều 235, Điều 266, Điều 271, Điều 273, Điều 278, Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 633, các Điều 646, 647, 648, 649, 651, 652, 654, Điều 667, điểm c khoản 1 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Căn cứ Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ các Điều 44, 46, 48, 49 Luật Công chứng năm 2014;

- Căn cứ Điều 2 Luật Người cao tuổi năm 2009;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Xử:

1. Giữ nguyên sơ thẩm số 39/2019/DSST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng và quyết định cụ thể như sau:

1.1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân đối với anh Đoàn Văn Thông về việc chia thừa kế theo pháp luật di sản của ông Nguyễn Văn Hảo là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

1.2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Đoàn Văn Thông đối với bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân về việc yêu cầu công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo là hợp pháp.

1.3. Công nhận di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo do bà Lê Thị Liên và bà Dương Thị Thuận ghi chép lại tại Giấy xác nhận di chúc miệng ngày 05/2/2016, được Văn phòng Công chứng Bảo Việt chứng thực ngày 05/02/2016 là hợp pháp.

1.4. Di chúc miệng của ông Nguyễn Văn Hảo có hiệu lực pháp luật từ ngày 04/02/2016.

1.5. Về nội dung di chúc: Xác định anh Đoàn Văn Thông là người thực hiện nghĩa vụ lo tang lễ cho ông Nguyễn Văn Hảo và đưa ông Nguyễn Văn Hảo về quê anh Đoàn Văn Thông tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội để chôn cất.

Xác định anh Đoàn Văn Thông là người được hưởng thừa kế di sản là nhà đất tại số 9 Ngách 204/3 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội của ông Nguyễn Văn Hảo.

Anh Đoàn Văn Thông có trách nhiệm đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên nhà đất theo quy định pháp luật.

Bác các yêu cầu khác của các đương sự.

2. Về án phí

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu, ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân đã nộp số tiền tạm ứng án phí là 6.250.000 đồng theo Biên lai số AC/2015/0003245 ngày 07/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tương ứng mỗi người đã nộp số tiền tạm ứng án phí là 1.250.000 đồng.

Ông Phạm Văn Vỹ, bà Phạm Thị Uyên, ông Phạm Văn Dân mỗi người phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự đã nộp là 1.250.000 đồng trong tổng số tiền tạm ứng án phí 6.250.000 đồng theo Biên lai số AC/2015/0003245 ngày 07/11/2017 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng. Ông Vỹ, bà Uyên, ông Dân, mỗi người được nhận lại số tiền tạm ứng án phí là 950.000 đồng.

Bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. Bà Vượng, bà Liễu, mỗi người được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp là 1.250.000 đồng.

Anh Đoàn Văn Thông được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phản tố đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số AA/2017/0002482 ngày 02/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6.2. Án phí dân sự phúc thẩm:

Bà Phạm Thị Vượng, bà Phạm Thị Liễu không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Ông Phạm Văn Vỹ, ông Phạm Văn Dân, bà Phạm Thị Uyên, mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại các biên lai số AA/2017/0002836, số AA/2017/0002837, số AA/2017/0002838 cùng ngày 24/9/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSNDTP Hà Nội;
- Sở tư pháp TP Hà Nội;
- TAND quận Hai Bà Trưng;
- VKSND quận Hai Bà Trưng;
- Chi cục THADS quận Hai Bà Trưng;
- Các đương sự;
- Lưu văn phòng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đinh Như Lâm

PHỤ LỤC VI

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 78/2023/DS - PT
Ngày : 14 - 7 - 2023
V/v tranh chấp về thừa kế tài sản.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lại Văn Tùng

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Mai Hương;

Bà Vũ Thị Thu.

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Lan Anh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Bích Huyền – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 37/2023/TLPT-DS ngày 15-6-2023 về việc “Tranh chấp về thừa kế tài sản”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 45/2022/DS – ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Xuân T bị kháng cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 118/2023/QĐXX-PT ngày 30 tháng 6 năm 2023 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Trịnh Quang T, sinh năm 1960; địa chỉ: Số 262, đường Ngọc H, thị trấn Văn Đ, huyện Thanh T, thành phố Hà Nội;

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức T - Luật sư của Công ty Luật TNHH Á Châu Việt thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.

- Bị đơn: Bà Trịnh Thị N, sinh năm 1967; địa chỉ: Xóm 27, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định;

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Trịnh Thị L, sinh năm 1957; địa chỉ: Khu tập thể đoàn 6 Hải Q, phường Anh D, quận Dương K, thành phố Hải P;

2. Bà Trịnh Thị Kim O, sinh năm 1969;

3. Bà Trịnh Thị Hồng T; sinh năm 1972

Cùng địa chỉ: Xóm 22, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định;

4. Bà Trịnh Thị B, sinh năm 1972; địa chỉ: Số 14/10, đường ngang Hạ L, phường Đằng H, quận Hải A, thành phố Hải P;

- *Người đại diện theo ủy quyền của bà T:* Bà Trịnh Thị N, sinh năm 1967; địa chỉ: Xóm 27, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định (văn bản ủy quyền ngày 17-8-2022).

5. Ông Trịnh Việt M, sinh năm 1949; địa chỉ: Khu phố 1, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

6. Anh Trịnh Quang T1, sinh năm 1998; địa chỉ: Số 262, đường Ngọc H, thị trấn Văn Đ, huyện Thanh T, Thành phố Hà Nội.

- *Người đại diện theo ủy quyền của ông M, anh T:* Ông Trịnh Quang T, sinh năm 1960; địa chỉ: Số 262, đường Ngọc H, thị trấn Văn Đ, huyện Thanh T, Thành phố Hà Nội (văn bản ủy quyền ngày 29-10-2022, ngày 24-4-2023).

- *Người làm chứng:*

1. Ông Vũ Văn H, sinh năm 1960; địa chỉ: Xóm 24, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định.

2. Bà Vũ Thị L, sinh năm 1949; địa chỉ: Thôn Hoàng T, xã Mỹ S, huyện Văn G, tỉnh Hưng Y.

- *Người kháng cáo:* Ông Trịnh Quang T là nguyên đơn trong vụ án.

Tại phiên tòa: Ông T, bà N, bà L, bà O, luật sư T có mặt; bà B, ông M, bà T, anh T, ông H, bà L1 vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Tại đơn khởi kiện, lời khai tại Tòa án, nguyên đơn ông Trịnh Quang T trình bày: Bố mẹ ông là Trịnh Quang N (chết năm 2002) và Phạm Thị Y (chết năm 2007). Bố mẹ ông sinh được 06 người con là Trịnh Thị L, Trịnh Quang T, Trịnh Thị N, Trịnh Thị Kim O, Trịnh Thị Hồng T và Trịnh Thị B. Ngoài ra, bố ông còn có 01 con riêng là Trịnh Việt M. Di sản thừa kế của bố mẹ ông để lại là 388,8 m² đất ở nông thôn và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản, thuộc thửa số 105, tờ bản đồ số 34 bản đồ địa chính xã Xuân H lập năm 2007. Trước khi qua đời, mẹ ông đã lập di chúc định đoạt toàn bộ tài sản của bà cho cháu đích tôn là Trịnh Quang T1 (con trai ông), di chúc này hiện bà N đang cất giữ. Sau khi mẹ ông qua đời thì bà N vẫn sống trên đất của bố mẹ ông để lại; ông và vợ ông không sống trên đất này nhưng đã dày công tôn tạo như trồng cây, đổ đất, san nền, xây tường bao. Trước đây, anh em ông đã thỏa thuận với nhau sẽ sử dụng một phần đất khoảng 155 m² để xây nhà từ đường dùng chung cho gia đình, phần còn lại sẽ chia đều cho các đồng thừa kế, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được thỏa thuận trên.

Nay ông đề nghị Toà án chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản của bố mẹ ông để lại trong tổng số 388,8 m² đất ở và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản và căn nhà cấp 4 trên thửa đất 105, tờ bản đồ số 34 bản đồ địa chính xã Xuân H lập năm 2007 và công nhận di chúc mẹ ông cho cháu Trịnh Quang T1 và bà N là người đang giữ di chúc này. Ông đã cung cấp cho Toà án 01 chiếc USB có chứa đoạn video mà mẹ ông đã di chúc lại cho cháu Tú.

* Tại Bản tự khai và lời khai tại Tòa án, bị đơn bà Trịnh Thị N trình bày: Về thành phần gia đình cũng như di sản thừa kế của bố mẹ bà là Trịnh Quang N và Phạm Thị Y đúng như lời trình bày của Ông T. Khi bố mẹ bà chết đều không để lại di chúc, Ông T trình bày mẹ bà để lại di chúc cho cháu Tú hưởng phần di sản thừa kế của bà và cho rằng bà đang giữ di chúc là không đúng. Trước kia khi còn sống, bố bà nói là từ mép ngõ đến ngõ bà Khăng là của Ông T, còn lại là của mẹ con bà. Trước khi ông bà nội bà chết có nói cho bà 04 miếng đất, tính ra là 144 m² và mẹ bà cũng nói cho bà 02 miếng nữa. Năm 2013, bà có nói với Ông T cất đất cho bà thì Ông T có hứa trước di ảnh của tổ tiên là cất đủ số đất ông bà, bố mẹ đã cho bà nhưng sau đó thì Ông T không thực hiện. Còn việc xây từ đường thì bà không đồng ý vì gia đình bà theo đạo Công giáo nên không cần phải xây từ đường. Di sản của bố mẹ bà để lại là 388,8 m² đất ở và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản. Bố mẹ bà chết đều không để lại di chúc nên bà đề nghị chia di sản thừa kế của bố mẹ bà theo quy định của pháp luật.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Trịnh Việt M trình bày: Ông được hưởng phần thừa kế của cha ông là Trịnh Quang N, phần này ông sẽ nhận nhưng vì dịch bệnh và điều kiện đi lại khó khăn nên ông xin được vắng mặt khi giải quyết vụ việc.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Trịnh Thị L, bà Trịnh Thị Kim O, bà Trịnh Thị B trình bày: Về thành phần gia đình như lời trình bày của Ông T, bà N là đúng. Việc Ông T trình bày mẹ các bà để lại di chúc định đoạt toàn bộ di sản của bà cho cháu Trịnh Quang T1 là không đúng, bản thân Ông T cũng không xuất trình được di chúc này. Và cũng tại biên bản hoà giải năm 2016 tại UBND xã Xuân H cũng thể hiện bố mẹ các bà chết đi không để lại di chúc, biên bản hoà giải này Ông T cũng đã ký xác nhận sự việc đó. Các bà khẳng định bố mẹ chết không để lại di chúc gì nên đề nghị Toà án chia di sản thừa kế của bố mẹ theo quy định của pháp luật là diện tích đất 388,8 m² đất ở và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản. Các bà nhất trí với kết quả đo đạc thực tế là 501 m². Kỳ phần thừa kế của các bà được hưởng bao nhiêu thì các bà nhận bấy nhiêu và nhận quyền sử dụng đất. Nay bà N và chị em các bà đều đề nghị Toà án giải quyết triệt để vụ án để tránh khiếu kiện kéo dài và cũng là để tránh tranh chấp xảy ra sau này.

* Người làm chứng ông Vũ Văn H trình bày: Ông là hàng xóm của cụ Phạm Thị Y từ năm 2005 đến năm 2012. Ông nhớ khoảng năm 2007, cụ Yên có nhờ ông đến nhà để lập di chúc cho cụ Yên với nội dung: Cụ Yên để lại toàn bộ di sản của cụ là quyền sử dụng đất tại xóm 27, xã Xuân H cho cháu nội là Trịnh Quang T1.

Cụ Yên là người đọc di chúc, ông đã chép tay lại đầy đủ ý nguyện của cụ. Ông đã đọc lại nội dung cho cụ Yên nghe, cụ Yên đã ký vào bản di chúc này trước sự chứng kiến của ông và bà Vũ Thị L. Sau đó ông và bà L1 đã ký vào bản di chúc này với tư cách người làm chứng. Cụ Yên giao bản di chúc này cho ông lưu giữ nhưng sau đó bà Trịnh Thị N đã mượn về để đi kê khai cấp giấy chứng nhận rồi đến nay không trả lại ông.

* Người làm chứng bà Vũ Thị L trình bày: Bà và cụ Yên không có quan hệ họ hàng hay nuôi dưỡng, bà là người trực tiếp chăm sóc cụ những năm cuối đời đến khi cụ chết. Khoảng tháng 3/2007, cụ Yên có nhờ ông Vũ Văn H là hàng xóm của cụ đến nhà để lập di chúc cho cụ với nội dung: Cụ Yên để lại toàn bộ tài sản của cụ là quyền sử dụng đất tại xóm 27, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định cho cháu nội là Trịnh Quang T1. Cụ Yên là người đọc di chúc, ông H chép tay lại đầy đủ ý nguyện của cụ và đọc lại nội dung di chúc cho cụ nghe. Cụ Yên đã ký vào bản di chúc này trước sự chứng kiến của bà và ông H. Sau đó bà và ông H đã ký vào bản di chúc này với tư cách người làm chứng. Cụ Yên giao bản di chúc trên cho ông H lưu giữ nhưng sau đó bà Trịnh Thị N đến mượn về để đi kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đến nay không trả lại.

* Kết quả đo đạc, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản ngày 01/4/2022 thể hiện: Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34, xã Xuân H lập năm 2007 có diện tích 388,8 m² đất ở, 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản; đo đạc thực tế 501 m², trong đó có: một nhà cấp bốn 3 gian của cụ Nhượng, cụ Yên xây dựng năm 1990; tường bao phía đông, nam, bắc xây dựng năm 2021; 01 sân bê tông xây dựng năm 2019; 2 trụ cổng xây năm 2021, tất cả các công trình tường bao và trụ cổng có giá trị sử dụng còn lại là 50.000.000đ; sân bê tông có giá là 12.000.000đ; nhà đã hết giá trị sử dụng. Tường và sân do Ông T xây dựng, tại phiên toà Ông T không yêu cầu các đương sự khác phải thanh toán giá trị chênh lệch cho Ông T. Giá trị tài sản là quyền sử dụng đất: Đất ở 6.000.000đ/m²; đất ao, vườn 75.000đ/m²; giá đất giao dịch tại thời điểm định giá theo giá thị trường là 13.000.000 đ/m² đất ở; đất vườn, ao 7.000.000đ/m².

* Kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ tại UBND xã Xuân H ngày 25/5/2022 thể hiện: Về nguồn gốc đất tranh chấp theo bản đồ địa chính xã Xuân H lập năm 1987: Diện tích đất tranh chấp là một phần của các thửa đất: Thửa 340, tờ bản đồ số 6, diện tích 790 m² (trong đó đất ở 360 m², thổ canh 360 m², đất ao 70 m²), đứng tên Nhượng, tức Nhự (bố Ông T, bà N). Thửa 341, tờ bản đồ số 6, diện tích 96 m² đều là đất ở, đứng tên ông Trịnh Văn Nghệ là ông nội Ông T. Và một phần của thửa đất 366, tờ bản đồ số 06, tổng diện tích thửa 366 là 288 m².

Theo bản đồ địa chính xã Xuân H lập năm 1992: Diện tích đất tranh chấp là thửa 51, tờ bản đồ số 30, diện tích 445 m², đứng tên Nhự; trong đó đất ở 250 m², ao 153 m², đất vườn 42 m². Đất ông Nhự giảm đi là do tách một phần thửa đất cho ông Trịnh Quang T, một phần chuyển nhượng cho ông Sơn.

Theo bản đồ địa chính xã Xuân H lập năm 2007: Đất đang tranh chấp là một

phần thửa số 105, tờ bản đồ 34, diện tích 692,3 m², đứng tên hai hộ sử dụng đất là Kiều và Yên (do đang có tranh chấp). Ông Kiều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/11/2005, diện tích 160 m².

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, ông Trịnh Quang T, ông Tống Văn Kiều cũng đã có văn bản xác nhận ranh giới, mốc giới đất của hai hộ. Ông T cũng đã tiến hành xây tường bao cho toàn bộ phần diện tích ranh giới đất giữa hai hộ. Cơ sở xóm và địa phương cũng đã xác nhận việc này. Do vậy, diện tích đất trong vụ án đang tranh chấp là 532,3 m².

Việc tranh chấp giữa các anh, chị em trong gia đình Ông T đã diễn ra từ lâu. Năm 2016, địa phương cũng đã tiến hành hoà giải 02 lần nhưng bà L ở Hải P không về nên không hoà giải được.

Theo kết quả đo đạc thực tế ngày 01/4/2022: Thửa đất đang tranh chấp có diện tích 501 m².

Về các thành viên trong gia đình: Bố mẹ ông Trịnh Quang T và bà Trịnh Thị N là cụ Trịnh Quang N (tức Nhự) và Phạm Thị Y; cụ Nhự mất năm 2002, cụ Yên mất năm 2007. Cụ Nhự và cụ Yên có để lại di chúc hay không thì địa phương không nắm được; địa phương không lưu giữ tài liệu gì liên quan đến di chúc của hai cụ. Cụ Nhượng và cụ Yên có 06 con chung là Trịnh Quang T, Trịnh Thị L, Trịnh Thị N, Trịnh Thị Kim O, Trịnh Thị B và Trịnh Thị Hồng T. Ngoài ra, cụ Nhượng còn có 01 con riêng là Trịnh Việt M, hiện đang sinh sống ở tỉnh Hậu Giang.

Quan điểm chung của địa phương: Đề nghị Tòa án tiến hành hoà giải để các đương sự thống nhất trong việc chia di sản thừa kế của bố mẹ để lại, giữ gìn tình cảm anh, chị em trong gia đình. Trường hợp không thống nhất được thì đề nghị Tòa án căn cứ vào các quy định của pháp luật để giải quyết.

* Tại phiên tòa sơ thẩm ông Trịnh Quang T, bà Trịnh Thị N vẫn giữ nguyên ý kiến; Ông T không đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thanh toán giá trị chênh lệch về việc xây tường bao, trụ cổng và đồ sân bê tông; các đương sự cũng không phải thanh toán chênh lệch tài sản cho nhau. Xác định và công nhận phần đất có diện tích đo đạc thực tế 501 m² là di sản thừa kế của cụ Nhượng, cụ Yên và chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

* Bản án sơ thẩm số 45/2022/DS – ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Xuân T đã quyết định: Căn cứ vào các Điều 649, 650, 651, 654, 660 và 688 của Bộ luật Dân sự; các Điều 95, 168, 170 của Luật đất đai; các Điều 147, 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm a khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trịnh Quang T đối với bà Trịnh Thị N về việc chia thừa kế tài sản của cụ Trịnh Quang N (tức Nhự) và cụ Phạm Thị Y để lại là hợp pháp.

Xác định di sản chung của vợ chồng cụ Trịnh Quang N (tức Nhự) và cụ Phạm Thị Y là thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 diện tích là 501m² xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 27 (nay là xóm 12), xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định.

Xác định người hưởng thừa kế của cụ Trịnh Quang N (tức Nhự) gồm: Bà Trịnh Thị L, ông Trịnh Quang T, bà Trịnh Thị N, bà Trịnh Thị Kim O, bà Trịnh Thị Hồng T, bà Trịnh Thị B, ông Trịnh Việt M.

Xác định người hưởng thừa kế của cụ Phạm Thị Y gồm: Bà Trịnh Thị L, ông Trịnh Quang T, bà Trịnh Thị N, bà Trịnh Thị Kim O, bà Trịnh Thị Hồng T, bà Trịnh Thị B.

Về chia di sản thừa kế:

Chia cho bà Trịnh Thị L được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 40 m², đất vườn 37,5 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

Chia cho ông Trịnh Quang T được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 28,5 m², đất vườn 49,0 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

Chia cho bà Trịnh Thị N được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 28,1 m², đất vườn 49,4 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

Chia cho bà Trịnh Thị Kim O được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 28,0 m², đất vườn 49,5 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

Chia cho bà Trịnh Thị Hồng T được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 28,8 m², đất vườn 48,7 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

Chia cho bà Trịnh Thị B được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 28,2 m², đất vườn 49,3 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

Chia cho ông Trịnh Việt M được quyền sử dụng 36,0 m² (trong đó đất ở 18,4 m², đất vườn 17,6 m²) thuộc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 xã Xuân H lập năm 2007 tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định và các công trình xây dựng trên phần đất này.

(Độ dài các cạnh, diện tích từng loại đất cụ thể các đương sự được quyền sử dụng có sơ đồ đo vẽ kèm theo bản án).

Các đương sự có trách nhiệm kê khai, đăng ký, làm thủ tục và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của bản án.

Các đương sự không phải thanh toán giá trị tài sản cho nhau.

Bác các yêu cầu khác của các đương sự.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên án phí, quyền kháng cáo và biện pháp thi hành án của các đương sự.

* Tại đơn kháng cáo ngày 22-9-2022 của ông Trịnh Quang T kháng cáo toàn bộ nội dung bản án vì Toà án nhân dân huyện Xuân T đã không công bằng và khách quan trong việc giải quyết vụ án.

* Tại phiên tòa phúc thẩm: Ông Trịnh Quang T vẫn giữ nguyên quan điểm như đã trình bày tại cấp sơ thẩm và yêu cầu kháng cáo, bà Trịnh Thị N không chấp nhận lý do kháng cáo của Ông T, đề nghị cấp phúc thẩm giải quyết giữ nguyên như bản án sơ thẩm. Các đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

Về tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử và thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, những người tham gia tố tụng chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung kháng cáo: Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì thấy rằng di sản của cụ Trịnh Quang N và cụ Phạm Thị Y để lại gồm: Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 bản đồ địa chính xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định diện tích là 388,8 m² đất ở nông thôn và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản. Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định chia cho ông Trịnh Quang T được quyền sử dụng 77,5 m² (trong đó đất ở 28,5 m², đất vườn 49,0 m²) là có cơ sở, đảm bảo đúng pháp luật. Vì vậy, kháng cáo của Ông T là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308 giữ nguyên bản án sơ thẩm. Về án phí đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Xét kháng cáo của ông Trịnh Quang T làm trong thời hạn luật định phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 272; khoản 1 Điều 273; Điều 276 Bộ luật Tố tụng Dân sự nên được HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết.

[2] Về tố tụng: Bà Trịnh Thị Hồng T đã uỷ quyền cho bà Trịnh Thị N, anh Trịnh Quang T1, ông Trịnh Việt M đã uỷ quyền cho ông Trịnh Quang T, bà Trịnh Thị B đã có đơn xin xét xử vắng mặt nên việc xét xử vắng mặt họ không ảnh hưởng gì đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Vì vậy, căn cứ khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt họ.

[3] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ông Trịnh Quang T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết chia di sản thừa kế của cụ Trịnh Quang N và cụ Phạm Thị Y chết để lại diện tích đất là 388,8 m² đất ở nông thôn và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 bản đồ địa chính xã Xuân H. Theo quy định tại khoản 5 Điều 26, Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Xuân T, tỉnh Nam Định. Quan hệ pháp luật trong vụ án này được xác định là “Tranh chấp chia di sản thừa kế” như cấp sơ thẩm đã xác định là chính xác.

[4] Xét về nội dung kháng cáo của ông Trịnh Quang T kháng cáo toàn bộ nội dung bản án vì Toà án nhân dân huyện Xuân T đã không công bằng và khách quan trong việc giải quyết vụ án thấy rằng: Về di sản thừa kế, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai của tất cả các đương sự trong vụ án đều trình bày nguồn gốc thửa đất số 105, tờ bản đồ số 34 có diện tích hiện trạng còn lại là 501m² tại xóm 12, xã Xuân H, huyện Xuân T, tỉnh Nam Định là của vợ chồng cụ Nhượng và cụ Yên chết để lại có nguồn gốc đất do tổ tiên để lại cho hai cụ. Trên đất hai cụ có xây 01 nhà cấp bốn 3 gian, đến nay đã hết giá trị sử dụng. Cụ Nhượng và cụ Yên đều đã chết nên phần tài sản của hai cụ để lại được xác định là di sản thừa kế theo quy định tại Điều 612 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

[5] Xét ông Trịnh Quang T trình bày trước khi qua đời, mẹ ông là cụ Yên đã lập di chúc định đoạt toàn bộ tài sản của bà cho cháu đích tôn là Trịnh Quang T1 (con trai ông), di chúc này hiện bà N đang cất giữ. Nay ông đề nghị Toà án chia thừa kế theo pháp luật đối với di sản của bố mẹ ông để lại trong tổng số 388,8 m² đất ở và 135,2 m² đất nuôi trồng thủy sản tại thửa đất 105, tờ bản đồ số 34 bản đồ địa chính xã Xuân H lập năm 2007 và công nhận di chúc cho cháu Trịnh Quang T1 và bà N là người đang giữ di chúc này. Ông đã cung cấp cho Toà án 01 chiếc USB có chứa đoạn video mà mẹ ông đã di chúc lại cho cháu Tú. Ông T trình bày và cung cấp cho Toà án đoạn video ghi lại hình ảnh cụ Yên để lại di chúc cho cháu Tú hưởng phần di sản thừa kế của cụ và cho rằng bà N đang giữ bản di chúc là không đúng, không có căn cứ vì không có lý do gì khi lập di chúc cho cháu Tú có mặt vợ chồng Ông T mà lại đưa di chúc cho bà N cất giữ, trong khi đó bà N không có mặt trong video và cũng không được hưởng lợi gì từ di chúc này. Mặt khác, điều kiện để di chúc bằng video có hiệu lực phải căn cứ vào khoản 5 Điều 630 của Bộ luật Dân sự quy định như sau: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày

làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Di chúc bằng video không hợp pháp thì di chúc sẽ không có hiệu lực pháp luật, do vậy sẽ không làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc. Nếu người để lại di chúc bằng video đã chết thì căn cứ Điều 651 của Bộ luật Dân sự về chia tài sản thừa kế theo pháp luật. Như vậy, có thể thấy, di chúc miệng cũng được xem là một hình thức của di chúc nhưng điều kiện để công nhận di chúc miệng hợp pháp khắt khe hơn rất nhiều so với di chúc bằng văn bản. Do vậy, chiếc USB có chứa đoạn video ghi lại cảnh mẹ ông đã di chúc lại cho cháu Tú không được công nhận là di chúc hợp pháp. Căn cứ vào các quy định trên thì di chúc của cụ Yến được thể hiện dưới dạng đoạn video chưa đáp ứng điều kiện của di chúc hợp pháp vì vậy di sản sẽ được chia thừa kế theo quy định pháp luật. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 650 của Bộ luật Dân sự quy định những trường hợp thừa kế theo pháp luật "Di chúc không hợp pháp". Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu trên của Ông T. Như vậy di sản thừa kế của cụ Nhượng, cụ Yến sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

[6] Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế: Cụ Trịnh Quang N chết năm 2002, cụ Phạm Thị Y chết năm 2007 hai cụ chết không để lại di chúc. Theo quy định tại khoản 1 Điều 623 BLDS năm 2015 có quy định “thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản,” cho nên đối với phần di sản của hai cụ vẫn còn nằm trong thời hiệu khởi kiện nên được phân chia theo quy định của pháp luật. Đến nay tất cả các đương sự cũng đều công nhận nguồn gốc diện tích đất đó là tài sản chung của cụ Nhượng và cụ Yến là đúng sự thật nên đây là tình tiết, sự kiện không phải chứng minh theo quy định tại điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[7] Xác định diện và hàng thừa kế: Di sản thừa kế của cụ Nhượng và cụ Yến được đo đạc hiện trạng hiện nay chỉ còn lại diện tích là 501 m^2 sẽ được chia theo pháp luật. Vợ chồng cụ Nhượng, cụ Yến có 6 người con đẻ gồm: Bà Trịnh Thị L, ông Trịnh Quang T, bà Trịnh Thị N, bà Trịnh Thị Kim O, bà Trịnh Thị Hồng T và bà Trịnh Thị B. Theo phân tích đánh giá ở trên, phần di sản của cụ Yến để lại được chia cho 6 người con, mỗi người được hưởng kỷ phần là $1/6$ với diện tích mỗi kỷ phần là $250,5 \text{ m}^2 : 6 = 41,75 \text{ m}^2$ đất. Ngoài ra, cụ Nhượng còn có 01 con riêng là ông Trịnh Việt M. Như vậy, di sản cụ Nhượng để lại được chia cho 7 người con, mỗi người được hưởng kỷ phần là $1/7$ với diện tích mỗi kỷ phần là $250,5 \text{ m}^2 : 7 = 35,78 \text{ m}^2$. Các đương sự đều có yêu cầu chia bằng hiện vật, yêu cầu này có cơ sở chấp nhận vì thổ đất này có diện tích lớn lại có một mặt tiếp giáp với đường 489, chiều rộng mặt đường và chiều dài, đảm bảo tương xứng với một diện tích sử dụng làm nhà ở được để chia cho các bên cùng sử dụng là phù hợp với các Điều 649, 650, 651, 652, 660, 688 Bộ luật dân sự năm 2015. Vì vậy, cần chia cho bà Trịnh Thị L, ông Trịnh Quang T, bà Trịnh Thị N, bà Trịnh Thị Kim O, bà Trịnh Thị Hồng T và bà Trịnh Thị B mỗi người được quản lý, sử dụng là $77,5 \text{ m}^2$, chia cho ông Trịnh Việt M được quản lý, sử dụng là $36,0 \text{ m}^2$, các đương sự trong vụ án

không phải thanh toán giá trị tài sản cho nhau là hoàn toàn phù hợp.

[8] Về công sức: Các đương sự đều không có yêu cầu xem xét về công sức bảo quản, duy trì di sản cũng như về phần xây dựng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Qua những phân tích nêu trên đã cho thấy những kết luận trong bản án sơ thẩm là hoàn toàn phù hợp với những quy định của pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết vụ án. Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa phúc thẩm Ông T không đưa ra được các chứng cứ và lý lẽ để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình. Lý do kháng cáo của Ông T là không có căn cứ. Vì vậy yêu cầu kháng cáo của Ông T không được chấp nhận cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

[10] Về án phí dân sự sơ thẩm: Các đương sự được chia di sản thừa kế phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với giá trị tài sản được chia theo quy định.

[11] Án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo của ông Trịnh Quang T không được chấp nhận nên Ông T phải nộp tiền án phí dân sự phúc thẩm, Số tiền Ông T đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm được đối trừ vào số tiền Ông T phải nộp.

[12] Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Không chấp nhận kháng cáo của ông Trịnh Quang T. Giữ nguyên án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 5 Điều 26; khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39; Điều 92; Điều 147; Điều 148; khoản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; các Điều 611; Điều 612; Điều 613; Điều 623; Điều 649; Điều 650; Điều 651; Điều 654; Điều 660; Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 95, Điều 168, Điều 170 của Luật đất đai; điểm đ khoản 1 Điều 12 và khoản 2, điểm a khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

1. Giữ nguyên Quyết định bản án sơ thẩm số 45/2022/DS – ST ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Xuân T, tỉnh Nam Định.

2. Án phí dân sự phúc thẩm: Buộc ông Trịnh Quang T phải nộp 300.000 đồng nhưng được đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí số 0003067 ngày 30-9-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân T, tỉnh Nam Định. Ông T đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên án.

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Thị Mai Hương

Vũ Thị Thu

Lại Văn Tùng

Nơi nhận:

- Đương sự;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- VKSND huyện Xuân T;
- TAND huyện Xuân T;
- Chi cục THADS huyện Xuân T;
- Lưu HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(đã ký)

Lại Văn Tùng